

目 录

第一部分 考研真题精选

- 一、概念题
- 二、简答题
- 三、论述题
- 四、法条评析
- 五、案例分析题

第二部分 课后习题

绪 论

- 第一章 刑法概说
- 第二章 刑法的基本原则
- 第三章 刑法的效力
- 第四章 犯罪概念与犯罪构成
- 第五章 犯罪客体
- 第六章 犯罪客观方面
- 第七章 犯罪主体
- 第八章 犯罪主观方面
- 第九章 正当行为
- 第十章 犯罪形态
- 第十一章 共同犯罪
- 第十二章 罪 数
- 第十三章 刑事责任

第十四章 刑罚及其种类

第十五章 刑罚制度

第十六章 刑法各论概述

第十七章 危害国家安全罪

第十八章 危害公共安全罪

第十九章 破坏社会主义市场经济秩序罪

第二十章 侵犯公民人身权利、民主权利罪

第二十一章 侵犯财产罪

第二十二章 妨害社会管理秩序罪

第二十三章 危害国防利益罪

第二十四章 贪污贿赂罪

第二十五章 渎职罪

第二十六章 军人违反职责罪



微信扫描上方二维码，获取更多免费资料

第一部分 考研真题精选

一、概念题

1 罪刑法定原则（浙江财大2019年研；广东财大2016年研；武大2013年研；南开大学2011年研）

答：罪刑法定原则是指什么是犯罪，有哪些犯罪，各种犯罪的构成条件是什么，有哪些刑种，各个刑种如何适用以及各种具体罪的具体量刑幅度如何等，均由刑法加以规定。对于刑法分则没有明文规定为犯罪的行为，不得定罪处罚。概括来说，即“法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚”。

2 犯罪构成（浙江工商2016年研；人大2013年研；武大2012年研）

答：犯罪构成，是指依照我国刑法的规定，决定某一具体行为的社会危害性及其程度，并为该行为成立犯罪所必需的客观要件和主观要件的有机统一。犯罪构成是一系列主客观要件的有机统一。任何一个犯罪构成都是包括许多要件的，这些要件有表明犯罪客体、客观方面的，有表明犯罪主体、主观方面的，它们的有机统一就形成某种罪的犯罪构成。只有对行为的社会危害性及其程度具有决定意义而为该行为所必需的那些事实特征才是犯罪构成的要件。行为成立犯罪所必须具备的诸要件，是由我国刑法加以规定或包含的。

犯罪构成是追究行为人刑事责任的依据，是区分罪与非罪、此罪与彼罪界限的标准，也为无罪的人不受非法追究提供法律保障。

3 犯罪客体（山东大学2018年研；广东财大2018年研；武大2014年研；南开大学2006年研；西北政法2006年研）

答：犯罪客体，是指我国刑法所保护的、为犯罪行为所侵害的社会关系，是构成犯罪的必备要件之一。行为之所以构成犯罪，首先就在于侵犯了一定的社会关系，而且侵犯的社会关系越重要，其对社会的危害性就越大。刑法理论将犯罪客体划分为三类或三个层次：一般客体、同类客体、直接客体。三类客体是三个不同的层次，它们之间是一般与特殊、共性与个性、抽象与具体、整体与部分的关系。同类客体是在直接客体基础上的分类和概括，而一般客体又是对一切犯罪客体的抽象和概括。

4 不作为（浙江财大2019年研；四川师大2018年研；西北政法2005年研；上海交大2005年研）

答：不作为是指行为人负有实施某种行为的特定法律义务，能够履行而不履行的危害行为。成立不作为，在客观方面应当具备以下三个条件：① 行为人负有实施某种作为的特定法律义务，这是构成不作为的前提条件。② 行为人有能力履行特定法律义务，这是不作为成立的重要条件。③ 行为人没有履行作为的特定法律义务，这是不作为成立的关键条件。

5 刑事责任能力（浙江财大2019年研；宁波大学2017年研；广东财大2016年研；暨南大学2015年研；北师2012年研；武大2009年研）

答：刑事责任能力，是指行为人构成犯罪和承担刑事责任所必需的，行为人具备的刑法意义上辨认和控制自己行为的能力。刑事责任能力包括辨认能力和控制能力。辨认能力，是指行为人具备对自己的行为在刑法上的意义、性质、后果的分辨认识能力。控制能力，是指行为人具备决定自己是否以行为触犯刑法的能力。辨认能力是刑事责任能力的基础；控制能力是刑事责任能力的关键。

6 直接故意与间接故意（西南政法2012年研；武大2007年研）

相关试题：

（1）直接故意（山东大学2019年研）

（2）间接故意（暨南大学2018年研；人大2013年研；华侨大学2011年研；西北政法2007年研；武大2007年研）

答：（1）犯罪的直接故意，是指行为人明知自己的行为必然或者可能发生危害社会的结果，并且希望这种结果发生的心理态度。

（2）犯罪的间接故意，是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且放任这种结果发生的心理态度。

（3）二者区别在于：① 认识因素上，二者对行为导致危害结果发生的认识程度上有所不同。直接故意既可以是行为人明知自己的行为必然发生危害结果，也可以是明知其行为可能发生危害结果。而间接故意只能是行为人明知自己的行为可能发生危害结

果。② 意志因素上，二者对危害结果发生的心理态度显然不同。直接故意是希望即积极追求危害结果的发生。间接故意则是放任危害结果的发生。③ 特定危害结果的发生与否，对这两种故意及其支配下的行为定罪的意义也不同。对直接故意来说特定危害结果发生与否往往不影响其定罪；而对间接故意而言，只有发生了特定危害结果才能认定构成特定犯罪。

7 犯罪过失（暨南大学2017年研；中财2015年研；东财2010年研）

答：犯罪过失是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免的一种心理态度。按照犯罪过失心理态度的不同内容，刑法理论上把犯罪的过失区分为过于自信的过失与疏忽大意的过失两种类型：① 过于自信的过失，是指行为人预见到自己的行为可能发生危害社会的结果，但轻信能够避免，以致发生这种结果的心理态度。② 疏忽大意的过失，是指行为人应当预见到自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生这种结果的心理态度。

8 事实认识错误与法律认识错误（人大2016年研）

答：事实认识错误，是指行为人对自己行为的事实情况的不正确理解。法律认识错误，是指行为人对自己的行为在法律上是否构成犯罪、构成何种犯罪或者应当受到什么样的刑事处罚的不正确的理解。

事实认识错误与法律认识错误的区别在于：① 事实认识错误是行为人对与自己行为有关的事实所产生的错误认识，包括打击错误，对客体、对象、行为、因果关系、主体身份认识错误六种；而法律认识错误是行为人对法律规定或者行为所产生的法律意义的错误认识。② 有些事实认识错误会直接影响到法律对于行为人的定罪、量刑；而法律认识错误既不影响定罪也不影响量刑。

9 防卫过当（暨南大学2019年研；山东大学2018年研；南开大学2011年研；人大2010年研）

答：防卫过当，是指防卫行为明显超过必要限度，造成重大损害应当负刑事责任的行为。防卫过当是防卫行为的正当性和损害结果的非正当性的对立统一。防卫行为的正当性是指实施防卫行为时确有不法侵害存在；不法侵害正在进行；防卫的目的是保护合法权益不受非法侵害；防卫行为是针对不法侵害者本人实施。损害结果的非正当性

是指防卫行为的强度和力度明显超过了不法侵害的强度和力度，对不法侵害人造成了重大损害。防卫过当没有独立的罪状，也没有独立的法定刑，法律规定按照行为人触犯的有关条文和罪名酌情减轻或者免除处罚。

10 犯罪中止（武大2020年研；安徽师大2018年研；青岛大学2017年研；暨南大学2016年研；中山大学2015年研；南开大学2011年研）

答：犯罪中止，是指在犯罪过程中，行为人自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生，因而未完成犯罪的一种犯罪停止形态。犯罪中止形态有两种类型：①自动停止犯罪的犯罪中止；②自动有效地防止犯罪结果发生的犯罪中止。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。

11 共同犯罪（中国政法2020年研；中山大学2015年研）

答：共同犯罪，是指二人以上共同故意犯罪。构成共同犯罪，必须具备如下要件：①共同犯罪的主体，必须是两个以上达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人或单位。②构成共同犯罪必须二人以上具有共同的犯罪行为。事后通谋的窝藏行为、包庇行为，不构成共同犯罪。③构成共同犯罪必须二人以上具有共同的犯罪故意，共同过失不构成共同犯罪。

12 想象竞合犯（安徽师大2018年研；青岛大学2015年研；武大2014年研；东财2011年研；南开大学2010年研）

答：想象竞合犯，又称想象的数罪、观念的竞合，是指一个行为触犯数个罪名的犯罪形态。想象竞合犯的要件有：①行为人只实施了一个行为。一个行为，指在社会生活的意义上被评价为一个的行为。这里所说的行为不只是狭义的行为，也指包括结果在内的广义的行为。②一个行为触犯了数个罪名。一个行为触犯数个罪名，就是一个行为在形式上或外观上同时符合刑法规定的数个犯罪构成。

13 管制（山东大学2017年研；东财2010年研；武大2008年研）

答：管制，是指对犯罪人依法实行社区矫正的一种刑罚方法，是我国刑法中的一种主刑。管制是我国独创的一种刑罚方法，它产生于我国民主革命时期。管制刑的存在，使我国刑罚体系更加完善，因为它作为一种限制自由的刑罚方法，起到了连接剥夺自由刑和非自由刑的纽带作用，使各种刑罚的结构更加紧凑自然。其特征主要包括：①

对犯罪分子不予关押；② 限制犯罪分子一定的自由；③ 对犯罪分子自由的限制具有一定的期限；④ 由公安机关执行和群众监督改造。

14 剥夺政治权利（西北师范2015年研；人大2007年研；西北政法2007年研）

答：剥夺政治权利，是指剥夺犯罪人参加国家管理和政治活动的权利的一种刑罚方法。剥夺政治权利是一种资格刑，是剥夺犯罪人参加国家管理和政治活动的资格。根据《刑法》第54条规定，剥夺政治权利的执行内容包括四个方面：① 选举权和被选举权；② 言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；③ 担任国家机关职务的权利；④ 担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。剥夺政治权利既可以适用于危害国家安全的犯罪，也可以适用于普通刑事犯罪。

15 特别累犯（中山大学2018年研；浙大2014年研；人大2006年研；西北政法2006年研）

答：特别累犯是指犯危害国家安全罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子受过刑罚处罚，刑罚执行完毕或者赦免后，在任何时候再犯上述任一类罪之人。构成特别累犯的条件为：① 前罪和后罪必须都是危害国家安全罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪其中之一的犯罪；② 前罪被判处的刑罚和后罪应判处的刑罚的种类及其轻重不受限制，即使前后两罪或者其中之一罪被判处或者应判处管制、拘役或者单处某种附加刑的，也不影响其成立；③ 前罪的刑罚执行完毕或者赦免以后，任何时候再犯上述任一类罪，即构成特别累犯，不受前后两罪相距时间长短的限制。

16 特别自首（华侨大学2018年研；中山大学2015年研；北理2008年研；南开大学2007年研）

答：特别自首，又称“准自首”或者“余罪自首”，是指被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为。特别自首的成立不要求自动投案，但是有特殊的条件要求，主体必须是被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，必须如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行。

17 以危险方法危害公共安全罪（安徽师大2018年研；南开大学2011年研）

答：以危险方法危害公共安全罪，是指使用与放火、决水、爆炸、投放危险物质等危

险性相当的、能够造成不特定的多数人死伤或者公私财产广泛破坏的其他危险方法，危害公共安全的行为。本罪的客观方面表现为以其他危险方法危害公共安全的行为，所谓“其他危险方法”是指使用与放火、决水、爆炸、投放危险物质的危险性相当的危险方法，如私设电网、驾车冲撞人群、使用放射性物质、服用致幻药品（毒品、精神药品）驾驶车船、扩散致病微生物等危险方法危害公共安全的行为，只要足以危害公共安全的，即可以构成本罪。由于实践中实施危害公共安全的犯罪形式、手段很多，刑法不可能也无必要将所有的犯罪形式、手段都列举出来，因而以“其他危险方法”作概括性的规定。主体是一般主体，主观方面为故意。

18 拐卖儿童罪与拐骗儿童罪（武大2009年研）

答：（1）拐卖儿童罪，是指以出卖为目的，拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转儿童的行为。其构成要件为：① 本罪的客体是人身权利中的人身不受买卖的权利；② 本罪的客观方面表现为实施拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转儿童之一的行为；③ 本罪的主体是一般主体；④ 本罪的主观方面是直接故意，并且必须具有出卖的目的。

（2）拐骗儿童罪，是指拐骗不满14周岁的儿童，使其脱离家庭或者其监护人的行为。其构成要件是：① 本罪的客体为他人的家庭关系以及儿童的合法权益；② 本罪的客观方面表现为拐骗不满14周岁的儿童，使其脱离家庭或者监护人的行为；③ 本罪的主体为一般主体；④ 主观方面是故意。

（3）拐卖儿童罪与拐骗儿童罪都侵犯的是人身权利，都可以儿童为对象，也都能采用欺骗手段。区别在于：拐卖儿童罪是以出卖为目的，而拐骗儿童罪不以出卖为目的，一般是为了供自己或他人收养、奴役。

19 敲诈勒索罪与抢劫罪（武大2011年研）、敲诈勒索罪（武大2014年研）

答：（1）敲诈勒索罪，是指以非法占有为目的，以威胁或者要挟的方法，强索公私财物，数额较大或者多次实施但未达数额较大程度的行为。本罪的构成要件是：① 本罪的客体为复杂客体，主要客体是公私财产所有权，次要客体是他人的人身权利或者其他权益；② 本罪的客观方面表现为以威胁或者要挟的方法，向公私财物的所有人或持有人强索财物的行为；③ 本罪的主体为一般主体；④ 本罪的主观方面是直接故意，且以非法占有为目的。

（2）抢劫罪，是指以非法占有为目的，以暴力、胁迫或者其他方法，当场强行劫取公私财物的行为。抢劫罪的特征是：① 本罪客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，也侵犯了他人的人身权利；② 本罪的客观方面表现为行为人实施强制性行为，且

行为人必须当场抢走财物；③ 本罪的主体为一般主体；④ 本罪的主观方面是直接故意。

(3) 二者的区别在于：① 抢劫罪必须是行为人当着被害人的面发出威胁，而敲诈勒索罪可以当面威胁，也可以不当面威胁，可以由自己发出威胁，也可以由第三者转达威胁；② 抢劫罪必须是以当场实现威胁的内容相恐吓，敲诈勒索罪则可以当场实现或日后实现威胁内容相恐吓；③ 抢劫罪必须是当场夺取财物或迫使被害人交付财物，而敲诈勒索罪则可以是迫使被害人当场或者日后交付财物。

20 玩忽职守罪与滥用职权罪（人大2016年研）

相关试题：玩忽职守罪（人大2010年研）、滥用职权罪（上海交大2006年研）

答：玩忽职守罪，是指国家机关工作人员严重不负责任，不履行或者不正确履行职责，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。滥用职权罪，是指国家机关工作人员超过职权，违法决定、处理其无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。

二者的主体都是国家机关工作人员，客观上都要求造成公共财产、国家和人民利益的重大损失。但二者有明显的区别：① 主观方面不同。玩忽职守罪只能出于过失；而滥用职权罪主观上只能出自故意。② 客观行为的表现形式不同。玩忽职守罪客观上表现为严重不负责任，不履行或不正确履行职责；滥用职权罪客观上表现为超过职权，违法决定、处理其无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务。

二、简答题

① 简述我国刑法的空间效力范围。（华南理工2010年研）

相关试题：简述我国刑法的空间效力。（华南理工2007年研）

答：刑法的空间效力，是指刑法对地和对人的效力，即刑法在什么地方、对什么人具有效力。也就是要解决刑事管辖权的范围问题。对刑法的空间效力规定的原则主要有属地原则、属人原则、保护原则和普遍管辖原则四种。我国刑法以属地原则为主，兼采属人原则、保护原则和普遍管辖原则。我国刑法的空间效力包括：

（1）我国刑法的属地管辖权

① 凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。

② 凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。

③ 凡在我国驻外大使馆、领事馆内犯罪的，也应适用我国刑法。

（2）我国刑法的属人管辖权

① 中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为3年以下有期徒刑的，可以不予追究。

② 中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。

③ 中国公民在我国领域外犯罪，依照我国刑法应当负刑事责任的，虽然经过外国审判，仍然可以依照我国刑法追究；但是，在外国已经受过刑罚处罚的，可以免除或者减轻处罚。

（3）我国刑法的保护管辖权

外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，而按本法规定的最低刑为3年以上有期徒刑的，可以适用本法，但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。

（4）我国刑法的普遍管辖权

凡是我国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，不论犯罪分子是中国人还是外国人，也不论其罪行发生在我国领域内还是我国领域外，只要犯罪分子在我国境内被发现，我国就应当在所承担条约义务的范围内，行使刑事管辖权。

2 简述我国刑法中的犯罪构成及其共同要件。（中南财大2007年研）

相关试题：试论我国犯罪构成的基本要素。（论述题，中山大学2016年研）

答：犯罪构成，是指依照我国刑法的规定，决定某一具体行为的社会危害性及其程度而为该行为构成犯罪所必需的一切客观和主观要件的有机统一。

（1）犯罪构成是一系列主客观要件的有机统一。任何一个犯罪构成都是包括许多要件的，这些要件有表明犯罪客体、客观方面的，有表明犯罪主体、主观方面的，它们的有机统一就形成某种罪的犯罪构成。

（2）任何一种犯罪都可以由许多事实特征来说明，但并非每一个事实特征都是犯罪构成的要件；只有对行为的社会危害性及其程度具有决定意义而为该行为成立犯罪所必需的那些事实特征，才是犯罪构成的要件。

（3）行为成立犯罪所必须具备的诸要件，是由我国刑法加以规定或包含的。即事实特征必须经由法律的选择，才能成为犯罪构成的要件。根据我国刑法，任何一种犯罪的成立都必须具备四个方面的构成要件，即犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面。

① 犯罪客体是指我国刑法所保护的、为犯罪行为所侵害的社会关系。行为之所以构成犯罪，首先就在于侵犯了一定的社会关系，而且侵犯的社会关系越重要，其对社会的危害性就越大。如果某一行为并未危害刑法所保护的社会关系，就不可能构成犯罪。

② 犯罪客观方面，是指刑法所规定的、说明行为对刑法所保护的社会关系造成损害的客观外在事实特征。犯罪客观方面是构成犯罪所必须具备的要件。

犯罪客观方面的要件，也可称为犯罪客观方面的内容或犯罪客观要件，是指犯罪成立在犯罪客观方面所必须具备的条件，是犯罪客观方面的下位概念。犯罪客观方面是就刑法分则中各种犯罪成立均必须具备某些客观事实特征而概括出来的一个范畴，为犯罪构成的共同要件之一；犯罪客观方面的要件则是相对具体的，是指刑法分则中某种犯罪成立在客观方面应当具备的客观要素。犯罪客观方面的要件具体表现为危害行为、危害结果，以及行为的时间、地点、方法（手段）、对象。

③ 犯罪主体，是指实施危害社会的行为、依法应当负刑事责任的自然人和单位。自然

人主体是我国刑法中最基本的、具有普遍意义的犯罪主体，单位主体在我国刑法中不具有普遍意义但具有其特殊性。我国刑法中犯罪主体（就自然人犯罪主体而言）的共同要件有两个：a. 犯罪主体必须是自然人；b. 作为自然人的犯罪主体必须具备刑事责任能力。

④ 犯罪主观方面，是指犯罪主体对自己行为及其危害社会的结果所抱的心理态度。它包括罪过（即犯罪的故意或者过失）以及犯罪的目的和动机这几个因素。其中，行为人的罪过即其犯罪的故意或者过失，是一切犯罪构成都必须具备的主观要件；犯罪的目的只是某些犯罪构成所必备的主观要件，它一般不影响定罪，而只影响量刑。

3 简述我国刑法对刑事责任年龄的规定。（武大2007年研）

相关试题：

（1）最近14周岁以下的未成年人进行故意杀人或其他严重暴力行为的情况频繁发生，据此有人大代表认为应当降低我国的刑事责任年龄，就此问题谈谈你的看法。（论述题，人大2020年研）

（2）什么是刑事责任年龄？我国刑法对刑事责任年龄是如何划分的？（浙工大2018年研）

（3）简述我国刑法关于未成年人刑事责任年龄的规定。（暨南大学2017年研）

答：刑事责任年龄，是指法律所规定的行为人对自己实施的刑法所禁止的危害社会行为负刑事责任必须达到的年龄。我国刑法从我国实际出发，考虑刑法的世界发展趋势，在《刑法》第17条中对刑事责任年龄作了集中的规定，把刑事责任年龄划分为完全不负刑事责任年龄、相对负刑事责任年龄和完全负刑事责任年龄三个年龄阶段：

（1）完全不负刑事责任年龄阶段

按照我国《刑法》第17条的规定，不满14周岁，是完全不负刑事责任年龄的阶段。对不满14周岁的人所实施的危害社会的行为，一概不追究刑事责任，但是对于因不满14周岁不予刑事处罚的实施了危害社会行为的人，应依法责令其家长或监护人加以管教，必要时也可由政府收容教养。

（2）相对负刑事责任年龄阶段

根据我国《刑法》第17条第2款规定，已满14周岁不满16周岁，是相对负刑事责任年龄阶段。达到这个年龄阶段的人，已经具备了一定的辨别大是大非和控制自己重大行为的能力，即对某些严重危害社会的行为具备了一定的辨认和控制能力。因此法律要求

他们对自己实施的严重危害社会的行为负刑事责任。目前我国《刑法》的规定为：已满14周岁不满16周岁。犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。这八种特定严重犯罪，是指具体犯罪行为而不是具体罪名。已满14周岁不满16周岁的人只有实施上述8种犯罪行为，才负刑事责任，对于他们实施的其他危害社会的行为，不负刑事责任。同样，对于因不满16周岁而不予刑事处罚的实施了危害社会行为的未成年人，应依法责令家长或者监护人加以管教，必要时也可由政府收容教养。

(3) 完全负刑事责任年龄阶段

我国《刑法》第17条第1款明文规定，已满16周岁的人进入完全负刑事责任年龄阶段。由于已满16周岁的未成年人的体力和智力已有相当的发展，应该已经具备了基本的刑法意义上的辨认和控制自己行为的能力，因此我国刑法规定已满16周岁的人原则上可以构成刑法中的所有犯罪，并要求他们对自己实施的刑法所禁止的危害社会的行为承担刑事责任。

除了上述几点外，我国刑法还规定对于已满14周岁不满18周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚；对犯罪时不满18周岁的人不适用死刑。因此也有人认为已满14周岁不满18周岁的阶段可以被称为减轻刑事责任年龄阶段，即对于处于这一年龄阶段的人犯罪都应减轻其承担的刑事责任。

4 简述间接故意的特征及其与相近罪过形式的区别。（中南财大2005年研）

相关试题：

(1) 间接故意与过于自信的过失的联系与区别。（山东大学2018年研）

(2) 间接故意与过于自信的过失的异同。（广东财大2017年研）

(3) 间接故意与过于自信的过失（概念题，华南理工2016年研；武大2011年研）

答：（1）犯罪的间接故意，是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且放任这种结果发生的心理态度。间接故意在认识特征和意志特征上具体表现为：

① 在认识特征上，间接故意表现为行为人认识到自己的行为“可能”发生危害社会结果的心理态度。即行为人根据自身犯罪能力、犯罪对象情况、犯罪工具情况或者犯罪的时间、地点、环境等情况的了解，认识到行为导致危害结果的发生只是具有或然性、可能性，而不是具有必然性。这种对危害结果可能发生的认识，为间接故意的意志因素即放任心理的存在提供了前提和基础。如果明知行为必然发生危害结果而决意

为之，就超出了间接故意认识因素的范围，应属于直接故意。

②在意志特征上，间接故意表现为行为人放任危害结果发生的心理态度。所谓“放任”，当然不是希望，不是积极的追求，而是行为人在明知自己的行为可能发生特定危害结果的情况下，为了达到自己的既定目的，仍然决意实施这种行为，对阻碍危害结果发生的障碍不去排除，也不设法阻止危害结果的发生，而是听之任之，自觉自愿地听任危害结果的发生。

(2) 间接故意与相近罪过形式的区别：

①间接故意与直接故意的区别：

a. 从认识因素上看，二者对行为导致危害结果发生的认识程度上有所不同。犯罪的直接故意既可以是行为人明知自己的行为必然发生危害结果，也可以是明知其行为可能发生危害结果。而犯罪的间接故意只能是行为人明知自己的行为可能发生危害结果。

b. 从意志因素上看，二者对危害结果发生的心理态度显然不同。直接故意是希望即积极追求危害结果的发生。间接故意对危害结果的发生持放任的心理态度。“放任”就是对结果的发生与否采取听之任之、满不在乎、无所谓的态度。意志因素的不同，是两种故意区别的关键所在。

c. 特定危害结果的发生与否，对这两种故意及其支配下的行为定罪的意义也不相同。对直接故意来说，其行为性质与结果性质是同一的，其结果也是特定的，根据主客观相统一的定罪原则，只要行为人主观上有犯罪的直接故意，客观上有相应的行为，即构成特定的故意犯罪，危害结果发生与否不影响定罪，而只是在那些以结果为既遂要件的犯罪里是区分既遂与未遂形态的标志。对间接故意而言，特定的危害结果可能发生，也可能不发生，结果发生与否都不违背其意志，都包含在其本意中，因而要根据主客观相统一的原则，仅有行为而无危害结果时，尚不能认定行为人构成此种犯罪（包括其未遂形态），只有发生了特定危害结果才能认定构成特定的犯罪。即特定危害结果的发生与否，决定了间接故意犯罪的成立与否。

②间接故意与过于自信的过失的区别：

a. 认识程度有所不同，间接故意认识的程度较高。

b. 对危害结果所持的态度不同。过于自信过失的行为人对危害结果的发生持否定态度，危害结果的发生，是违背行为人意愿的。而间接故意的行为人，对危害结果的发生持放任态度，即危害结果发生与不发生，都不在乎。

5 正当防卫的概念和条件。（南开大学2011年研；中山大学2010年研；南师大2009年研）

相关试题：

（1）论正当防卫的成立条件。（论述题，宁波大学2019年研；浙江财大2019年研）

（2）正当防卫的构成要件有哪些？（安徽师大2018年研）

（3）正当防卫的成立条件有哪些？（青岛大学2017年研；北大2013年研）

答：正当防卫，是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而对不法侵害者实施的制止其不法侵害且未明显超过必要限度的行为。正当防卫是正当化事由之一。成立正当防卫必须满足以下要件：

（1）防卫起因：有实际的不法侵害存在，这是正当防卫的前提条件。不法侵害行为是指违反法律并具有社会危害性的行为，既包括构成犯罪的严重不法行为，也包括尚未构成犯罪的违反治安管理处罚条例之类的不法行为，而且这种不法侵害是客观的、现实的。

（2）防卫时间：不法侵害必须正在进行。指不法侵害人已经着手实施侵害行为且侵害行为尚未结束，不法侵害行为或其导致的危害状态尚在持续中。不法侵害行为开始和存续的时间，就是行为人实施正当防卫的时间。

（3）防卫意图：防卫人对正在进行的不法侵害有明确认识，并希望以防卫手段使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受不法侵害。不具有防卫合法权益的目的而实施的貌似正当防卫的行为，如防卫挑拨即故意挑逗、引诱对方实施不法侵害，然后以正当防卫为借口加害于对方的行为，不是正当防卫情况而是犯罪行为。

（4）防卫对象：防卫行为必须针对不法侵害人进行，是正当防卫的对象条件。正当防卫必须对准目标，针对不法侵害者本人。

（5）防卫限度：防卫行为没有明显超过必要限度，造成重大损害，是正当防卫的行为和结果限度要件。所谓必要限度是指有效地制止不法侵害所必需的防卫强度。防卫明显超过必要限度，造成重大损害的行为，是防卫过当。明显超过必要限度是指一般人都能认识到其防卫强度超过了正当防卫所必需的强度。重大损害是指防卫人明显超过必要限度的防卫行为造成不法侵害人或者其他人人身伤亡，或者造成其他能够避免的严重损害。防卫过当应当负刑事责任。

6 简述防卫过当的概念、罪过形式及其刑事责任。（山东大学2017年研）

答：（1）防卫过当的概念

防卫过当，是指防卫明显超过必要限度造成重大损害应当负刑事责任的行为。防卫过当与正当防卫是两个既有本质区别又有密切联系的概念。

① 区别：防卫过当是在主观罪过支配下实施的具有客观危害性的行为。从总体上说它是一种非法侵害行为，这是它区别于正当防卫的本质特征，也是刑法规定防卫过当应当负刑事责任的根据。

② 联系：防卫过当与正当防卫一样，都具有行为的防卫性，这是它们密切联系之所在。

（2）防卫过当的罪过形式

① 全面过失说，认为防卫过当的罪过形式只能是过失。

② 疏忽大意过失说，认为防卫过当的罪过形式只能是疏忽大意的过失。

③ 排除直接故意说，认为防卫过当的罪过形式只能是间接故意或过失，而不可能是直接故意。

④ 排除过失说，认为防卫过当的罪过形式都只能是故意，而不可能是过失。

⑤ 故意与过失说，认为防卫过当的罪过形式既可以是故意（包括直接故意和间接故意），也可以是过失（包括疏忽大意的过失和过于自信的过失）。

一般支持排除直接故意说，认为在防卫过当的场合，行为人对于其过当行为及其结果，主观上不可能出于直接故意，因为正当防卫目的和犯罪目的，不可能同时存在于一个主观意识支配外在行为的过程之中。

（3）防卫过当的刑事责任

正当防卫明显超过必要限度造成重大损失的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

① 防卫过当的定罪：防卫过当本身不是罪名，不能将防卫过当行为笼统地定为“防卫过当罪”。对防卫过当应根据防卫人主观上的罪过形式及客观上造成的具体危害结果来确定罪名。

② 防卫过当的量刑：我国刑法规定“应当减轻或者免除处罚”，应当综合考虑如下因

素：过当程度；权益性质；防卫目的；罪过形式。

7 简述犯罪未遂。（中财2015年研；北大2008年研；华南理工2007年研）

相关试题：

（1）简述犯罪未遂的特征与处罚原则。（暨南大学2019年研）

（2）简述犯罪未遂的认定与处罚原则。（山东大学2018年研）

（3）犯罪未遂的类型。（扬州大学2017年研）

（4）简述未遂犯的概念及法律后果。（中南财大2014年研）

（5）简述犯罪未遂形态的特征。（北师大2015年研）

（6）简述犯罪未遂的概念。（吉林大学2010年研）

答：（1）犯罪未遂形态的概念和特征

我国《刑法》第23条第1款规定：“已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。”所谓未得逞，一般认为其表现为未能完成犯罪即未能达到犯罪既遂。因而根据上述规定，我国刑法中的犯罪未遂，是指行为人已经着手实行具体犯罪构成的实行行为，由于其意志以外的原因而未能完成犯罪的一种犯罪停止形态。犯罪未遂形态的特征包括：

① 行为人已经着手实行犯罪。

已经着手实行犯罪，是指行为人已经开始实施刑法分则规范里具体犯罪构成要件中的犯罪行为。

② 犯罪未完成而停止下来。

按照我国刑法的规定和刑法理论，行为人在着手实行犯罪以后，犯罪“未得逞”，即犯罪未达既遂形态而停止下来，这是犯罪未遂形态的又一重要特征，是犯罪未遂形态区别于犯罪既遂形态的主要标志。

③ 犯罪停止在未完成形态是犯罪分子意志以外的原因所致。

犯罪活动在着手实行以后之所以停止在未完成形态，乃是由于犯罪分子意志以外的原因所致，这是犯罪未遂形态的又一重要特征，是犯罪未遂形态与着手犯罪后的犯罪中止区别的关键。后者是由于行为人意志以内的原因即自愿放弃犯罪而未完成犯罪。

(2) 犯罪未遂形态的类型

我国刑法理论一般从两个角度，根据两个不同的标准，把犯罪未遂划分为两对类型：实行终了的未遂与未实行终了的未遂；能犯未遂与不能犯未遂。

① 实行终了的未遂与未实行终了的未遂

刑法理论上以犯罪实行行为是否实行终了为标准，把犯罪未遂形态区分为实行终了的未遂与未实行终了的未遂两种类型。

在法定犯罪构成所要求、限定的客观行为范围内，行为是否实行终了，应以犯罪分子是否自认为实现犯罪意图所必要的全部行为都实行完毕为标准。实行终了的未遂有两种表现：

- a. 犯罪分子误认为其实现犯罪意图所必要的行为都已实行终了，因而停止了犯罪行为，但是却由于其意志以外的原因而未能使犯罪达到既遂状态。如在故意杀人罪中致人重伤，犯罪人误认为被害人已死亡或必然死亡，因而放弃加害而离去，后被害人遇救幸存的情况，就是这种表现形式的典型。
- b. 犯罪分子对完成犯罪所必要的犯罪行为已实行终了这一点并未发生错误认识，但是犯罪行为实行终了距犯罪既遂还有一段距离，在犯罪行为实行终了以后，由于犯罪人意志以外的原因致使犯罪未能达到既遂状态。如在投毒杀人中犯罪人已将毒投下，被害人因发现而未食毒物，或者被害人食毒物后遇救未死的，即属这种情况。

② 能犯未遂与不能犯未遂

刑法理论上以行为的实行能否构成犯罪既遂为标准，把犯罪未遂形态划分为能犯未遂与不能犯未遂两种类型。

- a. 能犯未遂，是指犯罪行为有实际可能达到既遂，但由于行为人意志以外的原因未能达到既遂而停止下来的情况。
- b. 不能犯未遂，是指因犯罪人对有关犯罪事实认识错误而使犯罪行为不可能达到既遂的情况。

(3) 未遂犯的处罚原则

我国《刑法》第23条第2款规定：“对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。”这一规定采取的是得减主义的处罚原则。正确适用这一处罚原则，应当注意以下几个问题：

① 对未遂犯定罪量刑，应当同时引用《刑法》总则第23条和刑法分则具体犯罪条文。在罪名后应加括弧标明未遂形态问题，如“故意杀人罪（未遂）”。

② 在对未遂犯处罚原则的理解与掌握上，所谓“可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚”，表明的是法律的一种倾向性要求，即与既遂犯相比，对未遂犯一般要从轻或者减轻处罚，但是法律的要求又没有绝对化，对于极少数综合整个案情看，其危害程度并不小于既遂犯的未遂犯应不予以从轻或者减轻处罚。

③ 对未遂犯确定是否可因犯罪未遂而从轻减轻处罚时，应把未遂情况置于全案情节中统筹考虑。如果综合全部案情看，未遂案件的危害性与既遂相比较轻或显著较轻而且未遂情节在全部情节中居于举足轻重的地位，从而影响甚至是显著影响了案件的危害程度时，就可以决定对行为人基于或主要是基于其犯罪未遂而予以从轻或减轻处罚，反之则不应基于未遂而从宽处罚。

④ 在对未遂犯决定从宽处罚的基础上，为正确确定从宽处罚的幅度，必须正确判定未遂案件与既遂案件危害程度的差别。这时主要应当考虑如下几种因素：a. 未遂形态距离犯罪完成的远近程度；b. 犯罪未遂所属的类型；c. 未遂形态所表现出来的行为人犯罪意志的坚决程度。

8 简述犯罪中止的特征及中止犯的刑事责任。（中南财大2006年研）

相关试题：

（1）简述犯罪中止的特征。（四川师大2018年研）

（2）犯罪中止的概念和特征是什么？（东财2011年研）

（3）简述犯罪中止的成立条件。（人大2009年研）

答：（1）犯罪中止的概念和特征

犯罪中止，是指在犯罪过程中，行为人自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生，因而未完成犯罪的一种犯罪停止形态。

① 自动停止犯罪的犯罪中止必须同时具备三个特征：

a. 时空性。按照法律的规定，必须是在犯罪过程中放弃犯罪，即必须是在犯罪处于运动过程中而尚未形成任何停止状态的情况下放弃犯罪。这是犯罪中止成立的客观前提特征。

b. 自动性。即行为人必须是自动停止犯罪。这是犯罪中止形态的本质特征，是犯罪中止形态与犯罪的未遂形态和预备形态的根本区别所在。犯罪中止的自动性，是指行为人出于自己的意志而放弃了自认为当时本可继续实施和完成的犯罪。

c. 彻底性。即行为人彻底放弃了原来的犯罪。这一特征意味着，行为人在主观上彻底打消了原来的犯罪意图，在客观上彻底放弃了自认为本可能继续进行的犯罪行为，而且从主客观的统一上行为人也不打算以后再继续实施此项犯罪。

② 自动有效地防止犯罪结果发生的犯罪中止的特征：

自动有效地防止犯罪结果发生的犯罪中止，是指在某些犯罪的某些特殊情况下，行为人已经着手实行的犯罪行为可能造成但尚未造成犯罪既遂所要求的犯罪结果，而在这种情况下所成立的犯罪中止。这可以说是一种特殊类型或特殊情况下的犯罪中止。这种特殊犯罪中止类型在上述三个特征之外，就还要求再具备“有效性”的特征，即行为人还必须有效地防止他已实施的犯罪之法定犯罪结果的发生，使犯罪未达既遂状态而停止下来。

(2) 中止犯的刑事责任

按照《刑法》第24条第2款规定，对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。要正确地适用这一处罚原则，应当注意以下几点：

① 对中止犯采取从宽处罚原则。采取从宽原则是刑事政策的要求，也是符合中止犯的社会危害性大小和主观恶性程度的。

② 对中止犯采取减轻处罚或者免除处罚原则。我国刑法中的从宽处罚原则是从轻处罚、减轻处罚和免除处罚的总称。对中止犯规定了减轻或者免除处罚的处罚原则。中止犯至少是减轻处罚。

③ 对中止犯采取必减主义。根据《刑法》第24条的规定，对中止犯必须予以从宽处罚，即：没有造成损害的，“应当”免除处罚；造成损害的，“应当”减轻处罚。可见，对于中止犯，审判人员必须予以从宽处罚，没有予以从宽或不予以从宽的自由裁量的余地。

④ 处罚原则的具体适用。根据《刑法》第24条的规定，中止犯包括应当减轻处罚和应当免除处罚两种处罚原则。该条还为具体适用这两种处罚原则的条件作出了明确规定，是否造成损害是适用两种不同的处罚原则的条件。

a. 应当减轻处罚原则的适用条件。根据《刑法》第24条的规定，对中止犯适用应当减轻处罚原则的条件是“造成损害”。造成损害，是指造成了一定的危害结果，但没有造

成刑法规定的犯罪构成要件结果。

b. 应当免除处罚。根据《刑法》第24条的规定，对中止犯适用应当免除处罚原则的条件是“没有造成损害”，没有造成损害，是指没有造成任何实际的危害后果。

c. 对中止犯的处罚，应当同时引用《刑法》第24条和《刑法》分则有关具体犯罪的条文。在罪名上应对中止形态有所体现。

⑤ 注意中止犯与《刑法》第13条“但书”的关系。对中止犯适用应当减轻或者免除处罚原则的前提是行为人的行为虽然未达到犯罪既遂，但还是已经达到足以构成犯罪的程度，如果行为人的行为属于《刑法》第13条“但书”规定的情节显著轻微，危害不大的情形，应不认为是犯罪。

9 简述主犯与首要分子的关系。（暨南大学2017年研）

相关试题：主犯与首要分子（概念题，武大2010年研）

答：（1）主犯，是指组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。主犯分为两种：

① 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，也就是犯罪集团的首要分子。

② 在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。

（2）首要分子，即在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子，相对于犯罪集团的首要分子，又称其他主犯或首要分子以外的主犯。我国《刑法》第97条规定：“本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。”这里规定的首要分子是就必要的共同犯罪而言的，亦即是对刑法分则条文明文规定的“首要分子”所作的解释。从这一规定可以看出，首要分子有两种：

① 在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子，即犯罪集团的首要分子，这种首要分子与我国《刑法》第26条规定的首要分子相当，但由于它是刑法分则所规定的，因而在处理有关犯罪的这种首要分子时，应当直接引用刑法分则的有关条文，不需要援引《刑法》第26条。

② 在聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子，即聚众犯罪的首要分子。这种首要分子与主犯的关系如何，看法不一：

a. 第一种主犯说，认为第一种主犯为首要分子，首要分子为两种即聚众犯罪的首要分子与犯罪集团的首要分子。

b. 独立主犯说，认为主犯分为三种，聚众犯罪的首要分子是犯罪集团的首要分子和在犯罪集团或一般共同犯罪中起主要作用的犯罪分子之外的一种独立的主犯。

c. 第二种主犯说，认为聚众犯罪的首要分子完全包括在第二种主犯即在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子当中。

聚众犯罪中起主要作用的犯罪分子属于第二种主犯，它包括如下一些情况：一是在以首要分子为重罪构成要件的聚众犯罪中的首要分子；二是在以首要分子为基本犯罪构成要件的聚众犯罪中，首要分子为二人以上时起主要作用的犯罪分子；三是在以首要分子和其他积极参加者为基本犯罪构成要件的聚众犯罪中的首要分子。

10 继续犯的特征。（扬州大学2017年研）

答：继续犯，是作用于同一对象的一个犯罪行为从着手实行到行为终了，犯罪行为与不法状态在一定时间内同时处于继续状态的犯罪。其特征包括：

(1) 继续犯必须是犯罪行为与不法状态同时继续，而不仅仅是不法状态的继续。

(2) 继续犯必须是犯罪行为在一定时间内（成立继续犯所需的时间内）不间断地持续存在。

(3) 继续犯必须是一个行为侵犯了同一具体的法益，即犯罪行为自始至终都针对同一对象、侵犯同一法益。

(4) 继续犯必须是一个犯罪行为，且在主观上继续犯支配行为的犯意只有一个。对于继续犯，不论其持续时间的长短，均应以一罪论处。因为，持续性的行为是在一个罪过心理支配下实施的，并且是针对同一对象侵犯同一法益，因而符合一个犯罪构成。

此外，根据《刑法》第89条的规定，对继续犯的追诉期限，从犯罪行为终了之日起计算，这也说明对继续犯只能以一罪论处。

11 想象竞合犯与法规竞合的异同点。（山东大学2014年研）

相关试题：

(1) 试述我国刑法中法条竞合适用的具体原则。（暨南大学2017年研）

(2) 想象竞合犯与法规竞合的区别有哪些？请简述。（华南理工2008年研；武大2010年研）

答：想象竞合犯，又称想象的数罪、观念的竞合，通说认为，想象竞合犯是指一个行为触犯数个罪名的犯罪形态。法规竞合，或称法条竞合，是指行为人实施一个犯罪行为同时触犯数个在犯罪构成上具有包容或交叉关系的刑法规范，只适用其中一个刑法规范的情况。

想象竞合犯与法规竞合都是实施了一个行为，都是触犯了数个罪名，这是相同的，但二者存在着重大区别，应当加以划分。二者的区别在于：

(1) 法规竞合的一个行为，只是出于一个罪过，并且是产生一个结果；想象竞合犯的一个行为，往往是数个罪过和数个结果。如开一枪打死一人，打伤一人，只能是想象竞合犯，而不可能是法规竞合。

(2) 法规竞合，是由于法规的错杂规定即法律条文内容存在着包容或交叉关系，以致一个犯罪行为触犯数个刑法规范；想象竞合犯则是由于犯罪的事实特征，即出于数个罪过、产生数个结果，以致一行为触犯数罪名。

(3) 法规竞合，一行为触犯的数个刑法规范之间存在着此一规范规定的犯罪构成包容另一规范规定的犯罪构成的关系；想象竞合犯，一行为触犯规定的数个罪名的法条不存在上述犯罪构成之间的包容关系。

(4) 法规竞合，在竞合的数法规中，仅仅一法规可以适用其行为，其法律适用问题，依照特别法优于普通法等原则来解决；想象竞合犯，竞合的数法规均可以适用其行为，其法律适用问题，依照“从一重处断”的原则来解决。

12 集合犯的概念和构成条件。（山东大学2010年研；中央党校2007年研）

相关试题：简述集合犯的成立要件及类型。（辽宁大学2020年研）

答：集合犯，是指行为人以实施不定次数的同种犯罪行为为目的，虽然实施了数个同种犯罪行为，刑法规定还是作为一罪论处的犯罪形态。集合犯的构成条件包括：

(1) 集合犯是行为人以实施不定次数的同种犯罪行为为目的。即行为人不是意图实施一次犯罪行为即行结束，而是预计实施不定次数的同种犯罪行为。例如，我国《刑法》第336条规定的非法行医罪，行为人就是意图实施不定次数的非法行医行为，这是集合犯主观方面的特征。

(2) 集合犯通常实施了数个同种的犯罪行为。集合犯虽然是行为人意图实施不定次数的同种犯罪行为，并且通常也实施了数个同种的犯罪行为，如非法行医罪，虽多次非法行医，仍然只构成非法行医一罪，但行为人即使非法行医一次，情节严重的，如因

非法行医造成就诊人身体健康受到严重损害，也构成非法行医罪。

(3) 集合犯必须是刑法将可能实施的数个同种犯罪行为规定为一罪。这就是说，“所谓‘集合犯’，因为构成要件本身预定同种行为的反复，所以被反复的同种行为无例外地予以包括，被作为一罪评价。”正因为刑法将可能实施的数个同种行为规定为一罪，所以行为人实施了数个同种行为，仍然只能构成一罪。例如前述的非法行医罪，虽然实施数个非法行医行为，仍只构成一个非法行医罪。

13 请简述牵连犯的概念、特征和处罚原则。（对外经贸2010年研；人大2006年研）

相关试题：

(1) 试述牵连犯的特征与处罚原则。（论述题，上海交大2020年研）

(2) 简述牵连犯的成立条件与处罚原则。（暨南大学2018年研）

(3) 论牵连犯。（论述题，中财2017年研）

(4) 简述牵连犯的特征及处断原则。（中南财大2010年研）

(5) 简述牵连犯的概念和要件。（东财2010年研）

答：（1）牵连犯的概念

牵连犯是指以实施某一犯罪为目的，其方法行为或结果行为又触犯其他罪名的犯罪形态。

（2）牵连犯的特征

① 牵连犯是以实施一个犯罪为目的。这是牵连犯的本罪。牵连犯是为了实施某一犯罪，其方法行为或结果行为，又构成另一独立的犯罪，这是牵连犯的他罪。牵连犯的本罪是一个犯罪，他罪是围绕本罪而成立的。如果行为人出于实施数个犯罪的目的，在此目的支配下实施了数个犯罪。这个犯罪不构成牵连犯。

② 牵连犯必须具有两个以上的行为。这是牵连犯与想象竞合犯的重要区别。即牵连犯是数个行为，想象竞合犯是一个行为。牵连犯的数个行为表现为两种情况：a. 目的行为与方法行为（或称手段行为）；b. 原因行为与结果行为。

③ 牵连犯的数个行为之间必须具有牵连关系。认定有无牵连关系，在刑法理论上主观说、客观说和折中说的分歧。a. 主观说认为有无牵连关系应以行为人的主观意思为标准，即行为人主观意思上以手段或结果的关系使其与本罪发生牵连，即为有牵连关

系；b. 客观说认为有无牵连关系应以客观的事实是否具有牵连的性质为标准；c. 折中说认为本罪与方法行为或结果行为的牵连关系，应当从主客观两方面考察，即行为人在主观上具有牵连的意思，在客观上具有通常的方法或结果关系。折中说既注意从主观意思上考察，又注意从客观事实上考察，克服了主观说和客观说的片面性，同时对牵连关系又作了适当限制，宜认为是可取的。

④ 牵连犯的数个行为必须触犯不同的罪名。即牵连犯以实施某一犯罪为目的，其方法行为或结果行为又触犯了其他罪名。包括两种情况：a. 实施一种犯罪，其犯罪所采用的方法行为又触犯了其他罪名；b. 实施一种犯罪，其犯罪的结果行为又触犯了其他罪名。

(3) 牵连犯的处罚原则

① 《刑法》分则条款未对如何处理牵连犯作特别规定的，应当按照其中最重的一个罪从重处罚，即“从一重从重处罚”。

② 《刑法》分则条款对如何处理牵连犯作了特别规定的，必须按照《刑法》分则有关条款的规定处理。

14 简述刑事责任与刑罚的关系。（山东大学2015、2011年研）

答：刑事责任，是指刑事法律规定的，因实施犯罪行为而产生的，由司法机关强制犯罪者承受的刑事惩罚或单纯否定性法律评价的负担。刑罚，是指刑法规定的由国家审判机关依法对犯罪人适用的限制或剥夺其某种权益的最严厉的强制性制裁方法。刑事责任与刑罚是两个不同的概念。

(1) 刑事责任与刑罚的主要区别：

- ① 刑事责任是一种法律责任，刑罚则是一种强制方法。
- ② 刑事责任是以犯罪人承受刑法规定的惩罚或单纯的否定性法律评价为内容，刑罚则是以剥夺犯罪人一定的法益为内容。
- ③ 刑事责任随实施犯罪而产生，刑罚则随法院有罪判决的生效而出现。

(2) 刑事责任与刑罚的联系：

- ① 刑事责任的存在是适用刑罚的前提。没有刑事责任，绝不可能适用刑罚；只有存在刑事责任，才能适用刑罚。

② 刑事责任的大小决定刑罚的轻重。刑事责任大的，刑罚就重；刑事责任小的，刑罚就轻，刑罚的轻重根据刑事责任的大小来确定。

③ 刑事责任主要通过刑罚而实现。非刑罚处理方法等虽然也是刑事责任的实现形式，但那是次要的，在司法实践中也是为数很少的，而刑罚则是实现刑事责任的主要形式，并且在司法实践中是大量的，因而非刑罚处理方法与刑罚不宜处于并列的地位。

15 简述死刑缓期二年执行制度。（南开大学2011年研）

相关试题：论我国死缓制度。（论述题，北大2020年研）

答：《刑法》第48条第1款后半段规定：“对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，可以判处死刑同时宣告缓期二年执行。”这就是死刑缓期执行制度，简称死缓。死缓不是独立的刑种，而是死刑的一种执行制度，死缓是我国的独创。

（1）根据上述刑法的规定，死缓的适用需要具备以下条件：

① 适用的对象必须是应当判处死刑的犯罪分子。这是适用死缓的前提。应当判处死刑，是指根据犯罪分子所犯罪行的严重程度和刑法的规定，对其应当判处死刑。

② 不是必须立即执行。不是必须立即执行，是指根据犯罪分子所犯罪行，虽然对其应当适用死刑但不是非立即执行不可的。刑法对哪些犯罪分子属于“不是必须立即执行”死刑的没有明确规定，根据刑事审判经验，应当判处死刑但具有下列情形之一的，可以视为“不是必须立即执行的”犯罪分子：a. 犯罪后自首、立功或者有其他法定从轻情节的；b. 在共同犯罪中罪行不是最严重的或者其他在同一或同类犯罪案件中罪行不是最严重的；c. 被害人的过错导致犯罪人激愤犯罪的；d. 犯罪人有令人怜悯之情形的；e. 有其他应当留有余地情况的等。

（2）由于死缓不是独立的刑种，而是暂缓执行死刑的一种制度，因此，被适用死刑的犯罪分子因其在缓期二年执行期间的表现不同而有三种不同的结果：

① 在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，二年期满后，减为无期徒刑；如果确有重大立功表现，二年期满以后，减为25年有期徒刑；至于哪些属于重大立功表现，应根据《刑法》第78条予以确定。

② 对被判处死刑缓期执行的累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处死刑缓期执行的犯罪分子，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定对其限制减刑。

③ 在死刑缓期执行期间，如果故意犯罪，且情节恶劣的，应报请最高人民法院核准后

执行死刑。对于故意犯罪但没有达到情节恶劣程度而未执行死刑的，应该重新计算死刑缓期执行的期间，并报最高人民法院备案。

16 简述罚金与行政罚款的区别。（浙江工商2016年研）

答：罚金是人民法院判处犯罪分子向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金不同于行政罚款。二者的区别表现在：

- （1）性质不同。罚金是刑罚方法，罚款是行政处罚。
- （2）适用对象不同。罚金适用于犯罪分子，罚款适用于一般违法子。
- （3）适用机关不同。适用罚金的机关是人民法院，适用罚款的机关则是公安、关、税务、工商等行政机关。
- （4）适用的法律根据不同。适用罚金的法律根据是刑法，适用罚款的法律根据是治安管理、海关、税务、工商等行政法律、法规。

17 我国刑法中剥夺政治权利的内容。（中山大学2015年研）

相关试题：

- （1）剥夺政治权利。（中山大学2018年研）
- （2）简述剥夺政治权利的内容与期限。（青岛大学2017年研）

答：（1）剥夺政治权利的含义

剥夺政治权利是剥夺犯罪分子参加国家管理和政治活动权利的刑罚方法。

（2）剥夺政治权利的内容

根据《刑法》第54条的规定，剥夺政治权利是剥夺犯罪分子以下权利：

- ① 选举权和被选举权。
- ② 言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利。
- ③ 担任国家机关职务的权利。
- ④ 担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。

(3) 剥夺政治权利的期限

剥夺政治权利的期限分为以下四种情况：

- ① 被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
- ② 在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当将附加剥夺政治权利的期限改为3年以上10年以下。
- ③ 独立适用或者判处有期徒刑、拘役附加剥夺政治权利的期限为1年以上5年以下。
- ④ 判处管制附加剥夺政治权利的期限与管制的期限相同。

18 一般累犯的成立条件和法律后果。（中南财大2014年研）

相关试题：

- (1) 简述一般累犯的成立条件。（广东财大2018年研）
- (2) 论一般累犯及其构成条件。（论述题，浙工大2018年研）
- (3) 一般累犯的概念和构成条件。（山东大学2010年研）
- (4) 简要说明一般累犯的成立条件。（武大2008年研）

答：（1）一般累犯，是指年满18周岁因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕或者赦免以后，在5年以内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪分子。

（2）一般累犯的构成条件：

- ① 前罪与后罪都是故意犯罪。前后两罪均为过失或者其中之一为过失的，不构成累犯。
- ② 犯前罪时必须年满18周岁，这是构成一般累犯的主体条件。如果犯前罪时不满18周岁，即使是故意犯罪，或者犯后罪是故意犯罪且年满18周岁的，也不构成累犯。
- ③ 前罪被判处有期徒刑以上的刑罚，后罪应当被判处有期徒刑以上的刑罚。这是构成累犯的刑种条件。其中，被判处有期徒刑以上刑罚，是指人民法院对前罪最后确定的宣告刑是有期徒刑以上的刑罚；应当被判处有期徒刑以上刑罚，是指根据犯罪事实和刑法的相关规定，应当被判处有期徒刑以上的刑罚，而不是指犯罪行为所触犯的刑法条文中规定了有期徒刑以上的刑罚。

④ 后罪发生的时间，在前罪判处的刑罚执行完毕或者赦免以后的5年之内。根据该条件，如果前罪与后罪发生的时间间隔在5年之后，则不构成累犯，而仅属于前科事实。至于被假释的犯罪人，前后罪的间隔时间应从假释期满之后起计算。如果被假释的犯罪人在假释期满之后5年内又犯新罪的，成立累犯。对于被判处有期徒刑缓期执行的犯罪人，在缓刑考验期满后又犯罪的，不构成累犯。

19 自首与坦白的异同。（中财2013年研）

相关试题：

- (1) 试论自首与坦白的关系。（论述题，浙江工商2016年研）
- (2) 论自首与坦白的关系。（论述题，广东财大2016年研）
- (3) 简述自首与坦白的区别。（暨南大学2019年研；武大2013年研）
- (4) 自首与坦白（概念题，西南政法2011年研；武大2006年研）

答：自首是指犯罪分子犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的行为。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。坦白，一般是指犯罪分子被动归案之后，自己如实交代犯罪事实的行为。

(1) 自首与坦白的相同之处

- ① 二者均以自己实施了犯罪行为为前提。
- ② 二者都是犯罪人犯罪之后对自己所犯罪行的主观心理态度的外在表现形式。
- ③ 二者都是在归案之后如实交代自己的犯罪事实。
- ④ 二者都是从宽处罚的情节。

(2) 自首和坦白的区别

- ① 自首是犯罪人自动投案，坦白则是犯罪人被动归案。
- ② 自首所交代的既可以是已被发觉的罪行，也可以是尚未被发觉的罪行，当然，如果是犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯的自首，则交代的必须是被指控的罪行以外的罪行，而坦白所交代的则只限于已被发觉、被指控的罪行。
- ③ 自首的犯罪分子供述自己罪行时的态度是主动的，而坦白的犯罪分子供述自己的罪

行时的态度是被动的。归案的方式和所交代的罪行的不同，表明了自首的犯罪人和坦白的犯罪人在认罪、悔罪乃至悔改的时间及其程度的不同。一般说来，自首的犯罪人认罪时间早，悔罪、悔改的程度高；坦白的犯罪人认罪时间晚，悔罪、悔改的程度也较自首的犯罪人要低。

④ 自首的人身危险性相对较轻，坦白的人身危险性相对较重，对自首的从宽幅度可以是“免除处罚”，而坦白的从宽幅度至多是“减轻处罚”。

20 简述我国刑法中缓刑的概念及其适用条件。（北大2004年研；武大2004年研）

相关试题：

（1）试述一般缓刑的适用条件。（论述题，上海交大2020年研）

（2）简述缓刑的适用条件。（暨南大学2017年研）

（3）简述一般缓刑的适用条件。（广东财大2018年研；武大2015年研；华侨大学2011年研）

（4）简述缓刑的适用条件及其与《刑法》第四百四十九条规定的战时缓刑的区别。（中南财大2008年研）

答：我国刑法所规定的缓刑，属于刑罚暂缓执行，即对原判刑罚附条件不执行的一种刑罚制度。具体说包括两类：一是一般缓刑，二是战时缓刑。

（1）刑法中一般缓刑的概念和适用条件

① 一般缓刑，是指人民法院对于被判处拘役或3年以下有期徒刑的犯罪分子，根据其犯罪情节和悔罪表现，认为暂缓执行原判刑罚，确实不致再危害社会的，规定一定的考验期，暂缓其刑罚的执行，如果被判缓刑的犯罪分子在考验期内没有发生法律规定应当撤销缓刑的事由，原判刑罚就不再执行的制度。

② 一般缓刑的适用条件：

a. 犯罪分子必须是被判处拘役或者3年以下有期徒刑的刑罚。因缓刑是对犯罪人不予以关押，附条件不执行原判刑罚，决定了缓刑的适用对象只能是犯罪罪行较轻的犯罪分子，社会危害性较小。对于被管制的，由于仅限制一定的人身自由，所以缓刑对其没有意义。

b. 根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，认为犯罪分子确实没有再犯罪危险，对所居

住社区没有重大不良影响。这是适用缓刑的本质条件。即使有些犯罪分子被判处拘役或者3年以下有期徒刑，但是犯罪情节比较重，无悔罪表现，很难确定不予关押不致再危害社会，也就不能对其适用缓刑。

c. 犯罪分子必须不是累犯和犯罪集团的首要分子。累犯和犯罪集团的首要分子，均具有较大主观恶性和人身危险性，改造的难度和再犯罪的可能性较大。因此，即使累犯和犯罪集团的首要分子被判处拘役或者3年以下有期徒刑，也不能适用缓刑。

适用缓刑必须同时具备上述三个条件，它们必须同时具备，缺乏其中任何一个条件都不能适用缓刑。

对被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子中不满18周岁的人、怀孕的妇女和已满75周岁的三类人，符合上述条件的，应当宣告缓刑。

(2) 战时缓刑的概念和适用条件

① 战时缓刑，是指在战时，对被判处3年以下有期徒刑没有现实危险的犯罪军人，暂缓其刑罚执行，允许其戴罪立功，确有立功表现的，可以撤销原判刑罚，不以犯罪论处的制度。相对于一般缓刑，也被称为“特别缓刑”。

② 战时缓刑的适用条件：

a. 适用的时间，必须是战时。在平时或非战争条件下，不能适用。

b. 适用的对象，只能是指判处3年以下有期徒刑的犯罪军人，不是犯罪的军人，或者虽是犯罪的军人，但被判处的刑罚为3年以上有期徒刑，均不能适用战时缓刑。同时，构成累犯的犯罪军人应当同样不适用于战时缓刑。

c. 在战争条件下宣告缓刑没有现实危险。这是战时缓刑制度最关键和最本质的适用条件。

(3) 一般缓刑与战时缓刑的区别

① 适用对象不同。一般缓刑可以适用于除累犯和犯罪集团首要分子以外的被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子；战时缓刑则适用于除累犯以外的被判处3年以下有期徒刑的犯罪军人。

② 适用的时间不同。一般缓刑的适用无时间方面的限制；战时缓刑只能在战时适用。

③ 适用的实质条件不同。一般缓刑适用的实质条件是“没有再犯罪的危险、对所居住社区没有重大不良影响”；战时缓刑适用的实质条件则是在战时状态下适用缓刑“没有现实危险”。

④ 适用方法和监督考察内容不同。一般缓刑必须是在宣告缓刑的同时依法确定缓刑考验期，考验期内的考察内容为犯罪分子是否具有《刑法》第77条规定的情形；战时缓刑没有缓刑考验期，缓刑的考验内容为犯罪军人是否具有立功表现。

⑤ 法律后果不同。一般缓刑的法律后果为，无论缓刑是否被撤销，所宣告的罪刑仍然成立；而战时缓刑在犯罪军人确有立功表现的条件下，原判刑罚可予撤销，不以犯罪论处，即罪与刑同时消灭。

21 简述减刑的适用条件。（中南财大2013年研）

相关试题：

（1）简述减刑的条件。（四川师大2018年研）

（2）减刑应当具备哪些条件？（浙江工商2016年研）

答：减刑，是指对被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的犯罪分子，因其在刑罚执行期间认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改或者立功表现，而适当减轻其原判刑罚的制度。减刑的适用条件包括：

（1）对象条件

减刑适用的对象是被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子。

（2）实质条件

① 可以减刑的实质条件是犯罪分子在刑罚执行期间认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，或者有立功表现。

② 应当减刑的实质条件是犯罪分子在刑罚执行期间有重大立功表现。

（3）限度条件

减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的 $\frac{1}{2}$ ；判处无期徒刑的，不能少于13年；人民法院依照《刑法》第50条第2款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于25年，缓期执行期满后依法减为25年有期徒刑的，不能少于20年。

22 简述交通肇事罪与危险驾驶罪的区别。（武大2014年研）

答：交通肇事罪，是指违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。危险驾驶罪，是指在道路上驾驶机动车具有追逐竞驶、醉酒驾驶等特定危险驾驶情形的行为。交通肇事罪与危险驾驶罪的区别：

(1) 保护的客体不同。前者的客体是交通运输安全，可以发生在所有交通运输领域。而后者的客体是公路交通运输安全及行人人身、车辆及其他公共设施的安全，只限于在陆路交通中的公路交通领域内。

(2) 客观行为不同。前者的客观方面表现为违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。后者的客观方面表现为在道路上实施下列行为之一的情况：①追逐竞驶，情节恶劣的；②醉酒驾驶机动车的；③从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；④违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。

(3) 主观方面不同。前者是过失犯罪，可以是疏忽大意，也可以是过于自信。而后者是故意犯罪，行为人对危及公共安全持放任的心理态度。

(4) 前者以发生严重后果为入罪的必要条件。后者为（抽象）危险犯，以行为在客观上具有公共危险为入罪标准。

23 简述信用卡诈骗罪的客观特征。（中南财大2009年研）

答：信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，骗取他人数额较大财物的行为。本罪在客观上表现为利用信用卡进行诈骗活动，且骗取财物的数额较大。本罪客观方面包括两个构成要素：

(1) 行为人实行了利用信用卡进行诈骗的活动。具体表现为下列情形：

① 使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的。使用伪造的信用卡，既包括行为人自己伪造信用卡然后使用的，也包括明知是他人伪造的信用卡而使用的。由于伪造的信用卡不是银行签发的，持卡人没有在银行设立账户，因而只要使用了伪造的信用卡购物或者接收服务，其行为就属于诈骗。使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，是指行为人使用虚假的本人居民身份证、军官证或者境外居民护照，以欺骗手段领取信用卡并使用。由于行为人在申领信用卡时使用了虚假的证明材料，在其消费或结算后，发卡银行无法通过申领者追偿而实现债权，因而使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，即属于对发卡银行实行的诈骗行为。

② 使用作废的信用卡的。由于信用卡作废后，已不具有消费结算功能，对接受使用者而言，其出售的商品或者提供的服务实际上不可能获得对价，因而使用作废的信用卡

行为构成对接受使用者的诈骗。

③ 冒用他人的信用卡的。冒用他人信用卡，是指行为人擅自以持卡人的名义，使用自己无权使用的他人的信用卡，包括拾得他人信用卡并使用的；骗取他人信用卡并使用的；窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；其他冒用他人信用卡的情形。

④ 恶意透支的。所谓恶意透支，是指以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的行为。区分善意透支与恶意透支，关键看行为人是否具有非法占有的目的。

(2) 骗取的财物数额较大。使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额较大的标准为5000元；恶意透支，数额较大的标准为1万元。同时规定，恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。

24 试述非法经营罪的客观行为方式。（中南财大2001年研）

相关试题：简述非法经营罪的构成要件。（辽宁大学2020年研）

答：非法经营罪，是指违反国家规定从事经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。《刑法》将本罪的行为规定为以下几种：

(1) 未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品。

未经许可，是指未经国家有关主管部门的批准。专营、专卖物品，是指国家法律、行政法规明确规定必须由专门的机构经营、销售的物品，如食盐、烟草等。其他限制买卖的物品，是指国家根据经济发展和维护国家、社会和人民群众利益的需要，规定在一定时期实行限制性经营的物品，如化肥、农药等。这些物品的范围随着社会经济的发展而不断调整。

(2) 买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件。

进出口许可证，是指国家外贸主管部门对企业颁布的可以从事进出口业务的证明文件。进出口原产地证明，是指在国际贸易活动中，进出口产品时必须附带的由原产地有关主管机关出具的确认文件。其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，是指法律、行政法规规定从事某些生产经营活动者必须具备的经营许可证或者批

准文件，如烟草专卖、种子经营、森林采伐、矿产开采、野生动物狩猎等许可证。

(3) 未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，或者非法从事资金支付结算业务。

(4) 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

这是因为立法无法穷尽所有非法经营行为而作的一个兜底性规定。目前有关法律法规和司法解释已明确作为其他非法经营行为处理的行为有10余种。

25 简述实施偷盗婴幼儿的行为，可能涉及哪几种犯罪？（南师大2008年研）

相关试题：结合刑法分则条文的有关规定说明对“偷盗婴幼儿”的行为应当如何定罪。
（南开大学2007年研）

答：实施偷盗婴幼儿的行为，可能涉及以下三种犯罪：

(1) 绑架罪。指以勒索财物为目的绑架他人，或者绑架他人作为人质的行为。其构成特征是：

① 本罪的客体是复杂客体，包括他人的人身自由权利、健康、生命权利及公私财产所有权利。

② 本罪的客观方面，虽然立法对本罪的绑架的手段行为没有规定，但是，从绑架的含义来说，是使用暴力、胁迫或者其他手段劫持他人的行为。

③ 本罪的主体是一般主体，即年满16周岁、具有刑事责任能力的人均可构成本罪主体。

④ 本罪的主观方面是直接故意。

以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，亦可构成绑架罪。

(2) 拐卖儿童罪。指以出卖为目的，拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转儿童的行为。其构成要件包括：

① 本罪的客体，是人身权利中的人身不受买卖的权利。儿童，指不满14周岁的男、女儿童。

② 本罪的客观方面，表现为实施拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转儿童之一的行为。

- a. 拐骗，是指采用欺骗、利诱等非强制性手段，将儿童置于自己的控制之下的行为。
- b. 绑架，是指采用暴力、胁迫、麻醉或其他强制性手段劫持儿童的行为。
- c. 收买，是指以出卖为目的，用货币等从他人处先买下儿童的行为。
- d. 贩卖，是指将儿童卖给第三者换取钱财的行为。
- e. 接送与中转，是指在拐卖儿童的过程中分工实施藏匿、移送、接转被拐卖儿童的行为。

③ 本罪的主体，是一般主体。为年满16周岁，具备刑事责任能力的自然人。

④ 本罪的主观方面，是直接故意，并且具备出卖的目的。

以出卖为目的而偷盗婴幼儿的，也可以构成拐卖儿童罪。

(3) 拐骗儿童罪。指拐骗不满14周岁的儿童，使其脱离家庭或者其监护人的行为。构成要件包括：

① 客体为他人的家庭关系以及儿童的合法权益。对象是不满14周岁的男女儿童。

② 客观方面表现为拐骗不满14周岁的儿童，使其脱离家庭或者监护人的行为。如以出卖或勒索财物为目的而偷盗婴幼儿的，则以拐卖儿童罪或绑架罪论处。

③ 本罪的主体为一般主体。

④ 主观方面是直接故意。动机多为收养或役使。

26 诬告陷害罪与报复陷害罪的区别。（上海大学2002年研）

答：（1）诬告陷害罪，是指捏造犯罪事实诬陷他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的行为。其构成要件为：

① 本罪的客体是他人的人身权利和司法机关的正常活动。

② 本罪的客观方面，表现为捏造犯罪事实，进行告发，情节严重的行为。

③ 本罪的主体，是一般主体。即年满16周岁具备刑事责任能力的自然人。

④ 本罪的主观方面，是直接故意，必须具有使他人受到刑事追究的目的。

（2）报复陷害罪，是指国家机关工作人员，滥用职权、假公济私，对控告人、申诉

人、批评人、举报人实行报复陷害的行为。

(3) 诬告陷害罪与报复陷害罪的区别：

① 主体不同。诬告陷害罪的主体是一般主体，即年满16周岁具备刑事责任能力的自然人；报复陷害罪的主体是国家机关工作人员。

② 客观方面不同。诬告陷害罪的客观方面表现为捏造犯罪事实，进行告发，情节严重的行为；报复陷害罪的客观方面表现为国家机关工作人员滥用职权、假公济私，对控告人、申诉人、批评人、举报人实行报复陷害的行为。

③ 客体不同。诬告陷害罪的客体为他人的的人身权利和司法机关的正常活动，作为对象的“他人”可以是任何人。报复陷害罪的客体为公民的控告权、申诉权等民主权利和国家机关的正常活动，对象包括控告人、申诉人、批评人和举报人。

27 简述抢劫罪的加重情形。（人大2007年研）

答：抢劫罪，是指以非法占有为目的，以暴力、胁迫或者其他方法，当场强行劫取公私财物的行为。抢劫罪的加重情形主要有以下八种：

(1) 入户抢劫。指为实施抢劫行为而进入他人生活的与外界相对隔离的住所，包括封闭的院落、牧民的帐篷、渔民作为家庭生活场所的渔船，为生活租用的房屋进行抢劫的行为。注意，“户”在这里指住所，其特征表现为供他人家庭生活和与外界相对隔离两个方面；① 入户目的要有非法性；② 暴力或暴力胁迫行为必须发生在户内。

(2) 在公共交通工具上抢劫。“公共交通工具”的界定，既包括在从事旅客运输的各种公共汽车，大、中型出租车，火车、船只、飞机等正在运营中的机动工具上对旅客、司售、乘务人员实施的抢劫，也包括对运输途中的机动公共交通工具加以拦截后，对公共交通工具上的人员实施的抢劫。

(3) 抢劫银行或者其他金融机构。指抢劫是指抢劫银行或者其他金融机构的经营资金、有价证券和客户资金等。

(4) 多次抢劫或抢劫数额巨大。“多次抢劫”是指抢劫3次以上（含3次），一般要求在不同时间、不同地点作案。

(5) 抢劫致人重伤、死亡。“致人重伤”既包括过失致人重伤，也包括故意致人重伤。抢劫“致人死亡”应当包括在抢劫过程中故意杀害财物的所有人、占有人或管理人之情情形在内，不应包括实施抢劫财物行为前后的故意杀人，无论是直接故意或者是间接故意。行为人为抢劫财物预谋故意杀人或者在劫取财物过程中，为制服被害人反抗而故

意杀人的，以抢劫罪定罪处罚。

(6) 冒充军警人员抢劫。最高人民法院《关于审理抢劫刑事案件适用法律若干问题的指导意见》第2条规定，认定“冒充军警人员抢劫”，要注重对行为人是否穿着军警制服、携带枪支、是否出示军警证件等情节进行综合审查，判断是否足以使他人误以为是军警人员。对于行为人仅穿着类似军警的服装或仅以言语宣称系军警人员但未携带枪支、也未出示军警证件而实施抢劫的，要结合抢劫地点、时间、暴力或威胁的具体情形，依常人判断标准，确定是否认定为“冒充军警人员抢劫”。军警人员利用自身的真实身份实施抢劫的，不认定为“冒充军警人员抢劫”，应依法从重处罚。

(7) 持枪抢劫。指行为人使用枪支或者向被害人显示其持有，佩带的枪支进行抢劫的行为。

(8) 抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资。“军用物资”是指除枪支、弹药、爆炸物之外的，供军事上使用的其他物资。“抢险、救灾、救济物资”是指已经确定将要用于或者正在用于抢险、救灾、救济的物资，包括正处于保管、运输、调拨、储存过程中，但已确定其为抢险、救灾、救济之特定用途的物资。抢劫军用物资或抢险、救灾、救济物资，必须以行为人明知是有这些特定用途的物资为成立条件，如果事前或者事中并不知道其特定用途，则不能构成本项的加重犯。

28 简述转化型抢劫罪的成立条件。（武大2014年研）

相关试题：试论转化型抢劫罪的构成条件。（论述题，暨南大学2019年研）

答：《刑法》第269条规定，犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照抢劫罪的规定定罪处罚。这种犯罪通常在理论上被称为准抢劫罪或转化型抢劫罪。认定转化型抢劫罪，应当把握三个构成条件：

(1) 实施了盗窃、诈骗、抢夺的犯罪行为。这是转化型抢劫罪的前提条件。行为人实施盗窃、诈骗、抢夺行为，未达到“数额较大”，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证当场使用暴力或者以暴力相威胁，情节较轻、危害不大的，一般不以犯罪论处；但具有下列情节之一的，可依照《刑法》第269条的规定，以抢劫罪定罪处罚：盗窃、诈骗、抢夺接近“数额较大”标准的；入户或在公共交通工具上盗窃、诈骗、抢夺后在户外或交通工具外实施上述行为的；使用暴力致人轻微伤以上后果的；使用凶器或以凶器相威胁的；具有其他严重情节的。此外，已满16周岁不满18周岁的人犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，应当依照《刑法》第269条的规定定罪处罚；情节轻微的，可不以抢劫罪定罪处

罚。

(2) 当场实施暴力或者以暴力相威胁。这是转化型抢劫罪的客观条件。“当场”是指实施盗窃、诈骗、抢夺罪的现场，或者刚一逃离现场即被人发现和追捕的过程中。“暴力或者以暴力相威胁”，是指当场对被害人或其他抓捕人的身体实施打击或强制，或者以当场实施打击或强制相威胁。

(3) 当场实施暴力或者以暴力相威胁，目的是窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证。这是转化型抢劫罪的主观条件。窝藏赃物，是指为保护已经到手的赃物不被追回；抗拒抓捕，是指抗拒公安机关的拘捕和公民的扭送；毁灭罪证，是指销毁自己遗留在犯罪现场的痕迹、物品和其他证据。暴力、威胁的对象，可以是财物的所有人、公安人员或其他任何参与抓捕的人。但是，不是出于上述目的而对他人实施暴力或以暴力相威胁的，不构成转化型抢劫罪。其行为构成犯罪的，应当以有关罪名定罪处罚。

29 举例简述盗窃罪、诈骗罪、侵占罪之间的区别。（西安交大2008年研）

相关试题：

(1) 简述盗窃罪与诈骗罪的区别。（武大2015年研）

(2) 侵占罪和盗窃罪的区别有哪些？（北大2013年研）

答：（1）盗窃罪，是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额较大，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。

（2）诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大的行为。

（3）侵占罪，是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物或者他人的遗忘物、埋藏物非法据为己有，数额较大且拒不退还或者拒不交出的行为。

（4）盗窃罪、诈骗罪、侵占罪之间的区别：

① 犯罪对象不同。侵占罪的犯罪对象是代为保管的他人财物、他人的遗忘物或者埋藏物，如主人将客人前来做客的人遗忘在室内的贵重物据为己有。盗窃罪的犯罪对象是不为行为人占有的他人财物，如将商店的贵重商品秘密地藏匿，在不付款的情况下据为己有。诈骗罪的犯罪对象也是不为行为人占有的他人财物。

② 客观方面不同。侵占罪的客观方面的行为是拒不退还或者拒不交出财物，方式可以是公开的也可以是非公开的，前者如保管人被合法地要求返还，但声称不再归还从而

据为己有，后者如饭店隐匿客人遗落座位上的贵重物品，企图非法占有而对客人谎称未见到。盗窃罪客观方面的行为是秘密窃取，行为方式只能是行为人认为不为财物所有人所知的秘密方式。诈骗罪的客观方面表现为用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法，骗取公私财物，其方式是公开的。

③ 占有财物的时间不同。侵占罪中行为人在实施犯罪行为之前就已经占有了他人的财物，且占有该财物的行为系合法的，如保管人是合法地占有他人寄存物，后见财起意拒绝归还。盗窃罪中的财物只能是在行为人实施了具体的犯罪行为之后才得以占有，如偷偷将其他乘客包内的贵重物品转移至自己占有。诈骗罪的行为人也是在实施犯罪之后占有他人财物，如谎称交易发生欺骗他人将大额款项汇往自己账户。

30 妨害公务罪的犯罪构成要件。（中国政法2020年研）

答：妨害公务罪，是指以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员、人大代表依法执行职务，或者在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁的方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责，以及故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，虽未使用暴力、威胁方法，但造成严重后果的行为。本罪的构成要件如下：

（1）本罪侵犯的客体是国家机关、人民代表大会、红十字会、国家安全机关以及公安机关的公务。公务，是指公共管理事务，即国家机关工作人员与人大代表依法执行职务的活动，红十字会工作人员依法履行职责的活动，以及国家安全机关和公安机关工作人员依法执行国家安全工作任务的活动。本罪侵犯的对象是正在依法执行职务、履行职责的上述四类人员。

（2）本罪的客观方面表现为行为人以暴力、威胁的方法阻碍国家机关工作人员、人大代表依法执行职务，或者在自然灾害和突发事件中以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责，或者虽未使用暴力、威胁的方法，但故意阻碍国家安全机关与公安机关工作人员依法执行国家安全工作任务，且造成了严重后果的行为。

（3）本罪的主体为一般主体，凡是已满16周岁具有刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的主体。

（4）本罪的主观方面是故意，即行为人明知对方是正在依法执行职务或履行职责的国家机关工作人员、人大代表、红十字会工作人员而有意以暴力、威胁方法加以阻碍，或者明知对方是正在依法执行国家安全工作任务的国家安全机关与公安机关工作人员，而有意进行阻碍，希望或放任使之，无法正常执行职务或者履行职责的结果发生。如果行为人对上述人员的身份或者执行公务的合法性发生认识错误而实施了妨害公务的行为，不构成本罪。

31 简述我国刑法规定贪污罪的构成特征。（中山大学2015年研）

答：贪污罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。根据《刑法》第382条第2款的规定，受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。贪污罪的构成特征如下：

（1）本罪的客体是复杂客体，即本罪既侵犯国家工作人员的职务廉洁性，也侵犯公共财产的所有权。本罪的犯罪对象是公共财物。根据《刑法》第91条的规定，公共财产是指下列财产：国有财产；劳动群众集体所有的财产；用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或专项基金的财产。在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论。

（2）本罪的客观方面表现为利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

① 必须利用职务上的便利。利用职务上的便利，是指利用职务权力和地位所形成的主管、管理、经营、经手公共财物的便利条件。

- a. 主管，主要是指负责调拨、处置及其他支配公共财物的职务活动。
- b. 管理，主要是指负责保管、处理及其他使公共财物不被流失的职务活动。
- c. 经营，主要是指将公共财物作为生产、流通手段等使公共财物增值的职务活动。
- d. 经手，主要是指领取、支出等经办公共财物的职务活动。

② 必须侵吞、窃取、骗取或以其他手段非法占有公共财物。

a. 侵吞，是指行为人利用职务上的便利，将自己主管、经手、管理的公共财物，非法占为己有。根据《刑法》第394条的规定，国家工作人员在国内公务活动或对外交往中接受礼物，依照国家规定应当交公而不交公，数额较大的，以贪污罪定罪处罚。

b. 窃取，是指行为人利用职务上的便利，采取秘密方式将自己合法管理的公共财物占为己有。

c. 骗取，是指行为人利用职务上的便利，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法非法占有公共财物。根据《刑法》第183条的规定，国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员，利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事

故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，以贪污罪定罪处罚。

d. 其他手段，是指行为人利用职务上的便利，采用侵吞、窃取、骗取以外的方法，非法占有公共财物。

(3) 本罪的主体是特殊主体，即国家工作人员。根据《刑法》第93条的规定，国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。此外，受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，也可以成为贪污罪的主体。

(4) 本罪的主观方面是故意，并且具有非法占有公共财物的目的。

32 构成挪用公款罪在客观方面应具备哪些条件？（武大2006年研）

相关试题：简述挪用公款归个人使用及其不同类型。（暨南大学2016年研）

答：挪用公款罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过3个月未还的行为。利用职务上的便利，是指利用职务权力和地位所形成的主管、管理、经营、经手公款（包括特定款物）的便利条件。既包括行为人直接经手、管理公款的便利条件，也包括行为人因其职务关系而具有的调拨、支配、使用公款的便利条件。挪用公款归个人使用分为以下三种类型：

(1) 挪用公款进行非法活动。“非法活动”，既包括犯罪活动，也包括其他违法活动。挪用公款归个人使用，进行赌博、走私等非法活动的，构成挪用公款罪，不受“数额较大”和挪用时间的限制。挪用公款给他人使用，不知道使用人将公款用于非法活动，数额较大、超过3个月未还的，构成挪用公款罪；明知使用人将公款用于非法活动的，应当认定为挪用人挪用公款进行非法活动。挪用公款归个人使用，进行非法活动的，以挪用公款5000元至1万元为追究刑事责任的数额起点。

(2) 挪用公款数额较大、进行营利活动。挪用公款数额较大，归个人进行营利活动的，构成挪用公款罪，不受挪用时间和是否归还的限制。在案发前部分或者全部归还本息的，可以从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动。所获取的利息、收益等违法所得，应当追缴，但不计入挪用公款的数额。挪用公款给他人使用，不知道使用人使用公款进行营利活动，数额较大、超过3个月未还的，构成挪用公款罪；明知使用人用于

营利活动的，应当认定为挪用人挪用公款进行营利活动。挪用公款归个人使用，“数额较大、进行营利活动的”，以挪用公款1万元至3万元为“数额较大”的起点。挪用公款归个人用于公司、企业注册资本验资证明的，应当认定为挪用公款进行营利活动。

(3) 挪用公款数额较大、超过3个月未还。即挪用公款进行营利活动、非法活动以外的活动，数额较大，挪用时间超过了3个月。挪用公款归个人使用，数额较大、超过3个月未还的，构成挪用公款罪。挪用正在生息或者需要支付利息的公款归个人使用，数额较大，超过3个月但在案发前全部归还本金的，可以从轻处罚或者免除处罚。给国家、集体造成的利息损失应予追缴。挪用公款数额巨大，超过3个月，案发前全部归还的，可以酌情从轻处罚。挪用公款归个人使用，“数额较大、超过3个月未还的”，以挪用公款1万元至3万元为“数额较大”的起点。

另外，挪用公款归还个人欠款的，应当根据产生欠款的原因分别认定属于挪用公款的何种情形。归还个人进行非法活动或者进行营利活动产生的欠款，应当认定为挪用公款进行非法活动或者进行营利活动。

33 玩忽职守罪与滥用职权罪的主要区别。（西北政法2006年研）

答：滥用职权罪，是指国家机关工作人员超过职权，违法决定、处理其无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。玩忽职守罪，是指国家机关工作人员严重不负责任，不履行或者不正确履行职责，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。比较两罪的概念可以看出，除了犯罪主体是完全相同的以外，其犯罪客体、犯罪的客观方面和主观方面都是有区别的。

(1) 直接客体不同。滥用职权罪与玩忽职守罪均属于渎职罪，其同类客体也是“国家机关的正常管理活动”。但滥用职权罪的直接客体是国家机关工作人员职务活动的正当性，玩忽职守罪的直接客体是国家机关工作人员职务活动的勤政性。

(2) 客观方面不同：

① 行为性质上的区别。滥用职权罪在客观方面的本质属性是对职权的“滥用”。这种“滥用”主要表现为两种情形：a. 超越职权的滥用，即行为人超越法定权力范围，违法决定无权决定的事项、擅自处理无权处理的事务；b. 违反规定处理公务，即行为虽未逾越行为人的职权范围，但行为人以不正当目的或非法的方式行使自己的职权，对有关事项作出符合法律法规规定的处理或者决定。玩忽职守罪的客观方面表现为行为人具有玩忽职守的行为，即严重不负责任，主要表现为两种情形：一是不履行职责，即行为人严重不负责任，对法定职责义务，该为而不为，放弃职守、擅离岗位；二是不

认真履行职责，即行为人严重不负责任，对法定职责义务马虎草率、敷衍塞责。

② 行为方式的主要区别。从行为方式上讲，滥用职权罪和玩忽职守罪都既可以由作为构成，也可以由不作为构成，只是行为的主要方式有所区别，即滥用职权罪主要表现为作为，玩忽职守罪多数表现为不作为。

(3) 主观方面不同：

滥用职权罪在主观上只能出自故意，而玩忽职守罪在主观上只能出自过失。

34 简述徇私枉法罪。（武大2005年研）

答：徇私枉法罪，是指司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉，对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的行为。

(1) 本罪侵犯的客体是国家司法机关的正常活动及司法机关严格执法的威信。此外，还包括因对无罪之人非法追究而侵犯的公民的人身权利。

(2) 本罪客观方面表现为三种行为：① 对明知是无罪的人而使他受追诉；② 对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉；③ 在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判，指故意枉法进行判决、裁定，使有罪判无罪、无罪判有罪、此罪判彼罪或者重罪轻判、轻罪重判。本罪的存在范围并不仅限于刑事诉讼的某个阶段或环节，而是包括侦查、起诉、审判、执行整个刑事诉讼过程。

(3) 本罪主体必须是司法工作人员。根据《刑法》第94条的规定，司法工作人员，是指有侦查、检察、审判、监管职责的工作人员。根据司法实践，司法机关专业技术人员，也可以成为本罪主体。

(4) 本罪主观方面只能出于故意，包括直接故意与间接故意。动机是为了徇私枉法或者徇情枉法。徇私枉法，是指为了个人利益而枉法，主要是贪图钱财而枉法。徇情枉法，是指为了私情而枉法，主要表现为出于照顾私人关系或感情、袒护亲友或者泄愤报复而枉法。

三、论述题

1 试论罪刑法定原则的基本内容与派生原则。（中山大学2017年研）

相关试题：

- （1）罪刑法定原则及其派生原则。（简答题，山东大学2018年研）
- （2）简述罪刑法定原则的派生原则。（辽宁大学2020年研；浙江工商2018年研）
- （3）罪刑法定原则的形成及在我国刑法上的体现。（中山大学2015年研）
- （4）简述罪刑法定原则的含义及适用原则。（简答题，中南财大2014年研）
- （5）简述罪刑法定原则的基本含义。（简答题，北大2010年研）

答：（1）罪刑法定原则的基本内容

罪刑法定原则的基本内容，即什么是犯罪，有哪些犯罪，各种犯罪的构成条件是什么，有哪些刑种，各个刑种如何适用以及各种具体罪的具体量刑幅度如何等，均由刑法加以规定。对于刑法分则没有明文规定为犯罪的行为，不得定罪处罚。概括来说，即“法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚”。

（2）罪刑法定原则的派生原则

主要包括：排斥习惯法、排斥绝对不定期刑、禁止有罪类推、禁止重法溯及既往。具体来说：

- ① 绝对禁止适用习惯法，把成文法作为刑法的唯一渊源。对于刑法上没有明文规定的行为，不允许通过适用习惯法定罪。
- ② 绝对禁止法外刑和绝对不定期刑。刑罚的名称、种类和幅度，都必须由法律加以确定，并且刑期必须是绝对确定的，既不允许存在绝对的不定期刑，也不允许规定相对的不定期刑。
- ③ 绝对禁止适用类推，但是不禁止扩大解释，把刑法的明文规定作为定罪的唯一根据。对于法律没有明文规定的行为，不能通过类推或者类推解释以犯罪论处。
- ④ 绝对禁止刑法溯及既往，把从旧原则作为解决刑法溯及力问题的唯一原则。对于行为的定罪量刑，只能以行为当时有效的法律为依据，行为后颁行的新法没有溯及既往

的效力。

【拓展】相对的罪刑法定原则是对传统的绝对罪刑法定原则的修正，其基本内容是：

① 在定罪的根据上，允许有条件地适用类推和严格限制的扩大解释，即适用类推必须以法律明确规定类推制度为前提，以有利于被告人为原则，不允许不利于被告人的类推；进行扩大解释必须以不超越解释权限为前提，以符合立法精神为原则，不允许越权解释或违背立法本意作任意解释。

② 在刑法的渊源上，允许习惯法成为刑法的间接渊源，但必须以确有必要或不得已而用之为前提。只有当构成犯罪的要件确定后，必须借助习惯法加以说明时，习惯法才能成为对个案定性处理的依据。

③ 在刑法的溯及力上，允许采用从旧兼从轻的原则，作为禁止刑法溯及既往的例外。新法对其颁布施行前的行为，原则上没有追溯的效力。但是，当新法不认为是犯罪或处罚较轻时，则可以适用新法。

④ 在刑罚的种类上，允许采用相对的不定期刑，即刑法在对刑罚种类作出明文规定的前提下，可以规定出具有最高刑和最低刑的量刑幅度，法官有权根据案件的具体情况，在法定的量刑幅度内选择确定适当的刑种和刑度。

从当今世界各国的刑法立法和司法现状来看，早期的绝对罪刑法定原则已受到严峻的挑战，代之而起的相对罪刑法定原则，成为各国刑法改革的发展方向。

(3) 罪刑法定原则在我国刑法中的体现

修订的《刑法》第3条规定：“法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。”这一原则的价值内涵和内在要求，在整部法典中得到了较为全面、系统的体现：

① 修订的《刑法》实现了犯罪的法定化和刑罚的法定化。

② 修订的《刑法》取消了1979年《刑法》第79条规定的类推制度，这是罪刑法定原则得以真正贯彻的重要前提。

③ 修订的《刑法》重申了1979年《刑法》第9条关于刑法在溯及力问题上从旧兼从轻的原则。

④ 在分则罪名的规定方面，修订的《刑法》已相当详备。

⑤ 在具体犯罪的罪状以及各种犯罪的法定刑设置方面，修订的《刑法》增强了法条的可操作性。对于大量犯罪，尽量使用叙明罪状；在犯罪的处罚规定上，注重量刑情节

的具体化。

2 论述犯罪的基本特征。（中山大学2016年研）

相关试题：简述犯罪的基本特征。（简答题，广东财大2018年研）

答：我国《刑法》第13条对犯罪下了定义：一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。犯罪的基本特征如下：

（1）犯罪是危害社会的行为，即具有一定的社会危害性。行为具有一定的社会危害性，是犯罪最基本的特征。社会危害性，是指行为对刑法所保护的社会关系造成或可能造成这样或那样损害的特性。没有社会危害性，就没有犯罪；社会危害性没有达到相当的程度，也不构成犯罪。

① 社会危害性的决定因素：a. 行为侵犯的客体，即行为侵犯了什么样的社会关系；b. 行为的手段、后果以及时间、地点；c. 行为人的情况及其主观因素。

② 社会危害性的考察角度：a. 要用历史的观点看问题；b. 要有全面的观点；c. 要透过现象抓住事物的本质。

（2）犯罪是触犯刑律的行为，即具有刑事违法性。违法行为有各种各样的情况，包括民事违法行为、经济违法行为以及行政违法行为等。犯罪也是违法行为，但不是一般违法行为，而是违反刑法即触犯刑律的行为，是刑事违法行为。只有当危害社会的行为触犯了刑律的时候，才构成犯罪。行为的社会危害性是刑事违法性的基础；刑事违法性是社会危害性在刑法上的表现。只有当行为不仅具有社会危害性，而且违反了刑法，具有刑事违法性，才可能被认定为犯罪。

（3）犯罪是应受刑罚处罚的行为，即具有应受惩罚性。犯罪是适用刑罚的前提，刑罚是犯罪的法律后果。因此，应受刑罚处罚也是犯罪的一个基本特征。不应受惩罚和不需要惩罚是两个意思。不应受惩罚，是指行为人的行为根本不构成犯罪，当然就不存在应受惩罚的问题；而不需要惩罚，是指行为人的行为已经构成了犯罪，本应惩罚，但考虑到具体情况，例如犯罪情节轻微，或者有自首、立功等表现，从而免予刑事处罚。

犯罪的三个特征是紧密结合的。一定的社会危害性是犯罪最基本的属性，是刑事违法

性和应受惩罚性的基础。社会危害性如果没有达到违反刑法、应受刑罚处罚的程度，也就不构成犯罪。因此，这三个特征都是必要的，是任何犯罪都必然具有的。

3 论述犯罪客体与犯罪对象的关系。（中山大学2009年研）

相关试题：

（1）刑法中犯罪对象与犯罪客体的区别。（简答题，复旦大学2020年研）

（2）论犯罪对象与犯罪客体的关系。（广东财大2016年研）

（3）犯罪对象与犯罪客体的联系和区别。（简答题，中财2013年研）

（4）简述犯罪客体与犯罪对象的联系、区别。（简答题，西安交大2008年研；山东大学2007年研）

答：犯罪客体是指我国刑法所保护的、为犯罪行为所侵害的社会关系。犯罪对象是指刑法分则条文规定的犯罪行为所作用的客观存在的具体人或者具体物。二者的联系和区别主要表现在：

（1）犯罪客体与犯罪对象的联系：

① 作为犯罪对象的具体物是具体社会关系的物质表现，作为犯罪对象的具体人是具体社会关系的主体或参加者。

② 犯罪分子的行为作用于犯罪对象，就是通过犯罪对象即具体物或者具体人来侵害一定的社会关系。

（2）犯罪客体与犯罪对象的区别：

① 犯罪客体决定犯罪性质，犯罪对象则未必。

仅从犯罪对象分析某一案件，并不能表明犯罪性质。只有通过犯罪对象体现的社会关系即犯罪客体，才能确定某种行为性质。

② 犯罪客体是任何犯罪的必要构成要件，而犯罪对象则仅仅是某些犯罪的必要构成要件。

如我国《刑法》第328条第1款规定的盗掘古文化遗址、古墓葬罪，其犯罪对象只能是古文化遗址、古墓葬，否则便不可能构成此罪。又如我国《刑法》第152条第1款规定的走私淫秽物品罪，其犯罪对象只能是具体描绘性行为或者露骨宣扬色情的淫秽性的

书刊、影片、录像带、录音带、图片及其他淫秽物品，否则就不可能构成此罪。而像妨害传染病防治罪、脱逃罪、偷越国（边）境罪以及非法集会、游行、示威罪等，则很难说有什么犯罪对象，但无疑这些犯罪都具有犯罪客体。

③ 任何犯罪都会使犯罪客体受到危害，而犯罪对象则不一定受到损害。

如诈骗犯将他人的计算机骗走，侵犯了他人的财产权利，但作为犯罪对象的计算机本身则未必受到损害。一般情况下，犯罪分子往往把诈骗所得之物妥为保存，以便自用或者销赃。

④ 犯罪客体是犯罪分类的基础，犯罪对象则不是。

犯罪客体是犯罪的必要构成要件，其性质和范围是确定的，因而它可以成为犯罪分类的基础。我国刑法分则规定的十类犯罪，主要是以犯罪同类客体为标准划分的。如果按犯罪对象则无法分类。犯罪对象并非犯罪的必要构成要件，它在不同的犯罪中可以是相同的，在同一犯罪中也可以是不同的。

4 论刑法上不作为的构成要件。（中山大学2010年研）

相关试题：

（1）论述不作为犯义务的来源。（清华大学2020年研）

（2）简述不作为犯罪义务的来源。（简答题，中南财大2009年研；北理2008年研）

（3）论不作为犯罪的概念及在客观方面的成立条件。（中山大学2006年研）

答：不作为，是指犯罪人负有实施某种行为的特定法律义务，能够履行而不履行的危害行为，即“当为而不为”。构成刑法中的不作为，在客观方面必须具备三个条件：

（1）行为人负有实施某种作为的特定义务

法律义务是构成不作为的前提条件。没有特定法律义务，也就没有不作为的行为形式。不作为的特定法律义务，不仅是指法律明文规定的义务。作为义务根据（来源或种类）包括以下几种：

① 法律明文规定的义务。其中的法律不仅指刑法，而是指由国家制定或认可并由国家强制力保证其实施的一切行为规范的总称，包括宪法、法律（狭义的）、行政法规、条例、规章等。另外并非法律规定的任何一种义务，都可以作为刑法中的不作为的根据。只有其他法律、法规所规定的义务且为刑法所认可，才是不作为的法律义务的根

据。

② 职务或业务上要求履行的义务。这一特定义务以行为人具有某种职务身份或从事某种业务并且正在执行为前提，否则，不发生履行该类义务的问题。

③ 法律行为引起的义务。法律行为是指在法律上能够产生一定权利义务的行为。若一定的法律行为产生某种特定的积极义务，行为人不履行该义务，以致使刑法所保护的社会关系受到侵害或威胁，就可以成立不作为形式的危害行为。在司法实践中，法律行为引起的义务，大多数情况下是指合同行为引起的义务。

④ 行为人的先行行为引起的义务。这种义务是指由于行为人先前实施的行为（简称先行行为），使刑法所保护的社会关系处于危险状态时，行为人负有以采取有效措施排除危险或者防止结果发生的特定义务。若行为人不履行这种义务，就是以不作为的形式实施的危害行为。

（2）行为人有能力履行特定法律义务

这是不作为成立的重要条件。如果行为人不具有履行特定法律义务的可能性，也不可能成立不作为。

（3）行为人没有履行作为的特定法律义务

这是不作为成立的关键条件。在不作为犯罪中，虽然行为人有时也实施某些积极的动作，但其基本点是未履行特定的义务。这是区别作为与不作为的外在根本标志。如行为人负有救治他人的义务但未予救治，而是从事其他活动。这种情况下，并非行为人无所“作为”，而是未为当为之事。

5 试论刑法上的因果关系。（中财2014年研）

相关试题：试论刑法中的危害行为与危害结果之间的因果关系。（人大2006年研）

答：刑法中的因果关系，一般是指危害行为与危害结果之间的关系。我国刑法上因果关系理论的研究主要是以辩证唯物主义因果关系理论为指导的。辩证唯物主义因果关系理论同刑法上因果关系理论是一般与个别、普通与特殊的关系。只有把辩证唯物主义因果关系的基本原理与刑法学所研究的犯罪现象有机结合起来，才能科学解决刑法中的因果关系问题。

以辩证唯物主义因果关系理论为指导来解决刑法因果关系问题，应注意掌握以下基本观点和基本问题：

(1) 因果关系的客观性

因果关系作为客观现象间引起与被引起的关系，它是客观存在的，并不是以人们主观是否认识到为前提。因此，刑事案件中查明因果关系，要求司法工作人员从实际出发，客观地加以判断和认定。在刑法学上通常所说的刑法因果关系，则是指危害行为与危害结果之间的客观联系，并不涉及行为人的主观内容。

(2) 因果关系的相对性

刑法中的因果关系，是要解决行为人对所发生的危害结果应负刑事责任的问题。因此，这里的因果关系是危害行为与危害结果之间的因果关系，这是刑法因果关系的特定性。

① 作为因果关系中的结果，是指法律所要求的已经造成的有形的、可被具体测量确定的危害结果；只有这样的结果才能被查明和确定，才能作为由危害行为引起的现象来具体把握，才能据此确定因果关系是否存在。

② 刑法因果关系中的原因，是指危害社会的行为，如果查明某人的行为是正当、合法的行为而不具有危害社会的性质，那么即使其行为与危害结果之间有某种联系，也不能认为是有刑法意义上的因果关系。

(3) 因果关系的时间序列性

即在发生时间上，原因必定在先，结果只能在后，二者的时间顺序不能颠倒。因此在刑事审判中，只能从危害结果发生的危害行为中寻找原因。如果查明某人的行为是在危害结果发生之后实施的，那就可以肯定，这种行为与这一危害结果之间没有因果关系。当然，先于危害结果出现的危害行为，也不一定就是该结果的原因；在结果之前的行为只有起了引起和决定结果发生的作用，才能证明是结果发生的原因。

(4) 因果关系的条件性和具体性

任何刑事案件的因果关系都是具体的、有条件的，一种行为引起什么样的结果，没有一个固定不变的模式。因此，查明因果关系时，一定要从危害行为实施的时间、地点、条件等具体情况出发来考虑。

(5) 因果关系的复杂性：

① “一果多因”，是指某一危害结果是由多个原因造成的，对于这种情况的刑事案件要分清主要原因和次要原因、主观原因和客观原因等情况。

② “一因多果”，是指一个危害行为可以同时引起多种结果的情况，在一个行为引起的

多种结果中，要分析主要结果与次要结果、直接结果与间接结果。这对于定罪量刑具有重要意义。

(6) 因果关系的必然联系与偶然联系

实践中，因果关系一般表现为两种现象之间内在的、必然的、合乎规律的引起与被引起的联系，但在具体实践中也大量存在着偶然因果关系，即某种行为本身不包含产生某种危害结果的必然性，但在发展过程中，偶然又有其他原因介入，由后来原因合乎规律地引起一种危害结果。偶然因果关系通常对量刑具有一定意义，对定罪与否也可能有影响。

(7) 不作为犯罪的因果关系

不作为的原因力，在于它应该阻止而没有阻止事物向危险方向发展，以至于引起危害结果发生。其特殊性在于，它以行为人负有特定义务为前提，除此以外，它的因果关系应与作为犯罪一样解决。

(8) 刑法因果关系与刑事责任的联系与区别

解决了刑法上的因果关系，只是确立行为人对特定危害结果负有刑事责任的客观基础，但不等于解决了刑事责任问题。要使行为人对自己的行为造成的危害后果负刑事责任，行为人还必须具备主观上的故意与过失，否则不构成犯罪和负刑事责任。

6 论单位犯罪的概念、特征和处罚原则。（中财2013年研）

相关试题：

(1) 简述我国刑法对单位犯罪的处罚原则。（简答题，暨南大学2018年研）

(2) 简述单位犯罪的处罚原则。（简答题，武大2015年研）

(3) 论述单位犯罪。（中山大学2011年研）

(4) 论单位犯罪的概念、特征、认定与处罚原则。（对外经贸2009年研）

答：（1）单位犯罪的概念

单位犯罪，是指由公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为。《刑法》第30条规定：公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。这是关于单位在多大范围内可以成为犯罪主体的规定。

(2) 单位犯罪的特征

① 单位犯罪的主体包括公司、企业、事业单位、机关、团体。

公司、企业、事业单位”，根据《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》，既包括国有、集体所有的公司、企业、事业单位，也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位。若个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的，依照《刑法》有关自然人犯罪的规定定罪处罚。“机关”是指国家各级权力机关、行政机关、司法机关、军事机关。“团体”主要是指人民团体和社会团体。

② 只有法律明文规定单位可以成为犯罪主体的犯罪，才存在单位犯罪及单位承担刑事责任的问题，而并非一切犯罪都可以由单位构成。

规定单位犯罪的“法律”，指的是刑法分则性条文，包括《刑法》分则及其颁行后国家最高立法机关又根据实际需要制定的单行刑法及有关附属刑法规范。从我国《刑法》分则的规定来看，单位犯罪广泛存在于危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利、民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪和贪污贿赂罪等章中，具体罪种约有120多种。这些单位犯罪多数是故意犯罪，但也有少数属于过失犯罪。

(3) 对单位犯罪的处罚

对单位犯罪的处罚，世界各国刑事立法和刑法理论上主要有两种原则：一是双罚制，即单位犯罪的，对单位和单位直接责任人员（代表人、主管人员及其他有关人员）均予以刑罚处罚；二是单罚制，即单位犯罪的，只对单位予以刑罚处罚而对直接责任人员不予处罚，或只对直接责任人员予以处罚而不处罚单位。

我国《刑法》第31条规定：“单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。”这是我国刑法关于对单位犯罪处罚原则的规定。根据这一规定，对单位犯罪，一般采取双罚制的原则，即单位犯罪的，对单位判处罚金，同时对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。但是，当《刑法》分则和其他法律（特别刑法）另有规定不采取双罚制而采取单罚制的，则属例外情况。这是因为，单位犯罪的情况具有复杂性，其社会危害程度差别很大，一律采取双罚制的原则，并不能全面准确地体现罪责刑相适应原则和对单位犯罪起到警戒的作用。

7 试论犯罪故意的构成要素。（南开大学2011年研）

相关试题：试论犯罪故意。（青岛大学2017年研）

答：犯罪故意是指明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生的主观心理状态。从内涵上分析，犯罪故意包含两项内容或称两个要素：一是行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，这种“明知”的心理属于心理学上所讲的认识方面的因素，又称意识方面的因素；二是行为人希望或者放任这种危害结果的发生，这种“希望”或“放任”的心理属于心理学上意志方面的因素。实施危害行为的行为人在主观方面必须同时具备这两个方面的因素，才能认定他具有犯罪的故意而构成故意犯罪。

（1）犯罪故意的认识因素

行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，这是构成犯罪故意的认识因素，是一切故意犯罪在主观认识方面必须具备的特征。如果一个人的行为虽然在客观上会发生甚至已经发生了危害社会的结果，但他本人在行为时并不知道自己的行为会发生这种结果，那就不构成犯罪的故意。

（2）犯罪故意的意志因素

行为人对自己行为所导致的危害结果的发生所抱的希望或者放任的心理态度，就是构成犯罪故意的意志因素。可见，犯罪故意的意志因素有希望和放任结果发生两种表现形式。所谓希望危害结果的发生，是指行为人对危害结果抱着积极追求的心理态度，该危害结果的发生，正是行为人通过一系列犯罪活动所意欲达到的犯罪目的。例如，盗窃犯希望即积极追求非法占有他人财物这种危害结果的发生。所谓放任危害结果的发生，是指行为人虽然不希望、不是积极追求危害结果的发生，但也不反对和不设法阻止这种结果的发生，而是对结果的是否发生采取听之任之的心理态度。

（3）认识因素与意志因素的关系

① 认识因素是意志因素存在的前提和基础，行为人对结果发生采取希望和放任的心理态度，是建立在对行为及其结果的危害性质明确认识的基础上的，唯有具有这种明确的认识，才谈得上对危害结果发生是持希望还是放任的心理态度，才会在持希望心理态度时确定行为的步骤和方法，并直接支配行为的实施，从而构成犯罪的故意。

② 意志因素又是认识因素的发展，如果仅有认识因素而没有意志因素，即主观上不是希望也不是放任危害结果的发生，也就不存在犯罪的故意，不会有故意犯罪的行为。

综上，认识因素和意志因素是犯罪故意中的两项有机联系的因素，在认定构成犯罪的

故意中缺一不可。其中，认识因素是意志因素的存在前提，也是犯罪故意成立的基础；意志因素则是在认识因素基础上的发展，是犯罪故意中具有决定性作用的因素，它对于把犯罪故意客观化即把犯罪思想变为犯罪行为，具有重要的主导作用。

8 我国刑法中的错误论。（华南理工2016年研）

相关试题：

（1）简述刑法上的认识错误理论。（简答题，华南理工2017年研）

（2）法律认识错误的基本表现形式有哪些？如何处理？（简答题，中山大学2010年研）

（3）简述刑法上法律认识错误的几种情况及其各自的后果。（简答题，北化工2008年研）

答：认识错误，是指行为人对自己的行为的刑法性质、后果和有关的事实情况不正确的认识。刑法学上的认识错误可以分为两类：一是行为人在法律上认识的错误；二是行为人在事实上认识的错误。

（1）法律认识错误

法律认识错误，即行为人在法律上认识的错误，是指行为人对自己的行为在法律上是否构成犯罪、构成何种犯罪或者应当受到什么样的刑事处罚的不正确的理解。

① 假想的犯罪，即行为人的行为依照法律并不构成犯罪，行为人误认为构成了犯罪。

这种情况下，判断和认定行为性质的依据是法律，而不是行为人对法律的错误认识。

② 假想的不犯罪，即行为在法律上规定为犯罪而行为人却误认为不构成犯罪。处理方法是：

a. 原则上，追究其应负的刑事责任，以防止犯罪分子借口不知法律而实施犯罪并逃避罪责。

b. 在某些特殊情况下，如果行为人确实不了解国家法律的某种禁令，从而也不知道行为具有社会危害性的，就不能让其承担故意犯罪的刑事责任。

③ 行为人对自己行为的罪名和罪刑轻重的误解，即行为人认识到自己的行为已经构成犯罪，但对其行为触犯了刑法规定的何种罪名，应当被处以什么样的刑罚，存在不正确的理解。行为人对法律的这种错误认识，并不影响其犯罪的性质和危害程度，应当

按照他实际构成的犯罪及其危害程度定罪量刑。

(2) 事实认识错误

事实认识错误，即行为人在事实上认识的错误，是指行为人对自己行为的事实情况的不正确理解。

① 客体的错误，即行为人意图侵犯一种客体，而实际上侵犯了另一种客体。对客体认识错误的案件，应当按照行为人意图侵犯的客体定罪。

② 对象的错误：

a. 具体的犯罪对象不存在，行为人误以为存在而实施犯罪行为，因而致使犯罪未得逞的，应定为犯罪未遂。

b. 行为人误以人为兽而实施杀伤行为，误把非不法侵害人认为是不法侵害人而进行防卫，根据实际情况或是过失犯罪，或是意外事件。

c. 具体目标的错误。这种错误认识对行为人的刑事责任不发生任何影响。

③ 行为实际性质的错误，即行为人对自己行为的实际性质发生了错误的理解。应根据具体情况，判定为过失犯罪或者意外事件。

④ 工具的错误。由于对犯罪工具实际效能的误解而致使犯罪行为未发生犯罪既遂时的犯罪结果，应以犯罪未遂追究行为人的刑事责任。

⑤ 因果关系的错误，即行为人对自己所实施的行为和行为所会造成结果之间的因果关系的实际发展有错误认识。

a. 行为人误认为自己的行为已经达到了预期的犯罪结果，事实上并没有发生这种结果，属于犯罪未遂。

b. 行为人所追求的结果事实上是由于其他原因造成的，行为人却误认为是自己的行为造成的。行为人负未遂之刑事责任。

c. 行为人的行为没有按照他预想的方向发展至其预想的目的实现后停止，而是发生了行为人所预见所追求的目标以外的结果。

d. 行为人实施了甲、乙两个行为，伤害结果是由乙行为造成的，行为人却误认为是由甲行为造成的，因而其错误认识不应影响行为人的刑事责任。

9 试论特殊防卫权。（人大2004年研）

相关试题：

（1）论特殊正当防卫权。（北大2020年研）

（2）简述刑法特殊防卫的成立条件。（简答题，暨南大学2018年研）

答：特殊防卫权，是指防卫人为了使国家、公共利益，本人或者他人的人身权利免受正在进行的行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪的不法侵害，对不法侵害者实施即使是造成不法暴力侵害者伤亡后果的损害行为，而享受不负任何刑事责任的一种权利。

（1）特殊防卫权的特征

① 特殊防卫权基于法律的规定而享有，具有目的的正当性与行为的防卫性相一致的特性。目的的正当性，是指特殊防卫权行使的目的在于保护国家、公共利益、本人或他人的人身权利免遭某些正在进行的特定暴力犯罪的不法侵害。行为的防卫性，是指特殊防卫权具有防卫的性质，是对正在进行的不法暴力侵害的必要反击。

② 特殊防卫权采取的反击特定暴力犯罪的行为是以损害不法暴力侵害人的人身或财产等权益为内容，以暴力手段为主要方法，具有加害性特征。

③ 特殊防卫权体现了社会政治评价和法律评价的有机统一，具有不可罚性。从主观上看，特殊防卫权的行使是防卫人面临暴力犯罪的不法侵害出于保护合法权益的目的，被迫采取反击的一种防卫行为，行为人不具有危害社会的主观罪过形式，他积极行使法律赋予的权利，显然没有主观恶性。从客观上看，正当防卫行为是与违法犯罪作斗争，其目的在于巩固、维护社会利益和秩序，并非危害社会，而特殊防卫权的行使是针对某些特定暴力犯罪的，比一般正当防卫的防卫功能更进一步。

（2）特殊防卫权的成立要件

① 行使特殊防卫权的前提——必须有某种特定暴力犯罪存在。

根据《刑法》第20条第3款的规定，这类特定暴力犯罪主要包括行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪。对这些暴力犯罪之外的其他犯罪，不能适用无限防卫权。这里所强调的暴力犯罪必须是严重危及人身安全犯罪。因为在不是严重危及人身安全的暴力犯罪场合，防卫人可以选择非致命的暴力防卫措施。只有在严重危及人身安全的暴力犯罪发生时，由于不法侵害人处于主动、有利的地位，防卫人在仓促、紧张的状态下，往往很难准确判断侵害行为的性质、强度，无法慎重地选择与侵害行为相适应的防卫措施，法律才明确允许行为人免除对不法暴力侵害人

造成伤亡后果的刑事责任。

② 行使特殊防卫权的时间——必须是某种特定暴力犯罪正在进行之时。

如果这类暴力犯罪还没有现实发生或者已经结束，便不能行使特殊防卫权，否则构成假想防卫或防卫过当，甚至构成犯罪。因此，特定暴力犯罪的实施时间决定特殊防卫权行使的时间。

③ 行使特殊防卫权的对象——特殊防卫行为必须是针对不法暴力侵害者本人实施的。

不法暴力侵害者本人始终是特殊防卫行为所直接指向的目标，第三人不可能成为特殊防卫行为所直接指向的目标。如果防卫行为损害了第三人的合法权益。则防卫人不能以特殊防卫权作为其免责事由，即这种情况下，防卫者的防卫行为不符合特殊防卫的构成要件。

④ 行使特殊防卫权的主观条件——防卫人必须具有防卫合法权益的意图。

特殊防卫权的主观条件，亦即防卫意图，是指防卫人实施特殊防卫行为时对其防卫行为以及行为的结果所应具备的一种以保护合法权益为目的的心理态度。

(3) 特殊防卫权与一般意义上的防卫权之异同

① 特殊防卫属于正当防卫的范畴，特殊防卫权与一般意义上的防卫关系密切，二者的共同点在于：

- a. 成立的前提条件都是必须不法侵害的现实存在。
- b. 适用的对象只能是正在实施不法侵害和犯罪的本人，不能及于他人。
- c. 行使的时间条件都必须是不法侵害正在进行过程中。
- d. 行使的目的相同，都是为了保护公民的合法权益。

② 特殊防卫权具有相对的独立性，与一般意义上的防卫权相比，不同之处在于：

- a. 不法侵害本身的性质和范围不同。对普通防卫权来讲，不法侵害的范围较广，而特殊防卫权所针对的不法侵害只限于犯罪行为，且在犯罪行为中又作了特定限制。
- b. 不法侵害针对的对象范围不同。对普通防卫权而言，不法侵害侵犯的对象不仅包括人身权利，而且还包括财产权利和其他方面的权利。而特殊防卫权所保护的仅仅是不法侵害危及的公民的人身权。
- c. 对防卫限度的要求不同。防卫人在行使普通防卫权时，必须把握合理的限度，如果

防卫行为明显超过防卫限度造成重大损害的，应当负刑事责任，相反在行使特殊防卫权时，防卫人则不必受此限制，无论其采取什么样的防卫方法，给对方造成什么样的后果，均不负刑事责任。

10 试论紧急避险的成立条件及其与正当防卫的区别。（南开大学2008年研）

相关试题：

（1）正当防卫和紧急避险的区别。（武大2020年研）

（2）正当防卫和紧急避险的主要区别有哪些？（北大2014年研）

（3）简述正当防卫和紧急避险的区别。（简答题，武大2014年研；中山大学2011年研；北大2008年研）

答：紧急避险是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已而采取的损害另一较小合法权益的行为。

（1）紧急避险的成立条件

① 避险意图。紧急避险的主观条件即行为人必须有正当的避险意图。正当避险意图，是指避险人对正在发生的危险有明确的认识，并希望以避险手段保护较大合法权益的心理状态。

② 避险起因。只有合法权益遭受损害危险时，才可以实施紧急避险。所谓危险，是指某种有可能立即对合法权益造成危害的紧迫事实状态。

③ 避险时间。紧急避险的时间条件，是危险正在发生或迫在眉睫，对合法权益形成了紧迫的、直接的危险。危险正在发生，是指已经发生的危险将立即损害合法权益，或正在造成合法权益损害而尚未结束。紧急避险只能在危险已经出现而又尚未结束的时间条件下进行，否则就不是紧急避险。

④ 避险对象。紧急避险针对的是第三者的合法权益。紧急避险的本质特征，就是为了保全一个较大的合法权益，而将其面临的危险转嫁给另一个较小的合法权益，即以损害某一较小合法权益保全另一较大合法权益。因而，紧急避险行为所指的对象，不是危险的来源，而是第三者的合法权益。

⑤ 避险限度。紧急避险不能超过必要的限度，造成不应有的损害。紧急避险造成的损害必须小于所避免的损害。

⑥ 避险限制。紧急避险只能在不得已的情况下才能实施，这是紧急避险的客观限制条件。只有在行为人没有任何其他方法排除危险的情况下，才允许选择损害第三者合法权益的方法。

⑦ 避险禁止。法律不允许职务上、业务上负有特定责任的人对个人面临的危险实行紧急避险，具体而言，在国家、公共利益、他人的人身、财产和其他权利遭受危险侵害时，职务上、业务上负有特定责任的人可以实施紧急避险；在本人的人身、财产和其他权利遭受危险侵害时，只要避险行为与所承担的特定责任不相冲突，职务上、业务上负有特定责任的人也可以实施紧急避险。

(2) 紧急避险与正当防卫的区别

紧急避险与正当防卫都是为了保护国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利，而给他人的某种权利或者利益造成一定损害的正当行为。但是二者的区别亦较为明显：紧急避险是两个合法权益之间的冲突，是“两害相权取其轻”的问题；而正当防卫则是合法权益与不法侵害之间的对抗。具体而言，二者的区别表现在：

① 危险来源不同。紧急避险的危险来源多种多样，除了人的不法侵害外，还包括自然的力量、动物的侵袭，以及人的生理、病理过程；而正当防卫的危险来源只限于人的不法侵害。

② 损害对象不同。紧急避险是损害第三者的合法权益；而正当防卫则只能是损害不法侵害者的利益。

③ 实施条件不同。紧急避险只能在没有任何其他方法排除危险的迫不得已的情况下才能实施，即紧急避险必须是排除危险的最后手段；而正当防卫则无此限制，即正当防卫并非是制止不法侵害的最后手段，即使在有条件采取躲避非法侵害、及时获得公力救助或者可能规劝不法侵害人放弃侵害等方法制止不法侵害的情况下，公民仍有权对正在进行的不法侵害实施正当防卫。

④ 限度标准不同。紧急避险造成的损害只能小于所避免的损害，不能等于甚至大于所避免的损害；而正当防卫的必要限度，应当综合制止不法侵害所必需的原则标准，以及防卫行为与不法侵害行为基本相适应的具体判定标准，予以整体判断。

⑤ 禁止条件不同。紧急避险中关于避免本人危险的规定，不适用于职务上、业务上负有特定责任的人；而正当防卫则无此方面的限制规定。

11 试述共同犯罪的成立要件。（广东财大2018年研）

相关试题：

(1) 简述共同犯罪的概念及其构成特征。（简答题，西北政法2005年研）

(2) 简述共同犯罪的概念及其成立条件。（简答题，人大2005年研）

答：（1）共同犯罪的概念

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处，应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

(2) 共同犯罪的构成特征

① 行为人为二人以上

共同犯罪的主体，必须是两个以上达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人或单位。共同犯罪必须是二人以上共同实施犯罪，二人以上必须是达到刑事责任年龄、具有责任能力的人。一个达到刑事责任年龄的人和一个未达到刑事责任年龄的人，或者一个精神健全有刑事责任能力的人和一个由于精神障碍无刑事责任能力的人共同实施危害行为，不构成共同犯罪。由于刑法规定了单位犯罪，因而也可能出现单位共同犯罪，即两个以上的单位共同故意犯罪。

② 共同的犯罪行为

从犯罪的客观方面来看，构成共同犯罪必须二人以上具有共同的犯罪行为。共同的犯罪行为，指各行为人的行为都指向同一犯罪，互相联系，互相配合，形成一个统一的犯罪活动整体。

a. 各行为人所实施的行为，必须是犯罪行为，否则不可能构成共同犯罪。

b. 危害行为的基本形式有作为与不作为。共同犯罪行为表现为三种形式：一是共同的作为，这是共同犯罪行为的主要形式。二是不作为。三是作为与不作为的结合。按照共同犯罪的分工，共同犯罪行为表现为实行行为，组织行为，教唆行为，帮助行为。共同犯罪的共同行为，可能是行为人共同实施实行行为，也可能是分担实施不同的行为，即有人实施实行行为，有人实施组织行为、教唆行为或帮助行为，这些都是共同犯罪。

c. 共同实施的犯罪是结果犯并发生危害结果时，每一共同犯罪人的行为与危害结果之间都存在因果关系。共同犯罪中的因果关系，是两个以上共同犯罪人的行为与危害结果之间的因果关系，共同犯罪行为是围绕一个犯罪目标，互相配合，互为条件的犯罪活动整体，正是这个行为的整体导致了危害结果的发生，而每个共同犯罪人的行为都

是危害结果发生原因的一部分。所以对共同犯罪人的行为不应孤立地而应当统一地考察，不能只就某一共同犯罪人的行为是否现实地导致危害结果发生，来认定其行为与危害结果之间是否存在因果关系。

③ 共同的犯罪故意

从犯罪的主观方面来看，构成共同犯罪必须二人以上具有共同的犯罪故意。共同的犯罪故意，指各共同犯罪人认识他们的共同犯罪行为和行为会发生危害结果，并希望或者放任这种结果发生的心理态度。共同犯罪故意可以从认识因素与意志因素两个方面来分析：

- a. 共同犯罪故意的认识因素，包括共同犯罪人认识到自己与他人互相配合共同实施犯罪；共同犯罪人认识到自己的行为性质，并且认识到共同犯罪行为的性质；共同犯罪人概括地预见到共同犯罪行为与共同危害结果之间的因果关系，即认识到自己的行为会引起的危害结果以及共同犯罪行为会引起的危害结果。
- b. 共同犯罪的意志因素，即共同犯罪人希望或者放任自己的行为引起的结果和共同犯罪行为会发生危害结果。共同犯罪人一般是希望共同犯罪行为所引起的危害结果发生，但在个别情况下也可能是放任危害结果发生。

在共同的犯罪故意要件上需要特别说明的是，为了成立共同犯罪，共同犯罪人之间必须存在意思联络（或称意思疏通）。意思联络是共同犯罪人双方在犯罪意思上互相沟通，它可能存在于组织犯与实行犯之间，教唆犯与实行犯之间或者帮助犯与实行犯之间，而不要求所有共同犯罪人之间都必须存在意思联络，如组织犯、教唆犯、帮助犯相互间即使没有意思联络，也不影响共同犯罪成立。

12 试述主犯的概念、种类、刑事责任。（北大2010年研）

相关试题：

- (1) 主犯的类型和刑事责任。（武大2020年研）
- (2) 简述我国刑法中共同犯罪中的主犯及其刑事责任。（简答题，暨南大学2018年研）
- (3) 主犯的概念和种类。（简答题，武大2013年研）
- (4) 简述主犯的概念、种类及其刑事责任。（简答题，山东大学2015年研；北师2009年研）

答：（1）主犯的概念

根据我国《刑法》第26条第1款的规定，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。这就是我国刑法关于主犯的法定概念。

（2）主犯的种类

根据刑法规定，我国刑法中的主犯包括以下两种人：

① 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，就是犯罪集团的首要分子。这种主犯只有在犯罪集团这种特殊的共同犯罪中才存在，没有犯罪集团，也就没有这种主犯。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是这种主犯的特征。

② 在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子，相对于犯罪集团的首要分子，又称其他主犯或首要分子以外的主犯。这种主犯有以下几种：

a. 在犯罪集团中起主要作用的犯罪分子。积极参加犯罪集团，在犯罪集团中特别卖力地进行犯罪活动，或者在犯罪集团中直接实行犯罪、罪行重大等。具有上述情况之一的，即构成犯罪集团的主犯。

b. 在一般共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。

c. 在聚众犯罪中起主要作用的犯罪分子。

（3）主犯的刑事责任

① 集团犯罪中首要分子的刑事责任。《刑法》第26条第3款规定：对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

② 首要分子以外的主犯的刑事责任。我国《刑法》第26条第4款规定：“对于第3款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。”对在犯罪集团、一般共同犯罪和聚众犯罪中起主要作用的主犯，应分为两种情况处罚：

a. 组织、指挥共同犯罪的，例如聚众犯罪中的首要分子，应按照其组织、指挥的全部犯罪负刑事责任。

b. 没有进行组织、指挥活动但参与实行犯罪的，应按照其所参与的全部犯罪负刑事责任。

13 试论教唆犯的成立条件和处罚原则，以及教唆犯与帮助犯、间接正犯的区别。

（南开大学2009年研）

相关试题：

- (1) 论述教唆犯的特征及其刑事责任。（浙江工商2018年研）
- (2) 简述教唆犯的概念与构成条件。（简答题，中山大学2013年研）
- (3) 教唆犯的概念、条件及处罚原则。（简答题，西南政法2012年研）
- (4) 我国刑法教唆犯理论评析。（简答题，华南理工2011年研）
- (5) 简述刑法规定的教唆犯的处罚原则。（简答题，人大2011年研）
- (6) 简述教唆犯的特征及其处罚原则。（简答题，北大2009年研）
- (7) 论教唆犯。（中财2018年研）
- (8) 试论教唆犯的构成条件、刑事责任以及教唆犯与刑法分则中规定的“煽动型犯罪”（如煽动分裂国家罪、煽动暴力抗拒法律实施罪等）的区别。（南开大学2007年研）

答：（1）教唆犯的成立条件

教唆犯是故意唆使他人实行犯罪的人。根据《刑法》第29条的规定，“教唆他人犯罪的”，是教唆犯。构成教唆犯，需要具备如下条件：

① 从客观方面说，必须有教唆他人犯罪的行为。教唆，是指唆使具有刑事责任能力没有犯罪故意的他人产生犯罪故意。根据《刑法》第29条规定，教唆犯存在着两种情况：

a. 该条第1款规定的“教唆他人犯罪的”，必须被教唆人由于教唆犯的教唆而实施所教唆的犯罪，教唆犯才能成立。在这种情况下，教唆犯的教唆行为与被教唆人所实施的犯罪之间必须存在着因果关系。

b. 该条第2款规定的“……被教唆的人没有犯被教唆的罪”，即说明只要行为人有教唆他人犯罪的行为，就能成立教唆犯。这表现了我国刑法关于教唆犯的规定的特点。

② 从主观方面说，必须有教唆他人犯罪的故意。这种故意也包括意识因素与意志因素两方面。

a. 其意识因素包括：

第一，认识到被教唆的他人是达到刑事责任年龄、具有责任能力的人。明知他人不具有刑事责任能力而教唆其犯罪，不构成教唆犯，而构成间接正犯。但如果行为人误认

为无刑事责任能力人为有刑事责任能力人而教唆其犯罪，仍然构成教唆犯。因为这种误认对教唆犯的故意不发生影响。

第二，认识到他人还没有犯罪故意，如果认识到他人已有犯罪故意，而为之提供犯罪计划的，构成从犯；对其传授犯罪技术的，构成传授犯罪方法罪，均不构成教唆犯。如果行为人不知他人已有犯罪故意仍然教唆其犯罪，不影响教唆犯的成立。

第三，预见到自己的教唆行为将引起被教唆人产生实行某种犯罪的故意，并实施该种犯罪。就是首先预见到自己的行为是教唆行为即意图引起他人犯罪故意的行为；其次预见到引起他人产生实行某种犯罪的故意。

第四，教唆人预见到被教唆人实行该种犯罪，在被教唆人实行某种犯罪时，被教唆人实行的犯罪应与教唆人教唆实行的犯罪相一致，才成立该种犯罪的教唆犯。

b. 教唆犯故意的意志因素是希望，但是否包括放任的心理态度，应做进一步的分析。

第一，构成《刑法》第29条第1款的教唆犯，通常是出于直接故意，但也可能出于间接故意，自然这种情况只能是个别的，并且只能在明知自己的教唆行为会引起他人产生实行该种犯罪的故意，并放任这种结果发生，他人因而实行了该种犯罪行为时才能发生。

第二，构成《刑法》第29条第2款的教唆犯，只有出于直接故意才能构成。因为在这里被教唆人没有犯被教唆的罪，也成立教唆犯。如果是出于间接故意，被教唆人是否犯被教唆的罪都不违背教唆人的本意，既然被教唆人没有犯被教唆的罪，也不违背教唆人的本意，那就不能认定构成教唆犯。

(2) 教唆犯的处罚原则

关于教唆犯的刑事责任，《刑法》第29条分为如下三种情况加以规定：

①“教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。”这里指的是被教唆人犯了被教唆的罪的情况即被教唆人已进行犯罪预备，或者已着手实行犯罪而未遂，或者已完成犯罪而既遂。“按照他在共同犯罪中所起的作用处罚”，指对教唆犯的处罚，是依照教唆犯自身在共同犯罪中所起作用的主次为转移。

②“教唆不满18周岁的人犯罪的，应当从重处罚。”这首先是因为未成年人思想还不成熟，具有很大可塑性，为了防止教唆犯对青少年的侵蚀，所以规定对教唆不满18周岁的人犯罪的，应当从重处罚。其次，在社会上一些老奸巨猾的犯罪分子，为了隐蔽自己，往往躲在幕后，教唆未成年人实施犯罪。这些教唆犯既教唆了他人犯罪，又腐蚀了未成年人的思想，制造了青少年犯罪者，不仅表现了这类教唆犯主观恶性较大，而

且造成的危害后果严重，因而对这类教唆犯应当从重处罚。

③ “如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。”被教唆人没有犯被教唆的罪，包括以下几种情况：

- a. 被教唆人拒绝了教唆犯的教唆，亦即根本没有接受教唆犯的教唆。
- b. 被教唆人当时接受了教唆，但随后又打消犯意，没有进行任何犯罪活动。
- c. 被教唆人当时接受了教唆犯关于犯某种罪的教唆，但实际上他所犯的不是教唆犯所教唆的罪。
- d. 教唆犯对被教唆人进行教唆时，被教唆人已有实施该种犯罪的故意，即被教唆人实施犯罪不是教唆犯的教唆所引起。这些情况，或者根本没有引起被教唆者的犯意，或者实际上没有造成危害结果，或者虽然造成了危害结果，但与教唆犯的教唆行为不存在因果关系。所以《刑法》第29条第2款规定“可以从轻或者减轻处罚”。

(3) 教唆犯和帮助犯的区别

帮助犯是“正犯”“实行犯”的对称，指共同犯罪中没有直接参与犯罪的实行行为，而是向实行犯提供帮助，使其便于实施犯罪，或者促使其完成犯罪的人。帮助犯是从犯的一种，即在共同犯罪中起辅助作用的犯罪分子。这种从犯的犯罪行为通常表现为提供犯罪工具、指示犯罪目标、查看犯罪地点、排除犯罪障碍以及事前通谋答应事后隐匿罪犯、消灭罪迹、窝藏赃物来帮助实施犯罪等情况。

① 教唆犯和帮助犯实施的动机不同。教唆犯是教唆他人去犯罪，主观有犯罪意识，而帮助犯是为了使他人的犯罪行为得到解脱，或者方便他人的犯罪行为。

② 二者的刑事处罚的形式不同。一般情形下，教唆犯按照其教唆的行为来定罪，而帮助犯则不是。

(4) 教唆犯和间接正犯的区别

间接正犯，是指行为人不直接去实施犯罪，而是利用无犯罪故意的人或无刑事责任能力的人为工具实施犯罪，以实现其追求的犯罪目的。教唆犯和间接正犯有明显的区别：

① 主观方面不同。教唆犯的主观方面是教唆者通过教唆使他人产生犯罪故意；而间接正犯只有单独犯罪的故意。

② 客观方面不同。教唆犯是教唆他人实施犯罪行为，而间接实行犯则是利用他人实施犯罪，被利用者或者无犯罪故意，或者无刑事责任能力。

③ 犯罪形态不同。教唆犯是共同犯罪，而间接正犯是单独犯罪。

④ 承担刑事责任的主体不同。教唆犯罪中，教唆者与实施犯罪行为的被教唆者都要承担刑事责任；而间接正犯只能是由利用他人犯罪者承担责任，被利用者由于无刑事责任能力或无犯罪故意而不承担刑事责任。

(5) 教唆犯与“煽动型犯罪”的区别

教唆行为是指教唆他人犯罪的行为。煽动行为与教唆行为的行为人都有通过劝诱、鼓动等方法，促使他人实施犯罪行为。从广义上讲，煽动行为也是一种教唆行为，但二者仍有明显的区别。

① 行为的内容不同。煽动行为的内容是特定的五种“关联的实行行为”；而教唆行为的内容是除煽动行为内容以外的其他一切犯罪行为，范围大大超过煽动行为的内容。行为人如果教唆实施特定的五种“关联的实行行为”，应以煽动型犯罪定罪，而不按教唆犯论处。例如，有学者认为，煽动军人逃离部队行为，实际上是逃离部队罪的教唆犯，若无《刑法》第373条之规定，对于这种行为完全可以作为逃离部队罪的共犯论处；但正因为现行《刑法》第373条规定了煽动军人逃离部队罪，所以应将煽动、教唆军人逃离部队行为认定为煽动军人逃离部队罪。

② 犯罪对象不同。煽动行为的对象可以是特定或不特定的他人，多数情况下是多人；而教唆行为的犯罪对象是特定的单个人或数人。

③ 对是否引起后果的要求不同。煽动行为是否引起后果以及所引起的后果如何，法律未作特别规定，如煽动颠覆国家政权罪，行为人以造谣、诽谤或其他方式进行宣传煽动之后，至于被煽动者是否接受煽动，以及是否实施具体的犯罪行为等（如进行武装叛乱或者间谍谋杀活动），法律没作特别规定；而教唆犯所引起的犯罪后果是特定的，若被教唆人的行为所引起的犯罪后果不是教唆犯所教唆的那种犯罪的结果，对教唆犯应只以其所教唆的犯罪来定罪处罚，对被教唆人所实施的被教唆的以外的其他罪，教唆犯不承担责任。

④ 法律对这两种犯罪的构成要求不同。煽动型犯罪属于举动犯，其构成不以被煽动者实施或者完成关联的实行行为为必要，且煽动型犯罪不存在犯罪的未遂形态；教唆犯的构成亦不以被教唆者接受教唆或者实施被教唆的犯罪行为为必要，但如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，则教唆犯成立犯罪未遂，也就是说，教唆犯在犯罪的未遂形态。

⑤ 罪名与法定刑不同。煽动行为与关联的实行行为相结合构成一个独立的罪名，有独立的法定刑；而教唆犯不是一个独立的罪名，没有独立的法定刑，其罪名的确定是按

教唆行为的具体内容来决定。

14 论刑罚目的。（华南理工2010年研）

相关试题：刑罚的目的是什么？（简答题，中山大学2016年研）

答：刑罚目的是国家据以确定刑事政策、制定刑事法律，特别是设计刑罚制度的基本出发点，也是国家适用刑罚同犯罪作斗争的最终归宿。它从根本上制约着刑罚的性质、内容、体系和方向，左右着刑罚的裁量、执行及其功效。刑罚的目的是指人民法院代表国家对犯罪分子适用刑罚所要达到的目标或效果，它就是预防犯罪。刑罚目的所预防的“犯罪”，包括已然之罪和未然之罪，由于预防的对象有所不同，故将刑罚的目的划分为特殊预防和一般预防两个方面，在理论上称为双面预防。二者的含义和作用分别是：

（1）特殊预防

特殊预防，是指通过对犯罪分子适用刑罚，惩罚改造犯罪分子，预防他们重新犯罪。对犯罪分子适用刑罚，除对极少数罪行极其严重者适用死刑外，主要是利用刑罚的剥夺、惩罚和教育改造功能，限制或剥夺犯罪分子的再犯能力，使其认罪伏法，悔过自新，重新做人。特殊预防的这种作用表现为如下两个方面：

① 剥夺与惩罚是预防犯罪分子再次犯罪的前提。

行为人实施犯罪是为了追求某种非法利益或满足某种非分的需要，而特殊预防则意味着犯罪人在法律面前必将付出一定的代价，使本来享有的权益受到一定的限制和剥夺。犯罪代价越大、获利越少，犯罪意念就越弱，当犯罪的代价大于获利时，犯罪意念就可能被抑制。因此，为了遏制犯罪，刑法对犯罪行为的否定评价、道义谴责、社会非难和权益剥夺程度，就应相当于或稍大于犯罪之所得，使惩罚成为真正的犯罪后果，让犯罪分子在生理上和精神上产生强烈的痛苦体验和畏惧心理，充分认识到犯罪不仅得不到任何好处，反而招致剥夺和惩罚，带来痛苦和耻辱，从而抑制或消除再次犯罪的意念，痛改前非。

② 教育与改造是预防犯罪分子重新犯罪的根本措施。

对犯罪分子适用刑罚如果只有惩罚威慑而没有教育改造，只能使罪犯在权衡利害后，消极地、被动地、暂时地抑制或者放弃犯罪念头，而不能彻底消除其犯罪心理。所以，应当在惩罚威慑从而造成犯罪分子痛苦体验和畏惧心理的同时，对其进行耐心细致的思想教育和必要的劳动改造，并针对其心理状态、人格特征和犯罪的具体原因，采取个别化的矫正措施，才能使他们从被迫接受改造转向自觉进行改造。只有既从功

利上遏制犯罪意念，又从思想根源上彻底消除犯罪意识，才能矫正其反社会的个性品质，树立起新的世界观和人生观，真正改恶从善，重新做人。

(2) 一般预防

一般预防，是指通过对犯罪分子适用刑罚，威慑、警诫潜在的犯罪者，防止他们走上犯罪道路。

刑法对具体犯罪明文规定应受到何种刑罚处罚与对犯罪分子依法适用刑罚，这就用具体的事实说明了什么是法律禁止的行为，实施这种行为将导致什么样的法律后果，于是刑法中抽象的罪刑关系得以现实化和具体化，它生动地表明了国家对犯罪行为的否定评价和非难谴责，向公众昭示了惩罚必将成为犯罪的真正后果。这种惩罚威慑效应不仅能够防止受到刑罚处罚的犯罪分子再次犯罪，而且也使意图实施犯罪的人目击他人受刑之苦而受到震慑，因惧怕将来受到刑罚惩罚而放弃犯罪念头。

15 死刑适用的限制性规定。（青岛大学2017、2015年研）

相关试题：

(1) 简述我国刑法适用死刑的限制性规定。（简答题，辽宁大学2020年研）

(2) 论述我国《刑法》对死刑的限制性规定。（烟台大学2019年研）

(3) 简述我国刑法总则关于适用死刑的限制性规定。（简答题，武大2010年研；中南财大2006年研）

(4) 我国现阶段保留死刑的原因及适用死刑的限制性规定。（简答题，中山大学2009年研）

答：死刑又称极刑，是指剥夺犯罪分子生命的刑罚方法。适用死刑的限制性规定：

(1) 适用条件的限制

死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。所谓“罪行极其严重”，是犯罪的性质极其严重、犯罪的情节极其严重、犯罪分子的人身危险性极其严重的统一。刑法分则对于可以适用死刑的条文作了严格的限制，如对可以判处死刑的，都规定了“对国家和人民危害特别严重、情节特别恶劣的”“致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的”“造成严重后果的”“情节特别严重”“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的”等。

(2) 犯罪主体的限制

犯罪的时候不满18岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑。18周岁，应当从生日的次日起算。审判时怀孕的妇女，也包括审判前羁押时已怀孕的妇女，不得用引产等方式而执行死刑。审判的时候已满七十五周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。这里的不适用死刑既不能适用死刑立即执行，也不能适用死缓。

(3) 犯罪性质的限制

① 《刑法修正案（八）》取消了近年来很少适用的13个经济性非暴力犯罪的死刑。

② 《刑法修正案（九）》又进一步取消了9个非暴力犯罪的死刑。这些犯罪是走私武器、弹药罪，走私核材料罪，走私假币罪，伪造货币罪，集资诈骗罪，组织卖淫罪，强迫卖淫罪，阻碍执行军事职务罪，战时造谣惑众罪。

(4) 适用程序的限制

① 从案件的管辖上进行限制。死刑案件只能由中级人民法院进行一审。

② 从死刑的核准程序上进行限制。死刑案件除由最高人民法院判决的以外，应当报请最高人民法院核准。

(5) 执行程序的限制

根据刑事诉讼法的规定，死刑立即执行的判决，应由最高人民法院院长签发执行死刑的命令。指挥执行的审判人员，在交付执行人员执行死刑前，应当对罪犯验明正身，并讯问有无遗言、信札，然后由执行人员用枪决或者注射等方法执行死刑。死刑的执行必须在人民检察院派员临场监督下进行。执行死刑应当公布，但不得示众。对于应当判处死刑的犯罪分子，不是必须立即执行的，可以判处死刑同时宣告缓期二年执行。

16 非刑罚处理方法的种类。（中山大学2011年研）

相关试题：我国刑法规定的“非刑罚处理方法”有哪几类？（浙江工商2018年研）

答：非刑罚处理方法，是指人民法院对犯罪分子适用的刑罚以外的处理方法。非刑罚处理方法的特点是：对犯罪分子适用，但不具有刑罚性质。换言之，非刑罚处理方法适用的前提是行为人的行为已经构成犯罪。如果行为人的行为不构成犯罪，就不能适用非刑罚处理方法。非刑罚处理方法包括以下四类：

(1) 判处赔偿经济损失和责令赔偿经济损失

① 判处赔偿经济损失，是指人民法院对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并根据其犯罪行为给被害人造成的经济损失情况，判处犯罪分子给予被害人一定经济赔偿的处理方法。

② 责令赔偿损失，是指人民法院对犯罪情节轻微不需要判处刑罚的犯罪分子，在免除其刑事处罚的同时，根据其犯罪行为对被害人造成的经济损失情况，责令其向被害人支付一定数额的金钱，以赔偿被害人经济损失的处理方法。

③ 判处赔偿经济损失与责令赔偿损失，都是赔偿被害人经济损失的非刑罚处理方法，但二者之间有所不同：前者与刑事处罚一并适用，后者则适用于依法被免于刑事处罚的犯罪分子，属于独立适用。

(2) 训诫、责令具结悔过和责令赔礼道歉

① 训诫，是指人民法院对犯罪分子当庭予以批评或谴责，并责令其改正的一种教育方法。

② 责令具结悔过，是指人民法院责令犯罪分子用书面方式保证悔改，以后不再重新犯罪的一种教育方法。

③ 责令赔礼道歉，是指人民法院责令犯罪分子公开向被害人当面承认错误，表示歉意的一种教育方法。

④ 训诫、责令具结悔过和责令赔礼道歉，是人民法院对犯罪情节轻微不需要判处刑罚而免除刑事处罚所采用的几种教育方法。用这些方法处理被免除刑事处罚的犯罪分子，有利于犯罪分子悔过自新，不再重新犯罪，可以使犯罪人取得被害人的宽恕，使犯罪人与被害人之间的矛盾得到缓和，从而维护社会的稳定。

(3) 由主管部门予以行政处罚或者行政处分

由主管部门予以行政处罚或者行政处分，是指人民法院根据案件的情况，向犯罪分子的主管部门提出对犯罪分子予以行政处罚或者行政处分的建议，由主管部门给予犯罪分子一定的行政处罚或者行政处分的一种非刑罚处理方法。这种处理方法的特点是人民法院并不直接作出对犯罪分子予以行政处罚或者行政处分的决定，而是向犯罪分子的主管部门提出建议，再由主管部门作出行政处罚或者行政处分的决定。

① 行政处罚，是指行政执法机关，依照国家行政法规和行政处罚法的规定，给予被免于刑事处罚的犯罪分子以经济制裁或剥夺人身自由的处罚，如罚款、行政拘留等。

② 行政处分，是指犯罪分子的所在单位或基层组织，依照行政规章、纪律、章程等，对被免于刑事处罚的犯罪分子予以行政纪律处分，如开除、记过、警告等。这种非刑罚处理方法也是对犯罪情节轻微不需要判处刑罚的犯罪分子适用的。

(4) 职业禁止

职业禁止是指人民法院对于因利用职业便利实施犯罪，或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的犯罪分子，根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起3年至5年内从事相关职业的一种非刑罚处理方法。

17 论我国刑法规定的自首制度。（山东大学2015年研）

相关试题：

(1) 试论自首。（中财2016年研）

(2) 简述刑法中的自首制度。（简答题，人大2014年研）

(3) 简述特别自首的成立条件。（简答题，武大2014年研）

答：自首，是指犯罪人在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，或者被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为。自首分为一般自首和特别自首两种，一般自首与特别自首的成立条件不同。

(1) 一般自首的成立条件

① 自动投案。自动投案，是指犯罪分子在犯罪之后，在未受到讯问、未被施以强制措施之前，出于本人的意志而向有关机关或个人承认自己实施了犯罪，并自愿置于有关机关或个人的控制之下，等待进一步交代犯罪事实的行为。对此，可从以下几个方面加以把握：

a. 投案行为必须发生在犯罪人尚未归案之前。这是对自动投案的时间限定。自动投案可以包括：犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施以前投案时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。

b. 自动投案一般应是基于犯罪分子本人的意志。即犯罪分子的归案，并不是违背其本人的愿意。

c. 最终必须自愿置于司法控制之下，等待进一步交代犯罪事实。根据司法解释规定，“犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。”此为自动投案的成立的必要条件，也是如实供述自己的罪行，成立自首的前提。

② 如实供述罪行。“如实供述自己的罪行”，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。因此犯罪嫌疑人只要根据客观事实供述所犯的所有罪行，对事实既不缩小也不夸大，就应当认为符合如实供述自己的罪行的条件。至于所供述的罪行司法机关是否已经掌握，是投案人自己单独实施的，还是与他人共同实施的，是一罪，还是数罪，并不影响对如实供述自己罪行条件的认定。如果由于主客观因素，不能全部供述所有的犯罪事实，但已经如实地供述自己的主要或基本的犯罪事实，据此可以确定犯罪性质、犯罪的情节的，就应视为如实供述罪行。此外，根据有关解释，犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。

(2) 特别自首的成立条件

根据刑法的规定，特别自首的成立不要求自动投案的条件，但是有特殊的要求。具体如下：

① 主体必须是被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯。被采取强制措施，根据我国刑事诉讼法规定，是指犯罪嫌疑人、被告人被采取拘传、拘留、取保候审、监视居住和逮捕措施。正在服刑的罪犯，是指已经人民法院判决、正在被执行所判刑罚的罪犯。

② 必须如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，这是成立特别自首的实质性条件。

a. 所供述的必须是本人实施的罪行。

b. 必须是司法机关还没有掌握的罪行。

c. 必须与被采取强制措施、所服刑的罪行是不同种罪。

根据有关司法解释，共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才是如实供述自己的罪行，才能认定为自首。

此外，犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。

(3) 自首与坦白的关系

坦白，一般是指犯罪分子被动归案之后，自己如实交代被指控的犯罪事实的行为。

① 自首与坦白的相同之处

- a. 二者均以自己实施了犯罪行为为前提。
- b. 二者都是犯罪人犯罪之后对自己所犯罪行的主观心理态度的外在表现形式。
- c. 二者都是在归案之后如实交代自己的犯罪事实。
- d. 二者都是从宽处罚的情节。

② 自首和坦白的区别

- a. 自首是犯罪人自动投案，坦白则是犯罪人被动归案。
- b. 自首所交代的既可以是已被发觉的罪行，也可以是尚未被发觉的罪，而坦白所交代的则只限于已被发觉、被指控的罪行。
- c. 自首的犯罪分子供述自己罪行时态度是主动的，而坦白的犯罪分子供述自己的罪行时的态度是被动的。
- d. 自首的人身危险性相对较轻，坦白的人身危险性相对较重。
- e. 自首是法定的从宽处罚情节，而坦白只是酌定的从宽处罚情节，并且在一般情况下，自首比坦白的从宽处罚幅度要大。

(4) 自首犯的刑事责任

根据刑法规定，对于自首犯应分别不同情况予以从宽处理。

① 对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。根据刑法规定，凡犯罪以后自首的，都可以根据案件的不同情况分别予以从轻处罚或者减轻处罚。

② 犯罪较轻的，可以免除处罚。也就是说，犯罪人犯有较轻之罪而自首的，不仅可以从轻或者减轻处罚，而且可以得到免除处罚的从宽处理。

③ 对于犯罪自首后有立功表现的，一般可以减轻或者从轻处罚。

18 论数罪并罚的适用条件及适用原则。（吉林大学2006年研）

相关试题：

(1) 简述我国刑法中数罪并罚的原则。（简答题，武大2015年研）

(2) 简述我国刑法中数罪并罚的原则和方法。（简答题，华南理工2011年研）

答：数罪并罚，是指对一人所犯数罪合并处罚的制度。

(1) 数罪并罚的适用条件

① 必须犯有数罪，这是适用数罪并罚的前提。

② 所犯数罪，必须发生在法定的时间界限内。

③ 必须在对数罪分别定罪量刑的基础上，依照法定的并罚原则、范围和方法决定并罚后应当执行的刑罚。

(2) 数罪并罚的适用原则

数罪并罚的适用原则，是指对一人所犯数罪在分别定罪量刑后，合并处罚所依据的原则。主要可归纳为四种：

① 并科原则，又称相加原则，是指将一人所犯数罪分别宣告的刑罚绝对相加，合并执行的处罚原则。该原则强调刑罚的威慑功能，在某种意义上可以说是报应主义刑罚思想的产物。

② 吸收原则，是指对一人所犯数罪采用重罪之刑吸收轻罪之刑的合并处罚原则。即由最重宣告刑吸收其他较轻的宣告刑，仅以已宣告的最重刑罚作为执行刑罚，其余较轻的刑罚因被吸收而不再执行的合并处罚原则。

③ 限制加重原则，又称限制并科原则，是指以一人所犯数罪中法定应当判处或者已经判处的最重刑罚为基础，再在一定限度之内对其予以加重作为执行刑罚的合并处罚原则。采用该原则的具体限制加重方法主要有两种类型：一是以数罪中最重犯罪的法定刑为基础，加重一定的比例的刑罚，并以加重后的刑罚作为执行的刑罚。二是在对数罪分别定罪量刑的基础上，以数罪中被宣告的数刑中最高刑期以上、总和刑期以下加重处罚，同时规定应执行的刑罚不能超过最高限度。

④ 折中原则，又称混合原则，是指根据不同情况以某一并罚原则为主，兼采其他原则。一般是根据法定的刑罚性质及特点，兼采并科原则、吸收原则或限制加重原则，将其分别适用于不同刑种或刑罚结构的数罪并罚原则。

我国刑罚的数罪并罚原则，具有以下特点：全面兼采各种数罪并罚原则，但限制加重原则的适用居于主导地位，吸收原则和并科原则处于辅助地位。而且，所采用的各种原则均无普遍适用性，每一原则仅适用于特定的刑种。

19 论假释的适用条件。（中山大学2016年研）

相关试题：假释的适用条件。（简答题，中国政法2015年研；首都师大2015年研）

答：假释，是对被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行一定刑期之后，因其认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险，而附条件地将其提前释放，在假释考验期内若不出现法定的情形，就认为原判刑罚已经执行完毕的制度。根据我国《刑法》第81条的规定，对犯罪分子适用假释，必须遵守下列条件：

（1）假释适用的对象

假释的适用对象只能是被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子。但对累犯和因杀人、爆炸、抢劫、强奸、绑架等暴力性犯罪被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。对死刑缓期执行罪犯减为无期徒刑或者有期徒刑后，符合《刑法》第81条第1款和经过一次或几次减刑，实际执行刑期不少于10年的，可以假释。

（2）假释适用的限制条件

适用假释的犯罪分子必须已经执行了一部分刑罚，这是适用假释的前提条件。《刑法》第81条规定，被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期1/2以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行13年以上，才能适用假释。最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》指出，对死刑缓期执行罪犯减为无期徒刑或者有期徒刑后，符合《刑法》第81条第1款和实际执行刑期不少于15年的，可以假释。被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子经过减刑，无期徒刑减为有期徒刑或有期徒刑减为较短刑期的，适用假释时，实际执行刑期的确定应以原判刑罚为标准。

（3）假释适用的实质条件

犯罪分子在刑罚执行期间认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，不致再危害社会，是适用假释的实质条件和最关键性条件。

① 在适用假释时，要注意以下两个方面：

a. “确有悔改表现”是指同时具备以下四个方面情形：认罪悔罪；认真遵守法律法规及监规，接受教育改造；积极参加思想、文化、职业技术教育；积极参加劳动，努力完成劳动任务。罪犯在刑罚执行期间提出申诉，要依法保护其申诉权利，对罪犯申诉应当具体情况具体分析，不应当一概认为是不认罪悔罪。

b. “不致再危害社会”是指罪犯在刑罚执行期间一贯表现好，确已具备上述确有悔改表

现所列情形，不致违法、重新犯罪的，或者是老年、身体有残疾（不含自伤致残），并丧失作案能力的。

② 另需特别注意以下三点：

a. 对犯罪时未成年的罪犯的假释，可以比照成年罪犯依法适当从宽。未成年罪犯能认罪悔罪，遵守法律法规及监规，积极参加学习、劳动的，应视为确有悔改表现，符合《刑法》第81条第1款规定的，可以假释。

b. 老年、身体残疾（不含自伤致残）、患严重疾病罪犯的假释，应当主要注重悔罪的实际表现。基本丧失劳动能力、生活难以自理的老年、身体残疾、患严重疾病的罪犯，能够认真遵守法律法规及监规，接受教育改造，应视为确有悔改表现。假释后生活确有着落的，除法律和司法解释规定不得假释的情形外，可以依法假释。

c. 对罪行严重的危害国家安全的罪犯，犯罪集团的首要分子、主犯、惯犯的假释，主要是根据他们的改造表现，同时也要考虑原判的情况，应当特别慎重，严格掌握。

20 试论我国刑法规定的时效制度。（人大1999年研）

相关试题：

（1）简述我国刑法的追诉期限。（简答题，中山大学2016年研）

（2）试论刑法上的追诉时效。（中山大学2009年研）

答：时效分为追诉时效和行刑时效两种。追诉时效是指刑法规定的，对犯罪人追究刑事责任的有效期限；行刑时效是指刑法规定的，对被判处刑罚的人执行刑罚的有效期限。目前我国刑法只规定了追诉时效，而没有规定行刑时效。我国刑法规定的时效制度就是追诉时效的制度，主要包括以下几点：

（1）追诉时效的计算

① 根据《刑法》第87条的规定，犯罪经过下列期限不再追诉：法定最高刑为不满5年有期徒刑的，经过5年；法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，经过10年；法定最高刑为10年以上有期徒刑的，经过15年；法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过20年。如果20年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

a. 我国刑法所规定的追诉时效期限，是根据犯罪的法定最高刑确定的，这是罪责刑相适应原则在追诉时效期限上的具体体现。因为犯罪的法定最高刑根基于其社会危害性程度，所以，以法定最高刑为根据确定追诉时效的长短，即是根据罪行的轻重来确定

追诉时效期限的长短，罪行越重，则追诉时效期限越长；反之，就越短。此外，犯罪人所犯罪行的轻重在很大程度上反映了其人身危险性的大小，其所犯罪行越重，人身危险性越大；反之，则越小。以法定最高刑为确定追诉时效期限长短的根据，也体现了犯罪人的人身危险性对追诉时效期限的作用，犯罪人人身危险性越大，追诉时效期限越长；反之，则越短。总之，我国刑法确定追诉时效期限的根据有二，即犯罪的社会危害性和犯罪人的人身危险性。

b. 犯罪的法定最高刑不能简单地理解为犯罪人所触犯的罪名的法定最高刑，而是要根据刑法对具体犯罪所规定的法定刑的具体情况以及犯罪人犯罪的具体情况来确定。如果犯罪人所犯罪行的刑罚分别规定有几条或几款时，犯罪的法定最高刑应指按其罪行应当适用的条或款的最高刑；如果犯罪人所犯罪行的同条或同款中有几个量刑幅度时，犯罪的法定最高刑应指按其罪行应当适用的量刑幅度的最高刑；如果条文只规定了单一的量刑幅度，犯罪的法定最高刑就是指该条的最高刑。

c. 我国刑法在规定了四个档次的追诉时效期限的同时，还做了一个灵活性规定，即：法定最高刑为无期徒刑、死刑的，20年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。这里所说的必须追诉的罪行，应限于那些社会危害性极其严重，犯罪人的人身危险性特别大，所造成的社会影响极坏，经过20年以后仍没有被社会遗忘的重大犯罪，而不能将适用这种期限的犯罪的范围随意扩大化。

② 此外，最高人民法院和最高人民检察院针对去台人员在去台前的犯罪的追诉时效问题发布过两个公告，至今仍然有效。其主要内容包括：

a. 去台人员在中华人民共和国成立前在大陆犯有罪行的，根据刑法有关追诉时效的精神，对其当时所犯罪行不再追诉。

b. 对去台人员在中华人民共和国成立后，犯罪地地方人民政权建立前所犯罪行不再追诉。

c. 去台人员在中华人民共和国成立后，犯罪地地方人民政权建立前犯有罪行，并连续或继续到当地人民政权建立后的，追诉期限从犯罪行为终了之日起计算。凡超过追诉时效期限的，不再追诉。

(2) 追诉期限的计算

① 一般犯罪追诉期限的计算

这里的一般犯罪是指没有连续与继续状态的犯罪。对这种犯罪的追诉期限从犯罪之日起计算。犯罪之日应指犯罪成立之日，即行为符合犯罪构成之日。由于刑法对各种犯罪构成要件的规定不同，因而认定犯罪成立的标准也不同。对不以危害结果为要件的

犯罪来讲，实施行为之日就是犯罪成立之日；对以危害结果为要件的犯罪而言，危害结果发生之日是犯罪成立之日。只要行为人所犯之罪经过的时间到案件开始进入刑事诉讼程序时尚未过追诉期限，对其就可以追诉。

② 连续或继续犯罪追诉期限的计算

《刑法》第89条第1款规定，犯罪行为有连续或继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。犯罪行为有连续状态的，属于连续犯；犯罪行为有继续状态的，属于继续犯。“犯罪行为终了之日”，就连续犯而言，是指最后一个独立的犯罪行为完成之日；就继续犯而言，是指处于持续状态的一个犯罪行为的结束之日。

③ 追诉时效的中断

追诉时效的中断是指在追诉时效进行期间因为发生法律规定的事由，而使以前所经过的时效期间归于无效，法律规定的事由终了之时，时效重新开始计算。《刑法》第89条第2款规定，在追诉期限以内又犯罪的，前罪的追诉期限从后罪成立之日起计算。这表明，在追诉期限内又犯罪的，前罪的追诉期限便中断，其追诉期限从后罪成立之日起重新计算。

④ 追诉时效的延长

追诉时效的延长是指在追诉期间，因为发生法律规定的事由，而使追诉时效暂时停止执行。我国刑法规定了两种追诉时效延长的情况。

- a. 《刑法》第88条第1款规定，在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。
- b. 《刑法》第88条第2款规定，被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。

21 试论交通肇事罪。（人大2003年研）

相关试题：

- (1) 试述“交通肇事罪”的构成条件。（简答题，宁波大学2018年研）
- (2) 简述交通肇事罪的构成要件。（简答题，人大2012年研）
- (3) 在行为人醉酒驾驶引起交通事故导致他人死亡时，请具体论述应如何区分交通肇事罪与以危险方法危害公共安全罪。（简答题，武大2011年研）

答：（1）概念及构成要件：

交通肇事罪，是违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。本罪的主要构成特征是：

① 本罪的客体是交通运输安全。交通运输安全是指在交通运输中不特定多人的生命、健康和重大公私财产的安全。

② 本罪的客观方面表现为违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。首先，必须有在交通运输过程中违反交通运输管理法规的行为，这是导致交通肇事的原因，也是构成本罪的前提条件。交通运输管理法规是与交通运输安全有关的各种法规，包括海上、内河、公路、城市道路等交通安全法规。违反规章制度的行为可以表现为作为，也可表现为不作为。其次，违反交通运输管理法规的行为还必须造成重大事故，导致重伤、死亡或者公私财产重大损失的严重后果，即违章行为必须与严重后果之间具有因果关系。虽有违章行为，但未造成上述严重后果的，或虽有违反交通运输管理法规的行为，但没造成任何后果，或虽发生了严重后果，但不是由违章行为引起的，均不构成本罪。

③ 本罪的主体为一般主体。在司法实践中，主要是从事交通运输的人员。所谓交通运输人员，是指具体从事交通运输业务，同保障交通安全有直接关系的人员。根据司法解释的规定，包括具体操纵交通运输工具的驾驶人员、交通设备的操纵人员、交通运输活动的直接领导和指挥人员（如调度员、领航员、船长、机长）和交通运输安全的管理人员（如交通警察）等。非交通运输人员也可成为本罪的主体。关于非交通运输人员的范围，尚有不同看法。一般认为，本罪的主体为一般主体无论是否交通运输人员，只要在交通运输过程中违反交通运输管理法规，造成重大事故，导致重伤、死亡或者公私财产重大损失严重后果的，均可构成本罪。

④ 本罪的主观方面是过失，具体内容是行为人对于发生的重大交通事故，造成的严重后果表现为过失，而对于违反交通运输管理法规，本身则往往是明知故犯的。

（2）交通肇事罪与非罪的界限：

① 交通肇事罪与一般交通事故的界限。二者区别的关键在于发生的事故是否重大，损失是否严重。本罪以发生重大事故、造成重大损失为构成要件，因此对于有违章行为但未造成重大事故的，不以本罪论处。

根据司法解释的规定，所谓重大事故，严重损失是指：a. 死亡1人或者重伤3人以上，负事故全部或者主要责任的；b. 死亡3人以上，负事故同等责任的；c. 造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在30万元以上

的。

交通肇事致1人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：a. 酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；b. 无驾驶资格驾驶机动车辆的；c. 明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；d. 明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；e. 严重超载驾驶的；f. 为逃避法律追究逃离事故现场的。

② 交通肇事罪同交通事故中意外事件的界限。区别二者的关键在于查明行为人对所造成的重大事故的主观上是否有过失，本罪在主观方面表现为过失，如果不是由于行为人的过失，而是由于不能预见的原因造成重大事故的，不构成本罪。

(3) 交通肇事罪与重大飞行事故罪、铁路运营安全事故罪的界限：

交通肇事罪与重大飞行事故罪、铁路运营安全事故罪同属重大交通肇事的犯罪。客体均为交通运输安全，主观上都出于过失，客观上也都以违反保障交通运输安全管理的规章制度并造成严重后果为要件。其区别主要在于发生的场合和主体不同。本罪发生在公路、水路交通运输过程中，其主体为一般主体。而重大飞行事故罪、铁路运营安全事故罪，分别发生在航空运输与铁路运输过程中，其主体为特殊主体，即分别为航空人员与铁路职工。

(4) 交通肇事罪与以危险方法危害公共安全罪的界限：

主要区别在于发生的场合及主观心理态度不同，本罪致人重伤与死亡发生在交通运输过程中，主观上是过失。而以驾车撞人的危险方法构成的危害公共安全罪，并非在从事交通运输，并且主观上是希望或放任死伤结果的发生。如果行为人利用驾驶的交通工具，在公路或者其他公共场所冲撞人群，造成或可能造成众多人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，则应以（驾车撞人的）危险方法危害公共安全罪论处。但如果行为人只是利用交通工具杀伤了特定的人，则侵害的是他人的生命或健康权利，不足以危害公共安全的，应以故意杀人罪或故意伤害罪论处。

(5) 交通肇事罪的刑事责任。根据刑法的规定，交通肇事罪有三个责任档次：

① 犯本罪情节一般的，处3年以下有期徒刑或者拘役。

② 交通肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处3年以上7年以下有期徒刑。所谓“交通肇事后逃逸”，是指行为人明知自己的行为已经造成了重大交通事故，为逃避法律追究逃离事故现场的行为，这是情节特别恶劣的首要标志。

③ 因逃逸致人死亡的，处7年以上的有期徒刑。根据司法解释的规定：“因逃逸致人死

亡”，是指行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑，致使被害人因得不到救助而死亡的情形。行为人在交通肇事后为逃避法律追究，将被害人带离事故现场后隐藏或者遗弃，致使被害人无法得到救助而死亡或者严重残疾的，应当分别依照《刑法》第232条、第234条第2款的规定，以故意杀人罪或者故意伤害罪定罪处罚。单位主管人员、机动车辆所有人或者机动车辆承包人指使、强令他人违章驾驶造成重大交通事故，具有构成交通肇事罪规定情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚。交通肇事后，单位主管人员、机动车辆所有人、承包人或者乘车人指使肇事人逃逸，致使被害人因得不到救助而死亡的，以交通肇事罪的共犯论处。

22 试述危险驾驶罪及其司法认定。（暨南大学2016年研）

相关试题：

（1）简述危险驾驶罪应当追究刑事责任的情形。（简答题，暨南大学2017年研）

（2）简述危险驾驶罪及犯罪构成。（简答题，武大2013年研）

答：危险驾驶罪，是指在道路上驾驶机动车具有追逐竞驶、醉酒驾驶等特定危险驾驶情形的行为。

（1）危险驾驶罪的构成要件：

① 本罪的客体是公路交通运输安全及行人人身、车辆及其他公共设施的安全。

② 本罪客观方面表现为在道路上实施下列行为之一的情况：

a. 追逐竞驶，情节恶劣的。追逐竞驶，俗语即“飙车”，是指以行驶速度和驾驶技术显示“胆识”和技术的另类体现自己能力的危险行为，是自我价值的变相体现，是以（自身和他人）生命安全为代价的危险行为。

b. 醉酒驾驶机动车的。在道路上醉酒驾驶机动车的行为，俗称“醉驾”。在道路上驾驶机动车，血液酒精含量达到80毫克/100毫升以上的，属于醉酒驾驶机动车，以危险驾驶罪定罪处罚。

c. 从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的。

d. 违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品的行为构成本罪，需判定该违规行为是否具有危及公共安全的危险。如果行为人虽然违反了化学品安全管理规定运输危险化学品，但不具有

危害公共安全的危险的，不能以本罪论处。

③ 本罪主体为一般主体。

④ 本罪主观方面，是对危及公共安全持放任的心理态度。

(2) 危险驾驶罪的认定（交通肇事罪与危险驾驶罪的区别）：

① 交通肇事罪可以发生在所有交通运输领域，而危险驾驶罪只限于在陆路交通中的公路交通领域内。

② 交通肇事罪是过失犯罪，而危险驾驶罪是故意犯罪。

③ 交通肇事罪以发生严重后果为入罪的必要条件，而危险驾驶罪为（抽象）危险犯，以行为在客观上具有公共危险为入罪标准。

(3) 犯本罪的，处拘役，并处罚金。犯本罪，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

23 试述保险诈骗罪。（人大2002年研）

相关试题：

(1) 试述保险诈骗罪的犯罪构成。（上海交大2020年研）

(2) 简述保险诈骗罪的概念和构成。（简答题，中财2008年研）

答：保险诈骗罪是指行为人故意虚构保险标的，或者对已发生的保险事故编造虚假的原因或夸大损失程度，或者编造未曾发生的保险事故，或者故意制造保险事故，进行保险诈骗活动，骗取数额较大的财物的行为。

(1) 保险诈骗罪的构成要件

① 本罪侵犯的客体是国家的保险管理秩序和保险人的财产所有权。

② 本罪客观方面表现为行为人实行了保险诈骗活动，骗取数额较大的财物的行为。本罪客观方面包括以下两个构成要素：

a. 行为人实行了保险诈骗活动。具体表现为如下几种情形：

第一，投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的。

第二，对已发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金。

第三，编造未曾发生的保险事故，骗取保险金。

第四，故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金的。

第五，故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金。

b. 骗取的财物数额较大。

个人进行保险诈骗，数额较大的标准为1万元，单位进行保险诈骗，数额较大的标准为5万元。

③ 本罪的主体是投保人、被保险人、受益人。

单位也可以成为本罪的主体。此外，保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。

④ 本罪主观方面是故意，并且具有诈骗保险金的目的。

(2) 保险诈骗罪的认定

① 保险公司工作人员进行保险诈骗行为的定性：

a. 保险公司工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，应区分其是否属于国家工作人员而定贪污罪或者职务侵占罪。

b. 保险公司工作人员与投保人、被保险人或受益人共同实施保险诈骗行为的，若保险公司工作人员参与保险诈骗行为没有利用职务上的便利，构成保险诈骗罪的共犯；若保险公司工作人员参与保险诈骗行为利用了职务上的便利，则其行为构成保险诈骗罪和贪污罪或职务诈骗罪的想象竞合犯，对其按照其中一个重罪处理。

② 本罪涉及的罪数问题。在实践中，一些投保人、被保险人、受益人为了骗取保险金，故意制造保险事故，往往同时又触犯了其他犯罪，这种情况，属于手段行为和目的行为存在牵连关系的牵连犯。对于牵连犯，按照一般原则，应当按其中的一个重罪定罪并从重处罚。但对上述情况，《刑法》第198条第2款明确规定应当按数罪实行并罚。

24 试论绑架罪的构成特征及其认定。（人大2006年研）

相关试题：

(1) 试述绑架罪与非法拘禁罪、抢劫罪的异同。（暨南大学2017年研）

(2) 简述绑架罪的行为类型。（简答题，武大2015年研）

(3) 试论绑架罪的概念及构成要件。（武大2010年研）

答：（1）绑架罪，是指以勒索财物为目的绑架他人，或者绑架他人作为人质的行为。其构成特征是：

① 本罪的客体是复杂客体，包括他人的人身自由权利、健康、生命权利及公私财产所有权利。

a. 以勒索财物为目的绑架他人的行为，由于使用暴力、胁迫等强制手段将他人掳为人质，又向人质的关系人勒索财物，所以，既侵犯他人的人身自由权利、健康、生命权利，也侵犯公私财产所有权利。

b. 绑架他人作为人质的，虽然也是使用暴力、胁迫等强制手段将他人掳为人质，但并不是以勒索财物为目的而绑架他人，所以，只侵犯到他人的人身自由、健康、生命权利。

② 本罪的客观方面，虽然立法对本罪的绑架的手段行为没有规定，但是，从绑架的含义来说，是使用暴力、胁迫或者其他手段劫持他人的行为。

a. 绑架，又称劫持，是指违背被害人或其法定监护人的意志，使用强制手段将被害人置于行为人控制之下，剥夺或者限制其人身自由的行为。

b. 强制手段，是指违背被害人意志的暴力、胁迫或其他手段。

第一，暴力，是指对被绑架人实施殴打、伤害、捆绑等，使被害人不能、不敢反抗的人身强制行为。至于实际是否达到该效果，在所不问。

第二，胁迫，是指对被绑架人以将要施以杀害、伤害进行威胁、恫吓，使其不敢反抗的精神强制行为。至于实际是否达到该效果，在所不问。

第三，其他方法，是指除暴力、胁迫外，使被绑架人不知反抗或不能反抗的人身强制行为，如诱骗、用药物麻醉、用酒灌醉等方法。至于实际是否达到该效果，在所不问。

③ 本罪的主体是一般主体，即年满16周岁、具有刑事责任能力的人均可构成本罪主体。

④ 本罪的主观方面是直接故意。根据《刑法》的规定，本罪的故意内容有二：a. 以

勒索财物为目的；b. 除勒索财物或者出卖为目的以外，以获取其他利益为目的，可以是为了满足政治目的，也可能是为其他利益，但都不影响本罪的成立。

(2) 绑架罪的认定：

① 本罪与非法拘禁罪的界限：

a. 主观方面不同。本罪是以勒索财物为目的，或者是除勒索财物或者出卖为目的以外，以获取其他利益为目的；后者是以非法剥夺人身自由为目的。

b. 客观方面不同。本罪一般既有绑架的行为，又有勒索财物或者要求其他利益的行为，剥夺人身自由是绑架的当然结果；而后者一般只具有非法剥夺人身自由的行为，除了因索取债务的情况外，既无勒索财物的行为，也无要求其他利益的行为。

c. 客体不完全相同。本罪既存在复杂客体的情况，也存在单一客体的情况；而后者只是单一客体。

② 已满14周岁不满16周岁绑架并杀害被绑架人的法律适用

对司法实践中出现的已满14周岁不满16周岁的人绑架人质后杀害被绑架人，拐卖妇女、儿童而故意造成被拐卖妇女、儿童重伤或死亡的行为，依据刑法是应当追究其刑事责任的。

③ 本罪的既遂与未遂的区分

本罪的既遂与未遂，应以绑架行为是否达到实际控制人质，将其置于自己实际支配之下为标准。

25 试论抢劫罪的概念、特征及其与敲诈勒索罪、绑架罪的界限。（西北政法2005年研）

相关试题：

(1) 论抢劫罪。（北理2008年研）

(2) 简述抢劫罪与敲诈勒索罪的区别。（简答题，中财2011年研；中南财大2010年研）

(3) 简述抢劫罪与绑架勒索行为的不同点。（简答题，中山大学2009年研）

(4) 采用胁迫手段实施的抢劫罪与敲诈勒索罪有何不同？（简答题，武大2006年研）

(5) 绑架罪和抢劫罪的区别和联系。(简答题, 人大2010年研; 吉林大学2007年研)

答: (1) 抢劫罪, 是以非法占有为目的, 以暴力、胁迫或其他方法, 当场强行劫取公私财物的行为。其特征主要有:

① 本罪的客体为复杂客体, 即公私财产所有权和人身权。我国《刑法》规定, 抢劫罪以公私财物为对象。从司法实践看, 抢劫对象多为有形动产, 是否应包括不动产, 理论上存在争议。

② 本罪的客观方面表现为以暴力、胁迫或者其他方法, 当场强行劫取公私财物的行为。抢劫罪的方法行为包括:

a. 暴力方法。暴力, 通常是指为达到某种目的, 而采取的具有攻击性的强烈行动, 包括对人身的暴力和对财物的暴力。

b. 胁迫方法。抢劫罪的胁迫方法, 是指行为人为了使被害人不敢反抗, 以便当场非法占有其财物, 以当场实施暴力相威胁。胁迫的内容是以立即实施暴力相威胁。胁迫的方式, 可以是语言, 也可以是某种动作。

c. 其他方法。抢劫罪的其他方法是指为了当场非法占有财物, 而采用的暴力、胁迫之外使被害人处于不能反抗或不知反抗状态的方法, 例如, 用酒灌醉、用药物麻醉等。

③ 本罪的主体是一般主体。根据《刑法》第17条的规定, 已满14周岁不满16周岁的人犯抢劫罪的, 应当负刑事责任。

④ 本罪的主观方面是直接故意, 且以非法占有公私财物为目的。

(2) 抢劫罪与敲诈勒索罪的界限:

敲诈勒索罪, 是指以非法占有为目的, 以威胁或者要挟的方法, 强索公私财物, 数额较大或者多次实施但未达数额较大程度的行为。

敲诈勒索罪的威胁、要挟方法与抢劫罪的胁迫方法, 同属精神强制方法, 但二者也有明显的区别, 主要表现在:

① 手段和方式不同。抢劫罪必须是行为人当着被害人的面发出威胁; 而敲诈勒索罪可以当面对面威胁, 也可以不当面威胁, 可以由自己发出威胁, 也可以由第三者转达威胁。

② 威胁实现的时间不同。抢劫罪的“威胁”是扬言当场实施, “威胁”的内容都是当场可以实施的; 敲诈勒索罪的“威胁”一般是扬言将要实施, 并不一定当场实施, 威胁的内容可以是当场能够实施的, 也可以是在以后的某个时间才能实施。

③ 交付财物的时间不同。抢劫罪必须是当场夺取财物或迫使被害人交付财物；敲诈勒索罪迫使被害人交出财物的时间、地点，可以是当场，也可以是在以后指定的时间、地点交出。

(3) 抢劫罪与绑架罪的界限：

绑架罪，是指以勒索财物或其他要求为目的，绑架他人作为人质的行为。

① 抢劫罪与以勒索财物为目的的绑架罪在犯罪客体、主体和主观方面基本相同，客观方面亦有相似之处。

② 抢劫罪与绑架罪的主要区别有：

a. 两罪的行为手段不尽相同。抢劫罪通过当场使用暴力或以暴力相威胁的方法迫使被害人交出财物，或直接抢走财物；绑架罪是在将人掳走限制其行动自由后，以杀害、伤害被害人威胁其家属、亲友，迫使其交出赎金。

b. 两罪实施行为的时间和地点不同。抢劫罪是当场使用暴力、威胁等强制手段，当场取得财物，侵犯财产所有权和他人的人身权利均在同地完成；绑架罪则是先绑架人质，然后勒令限期交付财物，侵犯人身权利和非法占有他人财物的行为有一定的时间间隔，发生的地点一般不同。

c. 主观方面不尽相同。抢劫罪中，行为人一般出于非法占有他人财物的故意实施抢劫行为；绑架罪中，行为人既可能为勒索他人财物实施绑架行为，也可能处于其他非经济目的实施绑架行为。

d. 二者归属的类罪名不同。两罪均为复杂客体，抢劫罪的主要客体是财产所有权；后罪的主要客体是他人的人身权利。因此前罪归入侵犯财产罪，绑架罪归入侵犯人身权利罪。

e. 主体条件要求不同。抢劫罪的主体为年满14周岁的人；绑架罪的主体则为年满16周岁的人。绑架过程中又当场劫取被害人随身携带财物的，同时触犯绑架罪和抢劫罪两罪名，应当从一重罪处罚。

26 论黑社会性质组织罪。（中山大学2010年研）

相关试题：

(1) 论黑社会性质组织。（北大2020年研）

(2) 简述黑社会性质组织罪的基本特征。（简答题，北航2020年研）

(3) 简述黑社会性质组织的特征。（简答题，武大2011年研）

答：（1）组织、领导、参加黑社会性质组织罪

组织、领导、参加黑社会性质组织罪，是指组织、领导、积极参加或者参加黑社会性质组织的行为。本罪的构成要件是：

① 本罪的客体是复杂客体，既侵犯了经济秩序、社会生活秩序，同时又侵犯了公民的人身财产权利。黑社会性质组织应当同时具备以下特征：

a. 形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。目前，黑社会性质的犯罪组织出现了一个明显的变化，即组织者、领导者、骨干成员可能并不多，但他们控制着一批社会上的闲散人员，这些人员形成了一个市场，需要实施违法犯罪时，即通过这个市场雇用打手，形成“一呼即来，一哄而散”的活动方式。对以这种方式存在的组织，只要其基本的组织者、领导者、骨干成员较为固定，就应认定其形成了“较稳定的犯罪组织”。

b. 有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。有些黑社会性质组织的头目，在其具备了一定的实力后，往往通过各种手段将财产洗白，合法地进行一些经营活动，以此支撑该组织的活动，这部分资产也应当算作该组织的“经济实力”。

c. 以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。

d. 通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。无论是合法行业还是非法行业，只要对其实行垄断或控制，严重影响了当地该行业的正常经营，扰乱了当地百姓的正常生活秩序就应当予以认定。

② 本罪的客观方面表现为行为人实施了组织、领导、积极参加或者参加黑社会性质组织的行为。

a. 组织，是指倡导、发起、策划、安排、建立黑社会性质组织的行为。

b. 领导，是指在黑社会性质组织中处于领导地位，对该组织的活动进行策划、决策、指挥、协调的行为。通常情况下组织者即是领导者，但也不尽然，非组织者（参加者）也可能通过犯罪表现及其他手段成为领导者。

c. 积极参加，是指虽然没有组织、领导，但积极主动地参加到他人组织的黑社会性质组织中去，并积极参与谋划、实施违法犯罪活动的行为。

d. 参加，是指一般参加者，即在黑社会性质的组织中，除组织、领导和积极参加者外，其他参加该组织的成员。

本罪是行为犯，属选择性罪名，只要行为人实施了组织、领导、积极参加或参加黑社会性质组织的行为之一，便成立本罪。

③ 本罪的主体为一般主体，任何已满16周岁并具有刑事责任能力的自然人，均可成为本罪的主体。国家机关工作人员组织、领导、参加黑社会性质组织的，应从重处罚。

④ 本罪的主观方面是直接故意，即行为人怀着明确的意图组织或领导黑社会性质组织，或者明知是黑社会性质组织而参加。

组织、领导黑社会性质的组织的，处7年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处3年以上7年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。犯本罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。

(2) 包庇、纵容黑社会性质组织罪

包庇、纵容黑社会性质组织罪，是指国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的行为。

① 本罪的客体是复杂客体，亦即本罪既侵害了社会治安管理秩序，又侵犯了司法机关打击黑社会性质组织的正常活动。

② 本罪的客观方面表现为行为人实施了包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的行为。

a. 包庇是指国家机关工作人员为使黑社会性质组织及其成员逃避查禁，而通风报信，隐匿、毁灭、伪造证据，阻止他人作证、检举揭发，指使他人作伪证，帮助逃匿，或者阻挠其他国家机关工作人员依法查禁等行为。

b. 纵容是指国家机关工作人员不依法履行职责，放纵黑社会性质组织进行违法犯罪活动的行为。

③ 本罪的主体是特殊主体，即国家机关工作人员。

④ 本罪的主观方面为故意。

犯本罪的，处5年以下有期徒刑；情节严重的，处5年以上有期徒刑。犯本罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。

(3) 入境发展黑社会组织罪

入境发展黑社会组织罪，是指我国境外的黑社会组织人员到我国境内发展组织成员的行为。

① 本罪的客体是社会治安秩序。

② 本罪的客观方面表现为行为人实施了到我国境内发展黑社会组织成员的行为。

我国境内”，主要是指我国内地。发展组织成员是指将境内、外人员吸收为该黑社会组织成员的行为。对黑社会组织成员进行内部调整等行为，可视为“发展组织成员”。港、澳、台黑社会组织到内地发展组织成员的，以本罪定罪处罚。

③ 本罪的主体为特殊主体，即行为人须是境外黑社会组织人员。

④ 本罪的主观方面为故意。

根据《刑法》第294条第2款和第4款的规定，犯本罪的，处3年以上10年以下有期徒刑。犯本罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。

27 试论受贿罪的概念和犯罪构成，以及受贿罪中斡旋受贿的特征。（南开大学2009年研）

相关试题：

(1) 受贿罪的概念及构成要件。（四川大学2020年研）

(2) 试论受贿罪。（青岛大学2017年研）

(3) 简述受贿罪的客观要件。（简答题，武大2014年研）

(4) 简述受贿罪的概念及构成特征。（简答题，人大2005年研）

答：（1）受贿罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。本罪的构成要件是：

① 本罪的客体是国家工作人员的职务廉洁性。

② 本罪的客观方面表现为利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财

物，为他人谋取利益的行为。受贿行为包括两种不同的基本形式：一是利用职务之便，索取他人财物；二是利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益。《刑法》第385条第2款规定，国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费归个人所有的，以受贿论处。

③ 本罪的主体是特殊主体，即只能由国家工作人员构成。国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益之前或者之后，约定在其离职后收受请托人财物，并在离职后收受的，以受贿论处。

④ 本罪的主观方面是故意。完整理解受贿罪的主观故意，需要注意从三个方面把握：
a. 行为人具有索取贿赂或者收受贿赂的意图。
b. 行为人认识到自己索取、收受贿赂的行为是在与对方进行权钱交易，认识到自己的行为会侵害职务行为的廉洁性。
c. 行为人对受贿行为本身的危害后果持希望或者放任的态度。

(2) 斡旋受贿，即国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的。斡旋受贿具有以下特征：

- ① 必须利用本人职权或者地位形成的便利条件。
- ② 接受他人请托，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益。
- ③ 必须索取请托人财物或者收受请托人财物。

28 论利用影响力受贿罪。（武大2011年研）

相关试题：

- (1) 利用影响力受贿罪的行为方式。（宁波大学2017年研）
- (2) 简述利用影响力受贿罪的概念和构成要件。（简答题，华东政法2012年研）

答：（1）利用影响力受贿罪，是指国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，以及离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人，利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的行为。本罪的构成要件是：

- ① 本罪的客体是国家工作人员的职务廉洁性。

② 本罪的客观方面表现为法定的利用影响力受贿行为。

③ 本罪的主体是特殊主体，即与国家工作人员（以及离职的国家工作人员）关系密切的非国家工作人员，包括国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，以及离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人。

④ 本罪的主观方面是故意。

（2）利用影响力受贿罪的认定

① 利用影响力受贿罪与受贿罪的界限。区分的关键是犯罪主体不同。本罪的主体是特殊主体，即与国家工作人员（以及离职的国家工作人员）关系密切的非国家工作人员，包括国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，以及离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人。受贿罪的主体是特殊主体，即在职的国家工作人员。根据2000年6月30日最高人民法院《关于国家工作人员利用职务上的便利为他人谋取利益离退休后收受财物行为如何处理问题的批复》的规定，国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，并与请托人事先约定，在其离退休后收受请托人的财物，构成犯罪的，以受贿罪定罪处罚。2003年11月13日最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》重申了前述规定。此外，利用影响力受贿罪与受贿罪的客观方面也有所不同。特定非国家工作人员利用在职或现职国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的，构成利用影响力受贿罪。

② 利用影响力受贿罪与共同受贿犯罪的界限。区分的关键是非国家工作人员与国家工作人员有无共同受贿的故意和行为。注意，这种实体判断标准同时也在很大程度上表现为二者的基本证据标准有所不同。2003年11月13日最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》规定，根据刑法关于共同犯罪的规定，非国家工作人员与国家工作人员勾结伙同受贿的，应当以受贿罪的共犯追究刑事责任。非国家工作人员是否构成受贿罪共犯，取决于双方有无共同受贿的故意和行为。国家工作人员的近亲属向国家工作人员代为转达请托事项，收受请托人财物并告知该国家工作人员，或者国家工作人员明知其近亲属收受了他人财物，仍按照近亲属的要求利用职权为他人谋取利益的，对该国家工作人员应认定为受贿罪，其近亲属以受贿罪共犯论处。近亲属以外的其他人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物后双方共同占有的，构成受贿罪共犯。国家工作人员利用职务上的便利为他人谋取利益，并指定他人将财物送给其他人，构成犯罪的，应以受贿罪定罪处罚。2007年7月8日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第7条第1款规定，国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，授意请托人以本意见所列形式，将有关财物给予特定关系人的，以受贿

论处。第2款规定，特定关系人与国家工作人员通谋，共同实施前款行为的，对特定关系人以受贿罪的共犯论处。特定关系人以外的其他人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物后双方共同占有的，以受贿罪的共犯论处。

四、法条评析

1 《刑法》第十七条第二款规定：“已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。”《刑法》第二十条第三款规定：“对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。”（中山大学2010年研）

问题：

（1）请用刑法理论（概念）将以上两个法条的内容表述出来。

（2）以上两个法条之间，是否存在矛盾或者立法上的缺陷？若有立法缺陷，应当如何完善？

答：（1）① 刑事责任能力，是指行为人构成犯罪和承担刑事责任所必需的，行为人具备的刑法意义上辨认和控制自己行为的能力。简言之，刑事责任能力就是行为人辨认和控制自己行为的能力。

上述法条是对相对无刑事责任能力人的阐述和规定。相对无刑事责任能力也可称为相对有刑事责任能力，是指行为人仅限于对刑法所明确限定的某些严重犯罪具有刑事责任能力，而对未明确限定的其他犯罪行为无刑事责任能力的情况。这种相对无责任能力人都是已超过完全无责任能力的年龄但又未达到成年的一定年龄段的未成年人。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。根据相关的司法解释，以上八种特殊的犯罪，是指的具体犯罪行为，而不是具体罪名。

② 正当防卫，是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而对不法侵害者实施的制止其不法侵害且未明显超过必要限度的行为。

上述法条中的规定是针对为制止正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪而造成不法侵害人伤亡的情形作出的，是正当防卫的特殊情形，又称无过当防卫。据此规定，对正在进行的严重危及人身安全的暴力犯罪实行正当防卫，不存在过当情形。关于特别防卫的规定，是对正当防卫的基本条件尤其是必要限度条件的特别提示性规定。特别防卫的成立，依然应依据正当防卫成立的基本条件，并结合特别防卫成立的附加条件予以综合判定。特别防卫权的行使，仍然有严

格的法律限制。

(2) 上述两个法条之间存在一定的矛盾和立法上的缺陷。

① 我国《刑法》规定，不满14周岁的人不负刑事责任；已满14周岁不满16周岁的人除实施少数几种特定犯罪外（犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪），不负刑事责任。对于实施侵害行为的未达到刑事责任年龄的未成年人能否进行正当防卫，是个值得争议的话题，在立法上有一定的矛盾和缺陷。

否定论者认为，不法侵害人除其行为在客观上危害社会、违反法律外，还必须具备责任能力和主观罪过。换言之，未成年人的侵害行为不属于不法侵害，对其一般不能进行正当防卫。肯定论者认为，不法侵害中的违法不包括行为人主观方面及其责任能力的内容，只要行为人的行为对法律所保护的权益有现实的危害性，就属于不法侵害，防卫人就有权对其进行正当防卫。即精神病人和未成年人的不法侵害，与有责任能力人的不法侵害并无本质区别，对之都可以进行正当防卫。

② 对于这一立法缺陷和不足，从原则上讲：

a. 对无责任能力人的侵害行为是可以实行正当防卫的。因为，无责任能力者的侵害行为，客观上也是危害社会的行为，广义上属于不法侵害，因此，不能完全将其排除在正当防卫的对象之外。

b. 但是对于无责任能力人的侵害行为实行正当防卫，需要加以一定的限制。从刑法精神来讲，无责任能力人的侵害行为明显不能等同于有责任能力人的故意侵害；从社会道义来讲，应当尽一切努力避免对精神病人、未成年人造成不应有的身体或精神的损害。

c. 在司法实践中遇到无责任能力人的侵害的案例时，如果明知侵害者是无责任能力的人并有条件用躲避等其他方法避免侵害时，则不得实行正当防卫；如果不知道侵害者是无责任能力人，或者不能用躲避等其他方法避免侵害时，才可以实行正当防卫。这样能够在权利和义务的天平上找到一个平衡点，立法上也应当参考以上意见。

2 我国《刑法》第二十五条第二款规定：“二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。”请说明该法条的含义有哪些？
(中山大学2011年研)

答：该法条从反面规定了共同犯罪所需要的主观条件。即共同犯罪必须是共同故意的犯罪，共同过失犯罪不构成共同犯罪。

(1) 从犯罪的主观方面来看，构成共同犯罪必须二人以上具有共同的犯罪故意。共同的犯罪故意，是指各共同犯罪人认识他们的共同犯罪行为和行为会发生的危害结果，并希望或者放任这种结果发生的心理态度。共同犯罪故意虽然与个人的犯罪故意有所不同，但其内容同样可以从认识因素与意志因素两个方面来分析：

① 共同犯罪故意的认识因素，包括如下内容：a. 共同犯罪人认识到自己与他人互相配合共同实施犯罪；b. 共同犯罪人认识到自己的行为性质，并且认识到共同犯罪行为的性质；c. 共同犯罪人概括地预见到共同犯罪行为与共同危害结果之间的因果关系，即认识到自己的行为会引起的危害结果以及共同犯罪行为会引起的危害结果。

② 共同犯罪的意志因素，即共同犯罪人希望或者放任自己的行为引起的结果和共同犯罪行为会发生的危害结果。例如，甲教唆乙伤害丙，甲希望自己的教唆行为引起乙产生伤害丙的意思，并且希望发生丙被伤害的结果。共同犯罪人一般是希望共同犯罪行为所引起的危害结果发生，但在个别情况下也可能是放任危害结果发生。

③ 在共同的犯罪故意要件上需要特别说明的是：为了成立共同犯罪，共同犯罪人之间必须存在意思联络（或称意思疏通）。意思联络是共同犯罪人双方在犯罪意思上互相沟通，它可能存在于组织犯与实行犯之间、教唆犯与实行犯之间或者帮助犯与实行犯之间，而不要求所有共同犯罪人之间都必须存在意思联络，如组织犯、教唆犯、帮助犯相互间即使没有意思联络，也不影响共同犯罪的成立。

(2) 二人以上共同过失犯罪，不构成共同犯罪。尽管这在国外是一个颇有争议的问题，在国内也有不同意见，但我国《刑法》第25条已经明文规定：“二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。”因为共同犯罪的特点是二人以上通过共同的犯罪故意，使各人的行为形成一个共同的有机整体，因而具有更大的社会危害性。而共同过失犯罪，双方缺乏意思联络，不可能形成共同犯罪所要求的有机整体性。并且在共同过失犯罪中，不存在主犯、从犯、教唆犯的区分，只存在过失责任大小的差别，因而也不需要对他们以共同犯罪论处，而只根据各人的过失犯罪情况分别负刑事责任就可以了。

3 《刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者确有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”如何理解“本法另有规定的，依照规定”？“本法另有规定的”的具体情形主要有哪些？（中山大学2009年研）

答：（1）我国《刑法》第266条的规定是关于普通诈骗罪的规定。其设置的定罪量刑标准也是针对一般诈骗罪而设定。但是，我国刑法中也规定了很多的特别诈骗罪名，特别诈骗罪名都是针对某一类诈骗行为而作出的特殊规定。根据法律适用的原则，当一般条款与特别条款相冲突时，特别条款优先于一般条款适用，那么，在某一犯罪行为构成特别诈骗罪时，则不再适用该条一般诈骗罪的规定。该条“本法另有规定的，依照规定”的规定就是指向的这种情形。

（2）“本法另有规定的”的具体情形包括：第192条的集资诈骗罪；第193条的贷款诈骗罪；第194条的金融票证诈骗罪；第195条的信用证诈骗罪；第196条的信用卡诈骗罪；第198条的保险诈骗罪；第224条的合同诈骗罪。

五、案例分析题

1 被告王某，男，38岁，复员军人，三等残疾。被告长期与女村民陈凤通奸。陈凤的丈夫李某（24岁，身强力壮）对其妻的不端行为有所觉察，曾捉奸未果。某日，大队放电影，李某发现其妻在开场后不久离开电影场，于是偷偷跟踪其妻回到家中。到家后，李看到其妻与王某抱在一起，便从厨房里拿了一把菜刀。王某发现李持刀逼近，便从另外一个小门逃跑，李从后面一刀砍下来，不料砍在门框上。这时王某拼命逃跑，李持刀力追，追了约一千米左右，王知道无法再逃，便跳入池塘（该池塘水深25公分，淤泥深20公分），李也跳入池塘，趁势又把王的手心砍伤。王某奋力夺刀，在此过程中，王的额头上又被李砍了两刀。由于用不上力，所砍两刀仍是轻伤。李杀王心切，最后一刀用力过猛，李身体失去平衡，面朝下扑倒在池塘里。王趁势用手在李的后脑上一压，然后爬上岸逃回家。第二天早上，有村民发现李面朝下死在池塘里。经法医鉴定：李心脏在收缩状态，肺扩张，支气管吸进泥水，系窒息而死。（华南理工2007年研）

问：该案应如何认定？说明理由。

答：李某应构成故意杀人罪（未遂），王某的行为构成正当防卫，具体分析如下：

（1）故意杀人罪，是指故意非法剥夺他人生命的行为。其犯罪构成为：

- ① 本罪的客体，是他人的生命权利。
- ② 本罪的客观方面，表现为非法剥夺他人生命的行为。
- ③ 本罪的主体，为一般主体。年满14周岁的具有刑事责任能力的自然人。
- ④ 本罪在主观方面，要求行为人具有非法剥夺他人生命的故意。可以是直接故意，也可以是间接故意。

（2）李某的行为构成故意杀人罪（未遂）。

- ① 李某的行为属于故意杀人的行为。李某拿菜刀追赶王某，最终二人跳入池塘，李某仍然对王某实施砍杀，显然是故意杀人的行为。
- ② 李某有杀人的故意，李某始终想要杀死王某，并且这种故意是直接故意。
- ③ 李某24岁，是完全行为能力人。

④ 李某的行为实际上没有造成王某死亡的结果。王某实施了正当防卫，爬上岸逃回家中。李某的故意杀人行为由于行为人意志以外的原因没有造成王某死亡的结果，属于未遂犯罪。

综上所述，李某的行为构成故意杀人罪（未遂）。

(3) 正当防卫，是指客观上造成一定损害结果，形式上符合某些犯罪的客观要件，但实质上既不具备社会危害性，也不具备刑事违法性的行为。李某持刀追杀王某，王某的反抗行为符合正当防卫的构成要件，不构成犯罪。

2 陈某因举报张某的违法行为而与张某结仇。某日下午六时许，陈某在街上行走时被张某兄弟发现而持刀追杀。逃避途中，陈某多次拦出租车均遭拒载。当逃到一正发动摩托车的中年妇女丁某身边时，陈某恳求其搭载自己，但也被丁某拒绝。眼看张某兄弟逐渐逼近，情急之中陈某一手抓住摩托车，一手将该丁某推倒，然后骑摩托车逃走。后丁某报警，陈某被巡警截住。（中南财大2009年研）

试分析陈某行为的性质。

答：陈某的行为属于紧急避险。陈某的行为符合紧急避险的构成要件：

(1) 避险意图。紧急避险的主观条件即行为人必须有正当的避险意图。正当避险意图是指避险人对正在发生的危险有明确的认识，并希望以避险手段保护较大合法权益的心理状态。陈某对自己遭到追杀这一危险有明确认识，并希望能够通过骑丁某摩托车逃走这一方式来躲避现实危险。

(2) 避险起因。只有合法权益遭受损害危险时，才可以实施紧急避险。所谓危险，是指某种有可能立即对合法权益造成危害的紧迫事实状态。危险是客观现实的存在，而不是假想的、推测的存在。陈某的行为发生时，正遭受张某兄弟的持刀追杀，其生命安全处于危险之中，其法益面临现实危险。

(3) 避险时间。紧急避险的时间条件，是损害危险正在发生或迫在眉睫，对合法权益形成了紧迫的、直接的危险。紧急避险只能在危险已经出现而又尚未结束这一时间条件下进行，否则就不是紧急避险。陈某行为发生时，正遭受张某兄弟的持刀追杀，现实危险正在发生。

(4) 避险对象。紧急避险针对的是第三者的合法权益。紧急避险的本质特征，就是为了保全一个较大的合法权益，而将其面临的危险转嫁给另一个较小的合法权益。因而，紧急避险行为所指的对象，不是危险的来源，而是第三者的合法权益。陈某的行为针对的是第三者丁某，侵犯的利益是丁某的合法权益。

(5) 避险限度。紧急避险不能超过必要的限度，造成不必要的损害。紧急避险造成的损害必须小于所避免的损害。为了保护一个合法权益而损害的另一合法权益，既不能等于、更不能大于所保护的权益。在本案中，陈某夺取丁某摩托车的行为并未给丁某造成不必要的损害，其行为所保护的人身安全这一权益大于侵害的丁某的财产权利。

(6) 避险限制。紧急避险只能在不得已的情况下才能实施，这是紧急避险的客观限制条件。陈某遭追杀时，遭到出租车和丁某的拒载，在这种情况下，陈某夺取丁某摩托车的行为完全是出于不得已。

(7) 避险禁止。根据刑法的规定，紧急避险中“关于避免本人危险的规定，不适用于职务上、业务上负有特定责任的人”。这是紧急避险的禁止条件。陈某的行为没有违反避险禁止的规定。

综上所述，陈某的行为属于紧急避险。

3 甲乙去看朋友丙，丙正与丁打架，丙叫甲乙帮忙，甲乙上前与丙一道将丁打成重伤。甲乙丙在逃跑途中，劫持一少女，甲乙对少女实施奸淫，但因少女反抗而未得逞，然后丙又对少女实施奸淫，少女力竭，丙奸淫成功。随后甲乙丙丢下少女逃跑。少女因被强奸而精神恍惚，跌跌撞撞，掉入河里溺死。（北大2007年研）

请分析此案应如何处理。

答：（1）甲乙丙三人构成故意伤害罪（既遂）。本案中，甲乙应丙的要求共同打击丁某，致丁某重伤，三人均存在故意，因而构成故意伤害罪。因丁为重伤，所以构成故意伤害罪（既遂）。

甲乙丙三人构成故意伤害罪的共同犯罪。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪的情况。本案中，甲乙丙三人在对丁实施伤害均有共同的故意，因而构成共同犯罪。三人都是共同犯罪中的主犯，因为他们都起到了主要作用。

（2）甲乙丙三人对少女实施强奸行为，构成强奸罪，且既遂。甲乙丙三人共同劫持少女，三人均实施了奸淫行为，因而构成共同犯罪。其中，丙某奸淫成功，构成既遂。其他两个人虽未成功，但是由于三人构成共同犯罪，所以三人都构成强奸罪既遂。

少女因精神恍惚误入河中被淹死，因为与奸淫行为没有直接因果关系，因而甲乙丙三人对少女的死不负刑事责任。但是，由于少女之死的直接诱因是精神受到了刺激，这种精神刺激是由三人的强奸行为引起的，所以，根据《刑法》第236条第2款规定，“造成其他严重后果”是指因强奸引起被害人自杀、精神失常及其他严重后果，因此，对甲

乙丙应当适用从重情节。

综上所述，对甲乙丙三人应按照故意伤害罪和强奸罪的共同犯罪定罪，并按照数罪并罚的规定进行处罚。

4 甲（20岁）、乙（19岁）、丙（16岁）三人于2002年4月某日深夜乘王某驾驶的出租车至A市。由丙望风，甲、乙翻墙进入某单位，窃取电脑一台，传真机一台，价值人民币8000余元，信用卡一张。王某看到甲、乙翻墙进入，后又看到甲、乙将东西放入汽车后备厢中。王某将车开到B市某一废品回收站，收取车费1000元。甲在离开该单位时，将一电炉插上电源放入办公桌抽屉内，出来以后，告诉乙我将电炉插上了。但乙当时并不理解插上电炉的含义。后工厂被大火烧毁。甲曾将信用卡用于提取现金，但因不知密码而未获成功。本案乙曾因盗窃罪判处有期徒刑3年，1997年6月刑满释放。公安机关在抓获乙以后，甲、丙感到事情已全部败露，遂向本单位领导交代了全部案情。（上海大学2003年研）

请回答以下问题：

- (1) 甲、乙、丙分别构成什么罪？为什么？
- (2) 本案有哪些是共同犯罪？为什么？
- (3) 本案有哪些从重、从轻的情节？
- (4) 王某的行为应如何处理？为什么？

答：（1）甲构成盗窃罪、故意毁坏财物罪。乙、丙构成盗窃罪。其与甲属于盗窃罪的共犯。理由如下：

① 盗窃罪，是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额较大，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。其构成要件为：a. 本罪的客体，是公私财产所有权。b. 本罪的客观方面，一般表现为以秘密窃取的方法，将公私财物转移到自己的控制之下，并非法占有的行为。c. 本罪的主体是一般主体。d. 本罪的主观方面是直接故意，且以非法占有为目的。

甲、乙、丙以非法占有为目的，翻墙进入某单位，窃取了电脑、传真机、信用卡等价值较大的财物，其行为构成盗窃罪。

② 故意毁坏财物罪，是指故意非法地毁灭或者损坏公私财物，数额较大或者情节严重的行为。

甲在离开某单位时，将一电炉插上电源放入办公桌抽柜内，其明知自己的行为会引起火灾并导致该单位被烧毁的危险，仍然故意实施此种行为，其行为已经构成故意毁坏财物罪。

(2) 甲乙盗窃某单位的电脑、传真机、信用卡，丙望风，王某开车的行为属于共同犯罪。

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。共同犯罪的成立要求行为人为二人以上、共同的犯罪行为、共同的犯罪故意。共同犯罪的共同犯罪人分为主犯、从犯、胁从犯、教唆犯。

本案中，甲乙丙合谋盗窃某单位的财物，其中由甲乙实施盗窃行为、丙望风，三人既有共同的犯罪行为，又有共同犯罪的故意，因此三人的行为构成盗窃罪的共犯。王某作为出租车司机，虽然没有与三人共同犯罪的事先通谋，但是其目睹了甲乙丙犯罪的经过，不仅没有制止，反而将车开到某废品收购站，并且收取的车费1000元明显超过正常范围，带有分赃的性质，其行为属于事中的帮助行为，与甲乙丙构成盗窃罪的共犯。

(3) ① 乙属于累犯，应当从重处罚。

一般累犯，是指年满18周岁因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚并在刑罚执行完毕或者赦免以后，在5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪之人。

在本案中，乙19岁，属于完全行为能力人，其曾被判处有期徒刑3年，在1997年6月刑满释放，在2002年4月又犯盗窃罪，属于在刑罚执行完毕之后的5年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪，因此属于累犯，应当从重处罚。

② 甲、丙属于自首，可以从轻或减轻处罚。

自首是指犯罪分子犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的行为。自动投案，一般应是犯罪人直接向公安机关、检察机关、人民法院投案，对于向所在的单位、城乡基层组织或者其有关的负责人投案的，也应视为自动投案。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

在本案中，甲、丙在乙被抓获后，主动向本单位的领导交代了全部罪行，也应当将其行为视为自首，对于其自首的行为，可以从轻或减轻处罚。

③ 丙属于未成年人，对其犯罪应当从轻或者减轻处罚。

《刑法》第17条第3款规定，已满14周岁不满18周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。这是我国刑法对于未成年人从宽处理的规定。丙16周岁，属于未成年人，对其行

为应当从轻或者减轻处罚。

(4) 对于王某应当按照盗窃罪定罪处罚。

从犯是指在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

从上面的分析可知，王某与甲乙丙属于盗窃罪的共犯，是事中帮助的共犯，属于帮助犯、从犯。对于其行为应按照共同犯罪人所犯罪名处罚，但是在处罚时应当从轻、减轻或免除处罚。

5 被告：章某，男，1982年4月5日生。2003年12月，章某与周某在网上相识，章某得知周某家中富裕，产生要从周某身上“搞一笔”的想法。12月10日，章某约周某到某影城看电影，并借故让周某关掉手机。看电影期间，章某给周某父亲打电话，讹称周某在其手中，要周某父亲在六点前往指定账号汇款20万，否则将杀害周某。经讨价还价，周某父亲向章某汇款10万。章某与周某看完电影在某餐厅用晚餐，后二人各自回家。（中山大学2010年研）

问：章某的行为构成何罪？为什么？

答：章某的行为构成敲诈勒索罪，具体分析如下：

(1) 敲诈勒索罪，是指以非法占有为目的，以威胁或者要挟的方法，强索公私财物的行为。本罪的构成要件是：① 本罪的客体为复杂客体，主要客体是公私财产所有权，次要客体是他人的人身权利或者其他利益。② 本罪的客观方面表现为以威胁或者要挟的方法，向公私财物的所有人或持有人强索财物的行为。威胁和要挟，都是能够引起他人心理恐惧的精神强制方法。

(2) 本案中，章某以非法占有他人财物为目的，向周某的父亲谎称要绑架周某，利用周某父亲对女儿安危的担心，勒索周某父亲的钱财。实际上，周某对此并不知情。章某在客观上是利用周某威胁其父亲交出巨款，符合敲诈勒索的客观特征。

(3) 在本案中，必须理清章某敲诈勒索的行为与绑架以及诈骗的区别。因为周某一直以为自己在与章某约会，并不知道章某假装绑架自己。而在绑架罪中，被绑架人意识到自己的人身受到威胁，进而产生恐惧的心理，在此案中，对周某的绑架，仅仅周某的父亲知道，对周某和章某而言，并不是所谓的绑架，因而主观上对周某而言，章某并无绑架的故意，只有虚构绑架事实的故意。而在诈骗的场合，被害人应该是陷入错误认识，自愿交出财物。在本案中，周某的父亲显然不是自愿，而是受到了威胁和恐惧。因而也不符合诈骗罪的特征。

6 被告人章某（男，武汉市人）从2001年1月起长期购买湖北省体育彩票但一直没有中大奖，两次去武汉市洪山体育馆路体育彩票开奖现场后，章某发现可以从厕所窗户上爬进摇奖大厅。后章某又多次去开奖现场观察开奖情况及程序。2001年4月初一个晚上的11时30分左右，章某潜入开奖厅，章窃走了一个用于装彩球的密码箱回家研究，但打开后发现密码箱是空的。同年4月18日晚，章某再次潜入开奖厅，从密码箱中窃得8个彩球并带回家中，18日上午章某剖开了8个彩球并分别在其中装入玳瑁、石头等物体并用胶水粘好。当晚，章某将彩球带回开奖厅，并按一定顺序装入摇奖机内。2001年4月20日晚，湖北省体育彩票第10303期开奖，晚8时左右摇奖机正式启动。第一、二球均顺利落入容器的出奖通道里，但第三个球却被卡在通道出口处，后被体彩中心工作人员用手拨下。现场彩民对此大为不满，纷纷要求检验彩球。其后，检验人员在用于开奖的彩球中发现6个球中被人做了手脚。于是，这一期的开奖活动被迫取消。公安机关立案后，章某很快被抓获。（中南财大2008年研）

请根据刑法的规定回答章某的行为构成什么罪并说明理由。

答：章某的行为构成破坏生产经营罪，具体分析如下：

破坏生产经营罪，是指由于泄愤报复或其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或以其他方式破坏生产经营的行为。生产经营活动，是指全社会的生产经营活动，包括国有的、集体的、个体的生产经营活动。

我国的体育彩票的发行销售是政府严格审批后，并在严格控制和监督管理下的一种特殊经营行为。章某出于图财及其他个人目的，窃取中国电脑体育彩票摇奖专用彩球造假投入使用，对体育彩票发行、销售、摇奖等经营管理秩序造成严重破坏，情节严重，其行为已构成破坏生产经营罪。章某主观上符合《刑法》第276条规定的“其他个人目的”；其造假球投入使用，确已对彩票的发行、销售、摇奖造成严重破坏，客观上和侵犯的客体方面，符合该条文规定的“其他方法破坏生产经营”。综上所述，章某的行为构成破坏生产经营罪。

值得注意的是，本案中章某为了影响中奖结果，采取了造假球的方式，其结果破坏了彩票的经营秩序而非虚构事实或者隐瞒真相，如果其伪造彩票冒领奖构成诈骗罪，但是其买的是真彩票、控制摇奖，其不构成诈骗罪而是构成破坏生产经营罪。

7 案情：被告人王某，系某市铁路局房地产经营管理中心修建段职工、福华街社区水暖收费办公室负责人（不具有国家工作人员身份）。2003年9月，某市铁路局房地产经营管理中心修建段以通知的方式公示了该市福华街社区西三号楼要参加市集中供暖和

暖气初装费用的收取标准。此后，被告人王某和单位其他工作人员参与了对该楼住户安装暖气的摸底调查和测量工作。但是，因为三号楼要求安装暖气的住户数没有达到集中供暖的标准，修建段未下达设计图纸，也未向该楼居民发出收取暖气初装费的通知。三号楼的居民徐某、何某不知道这些情况，以为集中供暖计划就要实施，为了使工程尽快得以实施，便自发地对要求安装暖气的12户居民按照事先通知的暖气初装费标准收取了100241元的暖气初装费，先分别以个人的名义存入银行（一笔为25376元，一笔为74865元），而后将各自持有的存折交给被告人王某。王某在明知单位没有安排收取暖气初装费工作的情况下，收下二人的存折，向二人出具了白条收据，落款为“铁路局房地产经营管理中心修建段收费组王某”，并加盖了其私人印章。2003年12月至2004年5月，被告人王某将上述款项从银行取出据为己有，并全部挥霍。（南开大学2007年研）

问题：运用刑法理论分析说明对王某的行为应当如何定性。

答：王某的行为应当构成职务侵占罪，具体分析如下：

（1）职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。

（2）被告人王某身为铁路局房地产经营管理中心修建段职工，系福华街社区水暖收费办公室负责人，利用职务之便，将该社区西3号楼12户居民向单位缴纳的暖气初装费100241元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。西3号楼居民缴纳暖气初装费，是为了享受集中供暖的权利而向暖气安装单位履行相应的付款义务。被告人王某收取100241元的存折，是在履行职务过程中发生的，是职务行为。从其收到存款时起，该笔存款的所有权就转移到了铁路局房地产经营管理中心修建段，应视为单位财产。被告人王某将该存款据为己有，属于利用职务的便利将本单位的财产非法占为己有，符合职务侵占罪的特征。被告人王某在接收存折之前没有犯罪的故意，也没有实施任何欺诈行为。其犯意的产生与犯罪行为的实施，均发生于取得存折之后，故不符合诈骗罪的构成要件。

第二部分 课后习题

绪 论

1 如何理解刑法学及其研究对象？

答：（1）刑法学的概念：

刑法学是以现行刑法为研究对象的学科，属于部门法学的范畴。刑法学有广义和狭义之分。

① 广义的刑法学，又称刑事法学，其研究的范围十分广泛，涉及与犯罪及其治理相关的所有问题，包括实体刑法规范、刑事诉讼程序、刑罚执行、犯罪原因与对策等。

② 狭义刑法学专以一国现行实体刑法规范为研究对象，又被称为规范刑法学或解释刑法学。

（2）刑法学的研究对象：

① 刑法学的基本理论：刑法学理论来源于刑法实践又高于刑法实践，它对刑法实践起着指导作用，有利于推动刑事立法的完善和刑事司法的进步。犯罪构成理论、刑事责任理论、刑罚理论构成了刑法理论的核心部分，这也是我们学习和研究刑法理论的重点。

② 实体刑法：刑法学不仅要系统论述我国刑法的概念、性质、地位、特点等问题，还要研究每条刑法规范的正确含义、立法精神，以有效地指导刑事司法实践。现行刑法体系由刑法典、单行刑法、附属刑法以及刑法立法解释、司法解释等部分组成。

③ 刑事司法实践：刑事司法实践是我国刑法学理论所关注和研究的基本出发点，也是检验刑法学理论能否发挥应有作用的重要标志。刑法学理论不仅要研究和论述实践的经验，找出其规律和特点，予以科学概括和总结，而且要吸取教训，为刑事立法或刑事司法的改进提供意见和建议。具体包括：a. 刑事司法实践中遇到的实体问题；b. 刑事司法解释；c. 典型刑法判例及其理由。

④ 刑事立法

高质量的刑事立法是良好的刑事司法的前提。由于社会生活的变动性和成文立法固有的局限性，刑法立法不是一劳永逸、静止不变的，而是一个不断完善、动态发展的过

程。从我国刑事立法的现状来看，在立法模式、立法技术以及具体的立法内容等方面，都在一定程度上存在着不能完全适应社会变化、有待提高和完善的地方。

2 西方刑法学派之争给我们什么启示？

答：（1）西方刑法学派之争及其发展

西方刑法学的发展史也是不同学派之争的历史。古典学派和近代学派的理论对峙，是近代以来西方刑法学发展的一条主线。近代西方刑事古典学派和刑事近代学派的对峙与争鸣持续久远，影响深远，奠定了现代刑法与刑法学的基本格局。第二次世界大战以后，世界范围内掀起的人权运动蓬勃发展，法治、民主等理念日益深入人心，成为现代各国法律领域基本的价值追求。在此背景下，古典学派和近代学派走向折中与融合。实际上，两大学派的主张都有一定的科学性和合理性，也都存在一定的局限性。例如，古典学派强调客观主义的犯罪论，有利于发挥刑法的人权保障机能，但忽视了行为背后的行为人，难以对犯罪进行个别化的处遇，影响了犯罪控制的效果。近代学派关注行为人因素及犯罪原因，但在定罪处刑中过分考虑人身危险性因素以及防止犯罪的功利目的，容易导致刑罚权的滥用。第二次世界大战后，两大学派彼此吸收、借鉴，逐步走向折中、融合。例如，德国刑法学者韦尔策尔提出的目的行为论，以及由德国学者比克迈尔首创、日本学者团藤重光发展的人格责任论，都可谓两派折中的产物。可以说，兼采两派理论之长的综合主义理论日渐成为刑法学的主流思想，并主导了许多国家的刑事立法与司法实践。

（2）评价和启示（言之有理即可）

西方刑法思想与刑法制度的发展，经历了一个漫长的演变过程，不同刑法学派的理论争鸣促进了西方刑法学的进步与发展。对不同时期刑法思想与制度进行分析与评价，必须将其放在特定的历史背景之下。即使现在看来愚昧、落后的一些观念或制度，在当时也可能具有一些合理、积极的因素。西方刑法的不同学派之争虽然直接服务于当时资产阶级的利益和需要，但在客观上顺应了时代发展规律，如刑法人道主义、罪刑法定、罪刑相适应、刑法面前人人平等、刑罚个别化等理念和原则，已经成为全人类共同的法治文明成果，也已经被我国刑法理论和刑事立法所接纳。但需要注意的是，在具体贯彻执行当中，需要在把握其理论精髓的同时，结合我国具体国情予以理解和阐释。

3 如何理解刑法学的地位和作用？

答：（1）刑法学的地位

刑法作为国家的基本法律，在法律体系中具有特殊的重要地位，由此决定了刑法学是一个十分重要的部门法学，也是法学教育的基础课程、核心课程之一。

(2) 刑法学的作用

① 支持刑事立法。提高立法的质量，推进刑法立法科学化，是刑事法治进一步发展的必然要求，也应是刑法学研究的重要内容。刑法的制定和修改，都需要成熟的刑法理论提供支持，刑法理论研究的落后，必然会制约立法的质量，进而影响司法的效果。新中国成立以来，尤其是改革开放以来，我国刑法学研究的不断深入，对于推动刑法立法的科学化起到了积极作用。不过，目前我国的刑法学研究还存在一些薄弱地带，导致相关立法的滞后，不能有力回应社会变迁与现实需要。

② 指导刑事司法。刑事司法活动的关键，是在准确认定犯罪事实的基础上，正确适用法律，确保定罪量刑的公正性、合理性。欲达到此目标，除了要严格遵守刑事诉讼法规定的办案程序、熟练运用刑事证据规则外，司法人员还必须掌握刑法学的相关理论，从而正确地理解和运用刑法规范。

③ 促进法学繁荣。刑法学是非常重要的一门法学分支学科，在法学体系中具有基础性地位。刑法学不仅是实务性、应用性很强的学科，也是理论性、思辨性很强的学科，是理论体系最为精致的法学学科之一。刑法学研究的水平直接反映了一个国家或地区法学的发达程度，刑法学研究的深入，也会促进刑事诉讼法学、犯罪学、刑事执行法学等相关刑事学科的发展。同时，作为法学教育的核心课程，刑法学的繁荣有利于提升法学教育的水平，有利于提升公民的法律意识，有利于培养高素质的法律人才，有利于建设社会主义法治国家。

4 研究刑法学的方法有哪些？

答：（1）研究刑法学的根本方法

坚持以马克思主义为指导，是当代中国哲学社会科学区别于其他哲学社会科学的根本标志。在刑法学研究中，必须坚持马克思主义的指导地位，把辩证唯物主义和历史唯物主义作为刑法学研究的根本方法。在具体运用这一根本方法研究刑法学时，应当注意以下几点内容：

① 强调理论联系实际。论联系实际，是马克思主义“活的灵魂”和最重要的理论品质。要立足中国国情研究刑法学。必须从中国的实际情况出发，深入调查研究，充分了解中国的国情、社情、民情。其次，要强化刑法学研究中的问题意识。坚持问题导向是马克思主义的鲜明特点。问题是理论创新的起点和动力。最后，要善于总结我国刑事

立法和刑事司法的实践经验。对有效的经验应当进行适当的理论概括，努力从中提炼出具有中国特色的理论命题，以丰富和发展刑法学研究，并有效地指导立法和司法实践。对于实践中存在的问题与不足，也应当理性、客观地进行检讨和反思，并寻求改进的方案，以促进立法完善与司法进步。

② 善于运用辩证思维。马克思主义唯物辩证法是关于自然、人类社会和思维的运动和发展的普遍规律的科学。唯物辩证法有三个基本规律，即对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律。刑法学所研究的犯罪及罪刑关系等问题，是十分复杂的充满矛盾的社会现象，把握好唯物辩证法的基本规律，有助于科学地认识罪刑现象。

③ 注重用历史的、发展的观点观察刑法现象。辩证唯物主义和历史唯物主义认为，一切事物都是不断地运动、变化和发展的，事物的发展具有普遍性和客观性，不能用孤立的、片面的、静止的眼光观察事物。由此出发，在刑法学研究中，要学会运用历史的、发展的观点，即观察某一刑法现象，要结合当时特定的历史条件与客观环境加以考察，不能简单套用现在的情势和标准加以评判。

(2) 研究刑法学的具体方法

刑法学的研究方法是多元的，除了上述根本方法之外，还有一些具体的研究方法。主要有以下几种：

① 注释研究法。指通过语义分析、逻辑分析等手段，对刑法规范的含义进行阐明的研究方法。注释方法是最古老也是最基本的刑法学研究方法。我国封建社会中的法学也被称为律学，主要就是对法条进行注疏。

② 比较研究法。指对世界各国的刑法和不同时期的本国刑法进行比较，从而区别异同、鉴别优劣、辨明是非的一种研究方法。

③ 法社会学研究法。指运用包括社会学、人类学、经济学等多学科理论资源，经验性地研究法律现象的一种法学研究方法。法社会学方法的应用拓展了刑法学的研究视野，使之从静态的规范视角转向动态的运作视角，对于促进刑法机制的完善、提高刑法运行的效益具有积极意义。

④ 思辨研究方法与实证研究方法。思辨研究方法指从概念与观念出发，通过抽象推理、逻辑演绎来认识、揭示事物的属性。实证研究方法是从对现象的观察出发，通过对实际材料的收集、整理、分析，以经验事实为依据，探寻事物的发展规律。实证方法可以弥补思辨方法过于空泛的不足，思辨方法也能补充实证方法难以揭示事物本质的缺陷。

⑤ 定性研究方法与定量研究方法。指从质的方面分析事物，确定事物的性质，揭示其

内部的规律性。定量研究方法，是指从量的方面分析事物，揭示其量的规定性，以检验和证实定性分析的结论。为了使刑法的制定与适用更为科学，须高度重视实证研究方法。同时，在加强实证研究与定量研究的同时，不应矫枉过正，而应当使思辨研究与实证研究、定性研究与定量研究有机结合起来，使之扬长避短，形成良性互补关系。

5 如何学好刑法学？

答：学好刑法学应处理好以下三个方面的关系。

(1) 处理好总论和分论的关系

刑法典分为总则和分则两大部分，总则是对犯罪和刑罚一般内容的规定，分则是对具体犯罪及其法定刑的规定。与此相应，刑法学可分为总论和分论两大板块，总论主要研究犯罪、刑事责任与刑罚的基本原理，分论主要对个罪的认定与处理进行研究。刑法学总论与分论的关系，如同刑法总则与分则的关系一样，是一般与特殊、抽象与具体的关系，二者相互依存，密不可分。刑法学的基础理论集中在刑法学总论当中。

学好刑法学，首先要学好刑法学总论，了解和掌握刑法总则的主要规定，同时要把握刑法学的基本范畴、基本关系与基础理论。尤其要学好犯罪构成理论，这是刑法学理论的精华所在。刑法学总论是以分论为依托的，仅仅掌握了犯罪和刑罚的一般规定与基本原理，而不深入了解刑法对于具体犯罪的规定，仍然无法解决司法实践中的问题。

(2) 处理好法条和法理的关系

学习刑法学，特别要强调对法条的学习。法条是刑法规范的基本存在形式，也是学习刑法学的起点。精研刑法中的重要条文，是学好刑法学的前提和基础。而对于刑法法条的学习，不能仅仅拘泥于对刑法条文字面意义的理解，要善于透过具体的法律条文，深入探究背后隐含的立法背景与理论依据，即立法者为什么要作这样的规定，这就上升到了法理的层面。了解法条背后的法理，能够帮助我们更准确地理解和适用刑法。

(3) 处理好规范和案例的关系

从广义上讲，刑法规范不仅包括立法机关制定的法律条文，还包括有关刑法适用的司法解释。在我国，存在大量的刑法司法解释，而且其实际上对办案机关是有法律约束力的。学习刑法学必然要掌握刑法规范，但仅掌握刑法规范而不结合具体案例来学习，是难以有效掌握刑法知识的。刑法学是实践性、应用性很强的学科，学好刑法学

有必要关注犯罪状况与司法实践动态，多研习一些刑法实际案例尤其是典型案例，这也是理论联系实践的一种路径，对于提升学习的效果、培养分析实际问题的能力大有裨益。面对疑难案例，要善于在梳理和归纳案件事实的同时，灵活运用刑法学理论对相关刑法规范进行分析、解释，进而在符合法治精神的前提下得出最合理的处理结论。

第一章 刑法概说

1 什么是刑法？

答：刑法是统治阶级为了维护本阶级政治上的统治和经济上的利益，根据自己的意志，以国家名义制定、颁布的规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。刑法具有双重性质，即阶级性质和法律性质。刑法的产生和发展是一个历史的范畴，是统治阶级对被统治阶级实行专政的工具，其阶级性质是由国家的阶级本质决定的。刑法区别于其他法律的特有属性主要体现在其所规定内容的特定性、保护社会关系范围的广泛性、强制方法的严厉性以及谦抑性。

刑法有广义和狭义之分。广义的刑法是指一切规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律规范的总和，主要包括刑法典、单行刑法与附属刑法。狭义的刑法则是指系统规定犯罪、刑事责任和刑罚的刑法典。我国1979年颁布、1997年修订并经多次修正的《刑法》是我国现行的刑法典。

2 如何理解刑法的机能？

答：刑法的机能是指刑法现实与可能发挥的作用。我国《刑法》第2条规定阐明了我国刑法的主要任务，同时也是我国刑法机能的主要体现。总体来看，我国刑法的机能主要体现在以下四个方面：

(1) 保卫国家安全，保卫人民民主专政的政权和社会主义制度。人民民主专政的政权和社会主义制度，是我国人民根本利益的集中体现。刑法是同各种危害国家安全和企图推翻人民民主专政的政权、破坏社会主义制度的犯罪分子进行斗争的重要武器，是维护国家安全，捍卫和巩固人民民主专政的政权和社会主义制度的重要保障。例如，我国《刑法》在分则第一章规定了危害国家安全罪，对各种危害国家安全的犯罪行为规定了较为严厉的法定刑。

(2) 保护社会主义经济基础。刑法对社会主义经济基础的保护机能主要体现在两个方面，一是保护公共财产和公民私人所有的合法财产，二是保护正常的社会主义经济秩序。经济基础是与一定社会历史阶段的生产力水平相适应的生产关系的总和，我国刑法对经济基础的保护是对以公有制为主的多种所有制和社会主义市场经济的保护。例如，刑法分则专章规定了“破坏社会主义市场经济秩序罪”和“侵犯财产罪”，从而使社会主义经济基础获得了较为有力的保障。

(3) 保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。我国《刑法》坚决保护公民所享有的人权，保护公民的人身权利、民主权利等权利。例如，我国刑法对严重侵犯公民人身权利的犯罪，如故意杀人、强奸、绑架等都规定有严厉的刑罚；《刑法》第四章中明确规定了“破坏选举罪”和“侵犯通信自由罪”等罪名及其相应的刑事责任。

(4) 维护社会秩序、经济秩序。正常的社会秩序和经济秩序是社会主义现代化建设正常进行的基础，是公民权利保障的前提。例如，刑法分则规定了“危害公共安全罪”“妨害社会管理秩序罪”和“渎职罪”等各类犯罪，以维护社会秩序和经济秩序，保障社会主义现代化建设事业的顺利进行。

3 具体阐述刑法解释的种类及其内容。

答：刑法的解释是指对刑法规范含义的阐明，对正确理解和运用刑法具有重要的意义。通过对刑法规范进行解释，可以使抽象的法条适用于具体的案件，使刑法条文具有一定的稳定性，同时也可以弥补刑法条文的缺陷。

根据解释主体和解释方法的不同，可以从不同方面对刑法解释的种类进行分类。

(1) 以解释的主体为依据，可将刑法解释分为立法解释、司法解释与学理解释。

① 立法解释是由立法机关对刑法的含义所作的解释。全国人大及其常委会对刑法规范本身需要明确的界限，或者为解决最高人民法院和最高人民检察院所作出的有关刑事司法的解释的原则性分歧而进行立法解释。刑法的立法解释包括三种情况：a. 在刑法中用条文对有关刑法术语所作的解释；b. 由国家立法机关在法律的起草说明或者修订说明中所作的解释；c. 刑法在施行中如发生歧义，由全国人大常委会进行解释。

② 司法解释是由司法机关对刑法的含义所作的解释，我国有权进行司法解释的司法机关是最高人民法院和最高人民检察院。在我国，凡属于法院审判工作中具体应用法律、法令的问题，由最高人民法院进行解释；凡属于检察院检察工作中具体应用法律、法令的问题，由最高人民检察院进行解释；若二者解释有原则性分歧，报请全国人民代表大会常务委员会解释或决定。

③ 学理解释是由专家、学者从学理上对刑法含义所作的解释。学理解释是立法解释和司法解释的理论基础。

(2) 以解释方法为依据，可将刑法解释分为文理解释和论理解释。

① 文理解释是对法律条文的字义，包括单词、概念、术语，从文理上所作的解释。例如对刑法条文中“可以”“应当”的解释等。

② 论理解释是按照立法精神，联系有关情况，对刑法条文从逻辑上所作的解释。论理解释又分为：a. 扩张解释是根据立法原意，对刑法条文作超过字面意思的解释。b. 限制解释是根据立法原意，对刑法条文作狭于字面意思的解释。c. 当然解释是指刑法条文虽没有明确规定，但已包含在法律条文的含义中，依据理所当然的方式，对刑法条文所作的解释。当然解释的基本方法是“出罪举重以明轻，入罪举轻以明重”。

第二章 刑法的基本原则

1 如何理解刑法基本原则的概念与意义？

答：（1）刑法基本原则的概念

1997年《刑法》确立了罪刑法定原则、适用刑法人人平等原则、罪责刑相适应原则等刑法的基本原则。刑法的基本原则是指贯穿全部刑法规范，具有指导和制约全部刑事立法和刑事司法的意义，并体现我国刑事法治基本精神的准则。刑法基本原则必须贯穿全部刑法规范，具有指导和制约全部刑事立法和刑事司法的意义；同时必须体现我国刑事法治的基本精神，这就是：坚持法治，摒弃人治；坚持平等，反对特权；讲求公正，反对徇私。

（2）刑法基本原则的意义

刑法基本原则是贯穿于全部刑法规范和刑法适用的准则，是刑事法治基本精神的集中体现，对刑事立法和刑事司法具有极大的指导意义。今后的刑事立法工作，必须完全符合刑法基本原则，而绝不能违背这些基本原则。当刑法有必要加以修改补充时，一定要以这些基本原则为指导，使罪刑规范更加具体、明确、清晰，既有利于保护社会，又有利于保障人权。刑事司法工作要大力贯彻这些基本原则，强化法治意识、平等观念和公正无私、刚直不阿的思想，使所办的案件既符合法律政策，又能经得起历史的检验。总之，刑法基本原则具有强大的威力：它们既有利于积极同犯罪作斗争，又有利于切实保障公民的合法权益；既有利于推进法治化进程，又有利于维护法律的公正性；既有利于实现刑法的目的，又有利于达到刑罚的最佳效果。因此，它们必将促进我国刑事立法的发展完善，促进刑事司法的文明进步，并更好地保障中国特色社会主义建设事业与法治事业的顺利进行。

2 为什么说保障人权原则也是刑法的基本原则？

答：尊重和保障人权原则，其基本含义就是尊重和保障人因其为人而应享有的基本权利。2004年我国首次将“人权”概念引入宪法，载明“国家尊重和保障人权”，它标志着我国现行宪法首次用一个概括性条款确认了尊重和保障人权的宪法原则。基于尊重和保障人权的宪法规定，保障人权原则应该成为刑法的基本原则。具体原因有以下几点：

（1）作为国家法治的重要组成部分，刑法直接关涉公民的基本人权，保障人权是刑法

的基础性要求，是当代刑法机能所蕴含的重要内容。

(2) 刑法对人权的保障，既包括对犯罪人人权的依法保障，更应当包括对被害人及广大守法公民人权的依法保障。刑法不仅可以通过依法惩罚犯罪来维护社会正常秩序，保护守法公民免受犯罪侵害，也保障无罪的人不受刑罚处罚，防止惩罚权的滥用，在惩罚罪犯时也要维护其应有权益，使其所受到的惩罚与其犯罪行为 and 刑事责任相适应，保证其免受不公正之惩罚，并通过刑罚的执行来感化和改造犯罪人，促使其重新回归社会。

3 什么是罪刑法定原则？如何贯彻落实罪刑法定原则？

答：(1) 罪刑法定原则的含义：

罪刑法定原则，是指什么是犯罪，有哪些犯罪，各种犯罪的构成条件是什么，有哪些刑种，各个刑种如何适用，以及各种具体罪的具体量刑幅度如何等，均由刑法加以规定。对于刑法分则没有明文规定为犯罪的行为，不得定罪处罚。即“法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚”。

(2) 罪刑法定原则的贯彻落实：

① 从立法上落实：

- a. 1997年《刑法》实现了犯罪的法定化和刑罚的法定化。犯罪的法定化具体表现为：明确规定了犯罪的概念、犯罪构成的共同要件和各种具体犯罪的构成要件。刑罚的法定化具体表现为：明确规定了刑罚的种类、量刑的原则和各种刑罚制度以及各种具体犯罪的法定刑。
- b. 1997年《刑法》取消了1979年《刑法》第79条规定的类推制度，这是罪刑法定原则得以真正贯彻的重要前提。
- c. 1997年《刑法》重申了1979年《刑法》第9条关于刑法在溯及力问题上从旧兼从轻的原则。
- d. 分则罪名的规定方面，1997年《刑法》已相当详备。分则条文由1979年的103条增加到350条，罪名数由1979年的129个增加到412个。1997年《刑法》通过以来，全国人大常委会因应社会政治、经济、文化等方面的变化及与犯罪作斗争的需要，又陆续制定了1部单行刑法和10部刑法修正案，对1997年《刑法》进行了诸多修改，刑法分则条文和罪名均有大幅度的增加。
- e. 具体犯罪的罪状以及各种犯罪的法定刑设置方面，1997年《刑法》增强了法条的可

操作性。对于大量犯罪，尽量使用叙明罪状，在犯罪的处罚规定上，注重量刑情节的具体化。

② 从司法实践中落实：

a. 正确认定犯罪和判处刑罚。对于刑法明文规定的各种犯罪，司法机关必须以事实为根据，以法律为准绳，认真把握犯罪的本质特征和犯罪构成的具体要件，严格区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限，做到定性准确，不枉不纵，于法有据，名副其实。对各种犯罪的量刑，亦必须严格以法定刑及法定情节为依据。

b. 正确进行司法解释。对于刑法规定不够具体的犯罪，最高司法机关通过司法解释指导具体的定罪量刑活动，这对于弥补立法的不足，统一规范和指导司法实务，具有重要的意义。但是，进行司法解释不能超越其应有的权限，无论是扩张解释，还是限制解释，都不能违反法律规定的真实意图，更不能以司法解释代替刑事立法。否则，就会背离罪刑法定原则。

4 适用刑法人人平等原则的基本要求有哪些？

答：法律面前人人平等是我国宪法确立的社会主义法治的基本原则。《宪法》明确规定，任何组织或个人，“都必须遵守宪法和法律”，“都不得有超越宪法和法律的特权”，“一切违反宪法和法律的行为，必须予以追究”。适用刑法人人平等的基本要求有：

(1) 定罪上一律平等。任何人犯罪，无论其身份、地位等如何，一律平等对待，适用相同的定罪标准。不能因为被告人地位高、功劳大而使其逍遥法外，不予定罪，也不能因为被告人是普通公民就妄加追究，任意定罪。

(2) 量刑上一律平等。犯相同的罪且有相同的犯罪情节的，应做到同罪同罚。虽然触犯相同的罪名，但犯罪情节不同，比如有的具有法定从重处罚的情节，有的具有法定从轻、减轻或者免除处罚的情节，从而同罪不同罚，这是合理的、正常的，并不违背量刑平等原则。因为对任何犯罪人来说，都有这样一个具体情况具体分析、针对不同情况区别对待的问题。

(3) 行刑上一律平等。在执行刑罚时，对于所有的受刑人都应平等对待，凡罪行相同、主观恶性相同的，刑罚处置也应相同。掌握法律规定的减刑、假释的条件标准也应体现平等，谁符合条件，谁不够条件，都要严格以法律为准绳，不搞亲疏贵贱。

5 如何在立法和司法实践中贯彻罪责刑相适应原则？

答：罪责相适应原则的含义是“刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。”，但如何贯彻其应从立法和司法实践中实行：

(1) 立法上：

① 确立科学严密的刑罚体系。我国刑法总则确定了一个科学的刑罚体系，这一体系由不同的刑罚方法构成。各种刑罚方法相互区别又互相衔接，能够根据犯罪的各种情况灵活运用，从而为刑事司法实现罪责刑相适应奠定了基础。

② 规定区别对待的处罚原则。我国刑法总则根据各种行为的社会危害程度和行为人人身危险性的大小，规定了轻重有别的处罚原则。此外，刑法总则还基于刑罚个别化的要求，规定了一系列刑罚裁量与执行制度。

③ 设置轻重不同的法定刑幅度。我国刑法分则不仅根据犯罪的性质和危害程度建立了一个犯罪体系，还为各种具体犯罪规定了可以分割、能够伸缩、幅度较大的法定刑。

(2) 司法实践上：

① 纠正重定罪轻量刑的错误倾向，把量刑与定罪置于同等重要的地位。为了切实贯彻罪责刑相适应的原则，必须提高审判机关和法官对量刑工作重要性的认识，保证量刑的合法与规范，把定性准确和量刑适当作为衡量刑事审判工作质量好坏的不可分割的统一标准，以此来检验每一个具体刑事案件的处理结果。

② 纠正重刑主义的错误思想，强化量刑公正的司法观念。我们必须清醒地认识重刑主义的危害，促使每一个法官都树立起量刑公正的思想，切实做到罪责刑相适应，既不轻纵犯罪分子，也不无端地加重犯罪人的刑罚。

③ 纠正不同法院量刑轻重悬殊的现象，实现司法中的平衡和协调统一。除继续及时完善刑法立法外，需要进一步加强刑事司法解释工作，加强刑事判例的编纂工作，推行量刑指导意见，以便为量刑工作提供更加具体明确的标准，同时提高刑事审判工作人员的素质，不断改进量刑程序和方法，从而逐步实现量刑的规范化和科学化。

6 如何理解罪责自负原则？

答：了解罪责自负原则对于学习刑法具有重要意义，可从以下方面理解：

(1) 罪责自负原则的基本含义：

谁犯了罪，就应当由谁承担责任；刑罚只及于犯罪者本人，而不能连累无辜。它是在与株连制度的对立面建立起来的。

(2) 罪责自负原则的基本要求：

- ① 犯罪的主体只能是实施了犯罪行为的人，对于没有实施犯罪行为的人，不能对其定罪。
- ② 刑罚的对象只能是犯罪者本人，对于仅与犯罪者有亲属、朋友、师生、邻里等关系而没有参与犯罪的人，不能追究其刑事责任。

(3) 罪责自负原则的立法体现：

- ① 明确规定了犯罪的概念和犯罪构成的共同要件，原则上划清了罪与非罪的界限，从而为无辜者不受刑事追究提供了法律保障。
- ② 明确规定了共同犯罪的条件和刑事责任原则，对于主犯、从犯、胁从犯和教唆犯，应当根据他们在共同犯罪中的实际地位和作用，来确定其刑事责任。对于没有共同犯罪故意或者根本未参加任何犯罪活动的人，不能以共同犯罪论处。
- ③ 明确规定了各种刑罚的适用对象，从根本上排除了株连无辜的可能。
- ④ 明确规定了各种犯罪的主体范围，以防止株连无辜。

(4) 罪责自负原则的司法适用：

- ① 对所有刑事案件的侦查、起诉和审判，都必须深入实际调查研究，做到事实清楚、证据确实充分，防止错捕、错判无辜，切实保障无罪者不受刑事追究。
- ② 对共同犯罪案件中各被告人刑事责任的确定，应当以共同犯罪人预谋范围内的犯罪为依据，令被告人承担共同犯罪的刑事责任；对超出共同预谋范围的犯罪，应当由实行者本人对该罪独立承担责任，其他未参与此罪的人，不应对该罪负责。
- ③ 对单位犯罪案件的处理，应严格依照刑法的规定追究单位及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任，不能把单位的其他成员也作为承担刑事责任的主体，对其定罪判刑。
- ④ 对于法律明文规定犯罪主体范围的犯罪，要严格依法办事，不能随意扩大犯罪主体的范围，以防累及无辜。

7 如何理解主客观相统一原则？

答：了解主客观原则对于学习刑法具有重要意义，可从以下方面理解：

(1) 主客观相统一原则的基本含义：

对犯罪嫌疑人、被告人追究刑事责任，必须同时具备主客观两方面的条件，并要求主客观两方面条件的有机统一。主客观相统一原则要求只有主客观要素同时具备，二者有机统一，才能作为使被告人承担刑事责任的根据。

(2) 主客观相统一原则的立法体现：

① 《刑法》第14条和第15条明文规定了故意犯罪和过失犯罪的概念，说明任何一种犯罪的成立，都必须是在犯罪故意或过失支配下所实施的行为。

② 《刑法》第16条明文规定：“行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不是犯罪。”

③ 《刑法》第18条第1款明文规定：“精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任……”其根据就在于精神病人在主观上没有犯罪的故意或过失。

④ 《刑法》第20条和第21条分别规定了正当防卫和紧急避险行为不负刑事责任，其原因在于这两种行为客观上没有社会危害性，行为人主观上也没有犯罪的故意或过失，而是出于正当合法性的目的而进行防卫或避险。

⑤ 《刑法》第22~24条规定了预备犯、未遂犯和中止犯，排除了犯意表示行为的犯罪性，表明了我国刑法不惩罚思想犯的立场。

⑥ 刑法分则条文明确规定了各种具体犯罪构成主客观方面的条件。

(3) 主客观相统一原则的司法适用：

① 坚决反对主观归罪。主观归罪在司法实践中主要有两种表现形式：一是把错误思想或犯意表示当作犯罪处理，二是把事前的犯意当作事中的犯意，以事前的犯意定罪判刑。主观归罪的危害，一是导致惩罚思想犯，二是混淆犯罪的性质。无论何种情况，都是对主客观相统一原则的破坏，因而必须坚决予以反对。

② 坚决反对客观归罪。客观归罪在司法实践中也有两种表现形式：一是强调行为、结果的客观危害性，对缺乏犯罪主观要件的意外事件、精神病人的侵害行为等定罪判刑。二是以行为所造成的实际结果确定犯罪性质，而忽视行为人对结果所持的真实心理状态。可见，客观归罪的实质是忽视或根本不考虑行为人的主观认识情况，唯行为、唯结果而定罪处刑。这种割裂犯罪构成主客观要件的做法，也是违背主客观相统

一原则的，因而应当坚决予以摒弃。

第三章 刑法的效力

1 什么是刑法的空间效力？我国刑法对空间效力作了哪些规定？

答：（1）刑法的空间效力，是指刑法在什么地方和对什么人具有效力，即刑法对何地与他人能够适用。关于刑法的空间效力，有以下几种不同的处理原则：

① 属地原则，又称属地主义，或称领土原则。该原则以犯罪发生地为标准确定刑法的空间效力。

② 属人原则，又称属人主义，或称国籍原则。该原则以犯罪人的国籍为标准确定刑法的空间效力。

③ 保护原则，又称保护主义，或称自卫原则。该原则以保护本国利益为标准确定刑法的空间效力。

④ 普遍管辖原则。该原则是指当一个国家既不是犯罪行为的发生地国，也不是行为人和受害人的国籍国，甚至也不是犯罪行为的受害国时，该国仅基于行为人所犯的罪行是严重的国际罪行而对该案件具有刑事管辖权。

⑤ 折中原则，又称折中主义，或称综合原则、混合原则。该原则以属地原则为基础，以属人原则、保护原则和普遍管辖原则为补充。

（2）我国刑法对空间效力的规定主要体现在管辖权的规定上，具体有以下几种：

① 我国刑法规定了属地管辖权，即在我国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用我国刑法；在我国船舶或者航空器内犯罪的，也适用我国刑法；犯罪的行为或者结果有一项发生在我国领域内的，就认为是在我国领域内犯罪。

② 我国刑法上规定了属人管辖权，即我国国家工作人员和军人在我国领域外犯我国刑法规定之罪的，一律适用我国刑法；军人和国家工作人员以外的其他人员在我国领域外犯我国刑法规定之罪的，同样适用我国刑法，但是，如果所犯之罪的法定最高刑在3年有期徒刑以下的，可以不予追究。

③ 我国刑法上规定了保护管辖权，即外国人在我国领域外犯罪，但侵害了我国国家或者我国公民的利益，且依我国刑法规定，所犯之罪的法定最低刑为3年以上有期徒刑，依照犯罪地的法律也构成犯罪的，我国刑法亦有管辖权。

④ 我国刑法上规定了普遍管辖权，即该犯罪行为必须是中华人民共和国缔结或者参加

的国际条约所规定的罪行，且必须在中华人民共和国所承担的条约义务的范围内。原则上，这些犯罪的行为人进入我国领域或被我国发现的，受我国刑法管辖。

2 为什么我国刑法对于溯及力问题采取从旧兼从轻原则？

答：从旧兼从轻原则是指新法原则上不具有溯及力，对于新法生效前发生的未经审判或者判决未确定的行为，原则上适用旧法，但当适用新法对被告人有利时，则适用新法。采取该种原则有以下几点原因：

(1) 公民有从事法律未禁止的行为的自由。如果公民在实施法律未被禁止的行为之后，国家又制定法律把这些行为宣布成为应受刑罚的违法行为，并根据此对它惩罚，就意味着惩罚公民自由权的行使，惩罚无辜。用事后法进行惩罚是不公正的，非正义的，侵犯人权的。

(2) 在涉及公法领域，公民相对于拥有的立法权、司法权的强大国家来说是弱势的一方，为了保护公民的权利不受国家立法和司法的肆意侵害，有必要对国家的权力进行限制，防止国家权力的滥用，以保障人权。

(3) 从轻是为了进一步的保护人权，正确的理解并实现法律工具的功能。法律是国家对一种行为是否具有社会危害性的评价工具。随着社会的发展、变化，其评价标准也在不断改变，原来认为具有社会危害性的行为，后来认为不具有社会危害性，而法律的修改正是对行为之社会危害性既定判断的确认。另外，惩罚的原则是惩罚与社会危害性的相适应。如果修改后的法律对一个行为时的法律认为有很大的社会危害性的行为做出了没有社会危害性或社会危害性较小的评价，并相应的取消对这种行为的惩罚或做出较轻的惩罚的规定时，应适用新的法律对这种行为重新进行评价并相应的调整惩罚。

第四章 犯罪概念与犯罪构成

1 什么是犯罪？犯罪有哪些基本特征？

答：（1）犯罪，是指对犯罪各种内在、外在特征的高度、准确的概括，是对犯罪的内涵和外延的确切、简要的说明。犯罪概念一般分为形式概念、实质概念、混合概念。

① 犯罪的形式概念，也称形式意义的犯罪概念，是指仅基于法律特征而给犯罪下定义，至于法律为何将诸如此类的行为规定为犯罪则不予涉及。

② 犯罪的实质概念，也称实质意义的犯罪概念，是指不涉及犯罪的法律特征，而从犯罪现象的本质给犯罪下定义，借此揭示一种行为被刑法规定为犯罪的内在原因。

③ 犯罪的混合概念，是指既强调犯罪的实质概念，亦注重犯罪的形式概念，以同时揭示犯罪的本质特征和法律特征的概念。

我国刑法中的犯罪，是指严重危害我国社会，触犯刑法并应受刑罚处罚的行为。该定义表明我国刑法的犯罪概念属于混合概念的类型。

（2）犯罪的基本特征有：

① 犯罪是具有严重社会危害性的行为。行为具有严重的社会危害性，是犯罪最本质最基本的特征。所谓社会危害性，是指行为对刑法所保护的社会关系造成或可能造成损害的特性。

② 犯罪是具有刑事违法性的行为。犯罪是触犯刑事法律的行为，这是犯罪的法律特征。犯罪不是一般的违法行为，而是触犯刑事法律的刑事违法行为，是最为严重的违法行为。

③ 犯罪是应受刑罚惩罚的行为。对于任何违法行为，无论是民事的、行政的还是刑事的，行为人都应当承担相应的法律后果。

犯罪的上述三个基本特征是紧密结合、有机联系的。严重的社会危害性是犯罪最基本的属性，是刑事违法性和应受刑罚惩罚性的基础。刑事违法性是严重的社会危害性的法律表现，应受刑罚惩罚性是行为严重危害社会、违反刑事法律应当承担的法律后果。因此，这三个基本特征都是必要的，是任何犯罪都必然具备的。这三个基本特征将犯罪与非罪区别开来。

2 什么是犯罪构成？犯罪构成有哪些基本特征？

答：（1）犯罪构成是指刑法规定的，决定某一具体行为的社会危害性及其程度，而为该行为构成犯罪所必须具备的一切客观要件和主观要件的有机统一的整体。

（2）犯罪构成的基本特征：

① 犯罪构成由刑法予以明确规定。行为成立犯罪所必需的犯罪构成要件，必须由我国刑法加以规定。此一特征体现了犯罪构成的法定性。

② 犯罪构成是行为具有严重社会危害性的法律标志。任何一个犯罪都包含着很多事实特征，但不是每一个事实特征都可以成为犯罪构成的要件，只有那些对行为的社会危害性及其程度具有决定意义而为该行为成立犯罪所必需的事实特征，才是犯罪构成的要件。

③ 犯罪构成是诸多客观要件和主观要件的有机统一的整体。任何一种犯罪的成立，都须具备若干要件。在这些要件中，既包含犯罪客体要件和犯罪客观方面要件，也包含犯罪主体要件和犯罪主观方面要件。

3 试述我国犯罪构成模式的选择及四要件犯罪构成理论的改进。

答：（1）我国刑法学界通行的观点认为，犯罪构成是我国刑法规定的、决定某一具体行为的社会危害性及其程度而为该行为构成犯罪所必需的一切客观要件和主观要件的总和。犯罪构成要件包括犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面，故而又被称为四要件犯罪构成理论。

四要件犯罪构成理论不仅是一种历史性的选择，具有历史合理性；也符合中国国情，契合中国的诉讼模式，具有现实合理性；而且其逻辑严密，契合认识规律，符合犯罪本质特征，还具有内在合理性。不仅能够通过各种相互联系、相互作用的要件及其要素，充分反映出社会危害性这一犯罪的本质，揭示犯罪行为内部构成要素的有机统一性质，而且这种犯罪构成的理论体系，总体上避免或至少减少了许多对行为是否构成犯罪而作的烦琐的重复评价。同时，这一理论所确立的犯罪构成要件的结构模式，使犯罪构成理论与犯罪构成的法律规定较为完美地达到了和谐与协调，因为构成要件的内容就是犯罪成立的要素。

（2）四要件犯罪构成理论的改进：明确犯罪构成四要件的判断顺序，在司法实践中，要严格按照犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面的逻辑顺序进行适用。既要防止客观归罪，也要反对从主观到客观、仅凭主观归罪的倾向，严格贯彻主客观相统一原则。进一步确定犯罪客体的定位及其在犯罪构成中的作用，防止犯罪客

体的形式化。此外，要将正当防卫、紧急避险等违法阻却事由，期待可能性、违法性认识等责任阻却事由放在构成要件中考虑，防止在犯罪构成要件之外认定犯罪，同时协调犯罪概念与犯罪构成之间的关系。

4 犯罪构成如何分类？

答：犯罪构成的分类具体如下：

(1) 根据犯罪构成要件组成的繁简程度，可以把犯罪构成分为单纯的犯罪构成与混合的犯罪构成。

① 单纯的犯罪构成是指刑法条文对具体犯罪所规定诸要件之各种要素均属单一的犯罪构成。

② 混合的犯罪构成，是指刑法条文对具体犯罪所规定的诸要件中存在要素复合或择一而定的犯罪构成。

(2) 按照犯罪构成类型所依赖的犯罪形态是否典型，可将犯罪构成分为基本的犯罪构成与修正的犯罪构成。此一分类方法，可以揭示同质的犯罪在不同形态下由于构成要件的组成结构不同而具有的不同程度的社会危害性。

① 基本的犯罪构成，是指刑法条文就某一犯罪的单独犯的既遂状态所规定的犯罪构成。基本的犯罪构成由刑法分则直接规定。

② 修正的犯罪构成，是指以基本的犯罪构成为前提，为适应犯罪行为的各种不同犯罪形态，而对基本的犯罪构成加以某些修改变更的犯罪构成。

(3) 按照犯罪行为危害程度的大小，可将犯罪构成分为普通的犯罪构成、加重的犯罪构成和减轻的犯罪构成。

① 普通的犯罪构成，是指刑法条文对具有通常社会危害程度的行为所规定的犯罪构成。

② 加重的犯罪构成，是指以普通的犯罪构成为基础，由于具有较重社会危害程度的情节而从普通的犯罪构成中分化出来的犯罪构成。

③ 减轻的犯罪构成，是指以普通的犯罪构成为基础，由于具有较轻社会危害程度的情节而从普通的犯罪构成中分化出来的犯罪构成。

5 犯罪构成的意义是什么？

答：犯罪构成具有以下几点意义：

(1) 有利于实现和维护罪刑法定原则，防止罪刑擅断。犯罪构成是犯罪成立条件的概括，有利于罪刑法定原则的贯彻实现。犯罪构成可以使确实犯了罪行的人受到追究，以维护社会秩序；同时可以使未实施罪行的人不受处罚，以保障人权。只有借助于犯罪构成，罪刑法定原则维护社会秩序和保障人权的功能才能够得以实现。

(2) 对刑事司法实践起着特别重要的指导作用。具体言之，它具有如下作用：

① 区分罪与非罪。一种行为是否构成犯罪，只能以犯罪构成为标准来判断。行为符合犯罪构成的，构成犯罪；不符合犯罪构成的，则不构成犯罪。犯罪构成为罪与非罪的区分提供了明确而具体的法律标准。

② 区分此罪与彼罪。犯罪构成也为此罪与彼罪的区分提供了法律标准。由于每一种犯罪都具有独一无二的具体构成要件，因此，只需严格把握各种具体犯罪的构成要件，就能将各种犯罪准确地加以区分。

③ 正确地裁量刑罚。犯罪构成可以为判定一罪与数罪提供标准，从而正确地进行数罪并罚。不同的犯罪构成也体现了犯罪不同的社会危害性，可以决定刑罚的轻重。尤其是加重的犯罪构成与减轻的犯罪构成，对于判断罪刑轻重，正确裁量刑罚具有更加直接的意义。



微信扫描上方二维码，获取更多免费资料

第五章 犯罪客体

1 如何理解犯罪客体在犯罪构成中的地位和作用？

答：（1）犯罪客体的含义

犯罪客体，是指我国刑法所保护的为犯罪行为所侵犯的社会关系。犯罪客体是犯罪构成的必备要件之一。任何一种犯罪都必然侵犯刑法所保护的社会关系，否则，就不具备严重的社会危害性，缺乏犯罪的本质特征。

（2）犯罪客体在犯罪构成中的地位

犯罪客体揭示了犯罪的实质——社会危害性。若无犯罪客体的存在，犯罪构成的其他要件就不能说明犯罪的本质，因为只有犯罪客体的内容才能表明行为的社会意义，对社会的负价值。

（3）犯罪客体在犯罪构成中的作用

① 构成刑法分则的基础。我国刑法分则体系的构建是以犯罪客体为基础的。按照犯罪行为所侵犯的同类客体，分则将犯罪分为三大类、十小类，在每一小类内部，也是按照犯罪行为对客体危害的程度予以排序。

② 分析犯罪行为性质的决定因素。犯罪客体体现了刑法所保护的社会关系。从立法上来讲，就是立法者要决定什么利益要受到刑法何种程度的保护；从司法上来讲，就是要用犯罪客体来判断一个行为是否符合犯罪的标准，只要受到犯罪行为现实或可能侵害的利益是刑法所保护的利益，那就符合客体的要求。

③ 正确评估罪刑的标准之一。按照犯罪客体的分类，犯罪客体有直接客体 and 间接客体，直接客体又可分为简单客体和复杂客体。对正确评价定罪和量刑来说，简单客体和复杂客体的区分有着重大的意义。

④ 区分此罪与彼罪的重要依据。对于客观行为与结果相同的犯罪，确定该行为所侵犯的社会关系，可以正确地地区分不同的犯罪。

2 犯罪对象与犯罪客体的关系是什么？

答：犯罪客体，是指我国刑法所保护的为犯罪行为所侵犯的社会关系。犯罪客体是犯罪构成的必备要件之一。犯罪对象，是指刑法分则条文规定的受犯罪行为直接作用或

影响的具体的人或物。

(1) 犯罪对象与犯罪客体的联系

犯罪对象反映犯罪客体，犯罪客体制约犯罪对象。

(2) 犯罪对象与犯罪客体的区别

① 犯罪对象是人、物等可以凭借人的感官感知的事物；犯罪客体是生命权、财产权、公共安全、国家安全等凭借人的思维才能认识的观念的东西。两者表现出具体与抽象的差异。

② 犯罪客体决定犯罪性质，犯罪对象则未必。

③ 犯罪客体是任何犯罪构成的必要条件，犯罪对象则不是任何犯罪都不可缺少的，它仅仅是某些犯罪的必要条件。

④ 任何犯罪都会使犯罪客体受到危害，而犯罪对象则不一定受到损害。

⑤ 犯罪客体是犯罪分类的根据，而犯罪对象不是犯罪分类的根据，因为犯罪对象相同并不意味着犯罪性质相同。

3 我国刑法分则的罪名是按照什么标准进行分类的？

答：犯罪客体是对犯罪进行分类排列的标准，按照犯罪行为侵犯的社会关系的范围，刑法上将犯罪客体划分为三类或三个层次：一般客体、同类客体和直接客体。我国刑法分则的罪名则是以犯罪同类客体为主，以犯罪主体或者惩治犯罪的特殊需要为辅，按照此标准对罪名进行分类的。

具体而言，我国刑法的犯罪同类客体分为十类：

(1) 国家安全，这是《刑法》分则第一章规定的同类客体。

(2) 公共安全，这是《刑法》分则第二章规定的同类客体。

(3) 社会主义市场经济秩序，其中又包括八小类，这是《刑法》分则第三章规定的同类客体。

(4) 公民人身权利、民主权利，这是《刑法》分则第四章规定的同类客体。

(5) 公私财产关系，这是《刑法》分则第五章规定的同类客体。

- (6) 社会管理秩序，其中又包括九小类，这是《刑法》分则第六章规定的同类客体。
- (7) 国防利益，这是《刑法》分则第七章规定的同类客体。
- (8) 国家的廉政制度，这是《刑法》分则第八章规定的同类客体。
- (9) 国家机关的正常活动以及公众对国家机关工作人员职务活动公正性的信赖，这是《刑法》分则第九章规定的同类客体。
- (10) 国家的军事利益，这是《刑法》分则第十章规定的同类客体。

第六章 犯罪客观方面

1 如何理解犯罪客观方面的要件在犯罪构成中的地位？

答：（1）犯罪客观方面是指刑法所规定的，说明行为对刑法所保护的社会关系的侵犯性，行为成立犯罪所必须具备的客观事实特征。犯罪的客观方面包括危害行为、危害结果、危害行为和危害结果之间的因果关系以及犯罪的时间、地点、方法等。

（2）犯罪客观方面是犯罪构成的四大要件之一，对于分析犯罪构成具有重大意义。具体表现如下：

① 有助于区分罪与非罪。如果不具备犯罪客观方面的要件，就失去了构成犯罪和承担刑事责任的客观基础。对一切犯罪来说，危害行为的有无是决定犯罪成立与否的标志，无行为则无犯罪。

② 有助于区分此罪与彼罪。在我国刑法中，有许多犯罪在犯罪客体、犯罪主体和犯罪主观方面都是相同的，将其区分为不同的犯罪通常是由犯罪客观方面来决定的。

③ 有助于正确分析和认定犯罪的罪过。刑法上的犯罪行为都是与一定的罪过相结合的，没有罪过就谈不上犯罪。

④ 有助于正确量刑。量刑要以犯罪的社会危害性及其程度为基础，而犯罪的社会危害性及其程度是由犯罪的主客观因素决定的。

2 如何理解“无行为则无犯罪”？怎样区分刑法中的危害行为与其他危害行为？

答：（1）犯罪是人的行为。“无行为则无犯罪亦无刑罚”已成为一种法律信念，是现代刑法的观念基础。在我国刑事立法中，“行为”一词不仅见诸刑法总则关于犯罪的概念以及其他规定中，而且见诸刑法分则的许多规范中。我国刑法所惩处的犯罪，首先是人的危害社会的行为。危害行为是我国刑法中犯罪客观方面首要的、必备的因素，它在每个犯罪构成中都居于核心的地位。

（2）刑法中的危害行为，又称危害社会的行为，是指表现人的意思自由、客观上危害社会并为刑法所禁止的身体动静。它具有以下特征：

① 客观上是人的危害社会的行为。

a. 我国刑法坚决摒弃“思想犯罪”，将单纯的人的思想活动、思想方式排除于危害行为

的外延。

b. 我国刑法所惩罚的行为，只能是危害社会的行为，而不是其他任何性质行为。

c. 发表有害言论，若仅是单纯暴露思想，不是刑法上的危害行为；但若意在实现这种言论所表达的思想，利用言论来危害社会的，则超越了思想方式的范围，能够成为刑法上危害社会的行为。

② 主观上是表现人的意志或意识的行为。

③ 危害行为的刑法禁止性。危害行为的刑法禁止性，是指这种行为违反了刑法的规定，已经或者可能给社会造成危害后果。

其他危害行为则无刑法禁止性，这是刑法中的危害行为与其他危害行为的最大区别。

3 如何理解不作为的行为性？不作为的成立条件是什么？

答：（1）不作为的行为性的概念

不作为是一种消极的身体活动。行为人对于自己所负有的特定作为义务，没有作出法律要求的一定的积极动作或举动，是消极地不实施某种积极行为。当然，在不作为的情况下，行为人并非什么也没有做，其身体并非处于彻底静止的状态，而是没有做法律要求他必须做的事情，这是一种法律意义上的“静”，而不是自然的、物理意义上的静止状态。

（2）不作为的成立条件

① 行为人应当履行特定义务。

不作为的义务来源于以下几个方面：

a. 来源于法律上的明确规定，即行为人违反的义务是法律明确规定的。

b. 职务上、业务上所要求的义务。

职务上要求的义务指国家工作人员基于其职务而产生的履行公务的职责。

业务指人们在社会生活中从事的具有一定专业性、持续性并能给其带来经济收益的活动。

c. 法律行为引起的义务。

本书认为，法益处于无助、危险或者脆弱状态时，行为人基于自愿承担保护义务，使法益的保护依存于自己，行为人就必须继续承担保护义务。

d. 先行行为引起的义务。

这个先行行为可以是合法行为，也可以是不法行为。

e. 公共秩序和社会公德要求承担的义务。

理论界认为，社会公德要求承担的义务一般不能成为不作为的义务来源，但在特定情况下可以成为刑法上的不作为的义务来源。

② 行为人有能力履行该特定义务。负有特定义务的人必须在能够履行特定义务的条件下不履行义务，即有能力履行并且有条件履行而不履行义务时，才构成刑法上的不作为。

③ 行为人不履行该特定义务，造成或者可能造成危害结果。多数情况下行为人不履行特定作为义务的行为造成危害结果才构成犯罪，但并不尽然，有时候没有造成危害结果，也会构成犯罪，也就是说不作为犯是有未遂、中止和预备的。

4 哪些危害结果对定罪有意义？哪些危害结果对量刑有意义？

答：（1）构成要件结果、物质性危害结果、直接结果、基本结果对定罪有意义。

构成要件结果是指由犯罪的实行行为造成的、根据刑法分则的规定对成立犯罪或者犯罪既遂具有决定意义的危害结果，它只存在于过失犯罪、间接故意犯罪和结果犯的既遂犯中。物质性危害结果又称有形的危害结果，具有具体、可见、可以计量的特点，如人的死亡、伤害结果的发生、财产的损害等。直接结果是指由危害行为本身直接引起的损害结果。基本结果是指作为一种犯罪构成基本要件的结果，也是对该罪直接客体的损害，是构成该罪的基本要件之一。上述结果对于犯罪构成具有重要意义，因而对定罪有意义。

（2）非构成要件结果、物质性危害结果、间接结果、加重结果对量刑有意义。

非构成要件结果是指由危害行为引起的、构成要件结果以外的、对于该种犯罪的社会危害性程度及其刑事责任的大小具有一定评价意义的损害结果。间接结果是指由直接结果进一步引起的危害结果。加重结果是指实施一种犯罪，具备该罪的基本要件，但却引起了另一种严重的危害结果。上述危害结果对于犯罪构成不具备直接的影响，但对量刑具有重要意义。

5 如何区分刑法上因果关系中的原因与条件？

答：（1）原因是指因果关系中能在一定条件下引起其他现象的现象。因果关系是哲学上的一个重要范畴，它是指一种现象在一定条件下引起另一种现象。条件则指对某一结果的产生起作用的各种因素。

（2）因果关系中的原因不同于条件。其具有区别于因果关系中的条件的四个特点：

① 原因是客观存在的，具有客观性，不以人们的意志为转移。

② 引起结果的原因是复杂不定的，具有复杂性。这主要表现为“一因多果”或“一果多因”。“一因多果”，是指一个危害行为可以同时引起多种结果的情况。“一果多因”，是指某一危害结果是由多个原因造成的。

③ 原因是相对结果而言的，具有相对性。在客观世界中，各种现象都是普遍联系、互相制约的，并形成一个错综复杂、相互联系的因果链条。在这一现象中成为原因的，其本身又可能是另一现象的结果，所以我们在研究哪个现象是原因，哪个现象是结果时，必须把一对现象从普遍联系的链条当中抽取出来。

④ 原因是必然引起结果的那个原因，具有必然性。某种危害结果由某人的行为内在、合乎规律地产生，行为与结果的这种联系，就是必然因果关系。

第七章 犯罪主体

1 如何理解犯罪主体的概念？

答：（1）犯罪主体是构成犯罪的必备条件之一，是指实施危害社会的行为并依法应当负刑事责任的自然人和单位。自然人可以成为我国刑法规定的所有犯罪的主体，单位则只可以成为我国刑法规定的部分犯罪的主体。

（2）确认犯罪主体的概念具有重要意义：

① 有助于准确定罪。主要表现为：

- a. 任何犯罪都有其犯罪主体，即任何犯罪都有犯罪行为的实施者，离开了犯罪主体就不存在犯罪。
- b. 只有具备法律所要求的犯罪主体条件的人，才能构成犯罪并被追究刑事责任；不符合犯罪主体条件的人，即使实施了刑法所禁止的危害社会的行为，也不构成犯罪和承担刑事责任。
- c. 分则某些条文中规定的关于犯罪人应具备的特殊身份要件，对于正确区分罪与非罪以及此罪与彼罪具有重要意义。

② 有助于合理量刑。在具备犯罪主体要件的相同情况下，犯罪主体的具体情况不同，则会影响到刑罚的轻重。例如，我国《刑法》第17条第3款规定，已满14周岁不满18周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。这说明犯罪主体的不同情况对量刑即刑罚裁量的重要影响。科学研讨立法与司法中有关犯罪主体的问题，对实践中正确适用刑罚是十分重要的。

2 何谓刑事责任能力？辨认行为能力与控制行为能力之间的关系为何？

答：（1）刑法理论通说认为，刑事责任能力指行为人具备的刑法意义上辨认和控制自己行为的能力。在我国刑事立法和刑法理论看来，刑事责任能力的本质，是人实施行为时具备相对自由的意志能力，即行为人实施刑法所禁止的严重危害社会的行为，具备相对自由的认识和抉择行为的能力。刑事责任能力作为犯罪主体的核心和关键要件，对于犯罪主体的成立与否以及对行为人的定罪量刑，具有至关重要的作用和意义。

(2) 辨认行为能力是指行为人具备的对自己的行为在刑法上的意义、性质、后果的分辨认识能力，即行为人有能力认识自己的行为是否为刑法所禁止、所谴责、所制裁。控制行为能力是指行为人具备的决定自己能否以行为触犯刑法的能力，即行为人有能力选择和决定自己是否实施这些触犯刑法的行为。

(3) 辨认行为能力与控制行为能力的关系：

辨认行为能力和控制行为能力是构成刑事责任能力的必要要素，两者只有同时具备，才可具备刑事责任能力。辨认行为能力与控制行为能力之间存在着有机的联系：

① 辨认能力是刑事责任能力的基础。控制行为能力的具备是以辨认行为能力的存在为前提的，不具备辨认行为能力的人，自然也就没有刑法意义上的控制行为能力。

② 控制行为能力是刑事责任能力的关键。具有辨认行为能力，还需要具有控制行为能力，才能具备刑事责任能力。刑事责任能力的存在，要求辨认行为能力与控制行为能力同时齐备，缺一不可。

3 如何理解我国刑法中刑事责任年龄阶段的划分？

答：（1）刑事责任年龄是指刑法所规定的行为人对自己实施的刑法所禁止的危害社会行为负刑事责任而必须达到的年龄，是决定刑事责任能力有无或影响刑事责任能力程度的重要因素之一。

（2）我国刑法中关于刑事责任年龄的规定，解决的是不同年龄人刑事责任的有无及程度问题。我国《刑法》第17条中对刑事责任年龄作了较为集中的规定，把刑事责任年龄划分为完全不负刑事责任年龄、相对负刑事责任年龄与完全负刑事责任年龄三个年龄阶段：

① 完全不负刑事责任年龄阶段。《刑法》第17条规定，不满14周岁是完全不负刑事责任年龄的阶段。一般地说，不满14周岁的人还不具备辨认和控制自己行为的能力，即不具备责任能力。因而法律规定，对不满14周岁的人所实施的危害社会的行为，一概不追究刑事责任。但应当注意，对于因不满14周岁实施了危害社会行为而不追究刑事责任的人，应依法责令其家长或监护人加以管教，也可视需要对接近14周岁，如12~13周岁的人由政府收容教养。

② 相对负刑事责任年龄阶段。《刑法》第17条第2款规定，已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁，是相对负刑事责任年龄阶段，也称相对无刑事责任年龄阶段。达到这个年龄阶段的人，已经具备了一定的辨别

行为的大是大非的能力和控制能力，即对某些严重危害社会的行为具备一定的辨认和控制能力。因此，刑法规定他们对自己实施的严重危害社会的行为负刑事责任。

③ 完全负刑事责任年龄阶段。《刑法》第17条第1款规定，已满16周岁的人进入完全负刑事责任年龄阶段。由于已满16周岁的未成年人的体力和智力已有相当的发展，具有一定的社会知识，是非观念和法治观念的增长已达到一定程度，一般已能够根据国家法律和社会道德规范的要求来约束自己，因而他们已经具备了基本的刑法意义上辨认和控制自己行为的能力。基于此，我国刑法规定已满16周岁的人原则上可以构成刑法中所有的犯罪，要求他们对自己实施的刑法所禁止的一切危害行为承担刑事责任。

4 怎样理解和掌握精神障碍人的刑事责任能力问题？

答：人达到负刑事责任的年龄，若存在精神障碍，该障碍可能影响其刑事责任能力，而使刑事责任能力减弱甚至不具备，从而使其实施危害行为时的刑事责任也受到影响。我国《刑法》第18条专门规定了精神病人（即精神障碍人）的刑事责任问题，将精神病人的刑事责任能力划分为完全无刑事责任能力、限制刑事责任能力和完全刑事责任能力，分别规定了相应的刑事责任问题。

（1）完全无刑事责任能力的精神病人。《刑法》第18条第1款规定，精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。实施刑法所禁止的危害行为的精神障碍人，只有同时符合医学标准和心理学（法学）标准，才应确认为无刑事责任能力人。

（2）限制刑事责任能力的精神病人。《刑法》第18条第3款规定，尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。对限制刑事责任能力的精神病人，从立法意图来说，应作广义理解，一般包括以下两类：一是处于早期或部分缓解期的精神病即严重精神障碍患者。二是某些非精神病性精神障碍人，包括轻至中度的精神发育迟滞者、脑部器质性病变或精神病后遗症所引起的人格变态者、神经官能症中少数严重的强迫症和癔症患者等。在司法实践中，是否对限制刑事责任能力的精神病人从轻或者减轻处罚、从轻或者减轻的幅度如何掌握，应以行为人所实施的犯罪是否与辨认或控制行为能力减弱有直接联系，以及有多大的影响为标准。

（3）完全刑事责任能力的精神病人。依据《刑法》第18条的规定和有关的司法精神病鉴定实践及司法实践经验，责任能力完备而应完全负刑事责任的精神障碍人包括两类：a. 精神正常时期的“间歇性精神病人”。《刑法》第18条第2款规定，间歇性的精

神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。b. 大多数非精神病性精神障碍人。其辨认或者控制自己行为的能力大多数情况下并不因精神障碍而丧失或减弱，具有完全的刑事责任能力，应在原则上对其危害行为依法负完全刑事责任。但在少数情况下，非精神病性精神障碍人也可成为限制刑事责任能力人甚至无刑事责任能力人，从而涉及减轻刑事责任或者不负刑事责任的问题。

5 聋哑人、盲人、生理性醉酒人的刑事责任能力如何？

答：（1）我国《刑法》第19条规定，又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。换言之，聋哑人、盲人实施刑法禁止的危害社会行为，构成犯罪的，应当负刑事责任并受刑罚处罚，但可以从轻、减轻或者免除处罚。适用该条规定应注意以下几点：

① 该条“又聋又哑的人”指同时完全丧失听力和语言功能者。

② 该条的“盲人”指双目均丧失视力者。

③ 是否对聋哑人、盲人犯罪“从轻、减轻或者免除处罚”，应根据该人对其实施的犯罪的辨认和控制能力状况来决定。

（2）《刑法》第18条第4款规定，醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。如果行为人在醉酒前对其在醉酒后实施的危害社会行为具有犯罪故意或犯罪过失，应负完全的刑事责任；反之，应依其醉酒后的实际精神状态确定其刑事责任，处于无刑事责任能力状态的则不负刑事责任，处于限制刑事责任能力状态的则应负刑事责任，但应从宽处罚。

6 犯罪主体的特殊身份有什么意义？

答：犯罪主体的特殊身份是指刑法所规定的影响行为人刑事责任的人身方面特定的资格、地位或状态，如国家机关工作人员、司法工作人员、军人等。这些特殊身份不是自然人犯罪主体的一般要件，而只是某些特定犯罪的自然人主体必须具备的要件。犯罪主体特殊身份对定罪量刑皆具有重要意义。

（1）影响行为的定罪是犯罪主体特殊身份的首要功能。主要表现在：

① 主体特殊身份具备与否，是区分罪与非罪的标准之一。

② 主体特殊身份具备与否，也是某些犯罪案件中区分和认定此罪与彼罪的一个重要标准。例如，同是隐匿、毁弃或者非法开拆他人信件的行为，具有邮政工作人员身份并

利用其职务便利实施者构成《刑法》第253条规定的私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪，一般公民则构成《刑法》第252条的侵犯通信自由罪。

③ 主体特殊身份影响无特殊身份者的定罪。指无特定身份者与有特定身份者共同实施要求特殊主体身份之罪的情况。例如，一般公民与国家工作人员一起利用该国家工作人员的职务便利向他人索取财物的，构成受贿罪。

(2) 犯罪主体特殊身份对量刑的意义主要表现在：

① 对行为类似的特殊主体的犯罪规定的刑罚一般都较一般主体的犯罪要重。例如，对于窃取、骗取行为的国家工作人员贪污罪的刑罚，重于对一般主体的盗窃罪、诈骗罪的刑罚。

② 对某些犯罪，若行为人具有特殊身份，就要从重处罚。例如，国家机关工作人员犯诬告陷害罪的，从重处罚。

7 怎样理解单位犯罪及双罚制？

答：（1）根据我国《刑法》第30条规定，单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为。单位犯罪的构成有两个主要特征：

① 犯罪的主体是单位。实施单位犯罪行为的主体只能是单位，具体包括公司、企业、事业单位、机关、团体。

② 犯罪行为体现单位意志。单位成员实施的犯罪行为并非单纯出于个人的意志，而是体现了单位的意志。这主要表现为两种情形：一种是执行单位决策机构的决策和单位法定代表人或者负责人的决定的行为。二是单位成员在单位业务范围内履行职责的行为。

(2) 双罚制是单位犯罪的处罚原则之一，世界各国刑事立法和刑法理论主要遵循两种原则：一是双罚制，即单位犯罪的，对单位和单位直接责任人员均予以刑罚处罚。二是单罚制，即单位犯罪的，只处罚单位或只处罚单位的直接责任人员。单罚制具体又分为转嫁制和代罚制两种类型。转嫁制指只对单位予以刑罚处罚，代罚制指只对直接责任人员予以刑罚处罚。

我国《刑法》第31条规定：“单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。”这是我国刑法关于单位犯罪处罚原则的规定。据此，我国对单位犯罪一般采取双罚制的原

则。即单位犯罪的，对单位处罚金，同时对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。

第八章 犯罪主观方面

1 为什么说罪过是行为人承担刑事责任的主观基础？

答：罪过是犯罪主观方面中犯罪故意和犯罪过失的统称。罪过是行为人承担刑事责任的主观基础，其原因在于：

(1) 罪过是行为人主观恶性的特征表现，而主观恶性是犯罪的社会危害性的重要组成部分。它反映了行为人对于刑法规范以及刑法规范所保护的社会关系的否定态度。其中，犯罪的故意表明了行为人对刑法规范及其所保护的社会关系所持有的敌视或蔑视态度。犯罪过失则表明了行为人对刑法规范及其所保护的社会关系所持有的漠视或忽视态度。因此，查清罪过，是揭示行为社会危害性的重要方面。

(2) 罪过是犯罪主观方面的必备要素，因而也是犯罪构成的必备要素。根据我国刑法理论，犯罪构成要件是追究行为人刑事责任的根据，罪过所揭示的行为人对其危害行为及其危害结果的故意或过失的心理态度，是犯罪构成的主观要件，所以，罪过是行为人承担刑事责任的主观基础。这是基于辩证唯物主义关于人的意识和意志具有相对的独立性和主观能动性，以及人应当对自己自觉的有意识、有意志的活动承担相应的社会责任这一基本原理所决定的。

2 如何区分刑法中的犯罪故意与日常生活中的故意？

答：刑法中的犯罪故意具有特定的内涵，特指行为人对其实施的行为所造成的危害结果所持的希望或放任的态度；而一般生活意义上的“故意”，只是表明行为人有意识地实施某种行为，并不包含其对结果的社会危害性的态度这一内容。

(1) 刑法上的犯罪故意具有法定性，其具体定义有刑法的专门规定；构成犯罪故意需要的认识内容也以刑法规定的事实要素为基础。

(2) 刑法上的犯罪故意既包括认识因素也包括意志因素，而其中认识因素的对象是犯罪客观要件的全部内容。生活中的故意强调的是行为人在意志支配下有目的的行为，不一定存在特定的认识对象和意志追求。

(3) 刑法上的犯罪故意具有规范含义和价值意义，其反映了行为人的社会危害性和主观恶性，犯罪故意表明行为人对法规范和刑法所保护的社会关系的漠视；而生活中的故意则不能反映出行为人的社会危害性和刑法上的主观恶性。

3 如何理解犯罪故意中的“明知”？

答：犯罪故意是指行为人明知自己的行为会造成危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生的心理态度。因此，“明知”是犯罪故意的认识要素，对“明知”的理解包括以下几个方面：

(1) “明知”的对象，应当限定为法律规定的构成某种故意犯罪所不可缺少的客观事实因素，大体上相当于作为犯罪客观要件的内容。但是，对于我国刑法分则中的“情节严重”“情节恶劣”“数额较大”“数额巨大”等这些反映定量因素的定罪情节，不应被纳入犯罪故意的认识因素中。

(2) “明知”的主要内容，具体包括：

① 对行为性质的认识：包括对其行为的内容、作用的认识。

② 对危害结果的认识：即对行为造成或可能造成的危害社会结果的内容与性质的认识。

③ 对刑法规定的行为对象的认识。

④ 对特定的时间、地点、方法的认识。

(3) 对于规范的犯罪构成要素（指需要根据生活经验、价值判断、法律规定等进行规范评价的要素）的认识，根据同类的外行人的平行评价标准，只要行为人对行为的社会意义认识到与规范概念实质相当的程度即可，即认识到与法律语言“平行”的日常用语层次即可成立故意。如果行为人不能认识行为的社会意义，则不成立故意。

(4) 在理解刑法中的明知时，还应注意不能把刑法中的明知简单理解为“确知”，即确切无疑地知道。明知还包括一定条件下的“应知”，即根据行为人的主观认识能力和行为时的客观情况，合理推断出行为人当时应当知道，也就是所谓的“推定的明知”。在推定明知的情况下，如果有相反的事实和证据足以证明行为人的明知不成立，就可推翻这种推定。

4 如何理解间接故意中的“放任”？

答：间接故意，是指行为人明知自己的行为可能会发生危害社会的结果，并且放任这种结果发生的心理态度。因此，“放任”是间接故意的意志因素，对“放任”的理解包括以下几个方面：

(1) 放任是一种不计后果的心理态度。即行为人对危害结果的发生，采取听之任之、满不在乎、无所谓的态度，结果未发生行为人并不遗憾，结果发生了也不违背其本意。

(2) 放任具有附属性。放任是附属在行为人希望其他结果发生的心态下的一种意志因素。在间接故意的情形中，行为人是为了追求自己意欲实现的行为而放任其他结果的发生，因此，它首先存在着对目的行为的希望意志，当然，这种希望意志的结果有犯罪结果也有非犯罪结果。为了追求目的行为结果的发生，行为人对于该结果的附属结果持顺其自然的心态。

(3) 放任的对象是可能发生的现实结果。如果在认识程度上是明知结果必然发生，则意志上不存在放任的间接故意，应认定为希望结果发生的直接故意。

(4) 在间接故意中，放任主要表现为以下三种情形：

① 行为人在追求某一非犯罪目的的同时，放任其行为可能引起的某一危害结果发生；如为防盗而私设电网且未采取任何避免措施，以致他人伤亡的案件。又如甲为打野兔而置正在附近采摘果实的某乙于不顾，开枪击中某乙致其死亡。

② 行为人在追求某一犯罪目的的同时，放任其行为可能引起的另一个危害结果发生；例如，某些盗窃公路上井盖的案件，行为人追求的是非法占有公私财物的目的，但对井盖被盗可能会发生的车辆或人员损伤的结果，就是一种放任的心态，其行为在可能构成盗窃罪的同时，也触犯了间接故意形式的以危险方法危害公共安全罪。

③ 在某些突发性犯罪中，行为人临时起意，不计后果，放任严重后果的发生。例如，某甲因违法犯罪被某乙当场抓获，为挣脱逃跑，某甲掏出匕首向某乙刺去，致某乙心脏被刺破伤重而死。

5 如何理解和把握犯罪过失中的“应当预见”？

答：犯罪过失指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见或已经预见但轻信能够避免，导致危害结果发生的一种心理态度。其中“应当预见”，是指行为人在行为时负有预见行为可能发生危害结果的义务，并且具有预见的能力。“应当预见”是“预见义务”和“预见能力”的统一。

(1) 预见义务，指行为人预测自己行为可能发生危害社会结果的责任。行为人缺乏预见义务，就无所谓疏忽大意的过失。预见义务的产生依据包括：

① 法律、法规、规章、制度等规定的注意义务，如《道路交通安全法》为保障交通安

全、避免交通事故而对有关主体设定的各种预见义务，以及航空、铁路、建筑、医疗等行业性法律及规章制度为相关从业人员规定的预见义务等。

② 社会共同生活准则，即习惯常理所要求的注意义务。

(2) 预见能力，是指行为人预见并避免其行为可能产生的危害结果的主观上的能力。

① 一方面，预见义务是针对一般人提出来的，一般理智正常的人能预见到的危害结果，理智正常的行为人在正常条件下也应当能预见到。

② 另一方面，判断行为人能否预见，不能脱离行为人的实际认识能力和行为时的具体条件。

(3) 在实践中具体把握行为人的预见能力时，既要充分考虑行为人本人的情况，又要仔细考察行为时的客观环境，把主客观因素结合起来考虑。有些行为人，按其本身的知识能力水平来说，能够预见危险程度高的行为可能发生危害结果，但不能预见危险程度低的行为可能发生危害结果；有些行为人，在一般条件下能够预见某种行为可能发生危害结果，但在某种特殊条件下，受客观环境的限制，就不能预见某种行为可能发生危害结果。对此，必须结合行为人自身的情况和案发时的具体环境和条件，综合分析认定。

6 如何处理事实认识错误？

答：事实认识错误，是指行为人对自己行为时的事实情况有不正确的理解。行为人对自已行为时的事实情况，尤其是对表明犯罪客观要件方面事实情况的认识错误，可能对其刑事责任发生影响。对事实认识错误的处理方法主要包括：

(1) 行为人对目标的认识错误。如果行为人对自己行为的社会危害性没有认识，则根据实际情况应当构成过失犯罪或者意外事件。

(2) 如果行为人对犯罪对象认识有错误，但是对犯罪客体认识没有错误，则对其刑事责任不发生任何影响。

(3) 如果行为人对犯罪对象认识有错误且对犯罪客体的种类认识有错误，则依行为人主观认识的客体种类定罪。

(4) 行为人对犯罪手段的认识错误，即行为人对其选择的犯罪手段的性质的认识错误。这种情况不影响罪过的成立。但是，危害结果没有发生的，行为人往往只负犯罪未遂的刑事责任。

(5) 行为人对因果关系的认识错误，即行为人对其所实施的行为和所造成的结果之间的因果关系的实际发展有错误认识，该种情况一般不影响对行为人刑事责任的认定。其中，对于犯罪结果的提前实现，即行为人所追求的犯罪结果提前于行为人的预想实现。处理标准在于行为人是否已经着手。如果已经着手，则认定为此罪的既遂。

(6) 行为人出现打击错误。

① 对于同一犯罪构成的错误，按照法定符合说，行为人对实际侵害对象成立犯罪既遂。

② 对于不同犯罪构成的错误，根据实际情况构成一罪或两罪的想象竞合，其中，对行为人实际侵害的对象成立过失犯罪，对行为人意欲侵害的对象成立犯罪未遂。

第九章 正当行为

1 如何看待预先安装防卫装置的行为？

答：（1）正当防卫的时间条件是不法侵害必须正在进行，即不法侵害处于已经开始并且尚未结束的进行阶段。刑法理论上将不符合正当防卫时间条件的防卫行为统称为“防卫不适时”。其中事前防卫是指不法侵害尚处于犯意表示阶段或者准备阶段，对于合法权益的威胁尚未达到现实状态时，行为人就对不法侵害人实施某种损害其权益的行为。行为人可以在正当防卫中做一些预防准备。如果行为人预见自己有被他人侵害的可能，可以适当地做一些预防准备，如预先安装防卫装置等。

（2）设立防卫装置后，如果遇到正在进行的不法侵害，该装置针对正在进行的不法侵害发挥作用，并且没有超过必要限度的，就应当认定为正当防卫。但是，预先安装防卫装置所造成的风险也应由安装者承担，例如防卫装置导致无辜者伤亡的，安装者应当承担相应的法律责任。

2 如何理解特殊防卫中“其他严重危及人身安全的暴力犯罪”的范围？

答：（1）鉴于严重危及人身安全的暴力犯罪的严重社会危害性，我国《刑法》第20条第3款明确规定，“对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。”对此规定，刑法理论通常将其称为特殊防卫，也有学者将其称为无限防卫或者无过当防卫。

（2）特殊防卫权的行使有严格的法律限制，必须具有明显的法定暴力性。“严重危及人身安全的暴力犯罪”不仅修饰“其他”行为，也修饰行凶、杀人、抢劫、强奸和绑架五种行为。亦即“行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架”与“其他”行为是一个整体，同时受到“严重危及人身安全”和“暴力”的限制。因此，对于那些采取隐蔽性、非暴力手段进行的杀人、抢劫、强奸、绑架等犯罪行为进行防卫，就不属于特殊防卫的范围，从而也就可能存在防卫过当的问题。例如，对以投毒方式杀人、以麻醉方式抢劫等行为，均不能实行特殊防卫。

（3）特殊防卫规定中的“其他严重危及人身安全的暴力犯罪”的范围，主要应从暴力犯罪的范围和程度两方面加以综合考量，即相关犯罪既要以暴力手段实施，同时又要达到严重危及人身安全的程度。例如，我国《刑法》第121条规定的劫持航空器罪等。

3 如何理解紧急避险中“另一较小合法权益”的定义？

答：（1）我国《刑法》第21条第1款规定：“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已采取的紧急避险行为，造成损害的，不负刑事责任。”紧急避险是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危害，不得已而采取的损害另一较小合法权益的行为。

（2）紧急避险的限度条件是避险行为不能超过必要限度，造成不应有的损害。通常认为，紧急避险的限度标准应当是紧急避险造成的损害必须小于所避免的损害。避险行为造成的损害大于或者等于所要保护的利益的属于避险过当，应负刑事责任。

（3）在司法实践中，如何衡量两个合法权益的大小是一个比较复杂的问题。一般而言，人身权利大于财产权利，财产权利的大小可以用财产的价值大小加以衡量。理论上一般认为，紧急避险不能以牺牲他人包括生命、健康在内的人身权利，来保全自己或者他人的合法权益。当然，这并非绝对的准则，如牺牲一个人的生命、健康而使很多人的生命、健康得到维护，能否认为是紧急避险，理论上就存在较大争议。在处理具体案件时，还应当具体情况具体分析。

4 如何看待安乐死中“权利人承诺”的问题？

答：由于我国《刑法》中没有明确规定排除积极实施“安乐死”行为的犯罪成立，因此，任何人实施“安乐死”的行为都仍然是构成犯罪的行为。

安乐死中的涉及“权利人承诺”问题，是指行为人经过有权处理某种权益的权利人同意后而实施的损害其本身利益的行为。这种情况下的行为虽然看上去符合犯罪的客观构成要件，但因排除犯罪性，不成立犯罪。通常认为，基于权利人承诺或自愿的损害需要具备以下条件：① 权利人必须有权处理其合法权益；② 权利人的同意必须是自愿的；③ 权利人的同意必须是合法的或者是合乎道德的；④ 权利人的同意必须是有益于社会的；⑤ 行为人实施的行为必须在权利人授权的范围内且没有超出必要限度。

依照我国法律规定，权利人是不能决定放弃自己的生命的，“安乐死”中的权利人的承诺行为是不符合法律规定的，也是不合乎道德的，因此不能成立“权利人承诺”，是构成犯罪的行为。当然，如果实施“安乐死”的行为人主观上出于善良的动机，在社会上亦未造成恶劣影响，在处罚时可以酌情从轻或者减轻处罚。

第十章 犯罪形态

1 故意犯罪停止形态与故意犯罪阶段有何联系与区别？

答：（1）故意犯罪停止形态与故意犯罪阶段的定义：

① 故意犯罪停止形态是指部分故意犯罪在实施过程中，由于主客观原因停止后所呈现的各种具体状态。

② 故意犯罪阶段是指故意犯罪发展过程中因主客观具体内容的不同而划分的段落。

（2）故意犯罪停止形态与故意犯罪阶段的联系：

故意犯罪的停止形态是在故意犯罪阶段中产生的，各种犯罪形态的产生及其界定，依赖犯罪过程和阶段的存在及其不同的发展程度。

通常来讲，犯罪人从产生犯意并形成犯罪决意、着手实行犯罪到最终完成故意犯罪存在一个过程。一个完整的犯罪过程，一般要经历预备犯罪、着手实行犯罪至最终完成犯罪这些步骤。但并不是所有故意犯罪活动都是完整的，许多犯罪会基于某些主客观原因而在完成以前就停止下来。换言之，故意犯罪在实施过程中会呈现出不同的结局，而故意犯罪这些表现各异的终局性状态就是故意犯罪的停止形态。它具体包括四种形式：犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止与犯罪既遂。犯罪预备形态仅仅出现在犯罪预备阶段；犯罪未遂形态只能出现在犯罪实行阶段；犯罪中止形态既可能出现在犯罪预备阶段，也可能出现在犯罪实行阶段；当某一故意犯罪处于完成状态时，则该犯罪表现为既遂形态。

（3）故意犯罪停止形态与故意犯罪阶段的区别：

① 故意犯罪的停止形态是故意犯罪已经停止下来的各种不同结局和形态，属于相对静止范畴的概念；故意犯罪阶段是故意犯罪发生、发展和完成的进程中划分的段落，是相继运动发展的概念。

② 就一个人实施某种犯罪的案件而言，他只能构成犯罪停止形态中的某一种犯罪形态，而不可能同时构成某种罪的两种以上的犯罪停止形态；而一个人实施某种具体犯罪案件时，完全可能同时具有两个犯罪阶段及完整的犯罪过程。

2 结果犯与行为犯在既遂形态上有何不同？

答：（1）结果犯与行为犯的定义：

① 结果犯是以法定的犯罪结果的发生与否作为既遂与未遂区别标志的犯罪。一般而言，成立结果犯的既遂形态不仅要实施符合具体构成要件的行为，而且必须发生法定的犯罪结果。所谓法定的犯罪结果，是指刑法分则所规定的、犯罪行为通过对犯罪对象的作用而给犯罪客体造成的物质性的、可以具体测量确定的损害结果。

② 行为犯是以法定的犯罪行为的完成作为既遂标志的犯罪。如《刑法》第108条规定的投敌叛变罪，只要行为人完成了投敌叛变行为，就成立本罪的既遂。

（2）结果犯与行为犯在既遂形态上的不同：

行为犯不要求造成物质性的和有形的犯罪结果，而是以行为的完成为标志，如《刑法》第108条规定的投敌叛变罪，只要行为人完成了投敌叛变行为，就成立本罪的既遂。但这些行为并非一着手即告完成，而是有一个实行的过程，要达到一定程度。如《刑法》第321条所规定的运送他人偷越国（边）境罪，并不是只要实施了运送行为就可以构成该罪的既遂，而是要求当运送他人非法出入国（边）境这个事实状态出现时，才能成立犯罪既遂。

法定的犯罪结果是否属于该罪的构成要件，是结果犯与行为犯在既遂形态上的不同。对于结果犯而言，法定的犯罪结果是成立该罪的必备构成要件。《刑法》第232条被认为是典型的结果犯的立法例，该条所规定的故意杀人罪的法定危害结果是物质性并可以具体测量确定的使他人死亡，因此，只有实际发生这种剥夺他人生命的结果才能成立故意杀人罪的既遂。

3 怎样区分犯罪预备形态与单纯犯意表示？如何理解预备犯的处罚原则？

答：（1）犯罪预备形态与单纯犯意表示的区别：

① 犯罪预备形态，是指为了实行犯罪而准备工具、制造条件，但基于行为人意志以外的原因而停止在犯罪预备阶段的形态。犯意表示是指行为人将自己的犯罪意图流露于外并为他人所知悉的行为。

② 行为方面的不同：犯罪预备是为实行犯罪而准备工具、制造条件，表现为一种主观影响客观世界的积极行为。而犯意表示只是以语言、文字等形式单纯流露其犯罪意图，它不是一种积极行为，而是表达行为人心理状态的一种活动。

③ 性质的不同：犯罪预备本身即独立地具有社会危害性，对刑法所保护的社会关系已经构成了现实的威胁。而犯意表示只能说明行为人有人身危险性或者犯罪的可能性，

不具有实际的社会危害性，没有对社会关系构成现实的威胁。

(2) 预备犯的处罚原则理解如下：

① 对于预备犯，我国刑法的立场是原则上应予以处罚。但是，如果从当时的实际情况看属于情节显著轻微危害不大的，也可以例外地不认为是犯罪。

② 在对预备犯裁量刑罚时，“可以”从轻、减轻处罚或者免除处罚。对预备犯在处罚时通常要从宽考虑，只有对准备实行性质特别严重的犯罪且手段特别恶劣的预备犯，才不予从宽处罚。

③ 对于预备犯的刑罚处罚应当“比照既遂犯”来裁量，并且比照的只能是同类型的既遂犯，即在性质、情节、危害程度等方面与预备犯向前发展可能形成的既遂犯相同或大体相同的既遂犯。

④ 对于预备犯，比照既遂犯“从轻、减轻处罚或者免除处罚”。至于实际上到底是选择从轻处罚，还是减轻处罚或者免除处罚，则应当综合考察犯罪预备行为的社会危害性程度以及行为人主观恶性大小等因素。

4 如何认定实行行为的“着手”？

答：（1）实行行为“着手”的认定理论界存在三种学说：

① 主观说认为，行为人意思的危险性被发现时就是着手实行。

② 客观说认为，是否属于实行行为的着手不应以行为人的主观思想为标准，而应以行为自身的客观性为标准。

③ 折中说认为，应以行为人的整体犯罪计划为基础，对构成要件的保护法益造成直接危险的行为明确地表示出行为人的意思时，就是实行的着手。

(2) 折中说较为合理，分三个层面进行认定：

① 在主观层面，行为人决意实施犯罪实行行为。

② 在客观层面，行为人所实施的行为是具备实现构成要件所要求的结果可能性的行为。

③ 在后果层面，行为人着手实行犯罪后，其行为对刑法所保护的客体具有现实的危害和威胁。

5 什么是不能犯未遂？对不能犯未遂应如何处理？

答：（1）不能犯未遂的概念：

① 不能犯未遂是指根据案件的具体事实，行为人所实施的行为本身就不可能达到既遂的情况。

② 不能犯未遂又可以分为对象不能犯未遂和工具不能犯未遂。对象不能犯未遂是指由于行为所指向的对象不在行为的有效作用范围之内，或者不具有特定犯罪对象的属性，从而使得犯罪不能既遂。工具不能犯未遂，是指行为人所使用的犯罪工具没有效果而使得犯罪不能既遂。

（2）不能犯未遂的处理：

① 对不能犯未遂的处理问题，我国刑法中没有具体规定，因此只能在理论上进行探讨。

② 理论认为，与普通犯未遂相比，不能犯未遂更加“安全”，从行为本身来看不存在产生社会危害或个人危害的可能性，因为在不能犯未遂的场合，行为人认识上的错误致使结果不可能发生。

③ 因此，在罪刑相匹配的前提下，应当适用较轻的刑罚，即适用比普通未遂更轻的处罚原则。

6 自动停止犯罪之后采取措施阻止危害结果出现，但是危害结果系基于其他原因而未发生的，应当认定为犯罪中止还是犯罪未遂？

答：（1）自动停止犯罪之后采取措施阻止危害结果出现，但是危害结果系基于其他原因而未发生的，是否成立犯罪中止，理论界存在两种学说：

① 否定说认为，在这样的情况下不能成立犯罪中止，而应认定为犯罪未遂。

② 肯定说认为，中止行为与结果没有发生之间不存在因果关系时，也成立犯罪中止，否则会造成刑罚的不均衡。

（2）否定说的见解更为恰当。因为只有有效地阻止了犯罪结果产生，才能表明行为社会危害程度的降低达到犯罪中止的程度；倘若中止行为与结果没有发生之间没有因果关系，根本不具备这种有效性，那么也就不符合犯罪中止的特征，而只能成立悔罪行为，在量刑时作为从宽情节考虑。

第十一章 共同犯罪

1 试述共同犯罪的概念和成立条件。

答：（1）共同犯罪的概念

根据我国刑法的规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，是故意犯罪的一种特殊形态，是相对于单个人故意犯罪而言的。它具有如下几个特点：

- ① 从形式上看，共同犯罪是二人以上共同实施的犯罪，具有两个以上的共同犯罪人。
- ② 从实质上看，共同犯罪的特殊性表现在它比单独犯罪具有更为严重的社会危害性。
- ③ 从法律规定上看，刑法分则除少数情况（必要共犯）外，对犯罪形态的规定，都是以单个人犯罪为标准的，亦即单个人犯罪形态为标准形态，因而共同犯罪这种特殊犯罪形态就有必要在刑法总则中加以规定。

（2）成立共同犯罪必须具备以下条件：

- ① 在主体方面，共同犯罪的主体必须是“二人以上”。二人以上，包括二人，但并无上限限制。这里的“人”，应作广义的理解，既包括自然人，也包括单位。就自然人而言，“人”一定是符合犯罪主体要件的人，即必须是达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人。
- ② 在主观方面，共同犯罪要求二人以上有“共同犯罪的故意”。所谓共同犯罪故意，是指各行为人通过意思的传递、反馈而形成的，明知自己是和他人配合共同实施犯罪，并且明知共同的犯罪行为会发生某种危害社会的结果，而希望或者放任这种危害结果发生的心理态度。
- ③ 在客观方面，共同犯罪必须有“共同的犯罪行为”。共同犯罪行为不仅指各共犯人都实施了同一犯罪构成要件行为，而且要求各共犯人的行为在共同故意支配下相互配合、相互协调、相互补充，形成一个整体。“共同行为”意味着各共犯人的行为都是共同犯罪行为这一整体的有机组成部分，在发生了危害结果的情况下，各共犯人的行为作为一个整体与危害结果之间具有因果关系。

2 犯罪集团成立的条件如何？

答：犯罪集团是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。成立犯罪

集团的条件包括如下几个方面：

(1) 组成人员的数量必须在三人以上。三人为众，刑法把三人作为构成犯罪集团的底数，这也是犯罪集团不同于一般共同犯罪的特点。司法实践中，犯罪集团在成员人数上多数都不止三人，有的达到数十、数百甚至上千人。二人共同犯罪的，即使在其他特征上与犯罪集团相似，也不能称为犯罪集团。

(2) 具有共同实施犯罪的目的性。这是犯罪集团在主观方面的重要特征，也是它与基于低级趣味或封建习俗而形成的落后组织，以及其他非法组织相区别的重要标志。犯罪集团在主观上是为了共同实施某种犯罪或某几种犯罪而组织起来的，具有鲜明的犯罪目的性。犯罪集团在主观上所具有的犯罪目的性，可以通过集团成员之间口头或者书面约定，也可以通过共同犯罪活动而逐渐形成，并不要求必须有书面的犯罪纲领，也不要求在实际上反复多次实施了某种或某几种犯罪。

(3) 具有较强的组织性。这是犯罪集团的组织特征，它表现为，犯罪集团成员相对固定，内部之间具有领导与被领导的关系，其中有首要分子，有骨干分子，有一般成员，首要分子组织、领导、指挥其他成员进行集团犯罪活动。

(4) 具有相当的稳固性。犯罪集团是三人以上为实施某种或者某几种犯罪而联合或组织起来的，其组织机构和活动计划都是出于长远的考虑，而不是为了实施一次犯罪而临时结伙，在实施一次犯罪之后，该组织或联合体仍继续存在。所以，只要各共同犯罪人是为了实施多次或者不定次数犯罪而联合起来的，即使他们只实施了一次犯罪或根本没有来得及实施任何犯罪，也不影响犯罪集团的成立。

3 试述主犯的概念、种类和刑事责任。

答：(1) 主犯的概念

主犯是指组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。

(2) 主犯的种类

① 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，亦即犯罪集团的首要分子。这种主犯具有以下两个特征：一是以犯罪集团的存在为前提条件；二是必须是组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子。

② 在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。这种主犯是指犯罪集团首要分子以外的在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。包括：

- a. 在犯罪集团中虽不起组织、指挥作用，但是积极参与犯罪集团的犯罪活动的人，即犯罪集团的骨干分子。
- b. 聚众共同犯罪中的首要分子或其他在聚众共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。
- c. 在聚众共同犯罪以外的一般共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。

(3) 主犯的刑事责任

① 对于犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；但如果犯罪集团成员实行过限、超出集团犯罪故意的范围，对于过限行为不应令首要分子对其承担刑事责任，而只能令实行犯本人负责。

② 对于其他主犯，应按照其所参加的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

4 简述从犯的概念、种类和刑事责任。

答：（1）从犯的概念

从犯是指在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的犯罪分子。

(2) 从犯的种类

① 在共同犯罪中起次要作用的犯罪分子，即次要的实行犯。这种从犯直接实施了具体犯罪构成客观要件的行为，但在整个犯罪活动过程中较之主犯所起的作用小。

② 在共同犯罪中起辅助作用的犯罪分子，即帮助犯。这种从犯不直接实施具体犯罪构成客观要件的行为，而是为共同犯罪的实施创造条件，辅助实行犯罪。

(3) 从犯的刑事责任

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。在具体案件中，对从犯是从轻处罚，还是减轻处罚，抑或是免除处罚，应综合考察共同犯罪的性质、从犯行为对犯罪结果产生的作用的大小等方面的情况。

5 试述教唆犯的概念、特征、成立条件和刑事责任。

答：（1）教唆犯的概念

教唆犯就是故意唆使他人犯罪的犯罪分子。

(2) 教唆犯的特征

教唆犯的基本特点是：本人不亲自实行犯罪，而故意唆使他人产生犯罪决意并实行犯罪。

(3) 教唆犯的成立条件

成立教唆犯必须具备以下条件：

① 客观上具有教唆他人犯罪的行为。即用授意、劝说、请求、命令、挑拨、刺激、收买、引诱等方法，唆使他人去实行某一具体犯罪。教唆的对象是本无犯罪意图的人，或者虽有犯罪意图，但犯罪意志尚不坚决的人。教唆的方式必须是作为的，不作为行为不可能成立教唆犯。

② 主观上具有教唆他人犯罪的故意。故意的内容包括：认识到他人尚无犯罪决意，预见到自己的教唆行为将引起被教唆者产生犯罪决意，而希望或者放任教唆行为所产生的结果。

(4) 教唆犯的刑事责任

对教唆犯应按如下原则处罚：

① 教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。这是指被教唆者已经犯了所教唆的罪的情况。已犯了所教唆的罪，是指被教唆者在教唆人的教唆下，实施了所教唆的罪的预备行为或者已经着手实行所教唆的犯罪而既遂，或者已经完成所教唆的犯罪而既遂。按照在共同犯罪中所起的作用处罚，是指根据教唆犯在共同犯罪中实际所起的不同作用分别处罚。

② 教唆不满18周岁的人犯罪的，应当从重处罚。此外，如教唆不满14周岁的人实施犯罪或教唆已满14周岁不满16周岁的人实施《刑法》第17条规定的8种犯罪以外的犯罪，对教唆人应以间接正犯论处。

③ 如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯可以从轻或者减轻处罚。

第十二章 罪 数

1 罪数的区分标准是什么？

答：罪数的区分标准在刑法理论中是一个非常复杂的问题，颇具争议。在中外刑法理论界，关于判断一罪与数罪的标准，存在多种学说：（1）行为标准说；（2）法益标准说（又称结果标准说）；（3）因果关系标准说；（4）犯意标准说；（5）目的标准说；（6）法规标准说；（7）构成要件标准说；（8）广义法律要件说；（9）折中主义标准说；（10）混合标准说等。所有这些判断罪数的观点，存在着一个共同的缺陷，即仅以犯罪构成要件的某一要素或某一方面为标准区分罪数，故其实际均未超出客观主义或主观主义的局限。运用这些以偏概全的标准，无法对罪数问题作出合理的解释。

我国的刑法学以马克思辩证唯物主义为指导思想，在全面剖析国外学者关于罪数标准学说的优劣利弊，吸收某些学说的合理成分的基础上，公认以犯罪构成标准说（主客观统一说）作为区分一罪与数罪的基本理论。我国刑法学中的犯罪构成标准说，与前述构成要件标准说、混合标准说、折中主义标准说具有本质的差别。因为，后者或者属于客观主义的罪数判断标准理论，或者是将客观主义和主观主义的罪数判断理论杂乱、无序地堆砌在一起，仍然无助于科学地区分一罪与数罪。根据犯罪构成标准说的主张，确定或区分罪数之单复的标准，应是犯罪构成的个数，即行为人的犯罪事实具备一个犯罪构成的为一罪，具备数个犯罪构成的为数罪。坚持犯罪构成标准说，不仅为司法实务准确区分一罪与数罪提供了可行和科学的标准，而且有助于罪数理论的深入研究和发

2 如何区分想象竞合犯与法条竞合？

答：想象竞合犯，又称想象数罪，是指行为人基于数个不同的具体罪过，实施一个危害行为，而触犯两个以上异种罪名的犯罪形态。法规竞合又称法条竞合，通常是指一种犯罪行为因刑事立法对法条的错综规定，导致数个法条规定的犯罪构成要件在内容上发生重合或交叉的情形。

想象竞合犯与法条竞合具有以下区别：

（1）想象竞合犯是犯罪行为或不同罪名的竞合，属于罪数形态；法规竞合是法律条文的竞合，属于法条形态。

(2) 想象竞合犯所触犯的规定不同种罪名的数个法条之间，不存在重合或交叉关系；法规竞合所涉及的规定不同种罪名的数个法条之间，必然存在重合或交叉关系。

(3) 想象竞合犯以行为人实施特定的犯罪行为为前提或中介；法规竞合所涉及的规定不同种罪名的数个法条之间的重合或交叉关系，并不以犯罪行为实际发生为转移。

(4) 想象竞合犯是数个法条均应适用于导致不同罪名竞合的犯罪行为，且应择一重者处之；法规竞合是在数个法条中只能选择适用一个法条而排斥其他相竞合的法条的适用。

(5) 想象竞合犯是在数个不同的具体罪过支配下实施一个危害行为；法规竞合是在一个具体罪过的支配下实施一个危害行为。

(6) 想象竞合犯所实施的犯罪行为，同时直接作用于体现不同直接客体的数个犯罪对象；法规竞合的犯罪行为，仅直接作用于体现一个直接客体的单一犯罪对象。

3 结果加重犯的成立条件是什么？

答：结果加重犯，又称加重结果犯，是指实施基本犯罪构成要件的行为，由于发生了刑法规定的基本犯罪构成要件以外的重结果，刑法对其规定加重法定刑的犯罪形态。结果加重犯的成立条件如下：

(1) 行为人所实施的基本犯罪构成要件的行为必须客观地引发了基本犯罪构成要件以外的重结果，即符合基本犯罪构成要件的行为与加重结果之间具有因果联系。

(2) 基本犯罪构成要件以外的重结果或者加重结果，必须通过刑法明文规定的方式，成为依附于基本犯罪构成要件而存在的特定犯罪的有机组成部分。即基本犯罪构成要件是成立结果加重犯的前提和基础，加重结果不能离开基本犯罪构成要件而独立存在。加重结果的这种法定性和非独立性的特征，是认定结果加重犯并将它与其他罪数形态相区别的重要标准。

(3) 行为人对所实施的基本犯罪构成要件的行为及其所引起的加重结果均有犯意。结果加重犯的罪过形式可以划分为三种类型：一是基本犯基于故意，对加重结果也基于故意；二是基本犯基于故意，对加重结果则基于过失；三是基本犯基于过失，对加重结果也基于过失。

4 如何区分牵连犯与吸收犯？

答：牵连犯，是指行为人实施某种犯罪（即本罪），而方法行为或结果行为又触犯其他罪名（即他罪）的犯罪形态。吸收犯是指，行为人实施数个犯罪行为，其中一个不具有独立性的犯罪，被另一个具有独立性的犯罪所吸收，对行为人仅以吸收之罪论处，而对被吸收之罪则置之不论的犯罪形态。

牵连犯与吸收犯具有以下区别：

（1）主观方面的差别。吸收犯必须基于一个犯意，为了实现一个具体的犯罪目的而实施数个犯罪行为。牵连犯是在一个犯罪目的的制约下，形成了与牵连犯罪的目的行为、方法行为、结果行为相对应的数个犯罪故意。

（2）数个犯罪行为的特定联系的形成机制不同。吸收犯的形成机制以刑事法律规定的犯罪构成之间的特定关联性为条件。牵连犯的形成机制并不以刑事法律规定的犯罪构成之间的特定关联性为条件。

（3）触犯罪名的性质不同。构成吸收犯的数个犯罪行为所触犯的罪名必须是一致的；构成牵连犯的数个犯罪行为所触犯的罪名必须是不同的。

（4）侵犯的客体和作用的对象不同。构成吸收犯的数个犯罪行为必须侵犯同一或相同的直接客体，并且指向同一的具体犯罪对象；构成牵连犯的数个犯罪行为侵犯的直接客体必然是不同的，也不必作用于同一的具体犯罪对象。

（5）处断原则的差别。吸收犯的处断原则是仅以吸收之罪论处，对被吸收之罪则置之不论；牵连犯的处断原则一般为从一重处断，即按重的罪从重处罚。

第十三章 刑事责任

1 刑事责任有哪些特征？

答：刑事责任是犯罪人因实施犯罪行为而应当承担的法律责任。有以下七项特征：

(1) 规范形式上的法定性。这是第一位的特征，具体有以下几点含义：

① 法定性是指狭义上的法定性。罪刑法定原则要求刑法必须事先明确具体地规定行为人对其行为是否应负刑事责任、负何种程度的刑事责任以及如何负刑事责任。

② 司法机关追究犯罪人的刑事责任，必须严格依照刑法的规定以及刑事诉讼程序进行。

③ 刑事责任的规范形式和法律渊源处于狭义的法律高度，而其他具体的法律责任未达到此高度。

(2) 规范内容上的特定性。这是本质特征，是刑事责任和其他法律责任的区别所在。即以刑法规定的刑罚处罚、非刑罚处罚措施或者单纯有罪宣告之否定评价为具体内容。

(3) 承担方式上的严厉性。即刑事责任是最为严厉的法律后果，刑事责任的严厉性主要体现在其实现方式上，而作为刑事责任的主要实现方式的刑罚可以做到以下三点：

① 剥夺犯罪人的财产或政治权利。

② 限制乃至剥夺犯罪人的自由。

③ 剥夺犯罪者的生命。

(4) 责任追究上的强制性。即刑事责任不以个人的意志为转移，犯罪人愿不愿意承担以及被害人愿不愿意追究犯罪者的刑事责任均不影响对刑事责任的追究（极少数告诉的才处理的犯罪除外）。

(5) 承担主体上的专属性。这是基本特征。即指刑事责任是严格的个人责任，应当坚持罪责自负原则，只能由实施违反刑事法律行为的人即犯罪者本人承担。

(6) 观念范畴上的中介性。即刑事责任是犯罪与刑罚处罚以及与非刑罚处罚措施和单纯有罪宣告的中介或纽带。现代刑法除了惩治犯罪，还关注犯罪人的人身危险性或再犯可能性，规定了刑罚之外的处置方式，在此犯罪和刑罚不再是唯一的对应关系，于

是刑事责任就起到了中介作用。

(7) 评价内容上的统一性。即刑事责任既体现了对犯罪人所实施犯罪社会危害性的回顾性判断，也反映了对犯罪人未来再次实施犯罪危险的展望性预判，是一种综合了回顾与展望的评价。

2 如何理解刑事责任与犯罪、刑罚之间的关系？

答：刑事责任是与犯罪和刑罚相互并列、彼此联系但意义有所不同的一个范畴。可从刑事立法和刑事司法两个角度来分别对刑事责任与犯罪和刑罚的关系进行理解。

(1) 刑事立法角度

刑事责任是第一位的，首先形成刑事责任观念，然后立法者在此观念指导下制定刑法，规定犯罪与刑罚。具体来说，立法者要设定犯罪与刑罚，首先要形成一定的刑事责任观，进而在此观念指导下确立其犯罪观和刑罚观，然后通过制定刑法对那些其认为严重危害社会需要追究刑事责任的行为，按照确定刑事责任的要求宣布为犯罪，并规定具体的犯罪构成要件。

(2) 刑事司法角度

犯罪引起刑事责任，刑事责任直接决定刑罚处罚。犯罪具有刑事责任前提的意义，犯罪的存在与否决定着刑事责任的存在与否，犯罪的危害程度决定着刑事责任的轻重程度。刑事责任是刑罚适用的内在根据，刑事责任程度直接决定着刑罚的分量，刑事责任重则刑罚重，刑事责任轻则刑罚轻。罪责刑三者是相适应的。

3 如何理解刑事责任的根据？

答：刑事责任的根据是指国家基于何种原因追究犯罪人的刑事责任，犯罪人基于何种原因承担刑事责任。包括刑事责任的哲学根据、法律根据和事实根据。

(1) 刑事责任的哲学根据

即是指实施犯罪时犯罪人所具有的相对意志自由。在坚持辩证唯物主义立场的前提下探讨刑事责任的哲学根据，人们实施何种行为，在一定限度内有相对的意志自由，这种相对的意志自由使得国家能够要求人们按照一定的社会标准选择和决定自己的行动，并且依据人们所选择实施的行为是否符合该社会标准来给予肯定或者否定的评价。

(2) 刑事责任的法律根据

刑事责任的法律根据分为主要法律根据和重要法律根据。

① 刑事责任的主要法律根据是指刑法规定的犯罪构成，符合犯罪构成的内容又包括以下三点：第一，行为人实施了某种行为；第二，该行为具有社会危害性；第三，行为符合刑法规定的犯罪构成。由于作为犯罪构成要件的都是因决定行为的社会危害性质及程度而为该行为成立犯罪所必需的事实特征，所以犯罪构成在决定刑事责任程度方面具有不可替代的基础性作用。

② 刑事责任的重要法律根据，具体是指刑罚裁量情节和刑罚执行制度。

(3) 刑事责任的事实根据

刑事责任的事实根据包括符合犯罪构成的事实和符合犯罪构成之外的事实。

① 符合犯罪构成的事实是决定刑事责任存在与否的唯一事实根据，同时也是决定刑事责任程度的事实基础。

② 符合犯罪构成之外的事实包括犯罪主观方面、犯罪客观方面、犯罪主体等方面的事实，这些事实也就是法律规定的法定量刑情节和酌定量刑情节，符合犯罪构成之外的事实反映了行为社会危害性程度以及犯罪人人身危险性程度，具有从重、从轻、减轻或者免除处罚的作用。

4 刑事责任的解决方式有哪些？

答：刑事责任的解决方式分为刑事责任的实现方式和刑事责任的其他解决方式。

(1) 刑事责任的实现方式

① 定罪判刑，是指人民法院对犯罪人作出有罪宣告并给予某种刑罚处罚。

② 定罪免刑，是指人民法院在判决文书中确定行为人的行为构成犯罪但最终决定不予以刑罚处罚。定罪免刑又分以下两种情况：

a. 非刑罚处置措施，即《刑法》第37条：“对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，免于刑罚处罚，但是依据案件的不同情况分别予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或行政处分。”

b. 仅作出有罪的宣告，具体有六种情形，第一，对外国刑事判决的消极承认，即域外犯罪，虽经外国审判并已在外国受过刑罚处罚，但仍可依照中国《刑法》追究的；第

二，免除处罚的又聋又哑的人或者盲人犯罪的；第三，防卫过当，随负刑事责任，但应当免除处罚的；第四，紧急避险超过必要限度造成不应有的损害，虽负刑事责任，但应当免除处罚的；第五，予以免除处罚的预备犯；第六，予以免除处罚的胁从犯。

③ 除外情形。还有三种情形不是刑事责任的实现方式，具体指酌定不起诉、人民检察院对未成年犯罪嫌疑人的附条件不起诉以及非刑罚处罚措施之外的强制措施。

(2) 刑事责任的其他解决方式

① 消灭处理，是指因存在法定的阻却刑事责任追究的事实而使本应承担的刑事责任归于消灭。例如：犯罪已过追诉时效、酌定不起诉、附条件不起诉等。因为刑事责任已经归于消灭，所以司法机关不能再追究刑事责任，犯罪人也无须承担刑事责任。

② 转移处理，即《刑法》第11条规定的“享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任，通过外交途径解决”。因为部分外国人享有外交特权和豁免权，所以追究这部分人的刑事责任需要通过外交途径解决，而不是由司法机关适用中国刑法进行追责。

第十四章 刑罚及其种类

1 如何认识刑罚的特征？

答：（1）刑罚是指刑法所规定的由国家审判机关对犯罪人所适用的限制或剥夺其某种权益的强制性制裁方法。

（2）刑罚具有以下几个特征：

① 由国家最高权力机关在刑法中制定。我国宪法规定，只有全国人民代表大会及其常委会才有权制定或补充、修改刑法和其中的刑罚，其他国家机关如国务院及其各部委、地方人民代表大会及其常委会等，均不能制定、修改刑法及其中的刑罚。

② 刑罚性质严厉。刑罚是用以惩罚犯罪的，而犯罪行为的社会危害程度重于其他违法行为，因此刑罚是最严厉的强制方法。

③ 仅对犯罪人适用。刑罚因犯罪而生，以犯罪为前提，所以受刑罚处罚的只能是实施了犯罪行为的人，对于无罪的人绝对不能适用刑罚。

④ 由人民法院依法科处。刑罚只能由人民法院适用，其他任何机关都无权适用。

⑤ 由特定机关执行。根据刑法和刑事诉讼法的规定，死刑、罚金和没收财产由人民法院执行，无期徒刑和有期徒刑由监狱或其他劳改场所执行，管制由负责社区矫正的司法行政机关执行，拘役和剥夺政治权利由公安机关执行。这也是刑罚与其他强制方法相区别的标志。

2 如何理解刑罚的目的？

答：刑罚目的是国家司法机关通过对犯罪分子适用刑罚所希望达到的目标。我国通说为预防说，即预防犯罪。刑罚目的所预防的“犯罪”，包括已然之罪和未然之罪。由于预防的对象有所不同，故将刑罚的目的划分为特殊预防和一般预防两个方面。

（1）特殊预防，是指通过对犯罪分子适用刑罚进行教育改造，预防他们重新犯罪。特殊预防是通过剥夺犯罪分子再次犯罪的能力，使之不再危害社会以及改造和教育犯罪分子，使其弃恶扬善，不敢或者不愿再进行犯罪活动来实现的。

（2）一般预防，是指通过对犯罪分子适用刑罚，威慑、警诫潜在的犯罪者，防止他们走上犯罪道路。我国刑罚一般预防的对象只限于潜在的犯罪人。一般预防是通过刑罚

的威慑、警诫功能表现出来的，主要表现为如下三种方式：一是通过制定、适用和执行刑罚，威慑社会上的危险分子和不稳定分子，抑制他们的犯罪意念，使他们不敢以身试法；二是通过制定、适用和执行刑罚，表明国家对犯罪的不能容忍，安抚被害人及其家属，以防止报复性犯罪活动的发生；三是通过制定、适用和执行刑罚，提高广大公民的法治观念，鼓励他们积极地同犯罪作斗争。

3 如何理解刑罚的功能？

答：刑罚的功能，是指国家正确制定、裁量和执行刑罚对社会个体以及整体所产生和可能产生的积极作用。国家创制、适用和执行刑罚的活动，对不同的对象会产生不同的功效与作用。根据功效、作用和对象范围的不同，刑罚的功能可从三个方向理解：

(1) 对犯罪人的功能。包括惩罚和改造功能。惩罚是刑罚的本质，也是刑罚的基本功能。在刑罚执行过程中，注重对犯罪人进行感化教育，使其洗心革面，痛改前非，成为遵纪守法、自食其力的公民。

(2) 对被害人的安抚功能。及时地对犯罪人施以应有的惩罚，不仅能够抚慰被害人受伤的心灵，还能满足被害人及其亲属本能的复仇需要，平息其愤怒和仇恨，避免私力报复，增进其安全感，恢复其心理平衡。

(3) 对社会的威慑和教育鼓励功能。刑罚不仅能够使受惩罚的犯罪分子感到痛苦，而且能够震慑、威吓意图实施犯罪的人，使他们不敢以身试法。此外，对犯罪分子适用刑罚，具有提高公民的法律意识和法治观念，教育公民自觉遵纪守法，积极维护法制，鼓励公民坚决同犯罪进行斗争的作用。

4 如何认识我国刑罚体系的特点？

答：(1) 刑罚体系，是指刑事立法者从有利于发挥刑罚的功能和实现刑罚的目的出发，选择一定的惩罚方法作为刑罚方法并加以归类，由刑法依照一定的标准对各种刑罚方法进行排列而形成的刑罚序列。我国刑罚体系由主刑和附加刑两类九种刑罚方法组成。主刑由轻到重依次包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑五种刑罚，附加刑包括罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境四种刑罚。

(2) 我国刑罚体系具有以下几个特点：

① 要素齐备，结构合理。我国具备不同的刑种，对受刑人所造成的剥夺性痛苦不同，可以适用于不同的犯罪和不同的犯罪人，这就使刑罚体系的构成要素臻于全面。

② 宽严相济、衔接紧凑。构成我国刑罚体系的刑种，无论主刑还是附加刑，都有轻有重。如主刑既有属于轻刑的管制和拘役，也有较重的有期徒刑和无期徒刑，更有最重的死刑。附加刑的各个刑种也是轻重有别。这表明我国刑罚体系具有宽严相济的特点。

③ 内容合理、方法人道。我国刑罚体系的内容立足于我国的实际情况，反映了我国长期以来同犯罪作斗争的成功经验，各种刑罚既有惩罚的一面，也有教育的一面。另外，我国刑罚体系中的各种刑罚方法，虽具有造成犯罪人一定痛苦的属性，但不具有残虐性。除死刑立即执行外，其他的刑种都强调对犯罪人的教育与改造。因此，我国刑罚方法又具有人道性。

5 如何认识死刑的存废之争？

答：（1）死刑，是指剥夺犯罪人生命的刑罚方法，包括立即执行与缓期二年执行两种。由于死刑的内容是剥夺犯罪分子的生命，因而又被称为“生命刑”；由于生命具有最宝贵的、剥夺之后不能恢复的价值，因此，死刑是刑法体系中最为严厉的刑罚方法，也被称为“极刑”。

（2）废除死刑是刑事立法发展的大趋势，但是我国目前还不能废除死刑。有以下几点原因：

① 我国同犯罪作斗争的形势依然严峻，一些地方的社会治安状况不好，杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危害社会治安的犯罪行为依然时有发生，贪污腐败现象仍然比较严重。运用死刑可以惩治极少数罪行极其严重并且非杀不可的犯罪分子。

② “杀人偿命”等传统观念在一些人的头脑中仍然根深蒂固，有相当多的人认为死刑是震慑犯罪的最有效的方法。在这种情况下如果废除死刑，不但会导致社会治安状况恶化，而且也不会得到广大人民群众的支持。

③ 我们应当坚持少杀的方针，确保死刑只适用于罪行极其严重非杀不可的犯罪分子，同时应当采取有效措施防止冤案错案的发生。根据这一指导思想，现行立法从以下几个方面规定了死刑的适用：

a. 坚持罪刑法定原则。即刑法分则明确规定死刑的犯罪，可以适用死刑；刑法分则未明确规定死刑的犯罪，不得适用死刑。

b. 正确理解死刑的精神。刑法虽然对有些犯罪规定了死刑，但是绝不意味着有死刑的犯罪都应当适用死刑。这是因为：

从刑法分则的规定看：刑法分则对有些犯罪的死刑的适用规定得比较具体，如贪污罪，必须是贪污数额在十万元以上并且情节严重的，才能适用死刑。此外，除个别条款外，死刑总是和无期徒刑等刑罚一道，组成一个量刑的幅度，如故意杀人罪，根据《刑法》第二百三十二条的规定，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。

从刑法总则的规定看：根据《刑法》第四十八条第一款的规定，死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是需要立即执行的，可以在判处死刑同时宣告缓期二年自执行。

c. 根据《刑法》第四十九条的规定，对于犯罪的时候不满十八周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑。

d. 不得违反法定程序适用死刑。这应当从以下两个方面来理解：关于死刑的审判管辖权。根据《刑事诉讼法》第十九条至第二十二的规定，死刑只能由中级人民法院（含中级人民法院）管辖一审。关于死刑核准权。根据《刑法》第四十八条第二款、《刑事诉讼法》第一百九十九条和《人民法院组织法》的规定，死刑除最高人民法院的判决外，都应当报请最高人民法院核准。死刑缓期二年执行的案件，应当报请高级人民法院核准。

6 怎样理解从业禁止的性质？

答：（1）从业禁止，是指对于实施了与职业相关犯罪的犯罪分子，限制其在特定时间段内从事相关职业的资格。

（2）关于从业禁止的性质，理论上存在争议。可以肯定的是，它不是一种刑罚，也不是一种行政处罚，而是由刑法规定并由人民法院裁决的预防性的法律措施。其目的主要是防止犯罪分子再次利用职业之便进行犯罪，与《刑法》第38条第2款规定的禁止令制度，即“判处管制，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人”的规定有相似之处。依照《刑法》第37条之一的规定，从业禁止制度包含以下内容：

① “因利用职业便利实施犯罪，或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚”，这是适用该制度的前提。所谓职业，就是个人在社会中所从事的作为主要生活来源的工作，如法官、教师、律师、医生、导游、会计等。现代社会中，由于社会分工不断细化，每一种职业均有其专业知识和技能乃至伦理的要求。

② 法院“可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要”而定，这是适用该制度的关键。

③ “禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业，期限为三年至五年”，这是该制度的主要内容。

④ 违反从业禁止规定的，必须承担一定的法律后果。即被禁止从事相关职业的人违反人民法院作出的从业禁止决定的，由公安机关依法给予处罚；情节严重的，依照《刑法》第313条规定的拒不执行判决、裁定罪定罪处罚。

第十五章 刑罚制度

1 在对犯罪分子裁量刑罚时，对于社会危害程度的判断是否要考虑社会治安形势等因素？

答：在对犯罪分子裁量刑罚时，对于社会危害程度的判断需要考虑社会治安形势等因素。

刑罚裁量，又称量刑，是指人民法院在依法认定行为人的行为构成犯罪的基础上，依据行为人的犯罪事实、各种量刑情节与规则，依法决定对行为人是否判处刑罚、判处什么刑罚以及如何执行刑罚的刑事审判活动。刑罚裁量的原则属于罪刑法定等刑法基本原则下位的刑事司法原则，是指由刑法明文规定的、贯穿于全部量刑活动并对量刑工作具有指导意义和制约作用的法律准则，具体规定于我国《刑法》第61条。该条规定：“对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。”

量刑需要“以案件事实为依据”，即确定犯罪分子应判处的刑罚，应当根据与案件相关的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。“对于社会的危害程度”是指对于行为人实施犯罪行为之危害社会程度的评价或判断，评价的依据是行为人实施犯罪的事实、犯罪的性质以及案件中具有的各种影响行为危害社会程度的情节。对于发生在不同时间或地点的同一行为，往往会根据其案件事实作出不同的处理，这也正说明了社会治安形势是定罪量刑的重要根据。

【说明】对于社会危害程度的判断是否需要考虑社会治安形势等因素，关于这个问题在刑法学界一直存在争议，答题时言之有理即可。也有观点认为社会治安形势本身不是量刑的根据，量刑的根据应当是犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等。不过在评定行为的社会危害程度时要适当考虑“形势”的因素，如平时与战时，治安秩序良好与混乱等。

2 为什么要设立特别累犯制度？

答：特别累犯是前后罪均为特定性质或种类的犯罪而构成的累犯。我国刑法总则规定了危害国家安全罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪特别累犯。设立特别累犯制度的原因主要可以从以下几个方面考虑。

(1) 设立特别累犯制度符合惩治严重犯罪的实际需要。危害国家安全罪、恐怖活动犯

罪以及黑社会性质的组织犯罪对我国造成了严重的现实威胁和长期的潜在威胁，严重威胁国家安全、社会稳定和人民群众的生命财产安全，危害国际社会的和平与安全。针对这三类罪行设立特别累犯制度，符合我国的实际需要，表明我国对该类犯罪防范和惩治的立场。

(2) 这符合累犯制度的设立目的。累犯主要针对主观恶性深、人身危险性大的再犯人，通过严厉的法律后果予以打击，并预防其再次犯罪和初犯者变成累犯。从客观上看，危害国家安全罪、恐怖活动犯罪和黑社会性质组织犯罪均具有较强的社会危害性、隐蔽性和较高的再犯率。从主观上看，这三类犯罪的犯罪人具有较强的主观恶性。因此，针对这三种罪行，应当适用更严厉的法律制裁措施，实现特殊预防和一般预防的目的，故而设立特别累犯制度。

3 成立自首和坦白是否以犯罪嫌疑人接受国家审查和裁判为条件？

答：成立自首和坦白需要以犯罪嫌疑人接受国家审查和裁判为条件，具体分析如下：

自首是指犯罪嫌疑人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，或者被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为。自首是犯罪嫌疑人出于自己的意志而主动将自己交付国家追诉，表现出犯罪嫌疑人所具有的接受国家审查和裁判的自觉性，进而体现出一定的认罪或悔罪态度以及其人身危险性已经在一定程度上得到减弱。以一般自首为例，犯罪嫌疑人必须自动投案。“投案”应当既包括犯罪嫌疑人向有关机关或者个人承认自己实施了特定的犯罪，也包括将自己置于有关机关或个人的控制之下，等待国家司法机关的审查和裁判。如果犯罪嫌疑人虽然向有关机关或者个人承认自己实施了特定犯罪，但不愿意将自己置于有关机关或个人的控制之下，从而接受国家司法机关的审查和裁判的，那么将这种情况认定为自首，就违背了刑法设立自首制度的宗旨。根据有关司法解释的规定，犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。

坦白是指犯罪嫌疑人在被动归案之后、被依法提起公诉之前，如实供述自己罪行的行为。犯罪嫌疑人如实供述自己犯罪的行为是基于几首国家审查和裁判的。如果犯罪嫌疑人被动到案后，如实供述后又翻供，这反映了犯罪嫌疑人拒绝接受国家的审查和裁判，该种情况依法不应当认定为坦白。

4 “先并后减”和“先减后并”有何区别？二者各具有什么功能？

答：“先并后减”是《刑法》第70条规定的并罚方式，先把前后两个判决所判处的刑罚按照《刑法》第69条的规定决定应执行的刑罚，如果应执行的刑罚是有期徒刑，则

应该把先前已经执行的刑期从并罚后确定执行的刑期中减去。

“先减后并”是《刑法》第71条规定的并罚方式，先从前罪应执行的刑罚中减去已经执行的刑期，再按照《刑法》第69条的规定，将前罪未执行的刑罚与后罪所判处的刑罚实行并罚。

“先并后减”与“先减后并”的刑罚计算方法具有明显的区别，主要表现在：

(1) 两者适用的对象不同。“先并后减”的刑罚计算方法适用于刑罚执行完毕以前发现漏罪的情况，“先减后并”的刑罚计算方法只适用于判决宣告后又犯新罪的情况。

(2) 两者的计算基础不同。“先并后减”的方法，是以前罪所判处刑罚及漏罪所判处刑罚作为决定刑罚的基础，已执行的刑期应当计算在新判决决定的刑期以内。“先减后并”的方法则是以前罪尚未执行的刑罚与新犯之罪所判处的刑罚作为决定刑罚的基础，已执行的刑期不再计算在新判决决定的刑期以内。

针对新罪的“先减后并”与发现漏罪的“先并后减”相比，可能会使犯罪分子受到更严厉的刑罚制裁。这符合主客观相统一的刑罚原则：判决宣告以后刑罚执行完毕以前正在服刑的犯罪分子又犯新罪，说明其在客观上具有严重的社会危害性，在主观上具有严重的人身危险性，而不交代判决宣告以前其他罪行的犯罪分子，尽管悔过不深，但不具有严重的、现实的社会危害性和人身危险性。因此，再犯新罪者比不交代漏罪者会受到更长刑期的实际执行。

5 从严掌握减刑、假释标准的规定有哪些？为什么？

答：(1) 从严掌握减刑标准的规定有：

① 对符合减刑条件的职务犯罪罪犯，破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪罪犯，组织、领导、参加、包庇、纵容黑社会性质组织犯罪罪犯，危害国家安全犯罪罪犯，恐怖活动犯罪罪犯，毒品犯罪集团的首要分子及毒品再犯，累犯，确有履行能力而不履行或者不全部履行生效裁判中财产性判项的罪犯，被判处10年以下有期徒刑的，执行2年以上方可减刑，减刑幅度应当从严掌握，一次减刑不超过1年有期徒刑，两次减刑之间应当间隔1年以上。

② 对被判处10年以上有期徒刑的上述罪犯，以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处10年以上有期徒刑的罪犯，数罪并罚且其中两罪以上被判处10年以上有期徒刑的罪犯，执行2年以上方可减刑，减刑幅度应当从严掌握，一次减刑不超过1年有期徒刑，两次减刑之间应当间隔1年6个月以上。

③ 罪犯有重大立功表现的，可以不受上述减刑起始时间和间隔时间的限制。

(2) 从严掌握假释标准的规定有：

《刑法》第81条第1款对可以适用假释的被判处有期徒刑和无期徒刑的犯罪分子在执行的刑期上进行了限制，即有期徒刑执行原判刑期1/2以上、无期徒刑实际执行13年以上，才可以假释。另有司法解释规定，被判处死刑缓期执行的罪犯减为无期徒刑或者有期徒刑后，实际执行15年以上，方可假释，该实际执行时间应当从死刑缓期执行期满之日起计算。死刑缓期执行期间不包括在内，判决确定以前先行羁押的时间不予折抵。

为了使适用假释有一定的灵活性，以满足国家政治、经济等方面的特殊需要，《刑法》第81条规定，如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。根据有关司法解释，所谓特殊情况，是指有国家政治、国防、外交等方面特殊需要的情况。

6 为什么假释比减刑的刑事政策意义更大？

答：（1）假释和减刑的含义及意义

① 假释是对被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行一定刑期之后，因其认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险，而附条件地将其提前释放，在假释考验期内若不出现在法定的情形，就认为原判刑罚已经执行完毕的制度。假释制度对于鼓励犯罪分子加速改造，化消极因素为积极因素，实现刑罚的目的，具有积极的作用。

② 减刑是指对被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的犯罪分子，因其在刑罚执行期间认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改或者立功表现，而适当减轻其原判刑罚的制度。通过减刑，既可以将较重的刑种减为较轻的刑种，也可以将较长的刑期减为较短的刑期。减刑制度对于鼓励犯罪分子加速改造，化消极因素为积极因素，实现刑罚的目的，具有积极的作用。

(2) 假释比减刑的刑事政策意义更大，主要体现在两个方面：

① 假释更有利于罪犯教育改造。减刑主要是根据罪犯某个阶段的表现折算成考核分数的结果确认和奖励，间隔相对较短、减刑频率较快，但其不能有效防止罪犯可能产生的伪装改造的投机行为。而提请假释则要求罪犯在刑罚执行期间一贯表现较好，妄图通过投机是不可能获得假释机会的。因此，假释比减刑更能促进罪犯的教育改造和自

我约束。

② 假释更有利于罪犯回归社会。罪犯减刑释放后，除公安机关对其进行重点关注外，与其他社会公民没有任何差异。假释则不同于刑满后的直接释放，是附条件地提前释放，能得到社区矫正机关和社会、家庭的严格管束和正确引导，假释考验期可以让罪犯从“监狱人”向“社会人”顺利过渡。因此，假释具有风险防范和缓冲功能，比减刑制度更安全。此外，假释还具有节约司法成本、减少司法腐败以及保障人权等优势。

7 社区矫正的刑事政策意义有哪些？

答：社区矫正是在依法在社区中监管、改造和帮扶罪犯的非监禁刑执行制度。人民法院依法对判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行的罪犯决定实行社区矫正；监狱管理机关、公安机关对暂予监外执行的罪犯决定实行社区矫正。司法所接收社区矫正人员后，应当及时向社区矫正人员宣告判决书等有关法律文书的主要内容，应当为社区矫正人员确定专门的矫正小组，开展监督管理工作；为社区矫正人员制定矫正方案，在对社区矫正人员被判处的刑罚种类、犯罪情况、悔罪表现、个性特征和生活环境等情况进行综合评估的基础上，制定有针对性的监管、教育和帮助措施。根据矫正方案的实施效果，适时予以调整。

确立社区矫正制度，从立法上明确确立了行刑社会化理念，使得社会化行刑有章可循，有法可依，有利于纠正司法实践中的报应刑主义和重刑主义的思想。从刑事政策来看，社区矫正的立法也是贯彻落实我国“宽严相济”刑事政策的具体体现，充分体现了我国对犯罪分子“教育、感化、挽救”和“惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合”的方针和政策；这是积极推进司法体制改革的迫切需要，也是对完善中国特色的刑罚执行制度的有益探索。此外，社区矫正写入刑法顺应了国际社会行刑社会化的潮流。是我国在行刑社会化发展中的一次里程碑式的规定，是对联合国公约的积极回应，表明了我国负责任大国的态度。（意义多样，书本无固定答案，言之有理即可。）

第十六章 刑法各论概述

1 如何理解刑法总则与刑法分则的关系？

答：刑法总论研究刑法的一般性理论和刑法规范的原理和基本原则，是对犯罪问题的科学概括，对应刑法总则。刑法总则规定了犯罪与刑罚的一般原理与原则，如犯罪的概念、犯罪构成的一般要件、正当行为、犯罪形态、刑罚制度等。刑法各论是对具体犯罪的研究，包括罪与非罪的界定、此罪与彼罪的认定、犯罪构成要件的解释等，对应刑法分则。刑法分则规定了各种犯罪的具体要件和对该种犯罪的法定刑。

刑法总论和刑法各论是刑法不可缺少的两部分，它们相互联系、相互作用。刑法总论是刑法分论的概括和抽象，刑法分论是刑法总论的具体化，是刑法总论原理和原则的具体运用。两者是一般与特殊、抽象与具体、共性与个性的关系。具体而言：

(1) 刑法总论对刑法各论具有指导意义

刑法总论所研究的犯罪概念、犯罪构成、故意犯罪的停止形态、共同犯罪、罪数等理论，对于具体犯罪问题的研究具有指导意义。

刑法各论在研究具体犯罪时，一般根据刑法总论的理论体系展开探讨。首先是研究具体犯罪的概念和犯罪构成，然后依次论述该具体犯罪的罪与非罪的界限、此罪与彼罪的区别以及罪数问题。如果该具体犯罪是故意犯罪，则还要研究其是否存在故意犯罪的停止形态、共同犯罪问题等。此外，还要研究该具体犯罪的刑事责任与法定刑。

刑法各论在研究具体犯罪的犯罪构成时，通常按照其客体、客观方面、主体、主观方面四个部分进行分析。由于刑法总论关于犯罪构成的理论认为，任何犯罪都是主观要件和客观要件的统一，因此，刑法各论在研究具体犯罪时，必须坚持主客观相统一的原则。同时，刑法各论在研究具体犯罪的犯罪构成时，不能仅依据刑法分则规范所描述的该罪的罪状，对于罪状中没有反映的某些犯罪构成要件，需要通过刑法总论的一般理论加以补充。例如，《刑法》第232条规定：“故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑”。该条可以反映出故意杀人罪的客体、客观方面和主观方面的内容，但是并没有描述故意杀人罪的主体要件，这就需要通过刑法总论的相关规范和理论加以明确。

(2) 刑法各论对刑法总论的意义

刑法各论对具体犯罪的罪与非罪的界限、此罪与彼罪的区别的研究，对犯罪构成要件的解释，可以使刑法总论所阐述的罪刑法定原则等抽象理论落到实处。刑法各论对具

体犯罪的研究，有利于深化对刑法总论的理解，推进刑法立法理论和刑法解释论的发展。

刑法总论阐述的犯罪、刑事责任和刑罚的一般原理、原则较为抽象，这些抽象的原理、原则只有通过刑法各论，才能得到实际的贯彻和体现。例如，刑法理论通说认为，对于牵连犯，除刑法明确规定按一罪或数罪处罚的以外，择一重罪处罚。但是，对于何罪为明确规定的一罪或数罪处罚，需要依据刑法分则规范来判断，而不能主观臆断。只有在刑法分则规范没有明确规定按一罪或数罪处罚的，才应按照一般原理择一重罪处罚。

刑法总则所阐述的原理和原则虽具有一般性和共性，但在刑法分则规范中有一些特别的规定，刑法各论需要对这些问题进行深入研究。例如，我国刑法总则关于故意犯罪停止形态的理念，对于刑法分则科学界定各种具体的故意犯罪的犯罪既遂、未遂、预备和中止具有指导作用。但是，并非所有故意犯罪的未完成形态都要定罪处罚，这些问题要在研究个罪时具体分析。又如，刑法分则规范将某些煽动、帮助行为规定为具体犯罪的实行行为，在认定时就不能再将其认定为其他罪的犯罪预备、帮助行为。再如，刑法分则对必要共同犯罪的定罪和量刑作出了明确规定，因此，在必要的共同犯罪范畴，便无须适用刑法总则的共同犯罪理论去界定主犯与从犯。

2 什么是罪状？罪状分哪几种？

答：罪状，是指刑法分则条文对具体犯罪的构成特征的描述。在刑法理论上，可以根据不同的标准对罪状进行分类：根据分则条文对罪状的表述方式的不同，罪状可分为简单罪状、叙明罪状、引证罪状和空白罪状；根据分则条文对罪状描述方式的多寡，罪状可分为单一罪状和混合罪状。

(1) 简单罪状、叙明罪状、引证罪状和空白罪状

① 简单罪状，即在分则条文中只简单规定罪名，或者简单描述犯罪的构成特征的罪状。例如，《刑法》第232条规定：“故意杀人的，处……”。简单罪状的特点是文字简练概括。适用简单罪状，是为了防止赘述，便于理解。同时，简单罪状为刑法解释留下了较大的空间。

② 叙明罪状，即在分则条文中比较具体、详细地对具体犯罪的构成特征加以描述的罪状。例如，《刑法》第384条规定：“国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处……”。该条对挪用公款罪的客观方面、主体和主观方面的要件进行了较为详细的描述。之所以采取此种方式，是因为人

们对于该类犯罪难以把握。叙明罪状的特点是通过罪状可以明确具体犯罪的构成要件，避免歧义，有助于人们对具体犯罪的认定，我国刑法分则所规定的多数条文都采用了叙明罪状。

③ 引证罪状，即引用同一法律中的其他条款来说明和确定某一犯罪的构成特征的罪状。采用引证罪状的方式描述犯罪，是为了避免条款间文字上的重复。我国刑法关于引证罪状的规定大体有两种情况：一是引用同条前款的规定来说明后款的犯罪构成特征。例如，《刑法》第307条之一第4款规定：“司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚”。二是引用刑法其他条文来确定具体犯罪的构成特征。例如，《刑法》第247条规定：“司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人实行刑讯逼供或者使用暴力逼取证人证言的，处三年以下有期徒刑或者拘役。致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪，从重处罚”。

④ 空白罪状，又称参见罪状，即在刑法分则条文中指明要参照其他法律、法规的规定，来确定某一犯罪的构成特征的罪状。例如，《刑法》第342条规定：“违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处……”。要确定非法占用农用地罪的构成特征，必须参照我国土地管理法规的相关规定。空白罪状的特点是参照其他法规，避免刑法条文的复杂表述。

(2) 单一罪状和混合罪状

① 单一罪状，即某一分则条文仅采用简单、叙明、引证、空白四种罪状方式中的一种对犯罪的构成特征进行描述。分则条文中的绝大多数罪状属于单一罪状。

② 混合罪状，即某一分则条文同时采用两种或两种以上罪状方式对某一犯罪的构成特征进行描述。例如，《刑法》第340条规定：“违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的，处……”。该条前半段指出了确定非法捕捞水产品罪的构成特征需要参照的其他法规，属于空白罪状的描述方式；后半段详细地描述了非法捕捞水产品罪的犯罪地点、时间、工具、方法、对象以及情节方面的特征，属于叙明罪状的描述方式。采用混合罪状描述方式是由某些犯罪的特殊性决定的。刑法分则条文中属于混合罪状的犯罪不多。

3 如何区分注意规定和法律拟制？其有什么意义？

答：（1）注意规定和法律拟制的定义

注意规定是在刑法已作基本规定的前提下，提示司法人员注意、以免司法人员忽略的

规定。其包括两个特征：① 注意规定的设置，并不改变基本规定的内容，只是对基本规定内容的重申；即使不设置注意规定，也存在相应的法律适用根据（按基本规定处理）。② 注意规定只具有提示性，其表述内容与相关基本规定的内容完全相同，因而不会导致将原本不符合相关规定的行为也按相关规定论处。

法律拟制，是将原本不符合某种规定的行为也按照该规定处理。刑法之所以设置法律拟制，主要是基于两个原因：① 形式上，基于法律经济性的考虑，避免重复。② 实质上，基于两种行为对法益侵害的相同性或类似性。

（2）注意规定和法律拟制的区分意义

正确区分注意规定和法律拟制是罪刑法定原则的要求。罪刑法定原则要求坚持明确性原则。注意性规定作为法律的应有之义，有助于更精确地掌握犯罪构成要件。在保障犯罪人权益的前提下，不放纵犯罪。法律拟制实质上属于适用新的法律规范，为定罪和量刑提供法律上的依据。至此，两者相辅相成，共同服务于惩罚犯罪和保障人权的刑罚目的。

4 如何理解空白罪状与罪刑法定原则的关系？

答：空白罪状对罪名及法定刑作了明确规定，但对犯罪构成要件的全部或者部分则委诸其他规范或制度，这导致空白罪状对罪刑法定原则产生了一定冲击。但是，并不能据此便认为空白罪状必然违反了罪刑法定原则。

（1）空白罪状对罪刑法定原则的冲击和解决

在空白罪状中，刑法分则条文并不直接规定某一犯罪的构成特征，而是指明了确定该犯罪构成所需要参照的其他法律法规。因此，其本质特征在于被类型化的具体犯罪构成要件必须参照刑法以外其他有关的规范或制度才能确定，而承载空白罪状的条文本身似乎过于简单概括、不够明白清晰。在此意义上，空白罪状对罪刑法定原则中的明确性原则造成了一定的冲击和挑战。但是，由于空白罪状对某一具体犯罪特征的描述借助于其所参照的规范或制度，如果参照的规范或制度对某一犯罪的构成作了明确规定，则空白罪状的明确性和引证罪状的明确性并无二致。

（2）空白罪状的必要性

空白罪状的设置是刑法的应有之义。首先，由于行政管理的内容大而面广，违反某一行行政管理法规的行为类型数量众多庞杂，立法者不可能在刑法分则中对所有严重违反行政管理法规的行为作出全面列举。同时，社会生活千变万化，过于明确的法律会导致其与社会生活脱节。其次，立法者将空白罪状构成要件的内容委诸其他行政法律、

法规或命令的前提是后者能够说明某一行为的构成特征，据以确定该罪状的明确性。最后，指示具有一定的优越性，它能够在维持刑法典相对稳定性的前提下，严密刑事法网。

因此，空白罪状是在遵循罪刑法定原则的前提下，避免刑法分则条文在犯罪构成上表述的重复、繁杂和琐碎，以此实现构成要件的确定的完整性。

5 什么是法定刑？什么是宣告刑？二者的关系是什么？

答：（1）二者的定义

法定刑是指刑法分则条文所确定的适用于具体犯罪的刑种和刑度；宣告刑是指审判机关对具体犯罪依法判处并宣告的应当执行的刑罚。

（2）二者的关系

法定刑是宣告刑的基础，宣告刑是法定刑的实际适用。如果法定刑是绝对确定的法定刑，宣告刑与法定刑相同。如果法定刑是相对确定的法定刑，二者则具有以下差异：

- ① 法定刑可以同时包含不同的主刑和量刑幅度，而宣告刑只能是一罪一刑，其选择结果是排他的。
- ② 一般情况下，宣告刑必须以法定刑幅度为限，但在加重、减轻或者免除刑罚情节下，则可以超出法定刑幅度。
- ③ 法定刑是立法机关在制定刑法时确定的，宣告刑是司法机关在审理具体案件时确定的。

第十七章 危害国家安全罪

1 如何区分背叛国家罪与分裂国家罪？

答：（1）背叛国家罪与分裂国家罪的定义：

① 背叛国家罪，是指勾结外国或者与境外机构、组织、个人相勾结，危害中华人民共和国的国家主权、领土完整和安全的行为。

② 分裂国家罪，是指组织、策划、实施分裂国家、破坏国家统一的行为。

（2）两罪的区别主要表现在：

① 客体不同。分裂国家罪侵犯的客体是国家的统一；背叛国家罪侵犯的客体是国家主权、领土完整和安全。分裂国家罪侵犯的客体范围小于背叛国家罪侵犯的客体范围。

② 客观方面不同。分裂国家罪的客观方面表现为组织、策划、实施分裂国家、破坏国家统一的行为；背叛国家罪的客观方面表现为勾结外国或者与境外机构、组织、个人相勾结，实施危害中华人民共和国的主权、领土完整和安全的行为。

③ 主体不同。分裂国家罪的主体是一般主体，即已满16周岁，具有刑事责任能力的自然人都可以成为分裂国家罪的主体，包括我国公民、外国公民和无国籍人；背叛国家罪的主体是年满16周岁、具有刑事责任能力的中国公民。

④ 主观方面不同。分裂国家罪的故意内容是分裂国家、破坏国家的统一；背叛国家罪的故意内容是危害国家主权、领土完整和安全。

2 对在武装叛乱、暴力过程中实施故意杀人、故意伤害、强奸、抢劫等行为的，应当如何认定？

答：对在武装叛乱、暴力过程中实施故意杀人、故意伤害、强奸、抢劫等行为的认定如下：

（1）故意杀人、故意伤害、抢劫、放火等行为可以被武装叛乱、暴乱行为所涵盖，前述行为是后者的手段，那么在武装叛乱、暴力过程中实施前述行为，认定为一罪，对行为人应以武装叛乱、暴乱罪定罪处罚。

（2）如果行为人在实施武装叛乱、暴乱行为后，另起犯意实施了故意杀人、故意伤

害、强奸、抢劫等行为，则应以武装叛乱、暴乱罪和其他犯罪实行数罪并罚。

(3) 如果行为人在武装叛乱、暴乱之外又实施了其他危害国家安全的行为，构成其他犯罪的，则应以武装叛乱、暴乱罪和其他犯罪实行数罪并罚。

3 间谍罪的行为方式有哪些？

答：间谍罪的行为方式具体包括三种：

(1) 参加间谍组织。“间谍组织”，主要是外国政府或者境外的敌对势力建立起来的组织，其成立的意义就是收集情报或者国家秘密，有组织地进行间谍活动和秘密进行颠覆破坏等活动。“参加间谍组织”，是指行为人主动申请或者被邀请加入间谍组织，成为间谍组织的成员。

(2) 接受间谍组织及其代理人的任务。“间谍组织代理人”，是指受间谍组织或者其成员的指使、委托、资助，进行或者授意、指使他人进行危害中华人民共和国国家安全活动的组织和个人。“接受间谍组织及其代理人的任务”，是指虽然没有加入间谍组织，但接受间谍组织及其代理人的指使、命令或者委托，窃取、刺探我国秘密或情报，建立间谍组织或者网络，或者进行颠覆破坏活动等任务。

(3) 为敌人指示轰击目标的行为。“为敌人指示轰击目标”，是指行为人通过各种联络方式，向敌人指示其所要轰击的目标，以使敌人能够准确地击中我方目标。“敌人”，主要是指战时或者宣布进入紧急状态时与我方交战的敌方，也包括平时采用轰击方式袭击我方目标的敌方。“轰击”包括各类武器爆炸、炮击、导弹袭击、轰炸等方式。不管行为人是否参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务，只要为敌人指示轰击目标的，即构成间谍罪。

4 为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪与非法获取国家秘密罪、故意泄露国家秘密罪的区别是什么？

答：(1) 定义

① 为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪，是指为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报的行为。

② 非法获取国家秘密罪，是指以窃取、刺探、收买方法，非法获取国家秘密的行为。

③ 故意泄露国家秘密罪，是指国家机关工作人员违反保守国家秘密法的规定，故意或

者过失泄露国家秘密的行为。

(2) 为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪与非法获取国家秘密罪的区别

① 犯罪对象不同。为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪的对象既包括国家秘密，又包括情报；非法获取国家秘密罪的对象仅限于国家秘密。

② 犯罪目的不同。非法获取国家秘密罪对犯罪目的没有特定要求，行为人只要实施窃取、刺探、收买国家秘密的行为，即可构成非法获取国家秘密罪；为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪的犯罪目的是境外的机构、组织、人员而窃取、刺探、收买。

(3) 为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪与故意泄露国家秘密罪两者的区别

① 犯罪对象不同。为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪的对象是国家秘密或情报；故意泄露国家秘密罪的对象仅限于国家秘密。

② 犯罪目的不同。故意泄露国家秘密罪对犯罪目的没有特定要求，行为人只要实施了故意泄露国家秘密的行为，即可构成故意泄露国家秘密罪；为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪的犯罪目的是境外的机构、组织、人员泄露国家秘密。如果行为人是为境外的机构、组织、个人实施故意泄露国家秘密行为的，则构成境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪，而不再以故意泄露国家秘密罪定罪处罚。

第十八章 危害公共安全罪

1 如何理解公共安全的核心是不特定多数人的的人身安全?

答：危害公共安全犯罪的客体是公共安全。这里的公共安全，是指不特定多数人的生命、健康、重大公私财产安全。所谓不特定多数人，指犯罪行为可能危害的对象不是某个、某几个特定的人或者某项特定的财产。

公共安全的核心是不特定多数人的人身安全。对“重大财产”侵害只有在危及公众人身安全时，方可认为具有公共危险性。不危及公众人身安全的重大或巨大财产损害，不应认为具有危害公共安全的性质，例如，使用斧头、棍棒砸毁停车场中的数辆汽车，或者烧毁价值数千万元的豪车，但不危及人身安全的，不具有公共危险性。

是否危害公共安全是本章之罪区别于刑法分则其他各章之罪的本质特征。例如，行为人使用爆炸方法杀人，如果足以危害公共安全的，应定爆炸罪，排斥故意杀人罪的适用；如果不足以危害公共安全的，则不构成爆炸罪，应以故意杀人罪论处。再如，放火烧毁无人建筑物且不至于延烧到其他有人建筑物、不危及人身安全的，因不危害公共安全而不能成立放火罪，只能成立刑法分则其他有关章节的犯罪，例如，故意毁坏财物罪或破坏生产经营罪等。

2 对以危险方法危害公共安全罪之“其他危险方法”，应当如何理解和限定？

答：以危险方法危害公共安全罪的“其他危险方法”是指放火、决水、爆炸、投放危险物质之外的“其他危险方法”。“其他危险方法”仅限于与放火、决水、爆炸、投放危险物质相当的方法，而不是泛指任何具有危害公共安全性质的方法。

《刑法》将本罪规定在第114条与第115条之中，根据同类解释规则，它必须与前面所列举的行为相当；根据该罪所处的地位，“其他危险方法”只是《刑法》第114条、第115条的“兜底”规定，而不是刑法分则第二章的兜底规定。换言之，对与放火、决水、爆炸等危险方法不相当的行为，即使危害公共安全，也不宜认定为本罪。从司法实务看，认定的“其他危险方法”主要有：①驾驶机动车辆在公共场所故意冲撞众人；②在公共场所私设电网危及众人安全；③破坏矿井的通风设备危及井下矿工生命安全；④拆卸公共道路中央的下水井盖；⑤以制作或者输送坏血、病毒血的方法致众人感染；⑥向人群开枪；⑦驾驶人员与人打闹而任由机动车处于失控状态。

如果是使用放火、爆炸、投放危险物质、决水等刑法已有专门规定的方法的，则排斥

适用以危险方法危害公共安全罪。

3 足以使交通工具发生倾覆、毁坏是具体危险还是抽象危险？如何认定？

答：足以使交通工具发生倾覆、毁坏是具体危险。

(1) 破坏交通工具罪在客观方面表现为破坏交通工具足以使其发生倾覆、毁坏危险。危险，指具体危险，即在具体场合下对交通工具的破坏具有发生倾覆、毁坏的现实可能性。

(2) 通常表现为破坏交通工具的安全装置或关键部件，使其在行驶中因为安全装置，例如，刹车失灵或者关键部位损坏而发生交通事故，危害交通运输安全。例如，某机场检票员因平素与领导有矛盾，意欲制造飞机事故，使领导受撤职处分，某日到停机坪，用改锥猛戳一架民航机的油箱，在油箱上造成5个凹陷痕迹和1个贯通洞，被执勤人员当场抓获。就本案而言，在飞机油箱造成“贯通洞”，若没有被发现，飞机在这种状态下飞行可能会出事故，即有“具体危险”，故成立破坏交通工具罪。若仅仅形成几个“凹陷痕迹”，经技术检验不会影响飞行安全，仅有抽象危险而尚未造成具体危险的，则是犯罪未遂。

4 恐怖活动犯罪的定义和范围是什么？

答：(1) 我国的定义和范围

我国立法载明的“恐怖活动”是指恐怖主义性质的下列行为：① 组织、策划、准备实施、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的活动的；② 宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动，或者非法持有宣扬恐怖主义的物品，强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志的；③ 组织、领导、参加恐怖活动组织的；④ 为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的；⑤ 其他恐怖活动。

(2) 国际上的界定

恐怖活动（犯罪）”是公认的国际罪行。国际社会一般认为恐怖活动是以“莫测的暴力”为手段实现其某种目的的行为，具有两个特征：① 客观上，以莫测的暴力为手段。由于暴力的方式、规模，实施暴力的对象、时间、地点不特定，因而危害公共安全和破坏公众的安全感；② 主观上，为了实现某种目的，即利用莫测的暴力对社会、

公众施加压力，以实现其政治、经济以及其他目的。这种目的性是恐怖主义犯罪与放火、爆炸、投放危险物质、劫机、绑架、破坏公共设施、故意杀人等犯罪的不同之处。

1977年《惩治恐怖主义的欧洲公约》第1条采取列举方式确认恐怖行为，具体包括：劫持航空器和危害民用航空安全的非法行为；涉及侵害应受国际保护人员包括外交代表的生命、健康或自由的严重罪行；诱拐、劫持人质或者严重的非法拘禁的犯罪；涉及使用炮弹、手榴弹、火箭、自动武器或信件或邮包炸弹而危及他人的罪行。此外，海盗行为被认为是最早出现的典型的恐怖行为。

5 交通肇事后逃逸对肇事人罪责有何不利影响？

答：交通肇事后逃逸会加重肇事人的罪责。根据《刑法》第133条规定，犯交通肇事罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役。但是，如果交通运输肇事后逃逸，则处3年以上7年以下有期徒刑；如果因逃逸致人死亡的，则处7年以上有期徒刑。具体而言：

(1) 关于逃逸与事故的责任认定，《道路交通安全法实施条例》第92条规定：“发生交通事故后当事人逃逸的，逃逸的当事人承担全部责任。但是，有证据证明对方当事人也有过错的，可以减轻责任”。据此，逃逸一般承担以下不利后果：① 对事故负全部责任；② 法定刑幅度升格至3年以上7年以下；③ 定罪结果降低标准：一般交通肇事造成1人死亡结果才达到定罪标准，有逃逸情节的造成1人重伤结果可达到定罪标准，此时，逃逸已经作为定罪因素被使用，不再重复作为量刑情节；④ 因逃逸致人死亡的法定刑升格至7年以上有期徒刑。

(2) “因逃逸致人死亡”，是指行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑，致使被害人因得不到救助而死亡的情形。其要件为：① 肇事者有逃逸行为。有逃逸行为表明肇事人认识到可能有被害人需要救助，若因逃逸发生致人死亡结果，证明存在过失，是归责的重要依据。如果肇事人没有逃逸行为，则不能认定为“逃逸致死”。② 因逃逸而不救助（不作为）与死亡结果有因果关系。首先，交通事故的被害人受伤当场未死。如果已经当场死亡，则其后发生的逃逸与死亡无关。其次，由于肇事人的逃逸，被害人既没有得到肇事人的救助，也没有得到其他人的救助，以至于延误了抢救时机而发生死亡结果。被害人死亡与因逃逸贻误抢救存在因果关系。这涉及不救助（不作为）与死亡结果之间的因果关系判断。《交通肇事解释》规定的逃逸“致使被害人因得不到救助而死亡”，指既得不到肇事者也得不到其他人救助而死亡。如果被害人获得最及时的救助仍然死亡，表明死亡结果与因逃逸未救助行为之间没有因果关系，死亡仍属肇事的结果，不属逃逸致人死亡。

6 醉驾致人死伤案应如何认定处理？

答：醉驾致人死伤，达到交通肇事罪标准的，以交通肇事罪定罪处罚；醉驾发生交通事故但尚未达到交通肇事罪的，以危险驾驶罪定罪处罚。

醉酒驾驶致人伤亡危害公共安全，且对致人伤亡结果达到故意程度的，可以成立《刑法》第115条之以其他危险方法危害公共安全罪。如何认定达到“故意”程度成为关键，为了统一标准，最高人民法院于2009年出台了《关于醉酒驾车犯罪法律适用问题的意见》（以下简称《醉驾法律适用意见》），并配发了两个典型案例。从《醉驾法律适用意见》来看，这种“故意”的内容是（行为人）对“致人死伤结果”明知，而非对“醉酒驾驶”的明知。从发布的两个典型判例（广东佛山黎景全醉驾致人伤亡案和成都孙伟铭醉驾致人伤亡案）来看，认定行为人达到故意程度的关键在于醉酒驾驶肇事之后，其后续行为又连续肇事造成新的损害结果。该《醉驾法律适用意见》指出：黎景全、孙伟铭“在醉酒驾车发生交通事故后，继续驾车冲撞行驶，其主观上对他人伤亡的危害结果明显持放任态度，具有危害公共安全的故意。二被告人的行为均已构成以危险方法危害公共安全罪”。为了进一步明确肇事之后的“后续行为及其结果”对认定故意心态的意义，最高人民法院法官特意将醉酒驾驶分为“一次碰撞”和“二次碰撞”两种情形，并指出：“在二次碰撞情形下，行为人醉酒驾车发生一次碰撞后……仍然继续驾车行驶，以致再次肇事，冲撞车辆或行人造成更为严重的后果。此种情形之下，行为人将他人的生命置于高度危险之中，其本人已经没有能力对这种危险予以控制，危险随时随地都会发生，却依然不管不顾、置之不理。这种状态，明显反映出行为人完全不计自己醉酒驾车行为的后果，对他人伤亡的危害结果持放任态度，主观上具有危害公共安全的间接故意，应定以危险方法危害公共安全罪。”由此可见，对于醉酒驾驶致人死伤案例外地适用以危险方法危害公共安全罪，关键在于肇事后发生“二次肇事”（碰撞），根据二次肇事及其后果所表现出的心态认定是否具有故意。

因此，醉驾没有逾越危险驾驶范围的，只能适用《刑法》第133条之一，不能适用《刑法》第114条。致人死伤的，通常是交通肇事罪。只有足以认定对致人死伤结果具有故意的，才能成立以其他危险方法危害公共安全罪。

7 重大责任事故罪与失火罪的界限是什么？

答：重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为；失火罪是指因过失引起火灾，造成严重后果，危害公共安全的行为。两者区分的关键在于是否属于业务过失。

重大责任事故罪与失火罪都属于过失犯罪，都造成了严重后果。但它们的区别在于：

重大责任事故罪是在生产作业活动中，由于违反规章制度而造成了责任事故；失火罪是在日常生活中由于用火、用电不慎而发生严重后果，与生产、作业活动无关。简言之，前者是业务过失犯罪，后者是普通过失犯罪。例如，某国有大型林场职工在作业中失火，属于业务过失，被认定为重大责任事故罪；再如，洛阳某商厦失火烧死三百余人案，因为是工人在装修施工过程中违反规章，造成电焊渣掉入易燃物质中引起火灾，故认定为重大责任事故罪。

第十九章 破坏社会主义市场经济秩序罪

1 运输、储存伪劣产品的行为能否作为犯罪处理？

答：运输、储存伪劣产品的行为能否作为犯罪处理要看伪劣产品的货值金额。

根据《刑法》第140条的规定，行为人实施的生产、销售伪劣产品的行为要构成犯罪，必须达到法定的销售数额较大的程度。对此，《伪劣商品解释》第2条规定，伪劣产品尚未销售，货值金额达到《刑法》第140条规定的销售金额3倍以上的，以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚。货值金额以违法生产、销售的伪劣产品的标价计算；没有标价的，按照同类合格产品的市场中间价格计算。

2 在同一宗走私物品中既有普通物品又有武器、弹药、贵金属等特定物品的，应如何处理？其法理依据是什么？

答：在同一宗走私物品中既有普通物品又有武器、弹药、贵金属等特定物品的，应实行数罪并罚。

走私普通货物、物品罪与走私特定的货物、物品犯罪是法条竞合的关系，两者的区别主要在于犯罪对象有所不同。走私普通货物、物品罪的犯罪对象限于特定的货物、物品以外的普通货物、物品；走私其他特定货物、物品罪的对象是法定的特殊物品，如武器、弹药、文物、贵金属等。

根据《走私案件解释》第21条的规定，未经许可进出口国家限制进出口的货物、物品，构成犯罪的，应当依照《刑法》第151条、第152条的规定，以走私国家禁止进出口的货物、物品罪等罪名定罪处罚。第22条规定，在走私的货物、物品中藏匿《刑法》第151条、第152条、第347条、第350条规定的货物、物品，构成犯罪的，以实际走私的货物、物品定罪处罚；构成数罪的，实行数罪并罚。

3 洗钱罪的主体应否包括上游犯罪的行为人？

答：洗钱罪的主体不应包括上游犯罪的行为人。具体分析如下：

洗钱罪的主体既可以由自然人构成，也可以由单位构成。结合《刑法》第191条的规定，洗钱罪的主体不应包括上游犯罪的行为人。从刑法条文的措辞上分析，《刑法》第191条第1款第1项至第4项的“提供”“协助”等词语表明立法初衷是否定上游犯罪的行

为人可以构成洗钱罪的。尽管第5项只有“其他方法”的规定而没有使用“提供”“协助”等词，但考虑到刑法中的“兜底条款”应与其他条款保持同质性的要求，也应将其第5项理解为“协助”上游犯罪行为人为人实施其他掩饰、隐瞒的行为。

4 如何认定伪造信用卡并使用的行为的性质？

答：信用卡诈骗罪的客观表现为使用伪造的信用卡、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡、恶意透支五种行为类型。其中，“使用伪造的信用卡”，是指使用伪造的信用卡购物、在银行或自动柜员机上支取现金以及接受服务等行为。“使用伪造的信用卡”只能是明知是他人伪造的信用卡而自己使用（与伪造者之间没有共同故意）。如果是自己伪造信用卡并加以使用，则属于刑法理论上的牵连犯，应当按照“从一重处断”或“从一重重处断”的原则。

5 如何认定集资诈骗罪中非法占有的目的？

答：集资诈骗罪的主观方面表现为故意，并且行为人具有非法占有集资款的目的。

根据《非法集资解释》第4条的规定，使用诈骗方法非法集资，具有以下情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：

- （1）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的。
- （2）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的。
- （3）携带集资款逃匿的。
- （4）将集资款用于违法犯罪活动的。
- （5）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的。
- （6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的。
- （7）拒不交代资金去向，逃避返还资金的。
- （8）其他可以认定非法占有目的的情形。

集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款

的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

6 如何理解受益人故意造成被保险人死亡以此骗取保险金的应数罪并罚的法理根据？

答：在以故意杀人等手段实施保险诈骗行为的案件中，虽然行为人的诈骗行为与杀人等行为之间具有一定联系，但实际上并不符合刑法理论中牵连犯的构成要件。

(1) 从主观方面分析，行为人的数个行为要构成牵连犯，行为人应具有一个犯罪目的。

(2) 从客观方面分析，行为人的方法行为与目的行为或者原因行为与结果行为在构成要件的客观方面应具有包容关系。

但在上述案件中，行为人的保险诈骗行为与杀人等行为在构成要件中并没有相互包容的关系，即杀人等行为无法被保险诈骗罪中“虚构事实、隐瞒真相”的客观要件所包含，因而不能将这种情况视为牵连犯。因此，《刑法》第198条第2款明确规定，实施保险诈骗行为，同时构成故意杀人罪、故意伤害罪等犯罪的，应当依照数罪并罚的规定处罚。

7 如何认定“相同的商标”？

答：根据《知识产权意见》，具有下列情形之一，可以认定为“与其注册商标相同的商标”：

(1) 改变注册商标的字体、字母大小或者文字横竖排列，与注册商标之间仅有细微差别的。

(2) 改变注册商标的文字、字母、数字等之间的间距，不影响体现注册商标显著特征的。

(3) 改变注册商标颜色的。

(4) 其他与注册商标在视觉上基本无差别、足以对公众产生误导的商标。

由此可见，所谓“相同商标”，不仅包括与被假冒的注册商标完全相同的商标，也包括与被假冒的注册商标在视觉上基本无差别、足以对公众产生误导的商标。司法机关在判断过程中，一般是以社会公众的认识作为基本标准。

8 如何认定侵犯著作权罪中的以营利为目的？

答：构成侵犯著作权罪，行为人主观上必须具有营利的目的。

根据《知识产权意见》第10条的规定，除销售外，具有下列情形之一的，可以认定为“以营利为目的”：

- (1) 以在他人作品中刊登收费广告、捆绑第三方作品等方式直接或者间接收取费用的。
- (2) 通过信息网络传播他人作品，或者利用他人上传的侵权作品，在网站或者网页上提供刊登收费广告服务，直接或间接收取费用的。
- (3) 以会员制方式通过信息网络传播他人作品，收取会员注册费或者其他费用的。
- (4) 其他利用他人作品牟利的情形。

9 如何认定侵犯商业秘密罪中权利人的损失？

答：（1）根据《最高人民法院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第73条规定，侵犯商业秘密，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

- ① 给商业秘密权利人造成损失数额在五十万元以上的。
- ② 因侵犯商业秘密违法所得数额在五十万元以上的。
- ③ 致使商业秘密权利人破产的。
- ④ 其他给商业秘密权利人造成重大损失的情形。

（2）其他法律、法规规定

① 《关于在办理侵犯商业犯罪案件中如何确定“给商业秘密权利人造成重大损失”计算方法的答复》规定，对难以计算侵犯商业秘密给权利人所造成的损失，司法实践一般可参照反不正当竞争法规定的民事赔偿额的计算方法。因此在侵犯商业秘密刑事案件中，法官常借鉴侵犯商业秘密民事案件中损害赔偿额的确定方法来认定权利人损失。

② 《反不正当竞争法》第20条的规定，侵犯商业秘密案损害赔偿额的确定依据依次为权利人损失和侵权人获利。

③ 《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第17条规

定，可以参照专利侵权的损害赔偿额方法，即依次根据权利人损失、侵权人获利、专利许可使用费的倍数来确定；同时规定，因侵权行为导致商业秘密已为公众所知悉的，应根据该项商业秘密的商业价值确定损害赔偿额，根据其研究开发成本、实施该项商业秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素确定。

(3) 在司法实务中，对权利人损失的确定一般有以下几种方法：

① 直接计算损失法，即直接计算权利人在被侵权期间损失的利润。可比较权利人在侵权期间的上一年度，相同时间段、相同生产量条件下的获利，利润的缩减量是其侵权期间的直接经济损失。这主要适用于市场行情相对稳定，权利人生产、经营处于连续状态、经营资料齐备的情形。

② 侵权人获利计算法，在权利人损失难以计算时，将侵权人获利的数额作为权利人损失的数额。

③ 成本计算法，即审计核算权利人研究、开发商业秘密所投入的费用，将其作为权利人损失。这主要适用于商业秘密在行业内或社会上被广为扩散，致使权利人研发的商业秘密完全丧失秘密性，从而丧失其作为商业秘密的价值的价值的情形。

10 如何区分合同诈骗与合同欺诈？

答：合同欺诈，是指签订经济合同的一方当事人用虚构事实和隐瞒真相的方法，引诱对方当事人对在不明真相、违背其真实意思表示的情况下，签订合同的行为。合同诈骗罪本身也是一种合同欺诈行为，因而两者之间存在一定的相似性，即两者都通过签订合同的方式获取非法利益，且签订的合同都属于无效的合同。但两者也存在显著差异：

(1) 主观方面不同。本罪要求行为人主观上具有非法占有的目的；合同欺诈的主观目的往往是通过瑕疵履行减少成本，增加利润，而并非非法占有。

(2) 客观行为方式不同。本罪的行为人往往是通过虚构事实、隐瞒真相的方式非法占有他人财物，而不会实施履行合同的的行为；合同欺诈则一般存在履行合同的的行为，只不过行为人履行合同的的行为存在一定瑕疵。

11 如何认定传销活动？

答：根据国务院2005年8月23日颁布的《禁止传销条例》的有关规定，传销活动的三种主要表现形式为：

- (1) “拉人头”，以发展下线的数量为依据计提报酬的传销行为。
- (2) “入门费”，直接收取或者以认购商品等方式间接收取加入费的传销行为。
- (3) “团队计酬”，以发展的下线的推销业绩为依据计提报酬的传销行为。

12 如何理解非法经营罪中“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”？

答：非法经营罪中的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”属于刑法中典型的兜底条款。兜底条款一般采用“其他……的行为”的表述方式，这种表述方式一方面增加了条文的弹性，另一方面也使得条文具有模糊性的特征。由于条文的模糊性有违罪刑法定原则“明确性”的要求，这就可能导致行为人难以预测其所实施的行为是否构成犯罪。正因如此，我们必须对兜底条款作出相应的限定，不宜使其范围过于宽泛。

在司法实务中，是否适用兜底条款取决于行为是否符合同质性要求。所谓同质性要求，是指行为不仅侵犯了与相应罪名相同的犯罪客体，而且在行为手段上也与相应罪名的明示条款具有相同的特征。根据同质性要求，在非法经营罪中，只有当相关行为侵犯了国家对市场的管理秩序，而且该行为在行为方式上与非法经营罪的其他明示性条文具有相同的特征，亦即未经批准非法进行经营活动时，才能将该行为认定为非法经营罪兜底条款所规定的行为。

最高人民法院2011年4月8日发布的《关于准确理解和适用刑法中“国家规定”的有关问题的通知》第3条载明：“各级人民法院审理非法经营犯罪案件，要依法严格把握刑法第二百二十五条第（四）的适用范围。对被告人的行为是否属于刑法第二百二十五条第（四）规定的‘其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为’，有关司法解释未作明确规定的，应当作为法律适用问题，逐级向最高人民法院请示。”这一司法解释鲜明地表达了对刑法第225条第4项“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”之认定要严格限制的司法立场。

第二十章 侵犯公民人身权利、民主权利罪

1 自杀关联行为中哪些应成立故意杀人罪？

答：一般来说，自杀是自己结束自己生命的行为，不成立犯罪。但是实际中有的人与自杀者自杀的行为存在关联性，对这些相关人员应该具体情况具体分析：

(1) 自愿自主自杀关联行为。指自杀者没有因为外人的迫使或诱骗，而是出于自己的真实自杀意愿自杀，而关联人在此时提供了帮助的情形。这种帮助一般包括心理帮助和物理帮助。

① 首先需要讨论的是相约自杀的情况。尽管相约自杀的邀约方或应约方的相约自杀行为可能会进一步坚定对方的自杀意愿，但单纯提供这样的心理帮助的，一般不构成故意杀人罪。即使相约自杀的一方死亡，但因为未死亡者没有实施杀人行为，因此不宜对未死亡者按故意杀人罪处罚。

② 其次要分析的是本人不打算自杀，而是单纯为自愿自主自杀者提供一定程度心理帮助。这种情况一般也不成立故意杀人罪，但是对于开设自杀网站传授自杀方法或为自杀者提供其他具体的心理支持的，或者为自愿自主自杀者提供物理帮助的，应该按照故意杀人罪处罚。

(2) 自愿非自主自杀关联行为。指关联人应出于自己真实自杀意愿的自杀者要求提前结束其生命的行为。在这种场合，自杀者自杀的意愿是真实的，但是没有自己实施自杀，而是要求关联人结束其生命，除极个别情节显著轻微危害不大的情况外，关联人的行为符合故意杀人罪的犯罪构成，应成立故意杀人罪。即使其杀人行为取得了被害人的同意，这种同意也是无效的。

(3) 非自愿自主自杀关联行为。指关联人强迫、教唆、诱骗或影响本无自杀意愿的人产生自杀念头而自杀的行为。具体包括以下情形：

① 逼迫自杀。逼迫者主观上意图剥夺他人生命，客观上存在逼迫他人自杀的行为，应成立故意杀人罪。

② 教唆自杀。对于教唆者而言，使没有自杀意愿的人产生自杀的念头，并进而自杀，应构成故意杀人罪。

③ 诱骗自杀。故意诱骗不能理解死亡意义的未成年人或精神病患者，造成未成年人或精神病患者自杀的，成立故意杀人罪的间接实行犯。

④ 其他行为引起他人自杀：

a. 正当行为引起他人自杀的，不成立犯罪。例如，领导者对于员工的正当批评引起员工自杀的，领导者或教师不承担责任。

b. 一般不当行为或轻微不法行为引起他人自杀的，也不成立犯罪。即使领导或教师的处分或惩戒行为是错误的或存在轻微违法的现象，该员工或学生因此自杀的，也不能要求领导与教师对他人自杀的后果承担刑事责任。

c. 由于严重的不法行为引起他人自杀的，应该将自杀作为该不法行为的一个严重情节，成立犯罪的，则按照相应犯罪处理。例如，因侮辱导致他人自杀的，自杀可以作为侮辱的一个严重情节，对行为人按照侮辱罪处罚。犯罪行为导致他人自杀的，则应将自杀作为该犯罪的一个从重量刑情节，按照相关规定处罚。

2 如何正确把握故意伤害罪与故意杀人罪的界限？

答：（1）故意伤害罪，是指故意非法损害他人身体健康的行为。本罪的构成特征是：侵犯的客体是他人的身体健康权；在客观方面表现为行为人实施了使他人身体健康受到损害的行为；主体为一般主体，即具备承担刑事责任能力的自然人；主观方面表现为故意，直接故意或者间接故意均可构成故意伤害罪。

（2）故意杀人罪，是指故意非法剥夺他人生命的行为。本罪的构成特征是：侵犯的客体是他人的生命权；在客观方面表现为非法剥夺他人生命的行为；主体是一般主体；主观方面包括直接故意和间接故意。

（3）一般来说，故意伤害（致死）罪和故意杀人罪（既遂）都出现了他人死亡的危害结果。但二者的主要区别是犯罪人的主观心理活动内容不同：故意伤害（致死）罪的犯罪人对致人死亡结果持过失的主观心态，而故意杀人罪的犯罪人对他人死亡结果持故意的主观心态。

除了主观心态的不同，区分故意伤害罪与故意杀人罪还可以从以下几个方面入手：

① 从犯罪发生的起因及背景，犯罪时间、地点及环境的选择。

行为人和被害人之间是否存在重大利益纠纷，是否有重大矛盾和积怨，是由一时激动还是经过密谋策划，是随意行凶还是刻意选择时间、地点后而实施犯罪。如果存在重大利益纠纷和积怨，并在事前经过周密策划，致人死亡却辩解说故意伤害的，可定间接故意的故意杀人罪。

② 作案时是否避开他人，害怕别人看见等。

故意杀人最高要判死刑，行为人如果预谋杀人，一般会行事谨慎，不是万不得已，一般不会让人看见。如果有刻意避开他人的行为，故意杀人的可能性较大。

③ 使用什么样的犯罪凶器？凶器的是否是事先准备的，杀伤力如何？

若使用枪支、砍刀、长矛等杀伤力较大的凶器，又系事先准备，伤害时行为没有节制的，则故意杀人的可能性较大，致人死亡定直接故意困难的，可直接定间接故意杀人。

④ 实施伤害时伤害的打击部位、力度和打击次数如何？是否在被害人失去反抗能力后，多次打击，事后是否有抢救或报警行为。

对于使用足以致人死亡的工具，用力打击或反复打击被害人头部、胸部等重要部位，或虽非打击重要部位，但用锐器刺破被害人体表流血不止时，将被害人丢于荒僻处，事后又不实施抢救和报警的；或在被害人失去反抗能力后，持锐器击打的，一般应定故意杀人罪。即便是因意志以外原因，被害人没有死亡的，根据打击部位、次数、被害人伤情等情况，结合当时的环境因素，亦可定故意杀人罪。

3 强奸罪的本质特征是什么？

答：强奸罪，是指强奸妇女或者奸淫幼女的行为。本罪具体包括强奸妇女和奸淫幼女两种类型。一般认为，违背妇女意志是强奸妇女犯罪的本质特征。

违背妇女意志往往表现为，行为人采取了一些使妇女不能反抗、不知反抗或不敢反抗的手段。需要指出的是，强奸妇女的实行行为实际上是一个复合行为，由强制行为和奸淫行为组成，二者缺一不可。

强制行为，是指行为人采取暴力、胁迫或者其他使被害妇女不敢反抗、不能反抗或不知反抗的行为。具体包括：

(1) 暴力行为。即行为人对被害人使用有形的打击力，包括殴打、捆绑、按倒、掐脖子等。

(2) 胁迫手段。即行为人对被害妇女施以威胁、恫吓，进行精神上的强制，如以杀伤被害人或其家属、揭发其隐私、利用迷信邪说对被害人进行恐吓，利用教养或从属关系以及被害人孤立无援的状态，使其不敢反抗等。

(3) 其他手段。即行为人使用暴力、胁迫以外的使被害妇女不知反抗或不能反抗的手段。

4 以索取债务为名扣押他人，而索取财物数额超过了债务范围的行为，应该如何定性？

答：《刑法》第238条第3款规定，为索取债务非法扣押、拘禁他人的，以非法拘禁罪处罚。

以索取债务为名扣押他人，而索取财物数额超过了债务范围的行为有两种处理方式：一种是比照《刑法》第204条第2款的规定，对属于债务范围和超出债务范围的索要事实分别认定为非法拘禁罪和绑架罪（或抢劫罪），然后实行数罪并罚；另一种是采用重罪吸收轻罪的处理方式，只按绑架罪或者抢劫罪一罪予以处断。

5 怎样区别绑架罪的既遂与未遂？

答：关于绑架罪的既遂标准，刑法理论界的有不同的主张。产生歧见的根源是将绑架罪构成要件中的行为视为单一行为还是复合行为。主张单一行为者认为，绑架罪的既遂应以被害人的人身自由被剥夺作为标准，即主张已经实际控制他人的即成立绑架罪既遂；主张复合行为者认为，要成立绑架罪既遂仅有劫持他人的行为尚不够，还要进一步实施勒索财物等目的行为，方能成立既遂。将绑架行为视为复合行为者，对既遂标准也存在争议。有学者认为，控制他人以后，提出勒索赎金的要求或其他不法要求的，即成立绑架罪既遂；另有学者认为，必须是行为人已经获得赎金或绑架者所提出的要求得到满足时，才能成立绑架罪的既遂。

我国刑法将绑架罪规定在侵犯公民人身权利、民主权利罪一章，说明该罪所侵犯的主要客体是他人的人身自由。因此，当绑架行为实际侵害了主要犯罪客体，即行为人实施了全部绑架行为时，绑架罪即成立既遂。

6 如何正确识别拐卖妇女、儿童罪中的一罪与数罪？

答：在实践中，拐卖妇女、儿童的犯罪分子大多手段凶残，完全不顾被害人的人身安全，往往在犯罪过程中殴打、侮辱或者以其他方式摧残被害人，从而可能涉及其他犯罪，如伤害、杀害、强奸被害人，或者强迫被拐卖的妇女卖淫等。

对这些行为的定罪可以根据实践的需要在不违背罪责刑相适应原则的前提下分别予以合理处理：

(1) 拐卖妇女的犯罪分子奸淫被拐卖妇女、强迫被拐卖妇女卖淫的，均作为吸收情

节，按拐卖妇女罪一罪定罪处罚。

(2) 拐卖妇女、儿童的犯罪行为本身直接导致被害人重伤、死亡的，成立拐卖妇女、儿童犯罪结果加重犯。

(3) 拐卖妇女、儿童过程中，行为人又故意伤害、杀害被害人的，应以拐卖妇女、儿童罪和故意伤害罪、故意杀人罪进行数罪并罚。

7 怎样正确把握诽谤罪中的“情节严重”？

答：所谓情节严重，实践中一般是指诽谤手段恶劣、诽谤者主观恶性大、造成严重后果或者恶劣影响等情形。根据《诽谤案件解释》，具有下列情形之一的，可认定为诽谤行为“情节严重”：

(1) 同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到5000次以上，或被转发次数达到500次以上的。

(2) 造成被害人或近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的。

(3) 2年内曾因诽谤受过行政处罚，又诽谤他人的。

(4) 其他情节严重的情形。

一年内多次实施利用信息网络诽谤他人行为未经处理，诽谤信息实际被点击、浏览、转发次数累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。

第二十一章 侵犯财产罪

1 如何区分抢劫罪与绑架罪？

答：绑架罪是侵害他人人身自由权利的犯罪，其与抢劫罪的区别在于以下两个方面：

(1) 主观方面不尽相同。抢劫罪中，行为人一般出于非法占有他人财物的目的故意实施抢劫行为；绑架罪中，行为人既可能为勒索他人财物而实施绑架行为，也可能出于其他非经济目的实施绑架行为。

(2) 行为手段不尽相同。抢劫罪表现为行为人劫取财物一般应在同一时间同一地点，具有“当场性”；绑架罪表现为行为人以杀害、伤害等方式向被绑架人的亲属或其他人或单位发出威胁，索取赎金或提出其他非法要求，劫取财物一般不具有“当场性”。绑架过程中又当场劫取被害人随身携带财物的，同时触犯绑架罪和抢劫罪两罪名，应择一重罪定罪处罚。

2 如何确定抢劫罪的既遂标准？

答：关于区分抢劫罪既遂与未遂的标准，理论上存在不同主张。

有的观点主张，抢劫罪侵犯的主要客体是财产所有权，因而抢劫罪既遂与未遂的界限应当以行为人是否非法占有公私财物为标准。

有的观点主张，抢劫罪不仅侵犯财产权利，同时还侵犯人身权利，而且人身权是更重要的权利。虽未抢到财物但已给被害人的人身造成危害的，也应认定为抢劫罪既遂；既未抢到财物，又未造成人身损害的，才可以认定为抢劫罪未遂。

《抢劫抢夺意见》基本上采用了上述第二种观点的主张，具体规定在第10条：抢劫罪侵犯的是复杂客体，既侵犯财产权利又侵犯人身权利，具备劫取财物或者造成他人轻伤以上后果两者之一的，均属抢劫既遂；既未劫取财物，又未造成他人人身伤害后果的，属于抢劫未遂。

据此，《刑法》第263条规定的八种处罚情节中除“抢劫致人重伤、死亡的”这一结果加重情节之外，其余七种处罚情节同样存在既遂、未遂问题，其中属抢劫未遂的，应当根据刑法关于加重情节的法定刑规定，结合未遂犯的处理原则量刑。

3 如何理解盗窃罪中的“秘密窃取”？

答：秘密窃取是指行为人采用自认为不使他人发觉的方法占有他人财物。只要行为人主观上是意图秘密窃取，即使客观上已被他人发觉或者注视，也不影响盗窃性质的认定。概括起来，秘密窃取行为主要包括三种表现形式：

(1) 将可移动的财物秘密转移到行为人控制之下，并且脱离财物所有人或持有人的控制范围。例如，将他人口袋里的钱包窃取到自己的口袋里，把单位的钢材秘密搬运到单位以外，等等。

(2) 通过传输系统加以使用和消耗。例如，盗窃电力、煤气、天然气等。只要行为人启动开关，电力、煤气、天然气等即开始消耗，所有人的损失就立即产生，盗窃行为即告完成。盗用电力、煤气、天然气，累计数额较大，构成盗窃罪。

(3) 以牟利为目的，盗接他人通信线路、复制他人电信号码或者明知是盗接、复制的电信设备、设施而使用。这是一种特殊形式的盗窃罪。根据最高人民法院2000年《关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》第8条的规定，盗用他人公共信息网络上网账号、密码上网，造成他人电信资费损失数额较大的，依照《刑法》第264条的规定，以盗窃罪定罪处罚。

4 如何理解诈骗罪的客观方面？

答：诈骗罪在客观方面主要表现为用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法，骗取公私财物，数额较大的行为。诈骗行为最突出的特点，就是行为人设法使被害人在认识上产生错觉，以致“自觉地”将自己所有或持有的财物交付给行为人或者放弃自己的所有权，或者免除行为人交还财物的义务。诈骗的手段多种多样，概括起来主要表现为：

(1) 虚构事实，即编造某种根本不存在的或者不可能发生的，足以使他人受蒙蔽的事实，骗取他人财物。例如，谎称能代被害人购买某种廉价商品或提供某种服务；谎称能代被害人疏通关系，打赢官司；谎称能为被害人治病；等等。这类诈骗，常常是利用有些人缺乏警惕，或愚昧无知，或贪财图利等心理，而使之受害。

(2) 隐瞒真相，即隐瞒客观上存在的事实情况，既可以是隐瞒部分事实真相，也可以是隐瞒全部事实真相。行为人往往通过隐瞒真相的方法，使公私财物所有人、管理人陷入错误，从而“自愿”交付财物。

根据最高人民法院2000年《关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》第9条的规定，以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话，造成电信资费损失数额较大的，以诈骗罪定罪处罚。

诈骗公私财物数额较大，方能构成诈骗罪。数额较大是构成诈骗罪的一个必要条件。根据最高人民法院、最高人民检察院2011年《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《诈骗解释》）第1条的规定，诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为《刑法》第266条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

5 如何具体区分侵占罪与盗窃罪？

答：侵占罪和盗窃罪都以他人财物为对象，都侵犯了公私财物的所有权，主观上都是故意，并都以非法占有他人财物为目的，这是二者的共同之处。但是，二者有着明显的区别。

（1）犯罪故意的内容和产生时间不同。

前者行为人认识到自己是以非暴力的手段非法占有自己业已持有的他人财物，且犯罪故意只能产生于持有他人财物之后；后者行为人认识到自己是以不为财物所有人或持有人知道的秘密方法非法获取他人财物，且犯罪故意只能产生于非法获取他人财物之前。

（2）客观表现不同。

侵占行为的突出特点是“变合法持有为非法所有”，前提条件是行为人业已合法持有他人财物，具体包括两种情况：一是以合法的方式代为保管他人的财物。二是合法占有他人的遗忘物或者埋藏物。侵占行为是将合法持有的财物非法据为己有，拒不退还或者拒不交出。而盗窃罪在客观方面一般表现为以秘密窃取的方法，将公私财物转移到自己的控制之下，并非法占有的行为。

（3）犯罪对象不同。

侵占罪的犯罪对象包括以合法的方式代为保管的他人财物、合法占有的他人的遗忘物或者埋藏物。其中，埋藏物，一般指埋藏于地下的财物。从司法实践看，侵占埋藏物的行为，以合法持有该埋藏物为前提，一般主要表现为行为人在进行地面挖掘时，偶然发现地下埋藏物，不知物主是谁，而将其占为己有。如果行为人明知某处埋藏有某人的财物，或者明知某古墓埋藏有古代珍贵文物，以非法占有为目的进行挖掘，将所有财物据为己有，则应分别以盗窃罪或盗掘古墓葬罪论处。

第二十二章 妨害社会管理秩序罪

1 试述妨害公务罪公务活动合法性的判断及其认定。

答：妨害公务罪是指以暴力、威胁的方法，阻碍国家机关工作人员、人大代表、红十字会工作人员依法执行职务、履行职责，或者故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的行为。

(1) 公务活动合法性的判断，需满足以下三个条件：

① 国家机关工作人员所实施的行为，属于该国家机关工作人员的抽象的职务权限或一般的职务权限。基于法治主义的原理，国家机关工作人员的职务具有事项上、场所上的范围，此即一般的职务权限，如果超出了这种一般的职务权限，则不能认定为依法执行职务。但国家机关工作人员如何分担内部事务，则不影响其职务权限。

② 国家机关工作人员具有实施该职务行为的具体的职务权限。在通常情况下，具有实施某种职务行为的抽象的职务权限的人，也具有实施该职务行为的具体的权限，但也存在两者不一致的情形，即在某些情况下虽然有抽象的职务权限，却无具体的职务权限。特别是在实际上需要通过分配、指定、委任才能实施某种职务行为时，只有经过分配、指定、委任，才能认为具有具体的职务权限，否则没有具体的职务权限。

③ 国家机关工作人员的职务行为必须符合法律上的重要条件、方式与程序。在许多情况下，职务行为要取得合法性，必须符合法律规定的重要条件、方式与程序。但应注意的是，对于法律上的一些任意规定，国家机关工作人员在执行职务时予以违反的，不应认为是非法执行职务。

(2) 公务活动合法性的认定

实践中，行为人有时可能会对国家机关工作人员职务行为的合法性产生认识错误。对此，刑法理论中存在不同的观点：

第一种观点认为，这种认识错误属于对法律的认识错误，不影响故意的成立，因而不影响本罪的成立。

第二种观点认为，这种认识错误属于对事实的认识错误，影响故意的成立，因而不成立本罪。

第三种观点则认为，这种认识错误应视具体情况而定，即应区分作为合法性基础的事实与合法性的评价，对前者的认识错误属于事实认识错误，影响本罪的成立；对后者

的认识错误属于法律认识错误，不影响本罪成立。

第四种观点认为，执行职务的合法性，只是客观处罚条件，故不要求对之有认识。

对公务活动合法性的认定应该基于上述第二种观点，因为国家机关工作人员依法执行职务这一要素，属于妨害公务罪的客观构成要件，对其产生认识错误理当属于事实认识错误。

2 试述非法侵入计算机信息系统罪的构成特征。

答：非法侵入计算机信息系统罪，是指违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的行为。本罪的构成特征是：

(1) 本罪侵犯的客体为国家对计算机信息系统安全的管理秩序和国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的正常活动。计算机信息系统是指由计算机及其相关的网络、设备、设施构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。随着计算机技术的发展和计算机的普及，计算机在国家各项事务中的使用越来越广泛，国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统也已广泛建立。这些计算机信息系统的正常运行，对于保障国家安全、经济发展和保护人民生命财产安全都起着十分重要的作用。这些重要的计算机信息系统一旦被非法侵入，就可能导致其中的重要数据遭受破坏或者某些重要、敏感的信息被泄露，不但系统内可能产生灾难性的连锁反应，还会造成严重的政治、经济损失，甚至还可能危及人民的生命财产安全。因此，对于此类非法侵入国家重要领域计算机信息系统的行为必须予以严厉打击。

(2) 本罪在客观方面表现为违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的行为。这里的违反国家规定，是指违反全国人大常委会制定的《关于维护互联网安全的决定》和国务院公布的《计算机信息系统安全保护条例》《计算机信息网络国际联网管理暂行规定》等规定。侵入，是指未经有关部门的合法授权与批准，使用破密、解码等技术擅自通过计算机终端访问国家事务、国防建设和尖端科学技术领域的计算机信息系统或者进行数据截收。

(3) 本罪主体为已满16周岁并具有刑事责任能力的自然人。

(4) 本罪在主观方面表现为非法侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的故意。

3 如何把握聚众扰乱社会秩序罪的构成特征？

答：聚众扰乱社会秩序罪，是指聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研、医疗无法进行，造成严重损失的行为。本罪的构成特征是：

(1) 本罪侵犯的客体为正常的社会秩序，具体表现为国家机关、企业、事业单位、人民团体、医疗单位正常的工作秩序、生产经营秩序、教学科研秩序和医疗秩序。

(2) 本罪在客观方面表现为聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研、医疗无法进行，造成严重损失的作为。此处所谓聚众，是指首要分子发动、纠合3人以上，在同一地点聚集。其中可以包括首要分子、积极参加者或者其他参加者，也可以是首要分子隐藏幕后唆使、策划而不亲自实施扰乱行为。所谓扰乱，是指对国家机关、企业、事业单位、人民团体、医疗单位的正常工作、生产、营业和教学、科研、医疗秩序进行干扰、破坏，如聚众在机关、单位门前、院内纠缠、哄闹，强占办公室、会议室、实验室、营业场地、生产车间、医护室或其他工作场所，封锁其出入通道，围攻、谩骂、强行留置有关单位的负责人或其工作人员等。此处的情节严重，一般是指聚众扰乱的时间长、纠合的人数多或造成的影响恶劣等。严重损失则主要是指导致被扰乱的单位停工、停产、停学、停业、停医，或者造成严重的经济损失，以及严重损害被害单位的形象和声誉等。

(3) 本罪的主体为年满16周岁并具有刑事责任能力的聚众扰乱社会秩序的首要分子和积极参加者。对一般参与者不能以本罪论处。此处所谓首要分子，是指在扰乱社会秩序活动中起组织、策划、指挥作用的人；所谓积极参加者，则是指主动参加扰乱社会秩序活动并起主要作用的人。

(4) 本罪的主观方面为聚众扰乱社会秩序的故意。

4 如何认定聚众斗殴罪？

答：聚众斗殴罪，是指基于私仇宿怨、争霸一方或者其他藐视法纪的动机，在首要分子的组织、策划、指挥下结伙成帮地进行殴斗，破坏公共秩序的行为。聚众斗殴罪的认定需要注意以下几点：

(1) 本罪与群众间因民事纠纷而发生的一般打斗行为的界限

社会生活中存在各种不同性质的矛盾，因而解决矛盾的手段也应该多种多样。具体而言，对于公民间因日常生活中产生的民事纠纷激化而发生的多人之间的打斗，以及山区或少数民族地区村寨之间因土地、山林、水源等纠纷而发生的双方结伙殴斗行为，不宜按本罪论处。其中没有发生严重后果的，应视为情节显著轻微、危害不大的情

况，按一般违法行为处理；造成严重后果的，则应根据严重后果的性质及行为人的主观心理状态以其他有关犯罪论处。

(2) 单方斗殴行为是否构成聚众斗殴罪

聚众斗殴犯罪中只要其中一方主观上是为了达到显示、炫耀武力，争霸一方，抢占地盘等目的，客观上纠集众人、结伙殴打另一方，不论对方是否与之互殴，均符合该罪的犯罪构成，该方积极参加者均可构成聚众斗殴罪。

(3) 不满3人而参与斗殴是否构成聚众斗殴罪

在聚众斗殴犯罪中，参与斗殴的一方只有1人或2人，不宜认定为构成聚众斗殴罪。因为聚众斗殴罪的客观行为具有复合性，包含“聚众”与“斗殴”两个连续的行为，两者有机联系、缺一不可。应根据案件的具体情况，以故意伤害罪、故意杀人等其他犯罪论处；若该方实施了聚众行为，只是因为其他情况召集的人未及时赶到斗殴现场的，该方则仍应构成聚众斗殴罪。

(4) 本罪与故意伤害罪、故意杀人罪的界限

若聚众斗殴行为致人重伤、死亡的，应根据《刑法》第292条第2款的规定，以故意伤害罪或故意杀人罪定罪处罚。

5 在网络空间里，如何认定寻衅滋事罪之所谓“造成公共场所秩序严重混乱”？

答：寻衅滋事罪，是指寻衅滋事，破坏社会秩序的行为。其具体表现为在公共场所无事生非，起哄闹事，随意殴打、追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，强夺硬要，任意损毁、占用公私财物，破坏公共秩序，情节严重的行为。关于在网络空间寻衅滋事的认定问题，主要在《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《网络诽谤解释》）中予以规定：

(1) 《网络诽谤解释》第5条第1款规定：“利用信息网络辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序的，依照刑法第二百九十三条第一款第（二）项的规定，以寻衅滋事罪定罪处罚。”

(2) 第5条第2款规定：“编造虚假信息，或者明知是编造的虚假信息，在信息网络上散布，或者组织、指使人员在信息网络上散布，起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的，依照刑法第二百九十三条第一款第（四）项的规定，以寻衅滋事罪定罪处罚。”

(3) 《网络诽谤解释》第5条第2款的规定则引起了极大的争议，其核心问题便在于网络空间是否属于公共场所以及网络空间秩序是否属于公共秩序。我们持肯定态度，将

网络空间解释为公共场所。理由如下：

- ① 因社会生活的客观需要，需要对刑法中的“公共场所不包括网络空间”这一立法原意进行改变。
- ② 不能将体系解释绝对化。《刑法》第291条聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪因其条文表述的局限，其规定的“公共场所”只能是现实世界真实的物理空间，不包括信息网络中的虚拟空间，但不能据此否认《刑法》第293条寻衅滋事罪也排斥网络空间，因为寻衅滋事罪的相关条款的表述为纳入网络空间留了解释的余地。
- ③ 网络空间具有公共性，将网络空间解释为“公共场所”并没有“超出法律用语可能含义的范围”，不违背国民预测的可能性。
- ④ 将网络空间解释为“公共场所”，不会因此而侵犯宪法所规定的言论自由。

6 试述黑社会性质组织的基本特征。

答：根据《刑法修正案（八）》第43条修正的《刑法》第294条第5款的规定，黑社会性质组织应当同时具备以下特征：

（1）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。这是黑社会性质组织的组织结构特征。具体而言，包括：

- ① 组织者、领导者，是指黑社会性质组织的发起者、创建者，或者在组织中实际处于领导地位，对整个组织及其运行、活动起着决策、指挥、协调、管理作用的犯罪分子，既包括通过一定形式产生的有明确职务、称谓的组织者、领导者，也包括在黑社会性质组织中被公认的事实上的组织者、领导者。
- ② 积极参加者，是指接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，或者积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，以及其他在组织中起重要作用的犯罪分子，如具体主管黑社会性质组织的财务等事项的犯罪分子。
- ③ 其他参加者，是指除上述组织成员之外，其他接受黑社会性质组织的领导和管理

的犯罪分子。

（2）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。此为黑社会性质组织的经济实力特征。无论其财产是通过非法手段聚敛，还是通过合法的方式获取，只要将其中部分或全部用于违法犯罪活动或者维系犯罪组织的生存、发展即可。

(3) 以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。这是黑社会性质组织的行为方式和特征。具体而言，包括：

① 所谓“暴力”，泛指侵害他人人身、财产的暴力行为；“威胁”则指以暴力逼迫、恫吓，通过精神强制使人屈服；“其他手段”主要包括：以暴力、威胁为基础，在利用组织势力和影响对他人形成心理强制或威慑的情况下，进行所谓的“谈判”“协商”“调解”，滋扰、哄闹、聚众等其他干扰、破坏正常经济、社会生活秩序的非暴力手段。

② “黑社会性质组织实施的违法犯罪活动”主要包括以下情形：由组织者、领导者直接组织、策划、指挥、参与实施的违法犯罪活动；由组织成员以组织名义实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的违法犯罪活动；多名组织成员为逞强争霸、插手纠纷、报复他人、替人行凶、非法敛财而共同实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的违法犯罪活动；组织成员为组织争夺势力范围、排除竞争对手、确立强势地位、谋取经济利益、维护非法权威或者按照组织的纪律、惯例、共同遵守的约定而实施的违法犯罪活动；由黑社会性质组织实施的其他违法犯罪活动。

(4) 通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。此为黑社会性质组织的危害性特征，也是黑社会性质组织的本质特征，是黑社会性质组织区别于一般犯罪集团的关键所在。具体而言，包括：

① 对于“一定区域”，应当根据具体案情，并结合黑社会性质组织对经济、社会生活秩序的危害程度加以综合分析判断；“一定行业”，既包括合法行业，也包括黄、赌、毒等非法行业。

② “形成非法控制或重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”，包括以下情形：对在一定区域内生活或者在一定行业内从事生产、经营的群众形成心理强制、威慑，致使合法利益受损的群众不敢举报、控告的；对一定行业的生产、经营形成垄断，或者对涉及一定行业的准入、经营、竞争等经济活动形成重要影响的情形等。

7 承办案件的警察能否成为伪证罪主体中的“证人”？

答：一般情况下，警察不能成为伪证罪主体中的“证人”，但存在例外情形。

伪证罪的主体是特殊主体，只能由参加刑事诉讼的证人、鉴定人、记录人、翻译人构成。其中证人是指与刑事案件无直接利害关系的、向司法机关提供自己知道的案件情况的诉讼参与人；鉴定人，是指受司法机关指派、聘请，对案件中某些专门性的问题进行鉴定并提出书面意见的具有专门知识的诉讼参与人；记录人，是指司法机关在案

件的侦查、起诉和审判过程中，为调查、搜查、询问证人、被害人或者审讯被告人担任文字记录的人，这里的记录人仅指公安局、检察院、法院在刑事案件中担任记录的人；翻译人，是指在诉讼中受司法机关的指派或者聘请担任外国语、民族语或者哑语翻译的诉讼参与人，包括对语言进行直接翻译及对外国语、民族语、哑语、盲文资料等进行书面翻译的人。

(1) 在刑事诉讼活动中，警察不是“作证者”，而是查找、发现“作证者”并及时收集证据的人，其法定职责是全面客观地收集证据，努力实现司法公正，不枉不纵。

(2) 需要注意的是，在刑事诉讼活动中，警察并非任何时候都不能成为证人，不能成为伪证罪的主体。当刑事侦查活动本身的行为和情节接受司法机关调查，需要涉事警察作证来证明其中的事实时，如法官检察官调查刑讯逼供事件时，警察此时的角色就是证人，他的行为就是作证。如果有伪证行为且情节严重，则构成伪证罪。

8 如何看待与我国古代“亲亲相隐”原则的冲突？

答：“亲亲相隐”原则，是指亲属之间有罪应当互相隐瞒，不告发和作证的不论罪，反之要论罪的制度。

(1) “亲亲相隐”是古代刑律的一项原则，其目的是维护宗法伦理和家族制度。在我国古代刑法史上，历朝历代都在重视对藏匿、包庇犯人的处罚的同时，而对亲属之间藏匿、包庇的行为予以特别的宽容，一般不处罚或者从宽处罚。现在，各国立法都承认亲属之间也可以构成包庇罪的主体，只是在处罚时会酌情从宽。

(2) 我国刑法规定，包庇罪的主体是一般主体，即已满16周岁并具备刑事责任能力的自然人，即犯罪分子的亲属能够成为窝藏罪的主体。很显然“法律面前人人平等”和古代“亲亲相隐”原则相冲突，根据“法律面前人人平等”，任何人在法律面前都没有特权，即使是犯罪嫌疑人或者被告人的亲属也不例外，这是贯彻公正司法原则的应有之义。这一冲突一定程度也可以理解为“情与法”的冲突，这就要求裁判者正确处理这一冲突，坚持公正司法，同时适当考虑“亲亲相隐”原则下的酌情从宽，以维护法律正义。

9 如何理解“犯罪”所得及其收益？

答：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒。其犯罪对象为犯罪所得及其产生的收益，应作以下理解：

(1) 犯罪所得，是指犯罪所得的赃物，即通过犯罪行为所获得的财物或财产性利益，故犯罪工具、犯罪本身所产生之物（如伪造的货币、制造的毒品）等不属于本罪的赃物。

(2) 犯罪所得产生的收益，是指利用犯罪所得的赃物获得的利益，如受贿存入银行后所获得的利益、利用走私犯罪所得投资房地产所获取的利润等。

(3) 犯罪所得及其产生的收益的范围是认定本罪与非罪的重要界限，关于未达到法定年龄、没有责任能力的人，实施盗窃、诈骗等行为所取得的财物，能否认定为“犯罪所得”等问题还需要学界进一步讨论、研究。

10 被超期羁押的人能否构成脱逃罪的主体？

答：一般情况下，被超期羁押的人可以构成脱逃罪的主体，具体分析如下：

脱逃罪是指依法被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人从羁押、监管场所脱逃的行为。本罪的主体是特殊主体。其包括被关押于服刑场所正在服刑的罪犯和被拘留、逮捕后关押在看守所的犯罪嫌疑人、被告人。未被羁押的犯罪嫌疑人、被告人不构成本罪。具体包括以下几种情形：

(1) 错羁错捕、错判的无辜者逃跑的，如果完全是因为司法机关的错误，不应以脱逃罪论处。

(2) 如果司法机关在关押的当时符合法定的程序和实体条件，就属于依法关押，被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人即使本身确实无罪，其脱逃行为也构成脱逃罪。

(3) 被民事拘留、行政拘留的人员，被司法机关采取拘传、取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人，以及被判管制、缓刑或被假释的犯罪分子，不能成为脱逃罪的主体。

11 如何理解有学者认为妨害传染病防治罪系外国刑法理论中的“过失危险犯”？

答：妨害传染病防治罪，是指违反传染病防治法的规定，引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的行为。学者认为妨害传染病防治罪系外国刑法理论中的“过失危险犯”存在合理之处，但也有否定意见。

(1) 肯定意见

过失危险犯，一般是指行为人严重违反某规章管理规定，从而过失地使重大法益处于

严重危险状态，由于偶然因素的介入而没有发生严重实害结果的犯罪。学者认为妨害传染病防治罪属于过失危险犯，主要是因为甲类传染病（鼠疫、霍乱）和检疫传染病（鼠疫、霍乱、黄热病以及国务院确定和公布的其他传染病）都是传播快、流行广、严重危害人们生命、健康安全的疾病，特别是鼠疫、霍乱等传染病，死亡率极高，一旦传播流行，就会对社会人群构成巨大威胁。因此，适用刑法尽可能地将此类危险行为控制住，对行为人过失引起甲类传染病严重传播危险的行为也应处罚。

此外，过失危险犯之所以成为一种犯罪根源于其自身的社会危害性。过失危险犯在主观上置重大法益于不顾，漠视社会责任，表现出一种严重的人身危险性，具有主观上非难的可能性；其在客观上违反重大注意义务，以至于使刑法所保护的社会关系处于一种严重的危险状态之中，具有客观上非难的可能性，正是这种主观危害和客观危害的有机统一构成了对过失危险犯归责的基础。

（2）否定意见

也有学者并不赞同将妨害传染病防治罪认定为过失危险犯。理由在于：妨害传染病防治罪主观方面既可以是故意，也可以是过失。主观是故意时，只要行为有危险即可构成犯罪；主观是过失时，只有行为引起检疫传染病传播才可构成犯罪。因为危害结果是限制过失责任的客观尺度，脱离这一标准，不仅会无限制地扩大犯罪过失的范围，也会丧失认定犯罪过失的客观依据。因此只承认故意行为犯和过失实害犯，不承认过失危险犯的存在。

12 医疗机构及单位的党政、后勤人员能否构成医疗事故罪的主体？

答：医疗机构及单位的党政、后勤人员可以构成医疗事故罪的主体。

医疗事故罪，是指医务人员在医务工作中严重不负责任，造成就诊人死亡或者严重损害就诊人身体健康的行为。本罪的主体是特殊主体，即国家正式批准有权从事医疗职业的医务人员。医务人员包括医疗人员、卫生防疫人员、护理人员、医疗技术人员，其中医疗技术人员又包括化验人员、药剂人员、麻醉人员、放射人员等。除了这四类人员以外，医疗辅助人员如救护车司机、电工等，则不能成为本罪的主体。

对本罪主体的判断，应从职责范围、具体工作范畴等角度综合进行。医疗机构工作人员大致分为四类：

（1）卫生技术人员，主要在医疗机构内直接从事医疗卫生保健服务。

（2）工程技术人员，主要是对医疗机构的建筑、设备、设施进行规划、选择、维修和研发，以保障医疗机构中的各种设备和设施正常运行。

(3) 工勤人员，是指医疗机构内从事各项后勤服务的人员，包括炊事员、保洁工等。

(4) 行政管理人员，因职务的不同而各司其职，各尽其责，如我国实施院长负责制后，院长就是该医疗机构的最高行政管理人员。本罪的主体应当以目前行政法规中关于“医疗活动”范围所涉及的人员为准，该人员的职责和工作行为必须与就诊人的生命、健康有关，如若违反相关规定，就应依照本罪进行处罚。

13 如何认定污染环境罪的因果关系？

答：污染环境罪，是指违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的行为。本罪在客观方面表现为违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的行为。排污行为与环境污染的结果之间必须有因果关系。这种因果关系与一般因果关系相比呈现出复杂性和隐蔽性，表现在以下几个方面：

(1) 主体的相互作用的复杂性。一次污染事故往往是由不同行为主体同时向环境中排放废气、废水、废渣的行为，污染源间反应、变化而引起的。

(2) 污染物传输过程的复杂性。各种污染物排入环境后，互相之间及其与环境各要素之间会进行多种物理的、化学的、生物的作用或反应，其各自的数量和形态都会发生变化。

(3) 结果的复杂性。污染行为往往不是立即发生的，违法排污行为与发生环境污染的结果之间的间隔时间可能相当长。

(4) 常常涉及高科技的背景。一般人包括司法人员往往不具有这样的知识，判断这类犯罪的因果关系的难度通常极大，需要花费相当的时间、人力、物力。

14 如何区别运输毒品罪与非法持有毒品罪？

答：运输毒品罪，是指采用携带、邮寄、利用他人或者使用交通工具等方法在我国领域内将毒品从此地转移到彼地的行为；非法持有毒品罪，是指非法持有毒品的行为。

关于运输毒品罪与非法持有毒品罪的界限，争议主要在于身处甲地的行为人为了自己吸食毒品而去乙地购买，并将毒品携带到甲地的行为应如何定性。有学者认为，只要具有位移的持有就是运输毒品，而无位移的持有是非法持有毒品。本书认为，运输毒品与非法持有毒品的区别应在于为自己运输还是为他人运输（无走私、贩卖、制造等

行为的前提下），前者应为非法持有毒品，后者为运输毒品。如果没有证据证明行为人运输毒品的行为是为了他人，就只能根据非法持有毒品罪来定罪量刑。

15 如何理解“淫秽物品”？

答：传播淫秽物品罪，是指传播淫秽的书刊、影片、音像、图片或者其他淫秽物品，情节严重的行为。本罪侵犯的客体是复杂客体，其既侵害了国家对文化生活的管理制度，同时又妨害了社会主义社会风俗理念。

本罪的犯罪对象是淫秽物品。根据《刑法》第367条的规定，“淫秽物品”是指具体描绘性行为或者露骨宣扬色情的淫秽性的书刊、影片、录像带、录音带、图片及其他淫秽物品。有关人体生理、医学知识的科学著作不是淫秽物品。包含色情内容的有艺术价值的文学、艺术作品不视为淫秽物品。“其他淫秽物品”包括具体描绘性行为或者露骨宣扬色情的淫秽性的视频文件、音频文件、电子刊物、图片、文章、短信息等互联网、移动通信终端电子信息和声讯台语音信息。

第二十三章 危害国防利益罪

1 危害国防利益罪的概念与特征是什么？

答：（1）危害国防利益罪的概念

危害国防利益罪，是指违反国防法律、法规，拒绝或者逃避国防义务，危害作战和军事行动，妨害国防管理秩序，或者以其他形式危害国防利益，依法应受刑罚处罚的行为。

（2）危害国防利益罪的特征

① 本类犯罪侵犯的客体是国防利益。“国防”，是指国家为了防备和抵抗侵略，制止武装颠覆，保卫国家的主权、统一、领土完整和安全所进行的军事活动，以及与军事有关的政治、经济、外交、科技、教育等方面的活动。

② 本类犯罪在客观方面表现为违反国防法律、法规，严重危害国防利益的行为。

a. 从行为内容来看，由于军队直接承担国防义务，故此类犯罪行为以破坏武器装备与军事设施、阻碍军人执行职务或阻碍军事行动、妨害部队管理、扰乱军事区域秩序、逃避军事义务等为主。

b. 从表现形式来看，行为方式多种多样，作为和不作为均可构成。

c. 从时间场合来看，有些危害国防利益的行为只有在战时实施才能构成犯罪，有些行为无论是平时实施还是战时实施都构成犯罪。

d. 从危害结果看，这种危害既可以表现为已造成一定的损害结果，也可以表现为足以造成危害国防利益的结果。

③ 本类犯罪的主体既有自然人，也有单位。大部分犯罪主体是一般主体，个别犯罪只能由特殊主体构成。

④ 本类犯罪的主观方面一般为故意。在本章犯罪中，除过失提供不合格武器装备、军事设施罪外，其他犯罪的主观方面均为故意。

2 试述阻碍军人执行职务罪与妨害公务罪的主要区别。

答：（1）二者的概念

① 阻碍军人执行职务罪，是指非军职人员利用暴力、威胁方法，阻碍军人依法执行职务的行为。

② 妨害公务罪，是指以暴力、威胁方法阻碍国家工作人员依法执行职务的行为。

(2) 本罪与妨害公务罪在客观方面均表现为以暴力、威胁的方法阻碍执行职务的行为，在主观方面均是故意犯罪，有其相似之处，二者区别如下：

① 侵犯的客体不同。本罪侵犯的客体是国防利益；后者侵犯的客体是公共秩序。

② 犯罪对象不同。本罪的犯罪对象是依法执行职务的军人；后者的犯罪对象是国家机关工作人员、人大代表、红十字会工作人员或国家安全机关、公安机关依法执行公务的人员。

③ 犯罪主体不同。本罪的犯罪主体是指除现役军人之外的普通公民；后者的犯罪主体为一般主体，即现役军人也可构成。

3 如何区分破坏武器装备、军事设备、军事通信罪与相关犯罪的界限？

答：(1) 破坏军事通信，并造成公用电信设施损毁，危害公共安全，同时构成破坏广播电视设施、公用电信设施罪和破坏武器装备、军事设施、军事通信罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。它们在犯罪的主体、对象、犯罪的手段、犯罪的故意等方面有相同之处。其主要区别在于：

① 本罪属于危害军事利益的犯罪，而后几种罪是危害公共安全的犯罪。

② 本罪破坏的对象只限于军事设施，而后几种罪破坏的对象不限于军事设施。

(2) 盗窃军事通信线路、设备，不构成盗窃罪，但破坏军事通信的，依照《刑法》第369条第1款的规定定罪处罚；同时构成《刑法》第124条、第264条（盗窃罪）和第369条第1款规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

(3) 违反国家规定，侵入国防建设、尖端科学技术领域的军事通信计算机信息系统，尚未对军事通信造成破坏的，依照非法侵入计算机信息系统罪定罪处罚；对军事通信造成破坏，同时构成《刑法》第285条、第286条（破坏计算机信息系统罪）、第369条第1款规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

(4) 违反国家规定，擅自设置、使用无线电台、站，或者擅自占用频率，经责令停止使用后拒不停止使用，干扰无线电通信正常进行，构成犯罪的，依照扰乱无线电管理秩序罪定罪处罚；造成军事通信中断或者严重障碍，同时构成《刑法》第288条、第

369条第1款规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

(5) 本罪与故意毁坏财物罪的界限。本罪是一种比故意毁坏公私财物罪的危害大得多的犯罪，它的严重性不仅仅在于被破坏的武器装备、军事设施、军事通信的财产价值，而是在于这种破坏行为能够使武器装备丧失其应有的效能，从而严重影响我军的战备和战斗能力。二者主要区别是：① 侵犯的客体不同。本罪侵犯的客体是与武器装备的使用能力相联系的军事利益，而后者侵犯的客体是公私财物的所有权；② 本罪破坏的是特定对象，即武器装备、军事设施、军事通信，后者破坏的对象，是各种公私财物。据此，非军职人员破坏武器装备、军事设施、军事通信以外的一般财物，如生活用品、办公设备等，或者破坏武器装备、军事设施、军事通信的局部，并不影响其使用的，应依故意毁坏财物论处。

(6) 用放火、爆炸等危险方法破坏武器装备、军事设施、军事通信的行为的定性。用放火、爆炸等危险方法破坏武器装备、军事设施、军事通信，属于牵连犯，应按照重罪吸收轻罪的原则，以放火罪、爆炸罪定罪处罚。

第二十四章 贪污贿赂罪

1 如何界定“国家工作人员”的概念和范围？

答：（1）国家工作人员的概念

国家工作人员是指一切国家机关、国有企业、事业单位和其他依照法律从事公务的人员。

（2）国家工作人员的范围

① 国家机关中从事公务的人员。

a. 各级国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关中从事公务的人员。

b. 依照法律、法规规定行使国家行政管理职权的组织中从事公务的人员。

c. 受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员。

d. 虽未列入国家机关人员编制但在国家机关中从事公务的人员。

e. 在乡（镇）以上中国共产党机关、人民政协机关中从事公务的人员。

② 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员。

③ 国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员。

④ 其他依照法律从事公务的人员。

2 如何理解贪污罪的构成要件？贪污罪的认定需注意哪些问题？

答：（1）贪污罪的构成要件

① 本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯公职人员的职务廉洁性，又侵犯公共财产所有权。其中，公职人员的职务廉洁性是本罪的主要客体。

② 本罪在客观方面表现为行为人利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

③ 本罪的主体是特殊主体。具体包括两类人员：第一类是国家工作人员；第二类是受委托管理、经营国有财产的人员，主要是指因承包、租赁、临时聘用等授权管理、经营国有财产的人员，不应包括国有单位正式、长期聘用的工作人员。

④ 本罪的主观方面是故意，并且以非法占有为目的，而非暂时地使用。

(2) 贪污罪认定需注意的问题

① 贪污罪与盗窃罪、诈骗罪、侵占罪的区别

a. 犯罪的客体 and 对象不同。本罪的客体是复杂客体，即国家公职人员的职务廉洁性和公共财产所有权，对象是公共财物；盗窃罪、诈骗罪、侵占罪的客体是简单客体，即公私财产所有权，对象是公私财物。

b. 客观方面不同。本罪的侵吞、窃取、骗取，是利用职务上的便利进行的；侵占罪、盗窃罪、诈骗罪的侵吞、窃取、骗取则不存在利用职务上的便利问题。

c. 犯罪主体不同。本罪的主体是特殊主体，即国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员；侵占罪、盗窃罪、诈骗罪的主体是一般主体。

② 贪污罪与职务侵占罪的区别

a. 犯罪客体不同。本罪是复杂客体，既侵犯国家公职人员的职务廉洁性，也侵犯公共财产所有权；职务侵占罪的客体则是简单客体，即只侵犯单位财物所有权。

b. 犯罪主体不同。本罪的主体是国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员；职务侵占罪的主体则是公司、企业中不具有国家工作人员身份的工作人员。

③ 既遂与未遂的认定

a. 贪污罪以行为人是否实际控制财物作为区分贪污罪既遂与未遂的标准。

b. 行为人控制公共财物后，是否将财物据为己有，不影响贪污罪既遂的认定。

④ 非国有公司、企业中的国家工作人员与非国家工作人员相勾结共同非法占有本单位财物行为的认定

a. 非国家工作人员与国家工作人员相勾结，利用国家工作人员职务上的便利共同非法占有本单位财物的，按贪污罪的共同犯罪处理。

b. 国家工作人员与非国家工作人员相勾结，利用非国家工作人员职务上的便利共同非法占有本单位财物的，按职务侵占罪的共同犯罪处理。

c. 国家工作人员与非国家工作人员相勾结，分别利用各自的职务上的便利共同非法占有本单位财物的，按照主犯的犯罪性质定罪。如果根据案件的实际情况，各共同犯罪人在共同犯罪中的地位、作用相当，难以区分主从犯的，可以贪污罪定罪处罚。

⑤ 国有公司、企业改制过程中贪污罪的认定

a. 国家工作人员或者受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员利用职务上的便利，在国家出资企业改制过程中故意通过低估资产、隐瞒债权、虚设债务、虚构产权交易等方式隐匿公司、企业财产，转为本人持有股份的改制后公司、企业所有，应当依法追究刑事责任的，以贪污罪定罪处罚。

b. 改制后的公司、企业中只有改制前公司、企业的管理人员或者少数职工持股，改制前公司、企业的多数职工未持股的，以贪污罪定罪处罚。

c. 国家工作人员利用职务上的便利，在国家出资企业改制过程中隐匿公司、企业财产，在其不再具有国家工作人员身份后将所隐匿财产据为己有的，以贪污罪定罪处罚。

3 如何理解挪用公款罪的构成要件？挪用公款罪的认定需注意哪些问题？

答：（1）挪用公款罪的构成要件

① 本罪侵犯的客体是复杂客体，即本罪既侵犯国家公职人员的职务廉洁性，也侵犯公共财产的所有权部分权能，即占有权、使用权、收益权。

② 本罪在客观方面表现为行为人利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动；或者挪用公款数额较大，进行营利活动；或者挪用公款数额较大，超过3个月未还的行为。

③ 本罪的主体是特殊主体，即只能由国家工作人员构成。

④ 本罪的主观方面是故意，即明知其是公款而有意违反有关规定予以挪用，其目的是暂时使用公款。

（2）挪用公款罪认定需注意的问题

① 挪用公款罪与贪污罪的区别

- a. 次要客体存在一定差别。挪用公款罪的次要客体限于公共财物的占有、使用、收益权；贪污罪的次要客体是公共财产所有权。
- b. 犯罪对象不同。挪用公款罪的对象原则上限于公款，法定的例外情形下包括特定公物；贪污罪的对象既包括公款，也包括其他公共财物。
- c. 客观方面的行为方式不同。本罪表现为利用职务上的便利挪用公款进行非法活动，或者挪用公款数额较大进行营利活动，或者挪用公款数额较大超过3个月未还；贪污罪的客观方面表现为利用职务上的便利，以侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。实施本罪的行为人通常不存在做假账、虚报账目等行为；实施贪污罪的行为人往往有做假账、虚报账目等行为。
- d. 主体的范围不同。本罪的主体只能是国家工作人员；贪污罪的主体除了国家工作人员以外，还可以由受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员构成。
- e. 主观目的不同。本罪以暂时使用公款为目的；贪污罪则以非法占有公共财物为目的。

② 挪用公款罪与挪用资金罪的区别

- a. 犯罪的客体 and 对象不同。本罪的客体是复杂客体，既侵犯公共财产的所有权，也侵犯国家公职人员职务的廉洁性，犯罪的对象是公款；挪用资金罪的客体是简单客体，即只侵犯单位资金的所有权，犯罪的对象是非国有单位的资金。
- b. 犯罪的主体不同。本罪的主体是国家工作人员；挪用资金罪的主体则是非国有公司、企业或者其他单位的不具有国家工作人员身份的人员。

③ 挪用公款罪与挪用特定款物罪的区别

- a. 犯罪的客体不同。二者的侵犯客体都是复杂客体，都有侵犯公共财产权利的一面，但本罪同时还侵犯国家工作人员的职务廉洁性，而挪用特定款物罪同时还侵犯国家特定款物的财经管理制度。
- b. 犯罪的客观行为要件有所不同。本罪在客观上只要求挪用公款归个人使用并达到一定的数额标准，不包含造成一定的损害结果；挪用特定款物罪则在客观上要求致使国家和人民群众利益遭受重大损害的结果发生，否则不构成犯罪。
- c. 犯罪的对象不同。本罪的犯罪对象包括特定款物；挪用特定款物罪的对象仅限于特定款物，即救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物。

d. 犯罪的主体不同。本罪的主体是国家工作人员，而挪用特定款物罪的主体则是主管、经管、经手特定款物的直接责任人员。

e. 挪用用途不同。本罪一般是挪用公款归个人；挪用特定款物罪是将特定款物挪归单位其他事项使用，未能专款专用。

4 如何理解受贿罪中的“财物”？

答：根据《贪污案件解释》第12条，受贿罪中的“财物”包括：

(1) 货币。

(2) 物品。

(3) 财产性利益。其中，财产性利益包括：

① 可以折算为货币的物质利益如房屋装修、债务免除等。

② 需要支付货币的其他利益如会员服务、旅游等。

5 如何看待贪污受贿犯罪定罪量刑标准的立法修改？

答：（1）《刑法修正案（九）》对贪污受贿犯罪定罪量刑标准的修改主要有三个方面：

① 取消原来的具体数额标准，采用数额加情节的标准，并且量刑相对较轻的档次中增加规定并处罚金刑，使并处财产刑贯穿到贪污受贿罪的全部量刑档次。

② 进一步补充对贪污受贿犯罪从轻、减轻、免除处罚的条件。

③ 增加规定对被判处死缓的重特大贪污受贿犯，在死缓执行二年期满依法减为无期徒刑后，不得减刑、假释的终身监禁制度。

（2）前述修改使得贪污受贿犯罪的裁判标准更加合理，有利于贯彻罪刑相适应原则。

（3）但该修改中数额与情节的关系并未明确，可能使得法官量刑有所差异。

6 如何理解行贿罪的既遂与未遂？

答：（1）行贿罪的既遂与未遂的区分标准在于是否已将财物交付给国家工作人员或者

其他相关人员。

(2) 财物已经交付的，构成犯罪既遂；如果只是着手实行交付财物的行为，但由于遭到拒绝或者其他原因没有交付成功的，则按照犯罪未遂处理。

(3) 其他国家和地区刑法对行贿罪的规定中，将行贿行为规定为行求、期约和交付三种行为，我国刑法仅规定“交付”一种行贿行为，从理论上讲对其他两种行为可以按照行贿罪预备或者未遂来处理，但是司法实践中对这两类行为基本都未予追究。

7 如何理解利用影响力受贿罪中的“影响力”？

答：利用影响力受贿罪，是指国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，或者离职的国家工作人员或者其他与其关系密切的人，利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的行为。

(1) 影响力的类型包括：

① 形式上的影响力和实质上的影响力。

② 权力性影响力和非权力性影响力。

③ 直接影响力和间接影响力。

(2) 利用影响力受贿罪中的影响力属于实质上的影响力、同时包含权力性影响力与非权力性影响力，和直接影响力。

① 利用影响力受贿罪要求行为人与国家工作人员或离职国家工作人员客观上有亲情关系或“密切关系”，因此利用影响力受贿罪中的“影响力”属于实质上的影响力。

② 利用影响力受贿罪中包括权力性影响力和非权力性影响力。权力性影响力基于国家工作人员的职务或者职权获得，具有公权力的性质；非权力性影响力范围比较广泛，如基于血缘、地缘、感情、一般事务性关系等产生的影响力，具有潜在性和便利性。

③ 利用影响力受贿罪要求不论采取哪种途径，最终必须通过“国家工作人员职权”来实现不正当利益，才能构成利用影响力受贿罪，因此利用影响力受贿罪中的“影响力”属于直接影响力。

8 如何理解私分国有资产罪的构成要件？私分国有资产罪的认定需注意哪些问题？

答：（1）私分国有资产罪的构成要件

- ① 本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性，又侵犯了国有资产所有权。
- ② 本罪在客观方面表现为行为人违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的行为。
- ③ 本罪的主体是特殊主体，即只能由国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员构成。
- ④ 本罪的主观方面是故意，即行为人明知是国有资产，而故意进行集体私分。

（2）私分国有资产罪认定需注意的问题

私分国有资产罪中最应注意的是其与贪污罪的区别，具体有以下几点：

- ① 犯罪的客观方面不同。本罪的客观方面表现为以单位的名义将国有资产集体私分给单位的所有人员或者绝大多数人员。而贪污罪的客观方面则表现为利用职务上的便利，以侵吞、盗窃、骗取或者其他手段将公共财产非法占为己有。
- ② 犯罪主体的范围不同。本罪的主体是单位即国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，实际上负刑事责任的是上述单位中的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，因此，只有部分国家工作人员能够成为本罪的主体。贪污罪的主体，不仅可以由所有的国家工作人员构成，而且还可以由受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员构成。
- ③ 犯罪的目的不同。本罪以单位成员共同非法分得国有财产为目的，贪污罪则以个人非法占有公共财产为目的。

第二十五章 渎职罪

1 如何理解滥用职权及其造成了公共财产、国家和人民利益的重大损失？

答：滥用职权罪是指国家机关工作人员超越职权，违法决定、处理其无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。滥用职权及造成公共财产、国家、人民利益的重大损失是滥用职权罪的客观方面。

(1) 滥用职权，就是非法使用职务上的权限，实施违反其职务宗旨的行为。国家工作人员所实施的侵害他人权利行为，如果与其职权无关的话，就不能成立本罪。滥用可分为两种情况：一是超越职权，违法决定、处理其无权决定、处理的事项。这是针对行为人无权处理的事务而言的。二是违反规定处理公务。这是针对行为人有权处理的事务而言的。例如公安机关本无权管理环境保护方面的工作，但却超越职权以环境污染为由而对工矿企业处以罚款等行政处罚的行为等。

(2) 行为人滥用职权的行为造成了公共财产、国家和人民利益的重大损失。所谓重大损失，依照相关司法解释，“经济损失”是指渎职犯罪或者与渎职犯罪相关联的犯罪立案时已经实际造成的财产损失，包括为挽回渎职犯罪所造成损失而支付的各种开支、费用等。立案后至提起公诉前持续发生的经济损失，应一并计入渎职犯罪造成的经济损失。债务人经法定程序被宣告破产，债务人潜逃、去向不明，或者因行为人的责任超过诉讼时效等，致使债权已经无法实现的，无法实现的债权部分应当认定为渎职犯罪的经济损失。渎职犯罪或者与渎职犯罪相关联的犯罪立案后，犯罪分子及其亲友自行挽回的经济损失，司法机关或者犯罪分子所在单位及其上级主管部门挽回的经济损失，或者因客观原因减少的经济损失，不予扣减，但可以作为酌定从轻处罚的情节。

2 如何理解“玩忽职守”？

答：玩忽职守罪是指国家机关工作人员严重不负责任，不履行或者不认真履行职责，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。

(1) “玩忽职守”表现为不履行或者不认真履行职责，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。具体来说，包括两方面的内容：

① 履行或者不认真履行职责。其中，不履行职责是不作为形式的玩忽职守行为，表现为擅离职守或者对自己工作范围内的事项不传达、不布置、不报告、不检查、不执行

等；不认真履行职责是作为形式的玩忽职守行为，表现为行为人虽然履行了职责，但却不尽职尽责，而是马虎草率、粗心大意、敷衍塞责。

② 致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。重大损失，与滥用职权罪的认定标准相同，可依照相关司法解释的规定认定。

(2) 玩忽职守的主观方面表现为过失。这种过失是针对所造成的重大损失结果而言的，但对违反工作纪律和规章制度，以及自己的作为或者不作为，行为人可能是明知故犯。如果行为人已经预见到自己的行为会发生重大损害结果，而希望或者放任其发生，那就不是玩忽职守的过失，而是故意。对行为造成重大损害结果的行为，必须以其他故意犯罪加以论处。

3 如何理解故意泄露国家秘密罪的犯罪主体？

答：（1）故意泄露国家秘密罪是指国家机关工作人员或者非国家机关工作人员违反保守国家秘密法，故意使国家秘密被不应知悉者知悉，或者故意使国家秘密超出了限定的接触范围，情节严重的行为。故意泄露国家秘密罪的犯罪主体是特殊主体，主要是国家机关工作人员，但非国家机关工作人员也可以成为本罪的主体。

(2) “非国家机关工作人员”应作限定理解，即此处的非国家机关工作人员不应是一般的自然人主体，而是具有一定职责，可以接触或知悉国家秘密的非国家机关工作人员，即特殊主体。故意泄露国家秘密罪规定在《刑法》分则第九章渎职罪中，因此，在解释该章条文时首先应考虑到渎职罪章的法益。即泄露国家秘密的行为并非任何人都可为之，其前提是“渎职”。在此，职责当然不应指一般主体的义务，而应是基于特定身份而产生的特定职责。

(3) 虽然泄露国家秘密罪的主体不限于国家机关工作人员，还包括非国家机关工作人员，但是这并不意味着所有的自然人都能成为泄露国家秘密罪的主体，要成为泄露国家秘密罪的主体，必须是知悉或者掌握国家秘密的自然人。根据刑法理论，行为人除具备自然人和刑事责任能力两个基本要件之外，还必须具有特定的身份才能构成的犯罪主体，是特殊主体。因此，泄露国家秘密罪的主体是特殊主体。

4 如何理解徇私枉法罪与徇私舞弊不移交刑事案件罪的区别？

答：徇私枉法罪是指司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的行为。徇私舞弊不移交刑事案件罪是指工商行政管理、税

务、监察等行政执法人员，徇私舞弊，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的案件不移交，情节严重的行为。

二者客观上都可能表现为对明知是有罪的人而故意包庇不使其受刑事追究。但区别在于：

(1) 主体不同。徇私舞弊不移交刑事案件罪的主体是行政执法人员，即没有对犯罪行为直接行使侦查、检察、审判等权力的行政机关的执法人员；而徇私枉法罪的主体是司法工作人员，即对犯罪行为有侦查、检察、审判等职责的人员。

(2) 客观方面不同。徇私舞弊不移交刑事案件罪发生在行政执法过程中，即将在行政执法活动中所查获的刑事案件不移交给司法机关，从而使犯罪嫌疑人逃脱刑事处罚；徇私枉法罪中尽管也有“对明知是有罪的人故意包庇不使他受追诉”的一面，但其发生在司法工作人员履行侦查、检察、审判职责的过程中，与发生在行政执法过程中的前者的情形不同。需要注意的是，公安机关既是行政执法机关又是司法机关，其中，具有侦查、监管职责的人是司法人员，这些人在履行职责时，徇私舞弊，使有罪的人不受刑事追诉的，应当构成徇私枉法罪；其他人则属于行政执法人员，他们在履行职责时，徇私舞弊，对所查获的应当移交的刑事案件不移交的，则应以徇私舞弊不移交刑事案件罪处理。

5 如何理解食品监管渎职罪中的“造成其他严重后果”？

答：（1）食品监管渎职罪是指负有食品安全监督管理职责的国家机关工作人员，滥用职权或者玩忽职守，导致发生重大食品安全事故或者造成其他严重后果的行为。就食品监管渎职罪来说，其结果是发生重大食品安全事故或者造成其他严重后果。负有食品安全监督管理职责的国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守的行为，导致发生重大食品安全事故或者其他严重后果，方可构成本罪，若没有导致发生重大食品安全事故或者其他严重后果，则不构成本罪。

（2）“食品安全事故”，按照《食品安全法》第150条的规定，是指食源性疾病的、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。至于何谓“重大食品安全事故”，有待于司法解释明确。

（3）所谓“其他严重后果”，是一个兜底性条款，是指虽未发生重大安全事故，但由于食品安全监管方面的原因，造成其他严重后果的情形。其意在严密刑事法网，因此，这里的“其他严重后果”，应当是指与食品安全事故有关的其他严重后果。对于玩忽职守行为，本罪的成立不要求达到玩忽职守行为直接引起了“导致发生重大食品安全事故或者造成其他严重后果”的程度，只要能够证明行为人的玩忽职守行为和已经审判终结

的生产、销售不符合安全标准的食品罪或者生产、销售有毒有害食品罪有因果关系即可。

第二十六章 军人违反职责罪

1 刑法专章规定军人违反职责罪的根据是什么？

答：军人违反职责罪是指军人违反职责，危害国家军事利益，依照法律应当受刑罚处罚的行为。军人违反职责罪侵犯的客体是国家的军事利益，也就是国家在军事行动、军事部队的管理活动、武器装备和军用物资及军事设施的管理制度等方面的利益。军事利益的维护和保障是国家自身的存在和安全的重要条件，因此，对于军人违反职责，侵犯国家军事利益的行为，应从严惩治。所以刑法专章规定军人违反职责罪。

具体来说，本类犯罪在客观方面表现为军人违反职责，实施了危害国家军事利益的行为。所谓违反职责，是指军人违反国家的有关法律、法规和中央军委、解放军各总部以及各军兵种公布的各种条例、条令中对军人规定应当履行的义务和担负的责任。军人依法负有的义务和担负的责任，都是保障国家的军事利益所必需的，因此，军人违反职责，都必然危害了国家的军事利益，在其危害达到一定的严重程度时，就应当以犯罪论处。

2 如何区分军人违反职责罪与危害国家安全罪、危害国防利益罪的界限？

答：犯罪的时间和地点在军人违反职责罪的构成中具有极为重要的意义，也是其与危害国家安全罪、危害国防利益罪的重要界限。

(1) 就犯罪时间而言，有相当一部分犯罪要求必须发生在战时才能构成，如战时违抗军令罪、战时临阵脱逃罪；有不少犯罪即使不以发生在战时为犯罪构成的要素，也被刑法规定为该种犯罪加重处罚的情节，如擅离、玩忽军事职守罪。

(2) 就犯罪地点而言，有的犯罪要求必须是在战场上发生才能构成，如投降罪、拒不救援友邻部队罪、遗弃伤病军人罪；有的犯罪要求必须是发生在军事行动地区才能构成，如战时残害居民、掠夺居民财物罪。

3 构成军人叛逃罪为什么必须具备“危害国家军事利益”的要素？

答：军人叛逃罪是指军职人员在履行公务期间，擅离岗位，叛逃境外或者在境外叛逃，危害国家军事利益的行为。军人叛逃罪是军人违反职责罪的一种，需要符合军人违反职责罪的构成标准，即军人违反职责，危害国家军事利益，依照法律应当受刑罚

处罚的行为。该类犯罪侵犯的客体是国家的军事利益，也就是国家在军事行动、军事部队的管理活动、武器装备和军用物资及军事设施的管理制度等方面的利益。因此，构成军人叛逃罪，要求客观上对国家军事利益造成危害。

4 我国刑法为什么设立虐待俘虏罪？

答：虐待俘虏罪是指虐待俘虏，情节恶劣的行为。本罪客观方面要求虐待的对象必须是俘虏，即在作战中被我方俘获的敌方武装人员及其他为敌方武装部队服务的人员。

根据现代国际法基本原则和具体规则，对俘虏以打骂、体罚、折磨及其他酷刑等方式进行肉体上的摧残，或者生活上不给予人道待遇等虐待俘虏的行为，是违背人道主义原则以及关于战俘待遇的《日内瓦公约》，同时也违反了我军的俘虏政策。因此我国设立虐待俘虏罪，对该类行为进行规制。



微信扫描上方二维码，获取更多免费资料